



عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن

2024/2025

ووكيل كلية الحقوق (سابقاً)

2. 22



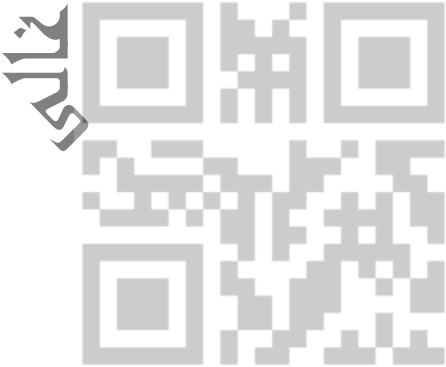


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025





بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾

صدق الله العظيم

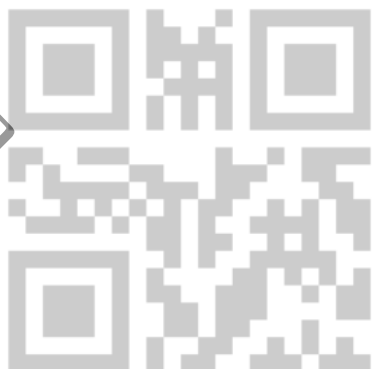
2024/2025

2024/2025

2024/2025

«سورة البقرة الآية ٢٨٢»

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن



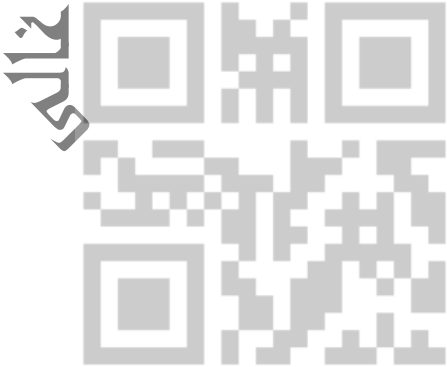


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



مقدمة:

١- كفل القانون للدائن من الوسائل ما يمكن به أن يستوفى حقه من المدين إذا لم يف هذا الأخير طواعية منه واختياراً. وأهم هذه الوسائل^(١) أو السبل التي تجعله في مأمن من الخطر الذي يصيب ذمة مدينه، هي الضمانات أو التأمينات التي جعلها القانون لبعض الدائنين تجعلهم في مركز خاص ممتاز يتقون به في الغالب إفسار المدين.

هذه التأمينات نوعان شخصية وعينية. والأولى - الشخصية - تتحقق إذا تقدم شخص آخر بجانب المدين يضمن للدائن أن يوفيه حقه إذا عجز مدينه عن الوفاء، ويكون التأمين في هذه الحالة شخصياً.

أما الثاني - العينية - يتحقق الضمان كذلك إذا خصص مال مملوك للمدين أو لغيره للوفاء بدين الدائن، فيستوفى الدائن حقه من هذا المال قبل غيره من الدائنين ويتبعه في أي يد يكون. والتأمين في هذه الحالة يرد على مال معين فهو تأمين عيني.

والتأمينات على هذا النحو تحقق للدائن فائدة كبيرة هي ضمان حقه قبل مدينه، إلا أنها تحقق في الوقت نفسه، وللسبب ذاته فائدة كبيرة للمدين هي ثقة الدائن فيه، وبغير هذه الثقة لا يحصل المدين على ائتمان من أحد.

2024/2025 والائتمان له أهمية خطيرة في 2024/2025 الحياة الاقتصادية للأفراد والجماعات

على السواء فقلما يعتمد التمويل الاقتصادي لمشروع ما على القدرة الذاتية لمن يقوم بهذا المشروع بل أن الغالب أن يتم التمويل عن طريق ائتمان الغير. ومن ناحية أخرى فإن احتمال استيفاء الدائن حقه كاملاً، وبسهولة عند حلول الأجل عن طريق ما يمنح من تأمينات ييسر للمدين الحصول على شروط أفضل وأقل شدة وصرامة فيستطيع مثلاً أن يحصل على سعر فائدة أقل مما لو لم يكن قد قدم تأميناً. كما يستطيع أن يحصل على آجال للوفاء بديونه وشروط ميسرة للسلعة التي تباع بالأجل.

(١) هناك الضمان العام المقرر في المادة ٢٣٤ مدني «أموال المدين جميعاً ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا ما كان له منهم حق التقدم وفقاً للقانون» بالإضافة إلى الوسائل التي يمنحها القانون للدائن للمحافظة على حق الضمان العام، المواد ٢٣٥ - ٢٦٤ مدني.

الأنواع المختلفة للتأمينات فى القانون المصرى:

٢- هناك نوعان رئيسيان للتأمينات، التأمينات الشخصية، والتأمينات العينية، والتأمينات الشخصية أو الكفالة الشخصية (١)، تتمثل فى انضمام شخص إلى المدين، هو الكفيل، يتعهد للدائن بأن يفى بالتزام المدين إذا أعسر هذا الأخير. والكفيل لا يخصص أى مال خاص من أمواله لضمان الدين، ولكنه يضع ذمته إلى جانب ذمة المدين. فبعد أن كان للدائن ضمان عام على أموال المدين، يصبح له ضمان عام أيضاً على أموال الكفيل، فالعملية تتلخص أذن فى تعدد الضمان العام للدائن.

وهذا التعدد يعطى فرصة أكبر للدائن فى استيفاء حقه. ومع ذلك فلازال الدائن مهدداً بمخاطر الضمان العام من إعسار المدين والكفيل معاً، ولهذا فمن المعتقد أن التأمينات الشخصية لا تعطى للدائن ضماناً أكيداً فى استيفاء حقه. وهذا لا يصدق بالطبع إذا كان الكفيل شخصاً موسراً كبنك مثلاً، وكفالة البنوك من أهم صور الكفالة فى العصر الحديث.

والكفالة الشخصية تتم بعقد رضائى بين الدائن والكفيل، وقد نظم المشرع هذا العقد فى الباب الخامس من الكتاب الثانى للقانون المدنى، المخصص للعقود المسماة فى المواد ٧٧٢ إلى ٨٠١.

2024/2025 أما التأمينات العينية أو الحقوق العينية التبعية فهى تقوم على تخصيص 2024/2025 مال معين كتأمين للوفاء بالدين، بالأفضلية على الدائنين الآخرين دون التعرض لقسمة الغرماء. ويكون للدائن أن يتتبع الشئ فى أيد كان ليستوفى حقه، ولا يتعرض بذلك لإعسار المدين، لأنه يستطيع أن يستوفى دينه مباشرة من المال المخصص للوفاء به. وقد أحس الرومان بذلك فقرروا أن الأشياء تعد أكثر ضماناً من الأشخاص، أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن التأمين العينى يعد أكثر ضماناً للدائن من التأمين الشخصى.

وأول الحقوق العينية التبعية هو الرهن الرسمى، وقد تناوله المشرع فى الباب الأول من الكتاب الرابع فى المواد ١٠٣٠ إلى ١٠٨٤. والرهن الرسمى ينشأ بمقتضى عقد بين الدائن والراهن. وهو عقد من العقود الشكلية، والشكل المطلوب

(١) الكفالة هى التطبيق النموذجى للتأمين الشخصى ويلاحظ أن التضامن بين المدينين يؤدى إلى زيادة ضمان الدائن ولكن لا يعتبر تأميناً شخصياً لأن كل مدين متضامن مسئول بصفة شخصية عن المدين فى مجموعة أيضاً كما فى حالة عدم قابلية لالتزام للانقسام (م ٢/٣٠٠ مدنى). راجع د/ توفيق فرج: التأمينات الشخصية والعينية، طبعة ١٩٨٤، ص ٤.



هو الرسمية، ولهذا سمي بالرهن الرسمي. وهو يرد بصفة أساسية على العقارات، ولا يرد على المنقولات إلا بصفة استثنائية.

والنوع الثانى من التأمينات العينية هو حق الاختصاص، وهو كالرهن الرسمي لا يرد إلا على عقار، ويجب شهرة حتى ينفذ فى مواجهة الغير. ألا أنه يختلف عن الرهن الرسمي فى المصدر، فهو لا ينشأ بمقتضى عقد، ولكن بمقتضى حكم من القضاء.

والنوع الثالث من التأمينات العينية هو الرهن الحيازى، وعلى خلاف الرهن الرسمي فهو يتميز بأن حيازة الشئ المرهون تنتقل من الراهن إلى الدائن المرتهن، وهو يرد على العقار والمنقول على السواء.

وهناك نوع رابع من التأمينات العينية هو الامتياز. وهو يختلف من مصدره عن الرهن بنوعيه، وعن الاختصاص فى أنه يتقرر بمقتضى القانون، والامتياز هو أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. والقانون هو الذى يحدد نوع الامتياز وبين مرتبته.

هذه هى التأمينات العينية، تجمعها فكرة الرهن أو تخصيص مال لضمان الدين. وينشأ بعضها بعقد رسمي أو رضائى أو حكم من القاضى أو نص من القانون. ويترتب على بعضها نقل حيازة الشئ المرهون إلى المرتهن، ولا يترتب هذا على البعض الآخر. ويجب أن يشتمل جميعاً اتخاذ إجراءات الشهر إذا كانت خاصة واردة على عقار. وتعطى كلها الحق فى الأفضلية، وكذلك الحق فى التتبع كقاعدة عامة.

وستتناول فى هذا الكتاب دراسة التأمينات الشخصية فى قسم أول ثم التأمينات العينية فى قسم ثانى.



٨

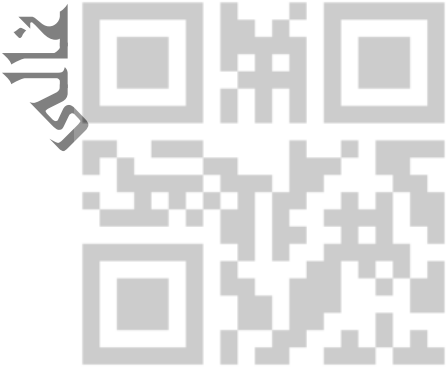


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025





القسم الأول
التأمينات الشخصية
عقد الكفالة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن خالي





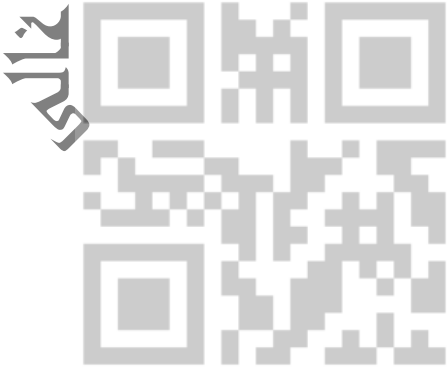
١٠

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الكفالة

تمهيد:

٣- رأينا أن التأمينات الشخصية تقوم على تعدد المدينين عن طريق إضافة مدين أو أكثر إلى جانب المدين الأصلي، بحيث يتسنى للدائن - عن لم يوف له المدين الأصلي في الميعاد - أن يرجع على الآخرين.

وسنعرض فيما يلي لدراسة الكفالة، فنبدأ في باب تمهيدى بتعريفها ثم نبين خصائصها، ونميز بينها وبين الأنظمة الأخرى القريبة منها، كما نتكلم عن مصادرها وشروط الكفيل.

أما الباب الأول فنتكلم فيه عن انعقاد الكفالة، أما الثانى فنبين فيه آثارها، ثم نعرض لانقضاءها في باب أخير.

الباب التمهيدي

التعريف بالكفالة

تقسيم:

٤- نبدأ في هذا الباب فنعرف الكفالة ونوضح خصائصها، ثم نميز بينها وبين الأنظمة القانونية الأخرى القريبة منها. ثم نتكلم بعد ذلك عن مصادرها ثم نتعرض أخيراً لشروط الكفيل.

2024/2025

الفصل الأول

2024/2025

التعريف بالكفالة وبيان خصائصها

تعريف الكفالة

٥- عرف الشرع الكفالة بأنها «عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه^(١)».

من هذا التعريف يتضح أن الكفالة عقد. هذا العقد يتم بين شخص يسمى الكفيل وبين الدائن، يتعهد فيه بالالتزام الذى له في ذمة مدينه إذ لم يقوم هذا المدين بالوفاء به.

(١) تعريف الفقه الإسلامى للكفالة أكثر توفيقاً من التعريف التشريعى، حيث يعرف الفقه الإسلامى الكفالة بأنها ضم ذمة إلى ذمة، وقد عرفت المادة ٨٣٩ من مرشد الحيران بأنها «ضم ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين: الأستاذ/ أحمد أحمد إبراهيم: التزام التجزعات. مجلة القانون والاقتصاد، السنة الثالثة، العدد الثانى، فقرة ٦٠، ٦١.



فالكفالة تفترض وجود دين أصلى تعمل على ضمان الوفاء به. فالكفالة تابعة دائماً للالتزام من الالتزامات. والتبعية هي أهم خصائص الكفالة، بل هي أهم خصائص التأمينات جميعاً على اختلاف أنواعها^(١).

وعقد الكفالة يتم بين الدائن فى الالتزام الأصلى وبين الكفيل، أما المدين فى الالتزام الأصلى فليس طرفاً فى عقد الكفالة. ومع ذلك فهو يلعب دوراً فى انعقادها لأنه هو الذى يدعو الكفيل فى معظم الأحيان إلى التعاقد مع الدائن ضماناً للالتزامه قبل هذا الدائن. ومع ذلك فإن هذا الدور يظل خارج منطقة عقد الكفالة.

وعقد الكفالة يؤدى إلى إنشاء التزام جديد على عاتق الكفيل فى مواجهة الدائن، هو الالتزام بضمان الدين الأصلى. وعلى هذا فإن الدائن يجد أمامه مدينين هما المدين الأصلى والكفيل، فالكفالة فى الواقع هى ضم ذمة جديدة إلى ذمة المدين فى ضمان دين الدائن. فهناك أن علاقة أصلية بين دائن ومدين، وعلاقة تبعية بين الدائن نفسه وشخص آخر هو الكفيل.

وينبغى ألا يفهم من القيد الوارد فى نهاية المادة ٧٢٢ مدنى «إذ لم يف المدين بنفسه» أن التزام الكفيل معلق على شرط واقف هو عدم قيام المدين المكفول عنه بالوفاء فالتزام الكفيل التزام بات، ويترتب فى ذمته نهائياً بمجرد إبرام عقد الكفالة^(٢)، وإنما يدل القيد على الصفة التكميلية أو التبعية للالتزام الكفيل.

خصائص الكفالة:

١- تعريف الكفالة الذى أوضحناه يدل على خصائصها، وهى أنها من نظم^{2024/2025} الضمان الشخصى، وأنها عقد رضائى، تابع، كما أنها عقد ملزم لجانب واحد، وهى من عقود التبرع. وهى تعد عملاً مدنياً بحسب الأصل.

١ - الكفالة عقد ضمان شخصى:

الكفالة من نظم التأمينات الشخصية، وهى الصورة النموذجية لهذه النظم. ذلك أنها تخول الدائن حق الضمان العام ليس فقط على أموال مدينه بل أيضاً وعلى أموال الكفيل. إذ يلتزم الكفيل التزاماً شخصياً قبل الدائن، فهى ضم ذمة إلى ذمه طبقاً لتعريف الفقه الإسلامى. وبهذا يكون للدائن ضمان أوسع نطاقاً. فبدلاً من مدين واحد يصير له مدينان، بذمتين مالتيتين تضمنان الوفاء بدينه.

وقد يقدم الكفيل أحياناً مالاً مملوكاً له ضمان لدين الدائن. ويسمى فى هذه الحالة بالكفيل العينى. وتسمى الكفالة بالكفالة العينية أما الكفيل العادى فيسمى

(١) د/ السنهورى الوسيط ج ١٠، طبعة ١٩٧٠. ص ١٩.

(٢) د/ محمود جمال الدين زكى: التأمينات الشخصية والعينية طبعة ١٩٧٩ ص ٣٣.

بالكفيل الشخصى وتسمى كفالته الشخصية وإذا أطلق لفظ الكفيل أو الكفالة دون تحديد فيكون المقصود هو الكفيل الشخصى والكفالة الشخصية باعتبار ذلك الأصل فى الكفالة. أما الكفيل العينى فهو ليس كفيل فحسب، ولكنه رهن أيضاً ويسرى عليه أحكام الرهن والكفالة فى نفس الوقت. ولكن لا تسرى عليه بعض أحكام الكفالة التى لا تتفق مع طبيعة مركزه.

٢ - الكفالة عقد رضائى

تتعقد الكفالة بترضى الطرفين - الدائن والكفيل - ويكفى التراضى لانعقادها دون استلزام شكل خاص. ومع ذلك فإن المادة ٧٧٣ مدنى نقض بأنه «لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأسمى بالبينة، فالكتابة تلزم هنا للإثبات فقط لا للانعقاد. أى أنه يمكن أن تتعقد الكفالة دون كتابة، وكل ما هناك تثار مسألة إثباتها، وهو ما يمكن عن طريق الإقرار واليمين. فالشكالية هنا للإثبات، وليس للانعقاد. وهذا واضح من عبارة النص ذاته أنه يقول «أن الكفالة لا تثبت» ولم يستعمل كلمة «لا تتعقد».

٣ - الكفالة عقد تابع

الغرض من الكفالة هو ضمان الوفاء بدين من الديون. ولذلك فهى تتبع هذا الدين. وهذه هى خصيصة التأمينات بأنواعها المختلفة شخصية منها والعينية، فالالتزام الكفيل يتبع التزام المدين فى وجوده وصحته. فلا تنشأ الكفالة إلا إذا وجد التزام أصلى، ولا يكون التزام الكفيل صحيحاً^{2024/2025} إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً^{2024/2025}. وفكرة التبعية هى التى تحكم كذلك آثار الكفالة، فلا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده قبل أن يرجع على المدين (م ١/٧٨٨ مدنى) ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل قبل أن ينفذ على أموال المدين (م ٢/٧٨٨). أى أن التزام الكفيل يتبع التزام المدين فى وجوده وصحته وآثاره وانقضائه^(١). وفكرة التبعية تجعل الكفيل فى مركز أفضل من مركز المدين، وهذا أمر طبيعى لأن المدين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين.

ويترتب على اعتبار الكفالة عقداً تابعاً نتائج متعددة:

أ - إذا وردت الكفالة فى عبارات عامة، فأنها تنصرف إلى ضمان كافة التزامات المدين حتى الملحقات. وقد نصت على هذا المادة ٧٨١ مدنى «إذا لم يكن

(١) قضت محكمة النقض «التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لالتزام المدين الأسمى فلا يقوم إلا بقيامه» نقض مدنى ١٩٨٤/١ طعن ١٧١٧ س ٤٩ ق.

هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصرفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصرفات بعد إخطار الكفيل.

ب - يترتب على اعتبار التزام الكفيل تابعاً أنه لا يمكن أن يكون أشد وأثقل من التزام المدين الأصلي وتنص المادة ١/٧٨٠ على أنه «لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول». وعلى ذلك إذا كان الدين الأصلي لا يغل فائدة فإن التزام الكفيل ينبغي أن يكون كذلك (١). وإذا كان الالتزام الأصلي معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أخذ التزام الكفيل الأوصاف نفسها. فضلاً عن ذلك فإن التزام الكفيل ينبغي ألا يتجاوز في مقداره ما هو مستحق على المدين، إذ لا يجوز الكفالة في مبلغ أكبر من المبلغ الأصلي.

ويترتب على فكرة التبعية أن التزام الكفيل إذا تجاوز التزام المدين، سواء في مقداره أم في أوصافه، فلا يكون باطلاً، بل يكون صحيحاً في حدود الالتزام الأصلي، وكل ما هنالك أنه ينقضى إلى هذه الحدود.

وإذا كان التزام الكفيل يتبع التزام المدين الأصلي بحيث لا يتجاوزه، فإن من الجائز أن تكون الكفالة في مبلغ أقل من الدين الأصلي وبشروط أهون. فللكفيل ألا يكفل إلا جزءاً من الدين فقط، كما أنه له أن يكفل بشروط أقل شدة وإرهاقاً من الالتزام الأصلي، وله أيضاً أن يطلب أجلاً، وفي مثل هذه الأحوال يقتصر التزامه على الحدود التي التزم بها.

2024/2025

2024/2025

٤ - الكفالة عقد ملزم لجانب واحد:

عقد الكفالة بحسب الأصل هو عقد ملزم لجانب واحد هو الكفيل الذي يتعهد بضمان الوفاء بدين المدين. أما الدائن وهو الطرف الآخر في عقد الكفالة فلا يلتزم بشئ في مواجهة الكفيل ولكنه يتلقى فقط تعهده ويستفيد منه.

وإذا كان القانون يفرض على الدائن بعض الالتزامات، فإن هذه ليست ناشئة عن عقد الكفالة، ولا تعتبر سبباً لالتزام الكفيل. من ذلك ما تفرضه المادة ٧٨٧ مدني على الدائن من تسليم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع، وأن يتخلى له عن المنقول المرهون أو المحبوس ضماناً لنفس الدين. ومما يفرضه القانون على الدائن أيضاً ألا يعمل بخطئه على إضاعة التأمينات الأخرى التي تضمن الوفاء بالدين، وأن يرجع على المدين خلال ستة أشهر من تاريخ إنذار الكفيل له بذلك، وأن يدخل في تقييسة المدين إذا

(١) د/ توفيق حسن فرج: التأمينات الشخصية والعينية طبعة ١٩٨٤ ص ١١.

أفلس، ولكن هذه الالتزامات وإن كان مصدرها القانون وتنشأ بمناسبة وفاء الكفيل بالدين وليس بمقتضى عقد الكفالة ذاته، إلا أنها لا تعتبر التزامات بالمعنى الصحيح ولكنها أسباب لانقضاء التزام الكفيل^(١).

ومع ذلك فإن عقد الكفالة قد يكون منطوياً على تعهد من الكفيل بالضمان وتعهد من الدائن بأن يمنح المدين أجلاً جديداً أو يمنحه قرضاً جديداً أو غير ذلك. وفي هذه الحالة فإننا نكون بصدد عقد مركب من كفالة واشتراط لمصلحة الغير، وإذا نظرنا لهذا العقد في مجموعة فإنه يعتبر ملزماً للجانبين^(٢)، والعبرة في تحديد كون عقد الكفالة ملزماً لجانب واحد - وهو الأصل - أو ملزماً للجانبين تكون دائماً بالنظر إلى ما يربته العقد نفسه بين الدائن والكفيل من التزامات، بصرف النظر عما قد يلتزم به المدين قبل الكفيل مقابل تدخل هذا الأخير لكفالاته.

٥ - الكفالة من عقود التبرع

الأصل أن الكفالة من عقود التبرع بالنسبة للكفيل، لأنه يلتزم بالضمان قبل الدائن دون مقابل. إلا أن صفة التبرع ليست من جوهر الكفالة أو مستلزماتها، فلا مانع من أن يطلب الكفيل مقابلاً لتدخل بالضمان. وهذا ما يحدث دائماً إذا ما قام بالكفالة أحد البنوك، وبذلك تكون الكفالة من المعارضات، إذ لا يكون التزام الكفيل نحو الدائن هذه الحالة بقصد التبرع. ووصف الكفالة بأنه عقد تبرع أو عقد معاوضة ينبغي النظر إليها دائماً من صلة طرفيها - الدائن والكفيل - فإذا كان الكفيل يلتزم قبل الدائن دون مقابل كان تبرعاً. وإذا ما التزم الدائن بإعطاء الكفيل 2025/2024 في مقابل تدخل بالضمان 2024/2025 العقد معاوضة. ولا ينبغي النظر هنا إلى صلة الكفيل بالمدين وما إذا كان تدخل الكفيل لإسداء خدمة للمدين أو بمقابل، إذ لا ينبغي أن نقيم وصف العقد بأنه معاوضة أو تبرع على عناصر خارجه في صلة أحد أطرافه بالغير. وبعبارة أخرى لا ينبغي أن ننظر إلى علاقة الكفيل بالمدين من حيث ما إذا كان الكفيل متبرعاً أو كان تدخل بمقابل لأن هذا لا يظهر أثره إلا بعد وفاء الكفيل وعند الرجوع على المدين.

ويتربط على اعتبار عقد الكفالة من عقود التبرع، اشتراط أهلية خاصة في الكفيل من يعتبر العقد صحيحاً، وهى أهلية التبرع، وكذلك تترتب آثار أخرى تتعلق بشروط دعوى عدم نفاذ التصرفات.

(١) د/ عبد الفتاح عبد الباقي - التأمينات الشخصية والعينية طبعة ١٩٥٤ ص ٣٦، ومنصور مصطفى منصور، التأمينات العينية طبعة ١٩٦٣ ص ١٣ هامش/١.

(٢) د/ توفيق حسن فرج: ص ١٢، د/ سمير عبد السيد تناغو.... التأمينات الشخصية والعينية طبعة ١٩٨٥ ص ٢٢.

٦- الصفة المدنية والتجارية للكفالة:

تعتبر الكفالة أصلاً من الأعمال المدنية، حيث أنها تحدث في غالب الأحوال بغير مقابل. ولهذا فإنها تعد عملاً مدنياً، يستوى في ذلك أن يكون الالتزام المكفول التزاماً مدنياً أو التزاماً تجارياً، كما يستوى في ذلك أن يكون الكفيل تاجراً أو غير تاجر.

ويرجع تأسيس هذا الحكم إلى أن نية التبرع لا تتفق مع مفهوم العمل التجارى. وقد نصت المادة ١/٧٧٩ مدنى على هذا تأكيداً للمعنى السابق «كفالة الدين التجارى تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً».

وإذا كان استبعاد وصف العمل التجارى عن عقد الكفالة يقوم على اعتبار أنها أصلاً عمر تبرعى، فإنه إذا ما أنتقت عنها هذه الصفة تصير عملاً تجارياً، وذلك كما إذا كان الكفيل تاجراً واحترف كفالة الأشخاص بمقابل، أن في مثل هذه الحالة تكون الكفالة عملاً تجارياً، وهذا ما يحدث إذا ما قام أحد البنوك بضمان أحد العملاء نظير مقابل يتقاضاه البنك.

ومع ذلك فإن المشرع قد قضى على حالة اعتبر فيها الكفالة دائماً عملاً تجارياً وهى حالة ما إذا كانت الكفالة ناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق (م ٢/٧٧٩ مدنى).

وقد راعى المشرع أن الصفة التجارية التى لهذه الأوراق تبرر اعتبار كفالة الالتزامات التى تنشأ عنها كفالة تجارية.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وفى هذا قضت محكمة النقض أن النص فى المادة ١/٧٧٩ من التقنين المدنى على أن كفالة الدين التجارى تعتبر عملاً مدنياً، ولو كان الكفيل تاجراً على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائماً عملاً تجارياً يدل على أن الأصل فى الكفالة أن تعتبر عملاً مدنياً وتبقى الكفالة عملاً مدنياً بالنسبة للكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين تاجراً وكان الكفيل نفسه تاجراً وذلك استثناء من القاعدة التى تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لأنه الأصل فى الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى (١).

(١) نقض مدنى ١٩٨١/٣/٢ طعن رقم ١٠٤١ س ٤٧ مدنى.

الفصل الثانى

التمييز بين الكفالة وبين غيرها

من النظم المشابهة لها

٧ - توجد أنظمة قانونية قد تشتهر بالكفالة من زاوية أو أخرى وأن كانت تختلف عنها فى أحكامها القانونية الجوهرية. ومن هذه الأنظمة، تضامن المدينين، والتعهد عن الغير، والتجديد، والتأمين.

أولاً: الكفالة والتضامن

يبدو التشابه بين الكفالة والتضامن من حيث أن كلا منهما يمنح الدائن ضماناً وتأميناً شخصياً، بحيث يكون له التنفيذ ليس فقط على أموال المدين بل وأيضاً على أموال المدين المتضامن معه أو على أموال الكفيل.

ولكن الكفالة عقد تابع، ويأتى التزام الكفيل لضمان التزام المدين الأصلي ويترتب على هذا أنه يكون على الدائن أن يطالب المدين أولاً قبل مطالبة الكفيل، وإذا ما طالب الكفيل أولاً كان له أن يدفع بالتجديد. بل أنه حتى فى الحالات التى يتنازل فيها الكفيل عن الدفع بالتجديد فإن التزامه يختلف عن التزام المدين المتضامن. ذلك أن المدين المتضامن يلتزم مع غيره من المدينين على قدم المساواة، أى أنهم يعتبرون جميعاً مدينين أصليين فى درجة واحدة، بحيث يكون للدائن أن يطالب أياً منهم بكل الديون، دون أن يكون له أن يدفع قبله بالتجديد، لأن التزام كل منهم التزام أصلى لا يقوم تبعاً لالتزام الآخرين.

وتبدو فكرة التبعية فى التزام الكفيل فى حالة ما إذا أبرأ الدائن المدين الأصلي، فإن الكفيل يبرأ تبعاً لذلك (م ١/٧٨٢ مدنى) وهذا بخلاف ما إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامين، فإن ذمة الباقيين لا تبرا، إلا إذا صرح الدائن بذلك (م ١/٢٨٩ مدنى).

والمدينين المتضامين يعتبرون ذوى مصالح شخصية بالنسبة للدين وهم يلتزمون بالنسبة لأنفسهم وليس عن الغير ولحسابه أما الكفيل فإنه لا يلتزم إلا لصالح الغير وهو المدين الأصلي، حتى ولو كان الكفيل متضامناً كما أنه لا يعتبر ذا مصلحة شخصية بالنسبة للدين.



ثانياً: الكفالة والتعهد عن الغير

التعهد عن الغير هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر معين (م ١٥٣ مدنى). ومن هذا المعنى قد يثور الخلط بينه وبين الكفالة، إذ قد يبدو أن المتعهد عن الغير إنما هو كفيل للشخص الذى تعهد بالحصول على قبوله.

ورغم هذا الشبه إلا أن فروق أساسية تباعد بين النظامين. فالمتعهد عن الغير يلتزم التزاماً أصلياً بالقيام بأداء معين هو حمل الغير على الالتزام بأمر معين، فى حين أن التزام الكفيل التزام تبعى.

وعلى هذا الأساس فإن الكفيل فى ضمانه لالتزام المدين الأصلي إنما يقوم بالوفاء إذا تقاعس هذا المدين عن الوفاء بالدين، فى حين أن المتعهد عن الغير أما أن يفى بما التزم به فى صورة حمل الغير على قبول التعهد فتنتهى مسؤوليته عند هذا الحد، وأما أن يفشل فى مهمته فيسأل عن تعويض المتعهد له عما لحق به من ضرر نتيجة لعدم تنفيذ ما تعهد به، أى أنه مسئول عن إخلاله بالتزامه بوصفه مديناً أصلياً وليس بوصفه كفياً.

ومن ناحية أخرى فإن الكفيل إذا وفى بالدين رجع على المدين بما أوفاه، أما المتعهد فهو ينفذ التزاماً شخصياً فلا رجوع له - بطبيعة الحال - على أحد، بل وليس له الرجوع من حيث المبدأ - بما أوفاه من تعويض حال فشله فى حمل الغير^{2024/2025} على الالتزام.

2024/2025

2024/2025

ثالثاً: الكفالة والتأمين

قد تشبه الكفالة مع عقد التأمين فى حالة التأمين ضد الإعسار أو تأمين التأمين أو تأمين الثقة. وهو عقد يغطى به دائن مخاطر إعسار مدينه عن طريق التأمين لدى إحدى الشركات ضد إعسار مدينه. وفى هذه الحالة تبدو الشركة فى مركز الكفيل. ولكن الواقع أن الشركة هنا (المؤمن) لا تكفل المدين إطلاقاً، ولكنها تلتزم التزاماً أصلياً بدفع تعويض إلى الدائن فى الحالة التى يتحقق فيها إخطار إعسار المدين. وفى هذه الحالة لا يكفى مجرد عدم الوفاء حتى يكون للدائن الرجوع على شركة التأمين طالما كان المدين موسراً.

رابعاً: الكفالة والحوالة

يحول الدائن حقه إلى غيره، وهو أمر جائز قانوناً ما لم تحل طبيعة الالتزام وما لم يوجد نص أو اتفاق يمنعه (م ٣٠٣ مدنى) ويضمن المحيل فعله الشخصى



إذ يلتزم بالامتناع عن أى عمل يكون من شأنه منع المحال من استيفاء حقه من المدين أو يجعل هذا الاستيفاء أكثر صعوبة أو مشقة.

يستوى فى هذا الضمان الشخص أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض. فإذا أخل المحيل بهذا الالتزام كان ملزماً بالتعويض، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط الضمان. ومن ناحية ثانية يضمن المحيل وجود الحق غير أن هذا الضمان لا يتحقق إلا فى حالة الحوالة بعوض وهذه الأحكام يجوز الاتفاق على خلافها.

ويكون المحيل ضامناً لاستحقاق الحق المحال فى صورة محددة قانوناً هى أن يرد ما أخذه من المحال مع الفوائد والمصروفات، ولا يجوز مطالبة إلا بهذه المبالغ.

والواضح من هذه الأحكام السابقة أن المحيل ضامن، ومع ذلك فهو ليس كفيل لأن التزام المحيل بالضمان هو التزام أصلى قائم بذاته يتمثل فى مسئوليته عما يلحق المحال من ضرر نتيجة للإخلال بالالتزام بالضمان. فالالتزام المحيل بالضمان يختلف فى موضوعه وفى حدوده عن التزام الكفيل لذلك فإن ذمة الكفيل لا تبرا لمجرد تأخر الدائن فى المطالبة بالمديونية عن حلول أجل الوفاء بها، ما لم يكن الكفيل قد قام بإنذار الدائن باتخاذ الإجراءات المطالبة ثم تأخر هذا الدائن عن القيام بذلك خلال ستة أشهر التالية للإنذار.

أما المحيل فإن ذمته تبرا إذا حصل المحال عليه على أجل إضافى باتفاق مع المحيل، حتى ولو أعسر المحال عليه بعد تاريخ هذا الاتفاق، لأن المحيل لا يضمن يسار المدين فى حالة الاتفاق على ذلك، على خلاف الكفيل - أن يتخذ إجراءات تحفظيه للمحافظة على الحق المحال.

أما فى حالة حوال الدين فهى تتم عادة باتفاق بين المدين الأصلى وشخص آخر (م ٣١٥ مدنى) يقبل أن يحل محله فى المديونية قبل الدائن. ولا تنفذ الحوالة فى مواجهة الدائن إلا إذا أقرها (م ٣١٦ مدنى) ويكون المدين الأصلى ضامناً يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن الحوالة. غير أن التزامه بالضمان هنا ليس التزاماً تبعياً ولكنه التزام أصلى قائم بذاته. وموضوع هذا الالتزام بالضمان وهو تعويض الدائن عن إفسار المحال عليه - لا يعتبر المحال عليه كفيلاً بل هو مدين بصفة أصلية حل بمقتضى الحوال محل المدين الأصلى. وإذا لم يقر الدائن الحوالة أو رفضها، فإن المدين الأصلى يظل ملتزماً فى مواجهته بالوفاء بالدين.

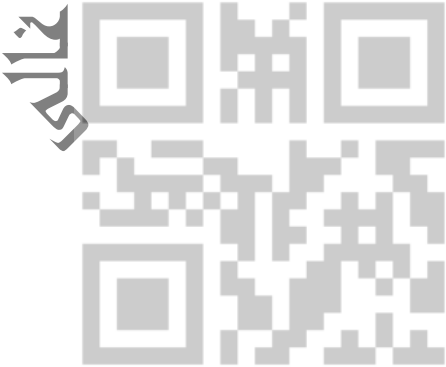


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الفصل الثالث

مصادر الكفالة وشروط الكفيل

نتعرض في هذا الفصل إلى مصادر الكفالة في بحث أول ثم للشروط التي يجب أن تتوافر في الكفيل في المبحث الثاني.

المبحث الأول

مصادر الكفالة

تحديد المقصود بمصادر الكفالة

٨- ينصرف الكلام عن مصادر الكفالة إلى ناحيتين: الأولى هي مصدر التزام الكفيل نفسه، والثانية هي مصدر التزام المدين بتقديم كفيل، أما من حيث مصدر التزام الكفيل نفسه، فإنه يكون دائماً اتفاقياً^(١). ذلك أن الكفيل يلتزم دائماً بناء على عقد الكفالة الذي يبرم بينه وبين الدائن فالكفالة عقد يتم بين الدائن والكفيل يتعهد فيه الكفيل بالوفاء بالتزام المدين إذا لم يقم به هذا الأخير. وتتم الكفالة بمحض إرادة الطرفين وينظمان العلاقة بينهما كيفما شاءوا.

مصدر التزام المدين بتقديم كفيل:

٩ - تنقسم الكفالة، حسب مصدر التزام المدين بتقديمها، إلى كفالة اتفاقية، وكفالة قانونية، وكفالة قضائية. 2024/2025 2024/2025

2024/2025

فالكفالة الاتفاقية هي التي يلتزم المدين بتقديمها للدائن بمقتضى اتفاق سابق بينهما، ويكون من ثم، الاتفاق مصدر التزام المدين بتقديم الكفالة.

والكفالة القانونية هي التي يلتزم المدين بتقديمها أنصياً نص في القانون، فيكون هذا القانون مصدر التزام المدين بتقديم الكفالة، كالمادة ٤٥٧ التي تلزم البائع بأن يقدم كفيلاً ليسقط حق المشتري في حبس الثمن إذا تعرض له أحد «مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري». والمادة ١/٩٩٢ التي تلزم المنتفع إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً، بتقديم كفالة به ضماناً لرد المنقول بعد انتهاء حقه.

والكفالة القضائية هي التي يلتزم المدين بتقديمها بناء على حكم قاضى، فيكون هذا الحكم مصدر التزام المدين بتقديمها. ومن أمثلة الكفالة القضائية ما نصت عليه المادة ٨٢٩ مدنى من أنه إذا ما وافقت المحكمة على قرار أغلبية

(١) د/ توفيق فرج: التأمينات ص ١٦، د/ جمال زكى: التأمينات، ص ٤٠.

الشركاء في الشروع، وهم الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، بإجراء تغييرات أساسية. أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما هو يستحق من التعويضات. وكذلك ما نصت عليه المادة ٩٠٠ مدنى من أن المحكمة تلزم الورثة بتقديم كفالة إذا ما طلبوا أن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة.

وتحتوى نصوص تقنين المرافعات فى النفاذ المعجل أمثلة هامة للكفالة القانونية والكفالة القضائية. فتكون الكفالة قانونية عندما يكون تقديم الكفيل واجباً على المحكوم له بنص القانون، كالمادة ٢٨٩ التى تقضى بأن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفيل.

وتكون الكفالة قضائية إذا كان للمحكمة، عندما تأمر بالنفاذ المعجل، أن تلزم المحكوم له بتقديم كفالة أو أن تعفيه من تقديمها، كالمادة ٢٩٠ التى تجيز للمحكمة الأمر بالنفاذ المعجل، فى الحالات المبينة فيها بكفالة أو بغير كفالة.

هذه هى المصادر المختلفة للالتزام المدين بتقديم كفيل. ويراعى أنه لمعرفة ما إذا كانت الكفالة اتفاقية أو قانونية أو قضائية أهميتها من حيث أنه فى حالة الكفالة القانونية والقضائية يكون الكفلاء دائماً متضامنين^(١) (م ٧٩٥ مدنى). فالتضامن هنا يكون بقوة القانون. وهذا مظهر من مظاهر التشديد يجعل الكفيل فى هذين النوعين من الكفالة فى مركز أحسن من الكفيل الاتفاقى، لأن المشرع لا يقررها إلا إذا كان مستحق الحماية. أما فى حالة الكفالة الاتفاقية فلا يتضامن الكفلاء إذا ما تعدموا، وإذا ما أريد تضامنهم، فلا بد من الاتفاق عليه طبقاً للقواعد العامة فى التضامن.

ويراعى أنه مهما كان مصدر التزام المدين بتقديم الكفالة، فإن عقد الكفالة ينبغى أن يتم بين الدائن والكفيل. وكل ما هنالك أنه إذا ما كان على المدين التزام بتقديم كفيل يتعين عليه أن يوفى بالتزامه، وأن على الدائن أن يقبل الكفيل الذى يقدمه له المدين، متى استوفى هذا الكفيل الشروط التى يتطلبها القانون فى الكفيل. ولهذا فإننا نعرض لهذه الشروط.

(١) قضت محكمة النقض بأنه إذا كان مؤدى نص المادة ٧٩٥ من القانون المدنى أنه فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين ومن ثم فإن الكفيل القانونى يكون بنص القانون متضامناً مع المدين والكفيل القانونى هو الذى يلتزم المدين بتقديمه نفاذاً للنصوص القانونية ومتى قدم المدين لدائنه هذا الكفيل، فإن هذا الكفيل القانونى يكون متضامناً مع المدين. نقض مدنى ١٩٨٤/٢/١٦ طعن ٢٣٧ س ٥٠ ق.

المبحث الثانى الشروط التى يتطلبها القانون فى الكفيل

١٠- تنص المادة ٧٧٤ مدنى على أنه «إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسراً ومقيماً فى مصر» من هذا النص يتبين أنه يلزم أن يتوافر فى الكفيل شرطان هما شرط اليسار وشرط الإقامة فى مصر. هذا بالإضافة إلى ما يتعين أن يتوافر فى الكفيل من أهلية الالتزام طبقاً للقواعد العامة. وهذه الأهلية ينبغى توافرها وقت العقد فقط ولا أثر لزوالها فيما بعد إذ يظل العقد قائماً منتجاً لآثاره.

الشرط الأول: اليسار

يلزم أن يكون الكفيل الذى يقدمه المدين موسراً. وهذا يعنى أن يكون لديه من الأموال ما يكفى على الأقل للوفاء بالالتزام الذى تقدم لضمانه. فالشرط الأساسى هو قدرة الكفيل على الدفع ولا عبء بما إذا كانت أمواله عقاراً أو منقولات، قريبة كانت من موطن الدائن أو بعيدة، طالما كان من الممكن التنفيذ عليها.

وتقدير كفاية أموال الكفيل للوفاء بالتزامه، أى معرفة يساره، من المسائل الموضوعية التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهو ينظر فى ذلك إلى حالة الكفيل العامة فى ضوء قيمة الالتزام المكفول. وإذا ما نوزع فى مقدره الكفيل، كان على المدين إثبات يساره، ولا شأن للكفيل بهذا الإثبات.

واستلزام اليسار يسرى فى حالة الكفالة القانونية والكفالة القضائية حيث يكون المدين ملزماً بتقديم كفيل. وهو يسرى كذلك فى حالة الكفالة الاتفاقية فى صلة الدائن بالمدين إذا ما اتفقا على أن يقوم هذا الأخير بتقديم كفيل، إذ فى هذه الحالة يكون المدين ملزماً بتقديم الكفيل على أساس الاتفاق.

الشرط الثانى: الإقامة فى مصر

استلزم المشرع إلى جانب يسار الكفيل أن يكون مقيماً فى مصر، والمقصود بالإقامة فى هذه الحالة الإقامة المعتادة، أى التوطن، لا إقامة عارضة والغرض من هذا هو كما جاء فى المذكرة الإيضاحية. مراعاة مصلحة الدائن والتسهيل عليه عند مطالبة الكفيل. فضلاً عن هذا فإن استلزام إقامة الكفيل فى مصر يمكن الدائن من مراقبته ومن تتبعه بسهولة. لكى يكون دائماً على علم بظروفه وحالته من الناحية المالية.

تخلف أحد الشرطين السابقين:

١١- إذا ما توافر الشرطان السابقان في الكفيل أعتبر المدين أنه قد أوفى بالتزامه، وإذا كان هذان الشرطان لازمين لقيام الكفالة، فهما أيضاً لازمان لبقائها. بمعنى أنه يلزم أن تستمر صفة اليسار والتوطن في مصر إلى أن تنتهى الكفالة، ولهذا يثور التساؤل على الحالة التي يتخلف فيها شرط من الشرطين السابقين بعد قيام الكفالة، كما إذا أعسر الكفيل أو غير موطنه بأن انتقل إلى دولة أخرى.

لم يورد القانون حلاً لهذا الموضوع، وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية تبين أن المادة ١/١١٤٠ من المشروع التمهيدي^(١) كانت تنص على أنه «إذا أعسر الكفيل بعد تقديم الكفالة وجب تقديم كفيل آخر». ولكن هذا النص حذف من لجنة المراجعة على أساس الاكتفاء في هذا الصدد بالقواعد العامة.

وبالرجوع لحكم القواعد العامة نجد أن إعسار الكفيل أو تغيير موطنه لا يبسر للدائن الحصول على حقه ولا يوفر له الضمان اللازم، أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن التأمين الذى للدائن قد أضعف بسبب لا يد للمدين فيه، وفي هذا تقضى المادة ٢/٢٧٣ مدنى بأنه «إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً. أى أن الأجل الممنوح للمدين يسقط، ويستطيع المدين أن يتوقى ذلك عن طريق تقديم كفيل آخر وفقاً للمادة ٢٥٥٠ مدنى تأمينا عينا».

2024/2025

هذا إذا كان المدين ملزماً بتقديم كفيل، سواء على أساس الاتفاق أو بمقتضى نص فى القانون أن بحكم قضائى ومع ذلك فإنه إذا ما اتفق على تقديم كفيل واشترط الدائن كفيلاً معيناً فقدمه له المدين ثم تخلف شرط اليسار أو الإقامة بالنسبة لهذا الكفيل، فلا يكون المدين ملزماً بتقديم كفيل غيره، كما لا يترتب على ذلك سقوط الأجل الممنوح للمدين طبقاً للقواعد السابقة. لأن الدائن رضى به منذ البداية وكان عليه أن يتحقق من كفايته للقيام بالكفالة. فالدائن إذن مقصر وعليه تقع تبعة تقصيره.

١٢- يحدث ألا يستطيع المدين تقديم كفيل، فقد لا يجد شخصاً يكفله أو قد لا يجد شخصاً تتوافر فيه الشروط السابقة وذلك فى الحالات التى يلتزم فيها بتقديم كفيل، فما هو الحكم.

(١) الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ج٣ ص ٧٣٦.



أعطى القانون للمدين فى هذه الحالة أن يقدم تأميناً عينياً بدلاً من الكفيل، ذلك أن المادة ٧٧٤ مدنى بعد أن بينت أنه «إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسراً ومقيماً فى مصر، أضافت أن له أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً.

فاللمدن الخيار فى أن يقدم تأميناً عينياً بدلاً من الكفيل وليس للدائن أن يعترض على ذلك لأن التأمين العينى أكثر ضماناً من التأمين الشخصى. ويكون للمدين هذا الخيار فى جميع الحالات التى يلتزم فيها بتقديم كفيل، إذ الغرض من ذلك هو التيسير عليه فى تقديم الضمان عينياً كان أم شخصياً. ويلزم فى التأمين الذى يقدمه المدين أن يكون كافياً، ولا يهم ما إذا كان عقاراً أو منقولاً طالما كان من الممكن أن يضمن للدائن حقه. وتقدير كفاية التأمين مسألة موضوعية يفصل فيها قاض الموضوع.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

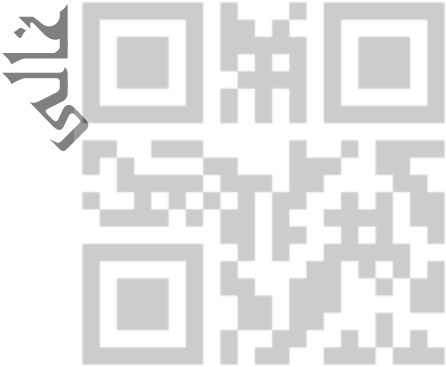


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الباب الأول انعقاد الكفالة

تمهيد:

١٣- يتم عقد الكفالة بين الدائن والكفيل، ويجب أن يتوافر لإبرام هذا العقد ما يجب توافره لإبرام كافة العقود، ورضاء العاقلين رضاء سليماً، مدفوعاً بسبب مشروع ومتعلقاً بمحل تتوافر فيه الشروط القانونية. ولما كانت الكفالة تتميز بأنها عقد تابع للالتزام أصلى تبرم لضمان الوفاء به، فإن ذلك يقضى مراعاة ما هو خاص بها وذلك على الإيضاح التالى.

الفصل الأول الرضا فى الكفالة

ركن الكفالة - التراضى

١٤- الكفالة عقد رضائى، ومن ثم ركنه التراضى، فيكفى لقيام الكفالة تطابق ارادتى الدائن والكفيل، دون حاجة إلى رضا المدين، لأنه ليس طرفاً فى العقد، بل أن الكفالة تجوز بغير علمه، بل وأيضاً رغم معارضته (م ٧٧٥ مدنى).

وإذا كانت الكفالة تتعقد على هذا النحو بتراضى طرفيها، وهما الدائن والكفيل، فهل يلزم أن يكون الرضا بالكفالة صريحاً.

2024/2025

تقضى القواعد العامة (م ٩٠ مدنى) «أن التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة والإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالاته على حقيقة المقصود. ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذ لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً. «من هذا يتضح أن التعبير عن الإرادة يكون صريحاً كما قد يكون ضمنياً، فهل يطبق هذا بالنسبة للكفالة لا شك فى تطبيق هذا الحكم بالنسبة للدائن لأن الكفالة تعقد لصالحه.

أما الكفيل فقد ثار الخلاف بالنسبة لجواز التعبير الضمنى، والرأى الصحيح والذى يؤيده غالبية الفقه (١) يرى أنه طالما أن القاعدة العامة عندنا أن التعبير عن الإرادة يمكن أن يكون ضمنياً إذ لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريح وإذ نحن استبعدنا حالة اتفاق الطرفان فإن رضا الكفيل يمكن أن

(١) د/ منصور مصطفى منصور: التأمينات ص ٢٨، د/ جمال زكى: التأمينات ص ٥١. د/ توفيق فرج: التأمينات ص ٢٤، د/ أحمد سلامة: دروس فى التأمينات المدنية - طبعة ١٩٧٨: ص ٣٢.

يكون ضمناً فلا يوجد نص يقضى بغير ذلك أما القول بأن التعبير الضمنى فيه خطورة على الكفيل فهو مردود، لأن المادة ١/١٥١ تنص على أن الشك يفسر لمصلحة المدين، وقد كفل أو لم يكفل فإنه يجب ترجيح الاحتمال الثانى الذى يحقق كل حماية للكفيل. وتبعاً لهذا إذا ما وقع الكفيل مثلاً بجانب توقيع المدين، دون أن يكشف عن حقه، وما إذا كان قد وقع بصفته شاهداً أم بصفته كفيلاً، قام هناك شك حول صفته، وبالتالي يفسر هذا الشك لمصلحته ويعتبر توقيعه بصفته شاهداً لا كفيلاً.

صحة التراضى:

١٥- ويجب حتى تقوم الكفالة صحيحة، أن يتوافر التراضى سليماً، بأن يصدر ممن يملكه، ويكون غير مشوب بعيب يفسده.

أما عن الأهلية اللازمة فى عقد الكفالة فإنه ينبغى أن تتوافر طبقاً للقواعد العامة، مع مراعاة أن الكفالة فى الأصل من عقود التبرع. ولهذا فإنه يكفى بالنسبة للدائن أن تتوافر فيه أهلية قبول التبرعات، وهى أهلية الصبى المميز ومن فى حكمه، إلا أنه لما كان من الممكن أن تتم الكفالة بمقابل، فإنها عندئذ تكون من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، وتبعاً لذلك تكون صحيحة متى كان الدائن كامل الأهلية، وقابل للأبطال متى كان صبيّاً مميزاً أو من فى حكمه. ويزول حق التمسك بالإبطال بالأجازة.

وبالنسبة للكفيل فإن الأمر يختلف^{2024/2025} وذلك ولما كانت الكفالة فى الأصل من أعمال التبرع، فإنه يلزم أن تتوافر فيه أهلية التبرع، وهى أهلية البالغ الرشيد. وإذا ما انتفت عن الكفالة الصفة التبرعية يكفى أن تتوافر فيه أهلية إبرام التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فإذا كان صبيّاً مميزاً أو من فى حكمه خضع تصرفه للأجازة.

أما بالنسبة لعبوب الإرادة، فلا تخرج الكفالة فى هذا الشأن عن أحكام القواعد العامة فإذا توافر واحد منها، الغلط، الإكراه، التدليس والاستغلال، أصبح عقد الكفالة قابلاً للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته والأكثر تصوراً من الناحية العملية هو عيب التدليس وعيب الغلط.

فقد يصدر التدليس أو الإكراه من المدين، ويعتبر فى هذه الحالة صادراً من شخص أجنبى عن العقد، ويسرى حكم المادتين ١٢٦، ١٢٨ مدنى وهما تقرران المتعاقد المدلس عليه أو المكره، لا يجوز له طلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض ضمناً أن يعلم بهذا التدليس.

أما بالنسبة للغلط، فإن أهم ما يمكن أن يثيره من مشاكل في العمل، هو أن يقع الكفيل في غلط متعلق بشخص المدين، والقاعدة أن الغلط يعتبر جوهرياً ويجوز طلب إبطال العقد على أساسه «إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد» (م ١٢١/٢ مدنى). وهذا الحكم يمكن أن يمتد أيضاً إلى الغلط في شخص المدين أو صفة من صفاته، لأن نص المادة ١٢١ مدنى لم يحصر حالات الغلط الجوهري، بل ضرب أمثلة لذلك. وهى أمثلة يجوز القياس عليها. والمدين وأن لم يكن طرفاً في العقد، إلا أن شخصه هو موضع الاعتبار في التعاقد، ومن ثم يكون الغلط فيه جوهرياً^(١).

الفصل الثانى

محل الكفالة

تمهيد:

١٦- محل التزام الكفيل هو أن يفي بالتزام المدين إذا لم يقم به المدين نفسه. وحتى يكون محل التزام الكفيل ممكناً يجب أن يكون الدين الأصلى موجوداً وصحيحاً. ولذلك ندرس الأحكام المتعلقة بالدين الأصلى لأن محل التزام الكفيل لا يكون ممكناً إلا بتوافر شروط معينة في هذا الدين ويشترط لصحة التزام الكفيل أن يكون محله معيناً أو قابلاً للتعيين والواقع أن هذا

2024/2025

2024/2025 مرتبط أيضاً بالتزام المدين. 2024/2025

أما شرط المشروعية فهو مفروض دائماً لأن التعهد بكفالة التزام صحيح هو محل مشروع في جميع الأحوال.

المبحث الأول

الوجود والإمكان

١٧- نصت المادة ٧٧٦ مدنى على أنه «لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً. وهذا الحكم هو تطبيق منطقى للتبعية القائمة بين عقد الكفالة والالتزام المكفول. فالكفالة ما هى إلا وسيلة لضمان الوفاء بالدين عند عدم الوفاء به من جانب المدين، ولذلك فلا تتصور الكفالة التزام غير موجود أصلاً، أو التزام باطل بطلاناً مطلقاً فالكفالة بوصفها تابعة للالتزام الأهلى تدور معه فى الوجود والعدم.

(١) د/ منصور مصطفى: التأمينات ص ٢٧.

وتطبيقاً لما سبق لا تصح كفالة دين القمار أو الرهان، ودين الربا الفاحش فيما يجاوز الفائدة القانونية، كما لا يجوز كفالة التزام مستحيل، أو التزام قائم على سبب غير مشروع، أو التزام به لم تفرع في الشكل القانوني والجامع المشترك في هذه الحالات هي عدم وجود الدين لاستحالة أو لبطلان سنده بطلاناً مطلقاً.

لكن ما الحكم إذا ما كان الالتزام الأصلي غير موجود وقت الكفالة لكنه يمكن أن يوجد في المستقبل كفالة الالتزامات المستقبلية، كما أن الالتزام الأصلي قد يكون معلقاً على شرط «كفالة الالتزام الشرطي». ومن ناحية أخرى فإن وجود الالتزام الأصلي يستلزم أن يكون صحيحاً «كفالة الالتزامات الباطلة» كما أن الالتزام الأصلي قد يكون التزاماً طبيعياً، فهل تجوز كفالته. ونعرض لكل من هذه الصور.

أولاً: كفالة الالتزامات المستقبلية

١٨- نصت المادة ٧٧٨ مدني على أنه:

١- تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً الدين المكفول.

٢- على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة فإن له في أي وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكلف لم ينشأ.

والالتزام المستقبل هو التزام لم ينشأ بعد، ومن صوره الواضحة فتح اعتماد وعقود الحساب الجاري لدى أحد البنوك. حيث يتصور أن يقدم العميل الذي فتح له الاعتماد شخصاً يكفله لدى البنك ليضمن المبالغ التي سوف يقبضها العميل مستقبلاً من هذا الاعتماد ففي مثل هذا الفرض تنشأ الكفالة قبل أن تنشأ المديونية بالفعل وتتصرف الكفالة إلى ما سوف ينشأ من مديونية بالفعل. وتتصرف الكفالة إلى ما سوف ينشأ من مديونية مستقبلاً، وقد أجازت المادة ٧٧٨ مدني مثل هذه الكفالة ولكنها ولا اعتبارات تنقيد بقيدتين:

القيد الأول: أن يتحدد المبلغ الذي تقوم الكفالة لضمانه الوفاء به، فيتقدم الكفيل لضمان المبالغ الذي يأخذها العميل من البنوك لصالح العميل، والغرض من تعيين المبلغ التي تجوز فيه الكفالة على هذا النحو هو حماية الكفيل حتى يعرف مقدماً الحدود التي يتدخل فيها لكفالة المدين. لأن الكفيل شخص يتورط عادة دون أن يجنى من وراء كفالته ربحاً^(١).

القيد الثاني: وهو قيد خاص بحماية الكفيل أيضاً ومن مقتضاه أنه إذا لم تحدد للكفالة مدة معينة كان للكفيل أن يرجع عنها مادام الدين لم ينشأ بعد، ومفاد

(١) الأعمال التحضيرية للقانون ج ٥ ص ٤٥٧.



هذا الحكم أن الكفيل إذا حدد مدة معينة لنشوء ظل على التزامه طوال هذه المدة، والتزم بضمان الوفاء بالديون التي تنشأ خلالها، كما إذا كفل شخص المبالغ الذي يأخذها العميل من البنك خلال ستة شهور في حدود خمسين ألف جنيه، فيظل ملتزماً طيلة هذه المدة. ويترتب على ذلك أنه إذا مضت المدة المحددة دون أن ينشأ الدين المكفول بأكمله برئت ذمة الكفيل، وإذا ما نشأ جزء منه خلال تلك المدة اقتصرت الكفالة على هذا الجزء، وفي هذا قضت محكمة النقض بأنه إذا عين الكفيل في الالتزام المستقبل مدة الكفالة فإنه يكون ضامناً لما ينشأ في ذمة المدين من التزامات خلال هذه المدة بشرط ألا تجاوز هذه الالتزامات الحد الأقصى المتفق على كفالته. وإذا كان الطاعن الثاني قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه ضمن الديون التي تنشأ في ذمة الطاعن الأول حتى.... وفي حدود مبلغ.... وأن الطاعن الأول قد ورد للبنك خلال تلك المدة أقساطاً تزيد قيمتها عن المبلغ المكفول فبرئت ذمته بذلك من هذا المبلغ وكان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان^(١).

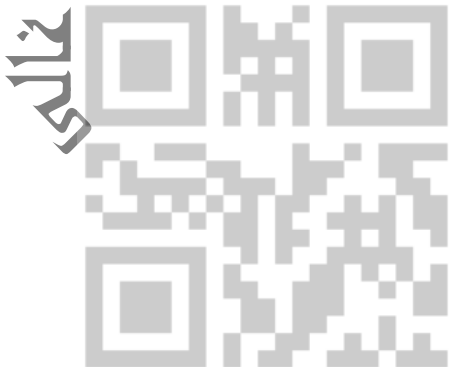
أما إذا لم يحدد أجلاً، فإن له أن يتخلص من كفالته مادام الدين لم ينشأ بعد، ولكن إذا ما رجع في كفالته قبل نشوء الدين فإنه ينبغي أن يخطر الدائن برجوعه حتى لا يضار من ذلك، وحتى نترك له الفرصة ليكيف وضعه مع المدين كأن يطلب منه كفيلاً جديداً مثلاً.

2024/2025 أما إذا نشأ الدين فإنه يلتزم بضمان الوفاء ولا يحق له الرجوع عن الكفالة بإرادته وحده، وإنما لأبد من رضا الطرف الآخر في العقد وهو الدائن طبقاً للقواعد العامة. وفي هذا قضت محكمة النقض^(٢) بأنه لا يقبل من ورثة الكفيل قولهم أنهم عدلوا عن كفالة مورثهم للربيع المطالب به باعتباره ديناً مستقبلاً، لأن الثابت من الحكم المطعون فيه، أن هذا الدين كان قد نشأ واستحق قبل رفع الدعوى به، بما ينفي عن كفالته، أنها عن دين مستقبل يقضى ذلك العدول.

ثانياً: كفالة الالتزام الشرطى:

١٩- بعد أن قضت المادة ٧٧٨ مدنى على جواز كفالة الدين المستقبل أضافت أنه «تجوز الكفالة في الدين الشرطى. والشرط هو وصف في الالتزام لا يمس وجوده أو صحته. فالالتزام المعلق على شرط هو التزام صحيح علق على الشرط نفاذه (الشرط الواقف) أو علق عليه استمرار وجوده (الشرط الفاسخ).

(١) نقض مدنى ١٩٧٦/٦/١٤ طعن رقم ٣١ س ٤٢ ق.
(٢) نقض مدنى ٩ - ٥ - ١٩٧٢ طعن رقم ٣٢٣ س ٣٧ ق.



وفي جميع الحالات تدور الكفالة مع الالتزام المكفول في حكمه، فإذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف كانت الكفالة كذلك فإذا تحقق الشرط الواقف نفذ الالتزام الأصلي وكذلك التزام الكفيل. أما إذا تخلف الشرط الواقف فإن الالتزام الأصلي يزول بأثر رجعي^(١)، ويلقى مع ذات المصير التزام الكفيل.

وإذا كان الالتزام معلقاً على شرط فاسخ، فإن الالتزام يكون موجوداً وناظراً منذ نشأته، غاية الأمر أن مصيره معلق على تحقق الشرط أو تخلفه فإن تخلف الشرط أصبح الالتزام باتاً وكذلك الالتزام الكفيل. أما إذا تحقق الشرط الفاسخ، فإن الالتزام المكفول يزول وتزول معه الكفالة ويصبح كل منها كأن لم يكن.

ثالثاً: كفالة الالتزامات الباطلة

٢٠- إذا كان الالتزام المكفول باطلاً بطلاناً مطلقاً، أيّاً كان سبب البطلان، فإنه لا يكون موجوداً، وبالتالي لا تجوز كفالته، وإلا اعتبر محل التزام الكفيل مستحيلًا في ذاته، واعتبرت الكفالة باطلة بطلاناً مطلقاً لاستحالة المحل^(٢)، أما إذا كان الالتزام المكفول قابلاً للإبطال لعيب في الرضا فإن الكفالة تقوم كذلك قابلة للإبطال أخذاً بفكرة التبعية التي تعد من خصائصها الجوهرية. ولما كان العقد القابل للإبطال يترتب آثاره إلى أن يقضى ببطلانه، فإنه ينبغي أن يراعى أنه إذا ما أُنقِرَ العقد الأصلي وأصبح نهائياً عن طريق الأجازة أو التقادم، فإن التزام الكفيل يصير نهائياً كذلك. 2024/2025 أما إذا طلب المدين إبطال العقد الأصلي وقضى له به، فإن التزام الكفيل 2024/2025 ينقضى كذلك بالتبعية. وهو ينقضى بأثر رجعي شأنه في ذلك شأن الالتزام الأصلي.

ولكن إذا لم يقر المدين بطلب البطلان، فهل للكفيل أن يطلب ذلك. تقضى المادة ١/٧٨٢ مدني بأن للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. وعلى ذلك يمكن - استناداً إلى هذا النص - أن يقوم الكفيل بطلب إبطال الالتزام الأصلي^(٣) لأنه يستفيد - فضلاً عن الدفع الخاصة به - من الدفع الخاصة بالمدين نفسه. هذا ما لم يكن الكفيل والدائن قد قصدا تأمين هذا الأخير ضد طلب المدين إبطال العقد لعيب في إرادته بعد علمهما بسبب الإبطال، إذ في هذه الحالة لا يكون للكفيل أن يطلب إبطال العقد استناداً إلى هذا السبب.

(١) د/ منصور مصطفى: التأمينات ص ٢٨.

(٢) د/ السنهوري: الوسيط ج ١٠ طبعة ١٩٧٠ ص ٤٣.

(٣) د/ توفيق فرج: التأمينات ص ٣١، د/ سمير تناغو: التأمينات ص ٤١، عكس ذلك،

د/ أحمد سلامة التأمينات ص ٢٨.

كفالة التزام ناقص الأهلية

٢١- نص القانون على حكم خاص بكفالة التزام ناقص الأهلية فقرر أن «من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية كان ملزماً بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول» (مادة ٧٧ مدنى) ويستلزم تطبيق هذا النص توافر شروط:

١- أن يكون الالتزام المكفول خاصاً بناقص الأهلية كالصبي المميز ومن فى حكمه. وعلى هذا لا يسرى ما جاء به إذا كان الالتزام المكفول خاص بعديم أهلية كالصبي غير المميز، لأن التزامه يكون باطلاً من أساسه، وبالتالي تكون كفالته باطله بطلاناً مطلقاً.

٢- يجب كذلك أن تكون الكفالة بسبب نقص الأهلية. وهذا يعنى أن كلا من الدائن والكفيل يعلمان بنقص أهلية المدين، ويتدخل الكفيل لكفالته على هذا الأساس، أى بسبب نقص أهليته، ولتأمين الدائن ضد خطر تمسك المدين بنقص أهليته لإبطال العقد.

وإذا ما التزم شخص بكفالة ناقص الأهلية على هذا النحو ترتب على ذلك:

١- أن يظل التزام الكفيل قائماً طالما بقى الالتزام الأصيل قائماً ولم يقضى ببطلانه. وإذا ما قام المدين بتنفيذ التزامه برئت ذمة الكفيل. ولا صعوبة فى ذلك باعتبار أن التزام الكفيل التزام تابع.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢- لكن إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه أو طلب إبطال العقد وقضى له به، يلتزم الكفيل بالوفاء. وهو يظل ملتزماً رغماً انقضاء الالتزام الأصيل. ولكنه يلتزم فى هذه الحالة التزاماً أصلياً لا باعتباره كفيلاً.

وقد اختلف فى تعليل التزام الكفيل فى هذه الحالة بصفة أصلية، والذى نفضله أن الكفيل يلتزم فى هذه الحالة لا على اعتبار أن كفيل، ولكن على اعتبار أنه كان متعهداً عن الغير^(١) لأنه عندما يتدخل لكفالة ناقص الأهلية وبسبب نقص الأهلية فإنه يتعهد للدائن بألا يتمسك المدين بنقص أهليته، فإن تمسك بها وقضى له بالبطلان، التزم الكفيل التزاماً أصلياً باعتباره مسئولاً لعدم إمكان حمل المدين على عدم التمسك بالبطلان. ومسئوليته تجعل منه مديناً أصلياً.

وبعبارة أخرى أن الكفيل يقوم فى هذه الحالة بدورين: دوره ككفيل طالما بقى الالتزام الأصيل قائماً ولم يقضى ببطلانه، ودوره كملتزم أصلى إذا لم يستطع

(١) د/ منصور مصطفى: التأمينات، ص ٣٤، د/ أحمد سلامة: التأمينات، ص ٤٠.
د/ توفيق فرج: التأمينات، ص ٣٢، د/ سمير تناغو: التأمينات، ص ٤٢.

حمل المدين على عدم التمسك بالبطان لنقص أهليته، باعتباره قد أخل بتعهده عن الغير فيلتزم التزاماً أصلياً على سبيل التعويض.

كفالة الالتزام الطبيعي

٢٢- الالتزام المدني هو الالتزام بالمعنى الفنى الكامل والذي يتوافر له عنصر المديونية والمسئولية. أما الالتزام الطبيعي هو التزام بنقصه عنصر المسئولية، وبالتالي لا يمكن فيه إجبار المدين على التنفيذ.

ولما كانت الكفالة التزاماً تابعاً يتعهد فيها الكفيل بالوفاء بالالتزام الأصلي إذا لم يقيم به المدين، فإنه يترتب على ذلك أنه لا تجوز كفالة الالتزام الطبيعي. لأن الكفالة تتضمن التزام الكفيل التزاماً مديناً، وليس من المقبول أن يكون الالتزام التابع أقوى وأشد من الالتزام الأصلي.

ومن ناحية ثانية وحتى لا يكون فى مثل هذا الحكم - لو أجزى - وسيلة غير مباشرة لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه الطبيعي بأن يجبره الكفيل على الوفاء فيكون من حقه الرجوع على المدين المكفول جبراً. وهو ما يخالف معنى الالتزام الطبيعي وحكمه. ولذلك فإنه لو حدث أن أوفى الكفيل فى التزام طبيعى بالدين فإنه لا يستطيع أن يرجع على المدين الأصلي للاستيفاء جبراً عنه.

غير أن المدين الأصلي بالالتزام طبيعى قد يتقدم باختياره بتقديم كفيل للوفاء بمديونيته، وهنا يتعين أن نعطي لهذه المبادرة معناها القانونى الصحيح، والأغلب أن المدين يقصد بها أن يتعهد بالوفاء بالالتزام رغم أنه التزام طبيعى وأنه يضيف عليه بالتالى عنصر المسئولية المفتقدة ويحملة بها إلى التزام مدنى. ومن هذه الحالة تصح الكفالة باعتبارها منشئة لالتزام مدنى.

وأخيراً قد يتقدم شخص تحت مسمى الكفالة بالتعهد بالوفاء بالالتزام الطبيعى القائم فى ذمة المدين، قد يفهم من عبارات هذا التعهد أن صاحبه يقصد من ورائه قيام التزام أصلى فى ذمته، وفى هذه الحالة لا تكون بصدد التزام تبعى (كفالة) إنما تكون بصدد تعهد عن الغير.

المبحث الثانى

تعين التزام الكفيل

تمهيد:

٢٣- يجب أن يكون محل التزام الكفيل معيناً أو قابلاً للتعين حتى تصح الكفالة. وبالنظر إلى فكرة التبعية التى تسيطر على كل أحكام الكفالة، فإن تعيين التزام الكفيل يرتبط بتعيين التزام المدين. ولكن نظراً لأن التزام الكفيل هو

التزام مستقل عن التزام المدين، فإنه من الجائز أن يختلف محل كل من الالتزامين. على أن الاختلاف المسموح به في هذا المقام محكوم بقاعدة أساسية وهي أن التزام الكفيل لا يجوز أن يكون أشد من التزام المدين، وأن جاز أن يكون أخف منه.

ولتوضيح ذلك فإننا ينبغي أن نميز بين نوعين من أنواع الكفالة، الأولى هي الكفالة المطلقة أو غير المحددة، والثانية هي الكفالة المحددة.

الكفالة المطلقة:

٢٤- في الكفالة المطلقة لا يعين الكفيل محل التزامه، ولكنه يعين فقط الذي يكفله، وهو ما يجعل محل التزامه قابلاً للتعيين.

ويجب أن يعين الكفيل الدين المكفولة تعيناً نافياً للجهالة. ويكون ذلك بتعين أطراف الدين محله ومصدره. وتعين أطراف الدين يكون بتحديد شخص الدائن والمدين. أما الدائن فهو الطرف الآخر في عقد الكفالة، أما المدين فهو لا يشترك في إبرام عقد الكفالة ولذلك يجب تحديده. إذ من الجائز أن يكون للدائن أكثر من مدين، فلا بد من معرفة أى مدين يضمنه الكفيل، والكفالة لا تتخطى شخص هذا المدين، فإذا تمت حوال الدين المكفولة وأختفى المدين الأصلي وظهر مدين جديد فإن الكفيل لا يضمن المدين الجديد إلا إذا تم ذلك باتفاق جديد (م ٢/٣١٨ مدنى) وإذا جدد الدين المكفول بتغير شخص المدين، فإن الكفيل لا يضمن المدين الجديد

2024/2025

2024/2025 م ٣٥٨ مدنى. 2024/2025

ويجب كذلك تعيين محل الالتزام المكفول، فيذكر أن الالتزام المكفول هو مبلغ عشرة آلاف جنيه أو بضاعة يحدد نوعها ومقدارها، والتزام الكفيل لا يتخطى هذا المبلغ أو القيمة المذكورة. فإذا قيل أن مبلغ الدين عشرة آلاف جنيه فلا يضمن الكفيل إلا هذا المبلغ ولو تبين أن الدين يزيد على ذلك.

والتزام الكفيل لا يتخطى محل التزام المكفول، فإذا اتفق على تجديد الالتزام بتغيير محله، فإن الكفالة تنقضى ما لم يرضى الكفيل بضمان الالتزام الجديد.

وإذا كان الاتفاق على التجديد قد تم قبل الكفالة، فإن هذه لا تتعقد لاستحالة المحل ما لم يتبين أن الكفيل قصد كفالة الالتزام الجديد.

ويجب أخيراً تعيين الالتزام المكفول من حيث مصدره فقد يكون للدائن أكثر من حق قبل مدينه قيمة كل منهما عشرة آلاف جنيه ولكن أحدهما مصدره عقد بين والثانى مصدره عقد قرض فينبغى تحديد أى الدينين يضمنه الكفيل، وإلا فإن الكفالة لا تتعقد، لأن مصلحة الكفيل ترتبط بدين معين بالذات هو الذى يحدده،

وليس بأى دين للدائن قبل مدينه. وتظهر مصلحة الكفيل فى ذلك بصفة خاصة إذا كان الدين الذى كفله باطلاً أو كان قد انقضى لسبب من الأسباب.

فإذا تحدد الالتزام المكفول على هذا النحو، دون تحديد التزام الكفيل فإن التزام الكفيل يكون مطابقاً لالتزام المدين. وهذا هو السبب فى تسمية الكفالة فى هذه الحالة بالكفالة المطلقة أو غير المحددة، لأن الكفيل أطلق التزامه، ولم يحدده بل جعله مساوياً لالتزام المدين فى مقداره وشروطه وأوصافه.

٢٥- ولكن التزام الكفيل يحتفظ مع ذلك باستقلاله عن التزام المدين وبصفة خاصة فإن الكفيل لا يكون متضامناً مع المدين، أو مع غيره من الكفلاء، ما لم يتفق على ذلك صراحة. أو ما لم يوجد نص فى القانون (م ٢٧٩ مدنى)، كما هو الحكم بالنسبة للكفالة القضائية أو القانونية، فالقانون يجعل الكفلاء فيها متضامين مع المدين ومتضامين مع أنفسهم^(١) (م ٧٩٥ مدنى).

ولتزام الكفيل فى الكفالة المطلقة، لا يشمل فقط أصل الدين المكفول بل يشمل كذلك ملحقات هذا الدين والمصروفات، حسبما أشارت المادة ٨٧١ مدنى حيث تقرر «إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل». وطبقاً لهذا النص فإن محل التزام الكفيل فى الكفالة المطلقة يتكون من عدة

2024/2025

2024/2025

٣٠٢٥ هـ

١- أصل الدين المكفول.

٢- ملحقات هذا الدين كالفوائد القانونية أو الاتفاقية، وكذلك التعويضات التى يحكم بها على المدين لإخلاله بالتزامه.

٣- المصروفات التى أنفقها الدائن فى رجوعه على المدين أو الكفيل.

وبالنسبة للمصروفات فإن المشرع أوجد تفرقة منطقية بين مصروفات المطالبة الأولى، وما يلى ذلك من مصروفات. ذلك أن القانون يوجب على الدائن أن يرجع أولاً على المدين قبل أن يرجع على الكفيل، ولذلك فإن الدائن مضطراً أن يوجه إجراءات المطالبة الأولى إلى المدين قبل أن يتجه إلى الكفيل، فيكون منطقياً أن يلتزم الكفيل بهذه المصروفات وهى تشمل مصروفات التنبيه على المدين ومصروفات رفع الدعوى عليه.

(١) د/ منصور مصطفى منصور: التأمينات، ص ٤٤، د/ توفيق فرج: التأمينات، ص ٣٨.

فإذا تمت المطالبة الأولى للمدين على هذا الوجه، فإنه يكون من الواجب على الدائن أن يخطر الكفيل باتخاذ هذه الإجراءات، لأن الكفيل قد يوفى الدين فيوفر المصروفات والإجراءات. لذلك فإن الدائن يخطئ إذا لم يخطر الكفيل برجوعه على المدين، فلا يتحمل الكفيل المصروفات التي ينفقها الدائن بعد المطالبة الأولى للمدين.

أما إذا قام الدائن بإخطار الكفيل، لم يقدّم هذا بالدفع بمعنى ذلك أنه ممتنع عن الوفاء، فيكون مسئولاً عن المصروفات التي ينفقها الدائن بعد إخطاره للكفيل. وهذا هو معنى ما يقرره المشرع من أن الكفالة تشمل مصروفات المطالبة الأولى ما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.

الكفالة المحددة

٢٦- قد لا يرضى الكفيل بضمان كل دين الدائن وملحقاته، فيقوم بتحديد محل التزامه تحديداً دقيقاً. وهذا الاتفاق جائز، وهو يخضع لقاعدة مؤداها أن التزام الكفيل لا يجوز أن يكون أشد من التزام المدين، ولكن من الجائز أن يكون أخف منه. وقد نص المشرع على هذه القاعدة في المادة ٧٨٠ مدني التي تقرر أنه:

١- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين. ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.

2024/2025

٢- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

يتضمن هذا النص أمرين:

الأول: لا يجوز أن يكون التزام الكفيل أشد من التزام المدين فلا يجوز أن يكون مقدار التزام الكفيل أكبر من مقدار التزام المدين. ولا يجوز أن يلتزم الكفيل بدفع فائدة إذا كان المدين لا يلتزم ذلك، ولا يجوز أن يلتزم الكفيل بدفع فائدة سعرها أكبر من سعر فائدة المدين، ولا يجوز أن يكون التزام الكفيل منجزاً بينما التزام المدين مضافاً إلى أجل، أو أن يكون التزام الكفيل باتاً بينما التزام المدين معلق على شرط، ولا يجوز للكفيل أن يلتزم بدفع الدين جملة واحدة إذا كان هذا الدين مقسماً على المدين، ولا يجوز أن يقتصر التزام الكفيل بشرط جزائي إذا كان التزام المدين غير مقتصر بذلك.

وإذا خولفت القاعدة السابقة بأن كان التزام الكفيل أشد من التزام المدين فلا يبطل عقد الكفالة، ولكن يرد التزام الكفيل إلى التزام المدين، وذلك طبقاً لنظرية انقراض العقد أو البطلان الجزئي م ١٤٣ مدني. أي أن التزام الكفيل المحدد في

هذه الحالة، يعتبر غير محدد ويكون تعينه على ما سبق أن ذكرناه بصدد الكفالة المطلقة^(١).

وإذا حدد التزام الكفيل بقدر التزام المدين، فإن الكفيل يستفيد من كل تغيير في شروط التزام المدين، ولكنه لا يضار من هذا التغيير، فإذا منح المدين أجلاً للوفاء فإن الكفيل يستفيد من هذا الأجل، ولكن يجوز له في نفس الوقت أن يوفى في الأجل القديم، حتى يتمكن من الرجوع على المدين في الوقت المناسب وقبل أن يلحق به إفسار.

ثانياً: الأمر الثاني من حكم المادة ٧٨٠ مدنى السالف أنه يجوز أن يكون التزام الكفيل أخف من التزام المدين، فلا يلتزم الكفيل إلا بضمان جزء من الدين فقط، أو لا يلتزم بكفالة ملحقات الدين أو المصروفات، أو يلتزم بالوفاء في أجل أبعد أو بالوفاء على أقساط، أو أن يجعل التزامه معلقاً على شرط فاسخ أو مضافاً إلى أجل فاسخ. ومن أمثلة الأجل الفاسخ أن يشترط الكفيل سقوط التزامه إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين خلال شهرين من تاريخ استحقاق الدين^(٢).

الفصل الثالث

سبب التزام الكفيل

تمهيد:

٢٧- اختلف الفقهاء حول موقف القانون المدنى المصرى من نظرية السبب. فذهب البعض إلى أنه يأخذ بالنظرية الحديثة فى السبب، والتي ترى أن السبب هو الباعث المستحث فى التصرفات القانونية عامة لا فرق فى ذلك بين التبرعات والمعارضات.

وذهب الجانب الأكبر إلى أن السبب فى ظل النصوص الحالية للقانون ينصرف إلى السبب بالمعنى الذى جاءت به النظرية التقليدية كما يتصرف كذلك إلى السبب فى النظرية الحديثة. أى أنهم يرون ازدواج السبب. ومن المعلوم أن السبب فى النظرية التقليدية هو سبب الالتزام، وهو الغرض المباشر للعقد، وفى المعاوزات سبب التزام أحد المتعاقدين هو التزام المتعاقد الآخر، وفى التبرعات سبب الالتزام هو نية التبرع. أما فى النظرية الحديثة فإن السبب هو سبب العقد، وهو الباعث.

(١) الأعمال التحضيرية ج٥ ص ٤٦٢.

(٢) د/ السنهورى: الوسيط ج١٠. طبعة ١٩٧٠ ص ٨٤، د/ منصور مصطفى منصور: التأمينات ص ٤٣.

٢٨- وفي صدد الكفالة يثور البحث حول تطبيق نظرية السبب بالنسبة لها. ويرى جانب من الفقه أنه إذا كان الأصل في القوانين اللاتينية هو أن الالتزام مسبب، فإنها مع ذلك تقرر الالتزام المجرد في حالات منصوص عليها بالذات، وأن القانون المدنى قد نص على حالتين أحدها حالة التزام الكفيل نحو الدائن.

فالالتزام الكفيل نحو الدائن التزام مجرد. ذلك أن الكفيل أن تمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين، ولكن التزام الكفيل نحو الدائن التزام مجرد لا يتأثر بالعلاقة بين الكفيل والمدين، ولا يجوز للكفيل أن يتمسك ضد الدائن بالدفع التي له أن يتمسك بها ضد المدين.

وإذا كان الاتجاه الراجح في ظل النصوص الحالية لنظرية السبب يأخذ بازدواج السبب، فينظر إلى السبب بمعنى الباعث، وبمعنى الفرض المباشر، فإننا ينبغي أن نفرق في صدد التزام الكفيل - من حيث أنه التزام بسبب أو مجرد - بين حالتين.

١- الحالة الأولى: حالة ما إذا أخذنا السبب بمعنى الباعث، وفي هذه الحالة لا محل للأخذ بفكرة الالتزام المجرد، طالما كان الباعث داخلاً في نطاق العقد، بان كان الدائن على علم به، سواء في علاقة الكفيل بالدائن وكان الكفيل متبرعاً له بالكفالة أو كانت الكفالة بمقابل التزام الدائن به، أم في علاقة الكفيل بالمدين وكانت الكفالة بمقابل من المدين أو بدون مقابل.

2024/2025

وفي جميع الحالات سواء في علاقة الكفيل بالدائن أم حتى في علاقة الكفيل بالمدين، تبطل الكفالة متى كان الباعث الدافع على التعاقد بالنسبة للكفيل غير مشروع، وكان داخلاً في نطاق العقد، أى كان الدائن على علم به.

٢- الحالة الثانية: وهى حالة السبب بمعنى الغرض المباشر طبقاً للنظرية التقليدية، يفرق بين السبب الداخل في نطاق عقد الكفالة، والسبب الخارج عن نطاق هذا العقد. فإذا كان السبب داخلاً في نطاق عقد الكفالة بين الكفيل والدائن، لا تعتبر الكفالة تصرفاً مجرداً، سواء كانت الكفالة تبرعاً أم كانت بمقابل. ذلك أنه في حالة ما إذا كان الكفيل متبرعاً، تكفى نية التبرع حتى يتحقق السبب بمعنى الغرض المباشر طبقاً للنظرية التقليدية. وإذا كانت معارضة بين الكفيل والدائن بأن التزم هذا الأخير بدفع مقابل للكفيل في مقابل كفالته، فإنها لا تكون مجردة كذلك، إذ سبب التزام الكفيل هو التزام

المقابل للدائن. ولهذا يمكن بطلان الكفالة إذا كان ما التزم به الدائن غير مشروع.

أما في حالة ما إذا كان السبب بمعنى الغرض المباشر خارجاً عن عقد الكفالة، أى خارجاً عن نطاق علاقة الكفيل بالدائن، فإن التزام الكفيل نحو الدائن يكون مجرداً، ويمتنع على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك ببطلان الكفالة على أساس السبب بهذا المعنى (الغرض المباشر).

فإذا تعهد المدين للكفيل بأن يعطيه شيئاً في مقابل قيامه بالكفالة. ثم أتضح أن التزام المدين باطل، فإن التزام الكفيل قبل الدائن يظل صحيحاً، بصرف النظر عن بطلان علاقة الكفيل بالمدين، لأن هذه العلاقة الأخيرة خارجة عن نطاق الكفالة. هذا خلافاً لما إذا كان الباعث للكفيل على الكفالة غير مشروع ويعلم به الدائن، فإن الكفالة تكون باطلة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الباب الثانى آثار الكفالة

٢٩- الكفالة عقد ضمان. ومن ثم إذا لم يتمكن الدائن من استيفاء حقه من المدين كان له، بمقتضى الكفالة، أن يستوفيه من الكفيل. ومن ناحية أخرى إذا أوفى الكفيل فإنه يجوز له أن يرجع على المدين بكل ما أوفاه، كما يجوز له أن يرجع على غيره من الكفلاء فى حالة وجودهم، كل بقدر نصيبه.

فينشأ عن الكفالة على هذا النحو، علاقات قانونية بين الكفيل والدائن ثم علاقات قانونية أخرى بين الكفيل والمدين، وبين الكفيل وبين غيره من الكفلاء إذا ما تعددوا ويراعى أن الطائفة الثانية من الآثار لا يعتبر على وجه الدقة آثاراً للكفالة، بل هى آثار تترتب على تنفيذ الكفالة ويكون ذلك بناء على نص القانون^(١)، فالكفالة عقد وبهذه الكيفية لا يكون لها آثار إلا بالنسبة لطرفيها، - الكفيل والدائن - ورغم هذا الاعتبار الفنى فإنه لا يزال يطلق عليها آثار الكفالة. ومسايرة لهذه التسمية نوصف هذه الآثار بأنها غير مباشرة.

ونعالج كلا من هاتين الطائفتين للآثار فى فصل مستقل، يخصص الأول لآثار الكفالة، ويخصص الثانى لآثار تنفيذ الكفالة. أو ما يطلق عليه علاقة الكفيل بالمدين.

الفصل الأول

2024/2025

2024/2025

2024/2025

آثار الكفالة فى حد ذاتها

تقسيم:

٣٠- إذا كان الكفيل يلتزم بالوفاء بالالتزام الأسمى عند عدم قيام المدين به، فإن للدائن أن يطالبه بذلك. وإذا ما قام الكفيل بالوفاء انتهى الأمر فى علاقته بالدائن. أما إذا لم يوف اختياراً فإنه يكون للدائن أن يطالبه قضاءً للحصول على حكم يلزمه بالوفاء إذا لم تكن الكفالة بعقد رسمى. وهذا أمر ضرورى فى صلة الدائن بالكفيل، حتى ولو كان فى يد الدائن سند تنفيذى قبل المدين الأسمى، لأن التزام كل منهما يختلف عن الآخر. لكن متى يحق للدائن أن يطالب الكفيل وما مدى هذه المطالبة. هذا هو محل البحث فى المبحث الأول من هذا الفصل.

(١) د/ أحمد سلامة: التأمينات، ص ٤٥.

ثم أن الدائن إذا ما طالب الكفيل كان لهذا الأخير أن يتمسك في مواجهته بالدفع التي تمكنه من تأجيل هذه المطالبة، أو دفعها، والتي قد تمكنه كذلك من إبراء ذمته كلاً أو بعضاً. وهذا ما نتكلم عنه بصدد الدفع التي للكفيل قبل الدائن وإذا لم يوفق الكفيل في دفع مطالبة الدائن أو لم يصل إلى إبراء ذمته، لا يكون أمامه من سبيل إلا الوفاء بالتزامه ويكون للدائن أن ينفذ على أمواله لاستيفاء حقه بموجب ما لديه من سند تنفيذي.

ولكن لما كان التزام الكفيل يأتي في المرتبة الثانية بعد التزام المدين، لهذا منح القانون الكفيل الحق في منع الدائن من التنفيذ على أمواله حتى ينفذ أولاً على أموال المدين أو حتى يجرد المدين من أمواله. وهذا ما يسمى بالدفع بالتجريد. وهذه الموضوعات محل دراسة المبحث الثاني.

المبحث الأول

مطالبة الدائن للكفيل

٣١- يتحدد عقد الكفالة على أساس الالتزام الأصلي، وعلى أساس الاتفاق بين الدائن والكفيل، ولا يستطيع الدائن مطالبة الكفيل قبل حلول الأجل المحدد على أساس عقد الكفالة أو بموجب الالتزام الأصلي. كما أنه لا يستطيع أن يطالبه وحده إلا إذا كان قد رجع على المدين. فهناك شرطان لإمكان المطالبة هما حلول أجل مطالبة الكفيل، وسبق مطالبة المدين أو مطالبة مع الكفيل. لكن ما مدى مطالبة الدائن للكفيل، هذا ما سوف نبينه.

2024/2025

2024/2025

أولاً: متى تجوز المطالبة

ضرورة حلول أجل ومطالبة المدين أو اشتراكه: لا تجوز مطالبة الدائن للكفيل إلا عند حلول الأجل، وبعد مطالبته للمدين، أو على الأقل بعد إشراكه مع الكفيل في المطالبة ونعرض تفصيلاً لهذين الشرطين.

الشرط الأول: حلول الأجل

٤٥- مطالبة الدائن للكفيل وإجباره على الوفاء هي غاية الكفالة، فهو يطالبه بمطالبة قضائية كي يحصل على سند تنفيذي في مواجهته، يستطيع بمقتضاه أن ينفذ على أموال الكفيل. وهذا السند ضروري حتى ولو كان بيد الدائن سند تنفيذي في مواجهة المدين. لأنه مهما كان التزام الكفيل تابعاً لالتزام المدين إلا أنه مستقل عنه في خصوص التنفيذ.

وتفترض مطالبة الكفيل هذه حلول أجل الكفالة، وأجل الكفالة غالباً ما يكون أجل الدين. على أنه يحدث أن يختلف الأجلان بالاتفاق أو بناء على واقعة

أخرى، فيجوز للكفيل أن يتفق مع الدائن على أجل للكفالة يحل بعد حلول أجل الدين الأصلي. أما إذا اتفقا على أجل أسبق فإن أجل الكفالة يمتد بالرغم من ذلك إلى أجل الدين، لأن الكفالة تكون حينئذ قد انعقدت بشروط أشد من شروط الالتزام المكفول وهو لا يجوز.

ومن ناحية أخرى يتفق رغم اتحاد الأجلين بالنسبة للدين والكفالة، أن يطرأ ما يؤدي إلى اختلافهما، فقد يمنح الدائن المدين أجلاً إضافياً، أو قد يتم ذلك بحكم من القاضي. وحينئذ يستفيد الكفيل تلقائياً من هذا الامتداد إلا إذا أثر الوفاء عند الأجل المحدد أصلاً حيث تدفعه مصلحة إلى ذلك كما إذا قدر أن المدين يحتمل أن يعسر عند حلول الأجل الإضافي، وأن مصلحته تتطلب أن يفى حتى يرجع على المدين فوراً^(١).

أما إذا كان من شأن ما طرأ أن يقدم وقت الوفاء بالنسبة للمدين فالقاعدة أن أصل الكفالة يبقى كما هو. وعلى ذلك إذا نزل المدين عن الأجل فإن هذا النزول لا يلزم الكفيل. وإلا تكون قد أبحنا للمدين أن يزيد عبء الكفيل بإرادته المنفردة، أو باتفاقه مع الدائن. وكذلك الأمر بالنسبة لسقوط التأمينات حسب الفقه الغالب.

ويلاحظ مبدئياً أنه لن يكون هناك مشكلة في هذه الحالة حيث يكون للكفالة أجلاً مستقلاً عن أجل الدين، إذ من المتفق عليه أن هذا الأجل الخاص للكفالة لا يسقط أجل الدين، ولكن المشكلة تنشأ حيث يكون الأجل واحد.

2024/2025

فذهبت الأغلبية إلى أن أجل الكفالة لا يسقط واستندت إلى ما يلي:

- ١- أن الكفيل يضمن الوفاء بالدين عند حلول أجله الأصلي وليس عند سقوط هذا الأجل.
- ٢- كما أن الحكمة التي من أجلها سقط الأجل بالنسبة للمدين هو فقدان الثقة فيه شخصياً ولا شأن للكفيل بذلك.
- ٣- ثم أن للمسألة نظير في القانون التجاري، إذ أن إفلاس المدين التاجر لا يترتب عليه حلول الأجل إلا بالنسبة للمفلس.

الشرط الثاني: سبق مطالبة المدين أو مطالبته مع الكفيل:

- ٣٢- إذا كان الدائن لا يستطيع الرجوع على الكفيل إلا عند حلول الأجل، فهل يمكنه أن يرجع مباشرة على الكفيل دون الدين الأصلي ؟

(١) د/ منصور مصطفى منصور: التأمينات ص ٥٣، د/ أحمد سلامة: التأمينات، ص ٤٣.

نصت المادة ١/٧٨٨ مدنى على أنه (لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين).

وإزاء هذا النص نفرق بين فروض ثلاث:

الأول: إذا ما رجح الدائن على المدين وحده، ولم يقم المدين بالوفاء، كان له أن يرجع بعد ذلك على الكفيل باعتباره يقوم بدور احتياطى وعليه أن يقوم بالوفاء بعد المدين. ولكنه يراعى أنه ليس المقصود بالرجوع مجرد التنبيه بالوفاء أو الأعذار، ولكنه المقصود به هو رفع الدعوى للحصول على حكمي لزم المدين بالوفاء، اللهم إذا كان بيد الدائن سند رسمى إذ يكفى للرجوع على المدين فى هذه الحالة مجرد التنبيه بالوفاء.

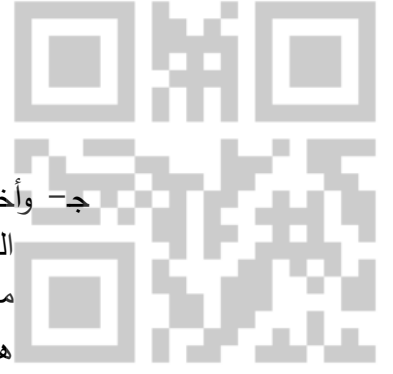
وإذا أفلس المدين يكفى أن يتقدم الدائن فى التفليسة حتى يقوم هذا مقام رفع الدعوى، وبالتالي يمكن للدائن أن يطالب الكفيل، ذلك أن التقدم فى التفليسة هو الطريق الوحيد الذى يمكن للدائن سلوكه، نظراً لأنه يترتب على الإفلاس وقف اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين المفلس. هذا بخلاف الإعسار، إذ لا يحول الإعسار دون اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين (م ١/٢٥٦ مدنى).
ثانياً: قد يرجع الدائن على المدين والكفيل معاً. وهذا جائز طبقاً لما يفهم من صريح نص المادة ١/٧٨٨ مدنى.

2024/2025

ثالثاً: إذا ما رجح الدائن على الكفيل وحده دون سبق الرجوع على المدين أو على الأقل إشراكه مع الكفيل، فلا يجوز له ذلك. فإذا ما رفعت الدعوى على الكفيل وحده، يمكن القول بأنها قد وقعت قبل الميعاد، أى قبل أوانها. ولهذا يكون له أن يدفع بعدم قبولها (١). وإن كان للكفيل ذلك إلا أنه لا يستطيع الدفع فى كل الحالات، ففى بعض الأحيان لا يمكنه أن يدفع بعدم القبول:

- أ - إذا كان قد تنازل صراحة أو ضمناً عن التمسك به.
- ب - إذا كان الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يكون للكفيل أن يدفع دعوى الدائن، إذ تخول القواعد العامة للدائن الحق فى الرجوع على أى من المدينين المتضامنين، أو عليهم مجتمعين (م ٢٨٥ مدنى).

(١) قضت محكمة النقض بأن «مفاد الفقرة الأولى من المادة ٧٨٨ مدنى أنه لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين متى تمسك الكفيل بذلك ولم يكن متضامناً مع المدين» نقض مدنى ١٩٨٣/١٢/٨ طعن رقم ٥٩٧ س ٤٩ق.



ج- وأخيراً لا يكون للكفيل أن يدفع قبل الدائن بمطالبة المدين إذا كان رجوع الدائن على المدين عديم الجدوى، بأن كان معسراً، إذ لا يكون للكفيل مصلحة من وراء تمسكه بالدفع.

هذه هي الحالات التي لا يكون فيها للكفيل التمسك بالدفع بسبق مطالبة المدين أو على الأقل بمطالبته معه، وفيما عدا ذلك يكون له أن يتمسك به.

ثانياً: مدى مطالبة الدائن للكفيل

٣٣- إذا كان الكفيل واحد وطالبه الدائن، طبقت الأحكام السابقة، مع مراعاة تحديد ما يطالب به الكفيل على أساس الالتزام الأصلي، وعقد الكفالة، فإذا كان قد كفل كل الدين طوالب به جميعه.

لكن قد يتعدد الكفلاء للدين الواحد، فما هو مدى ما يطلبه الدائن من مهم. نصت المادة ٧٩٢ على أنه:

١- إذا تعدد الكفلاء لدين واحد، ويعقد واحد، وكانوا غير متضامين فيما بينهم قسم الدين عليهم. ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.

٢- أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسؤولاً عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.

2024/2025

من هذا نتبين أنه لكي ينقسم الدين يجب أن تتوافر شروط معينة:

2024/2025

2024/2025

١- أن يتعدد الكفلاء لدين واحد. فلا ينقسم الدين بين الكفيل والمدين، ليس للكفيل أن يطلب تقسيم الدين بينه وبين المدين، لأن التزام كل منهما غير التزام الآخر. وللسبب نفسه لا يقسم الدين بين الكفيل وكفيله، إذ الكفيل يضمن الالتزام الأصلي أما كفيل الكفيل فإنه يضمن التزام الكفيل، فالتزام كل منهما يختلف عن التزام الآخر.

٢- يلزم أن يكون الكفلاء المتعددون بعقد واحد. ذلك أن كلا منهم في هذه الحالة يعتمد على الباقيين، خلافاً لما إذا كانت كفالة كل منهم بعقد مستقل فإن كل واحد منهم يلتزم بكل الدين، إذ المفروض أنه لم يعتمد على باقي الكفلاء الآخرين، إلا إذا تبين خلاف ذلك، بأن كل الكفيل يعلم أن آخرين قد تقدموا لكفالة الالتزام نفسه واحتفظ لنفسه بحق التقسيم، فلا يسأل إلا عن نصيبه. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٧٩٢ مدنى.

٣- عدم تضامن الكفلاء. لكي يمكن التقسيم، يلزم أن يكون الكفلاء على النحو السابق غير متضامين. ذلك أن تضامن الكفلاء يعنى أن للدائن الحق في



مطالبة أى منهم بالدين كله. وهذا بخلاف ما إذا كان التضامن بين أحد الكفلاء وبين المدين، إذ يكون للكفيل أن يطلب التقسيم مع غيره من الكفلاء غير المتضامنين.

٤- **التقسيم بين كفلاء المدين الواحد.** يمكن أن يضاف إلى ما سبق شرطاً آخر لم يعرض له المشرع، وأن كان واضحاً، وهو أن التقسيم لا يكون إلا بين كفلاء المدين الواحد، فلو تعدد المدينون حتى فى دين واحد وحتى ولو كانوا متضامنين، وكفل كلا منهم كفيل فليس لأى كفيل أن يطلب التقسيم مع الكفلاء الآخرين، إذ لا توجد علاقة بين كفلاء لمدينين مختلفين. وهذا خلافاً لما إذا كان كل كفيل قد تدخل لضمان جميع المدينين، فيجوز له أن يطلب التقسيم مع باقى الكفلاء الذين يكفلون جميع المدينين، فيجوز له أن يطلب التقسيم مع باقى الكفلاء الذين يكفلون جميع المدينين كذلك.

٣٤- إذا توافرت الشروط السابقة كان على الدائن أن يطالب كل كفيل بحصته فقط من الدين. والأصل أن تتساوى حصص الكفلاء، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وإذا ما طالب الدائن أحد الكفلاء بكل الدين يكون له أن يدفع هذه المطالبة فى أية حالة كانت عليها الدعوى. بل أن للمحكمة أى تحكم على الكفيل بغير حصته من تلقاء نفسها.

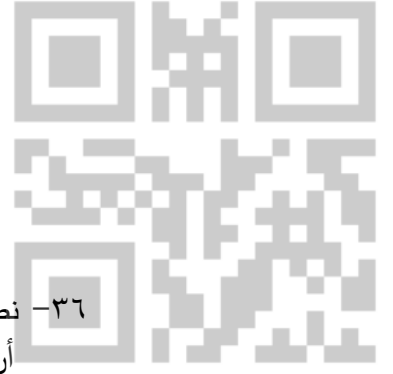
ولما كان التقسيم حتمياً ويتم بقوة القانون، يترتب على ذلك أنه إذا أعسر 2024/2025 الكفلاء تحمل الدائن نتيجة الإعسار، وليس له أن يطالب باقى الكفلاء 2024/2025 بحصة المعسر. ولهذا فإن من مصلحة الدائن عند تعدد الكفلاء أن يشترط تضامنهم حتى يتلافى نتيجة إعسار أحدهم.

المبحث الثانى

دفع الكفيل قبل الدائن

تقسيم:

٣٥- لما كان التزام الكفيل يتحدد على أساس عقد الكفالة، والالتزام الأصلى، فإن ما يثبت له من دفع يتحدد على هذا الأساس كذلك فهناك دفع تثبت له بمقتضى الالتزام الأصلى، وهناك دفع تثبت له من عقد الكفالة وإلى جانب ذلك فإن للكفيل دفع تترتب على الكفالة إذا ما قامت صحيحة. ونعرض لهذه الأنواع من الدفع.



المطلب الأول الدفع المتعلقة بالالتزام الأصلي

٣٦- نصت المادة ١/٧٨٢ مدنى على أنه «بيراً الكفيل بمجرد براءة المدين وله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين».

من هذا النص نتبين أن ذمة الكفيل تبرأ بمجرد براءة المدين، باعتبار أن التزام الكفيل التزام تابع، يستمد وجوده من الالتزام الأصلي، فإذا انقض هذا الأخير بأى سبب كالوفاء والإبراء والمقاصة والتقادم، فإن التزام الكفيل ينقضى بالتبعية. وللکفيل أن يتمسك بانقضاء التزامه تبعاً لانقضاء الالتزام الأصلي، بل وله أن يتمسك بأوجه الانقضاء المتعلقة بالالتزام الأصلي.

وإذا كانت ذمة الكفيل تبرأ على هذا النحو فإن له كذلك أن يتمسك بجميع الدفع التى يحتج بها المدين. وللکفيل أن يتمسك بالدفع التى يحتج بها المدين سواء تعلقت بالالتزام الأصلي أم بالمدين نفسه. فله أن يتمسك فى مواجهة الدائن ببطلان الالتزام الأصلي أياً كان سبب البطلان كانهدام الرضا أو المحل أو السبب أو لتخلف الشكل الذى يستلزمه القانون. كما أن له أن يتمسك بإبطال العقد الأصلي أياً كان سبب الإبطال.

ويتمسك الكفيل بالدفع المتعلقة بالالتزام الأصلي حتى ولو كان متضامناً مع المدين وهذا ما نصت عليه المادة ٧٩٤ بقولها «يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفع متعلقة بالدين».

2024/2025

2024/2025

2024/2025

يتمسك الكفيل بالدفع المتعلقة بالالتزام الأصلي ليس فقط باسم المدين، بل وأيضاً باسمه هو لأنه صاحب مصلحة شخصية ومباشرة، إذ يترتب على انقضاء الالتزام الأصلي أو بطلانه، انقضاء التزامه الذى يقوم تبعاً للالتزام الأصلي ويزول بزواله، فالتمسك بالدفع المتعلقة بالالتزام الأصلي حق خاص للكفيل، ويترتب على ذلك.

١- أن له أن يتمسك بها ولو نزل عنها المدين، فإذا نزل المدين عن التمسك بحقه فى التقادم كان للكفيل مع ذلك التمسك به. يعتبر الدين قائماً فى ذمة المدين دون الكفيل الذى يمك بالتقادم، لأن نزول الدين عن التمسك بالتقادم لا يصح أن يضر بالكفيل.

٢- يكون للكفيل أن يتدخل فى الدعوى بين الدائن والمدين لى يتمسك بالدفع التى قد لا يتمسك بها المدين، بل أن له أن يرفع دعوى مبتدأه على الدائن يتمسك فيها بالأوجه الخاصة بالالتزام الأصلي.



على أنه قد يحدث أن يكون العقد الأصلي قابلاً للإبطال، فتنازل المدين عن حقه في طلب الإبطال بأجازة العقد، وفي هذه الحالة إذا ما صار العقد نهائياً بالأجازة لا يكون للكفيل التمسك بالإبطال، إلا إذا ثبت تواطؤ المدين مع الدائن إضراراً بالكفيل.

حالة نقص أهلية المدين

٣٧- أضافت المادة ٧٨٢ في فقرتها الثانية ما نصه «أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه».

تبين من هذا أن عدم احتجاج الكفيل بنقص الأهلية ينبغي ألا يكون مطلقاً، وينبغي أن يميز بين ما إذا كان الكفيل يعلم بنقص أهلية المدين فلا يجوز له، في هذه الحالة، أن يحتج بذلك، وبين ما إذا كان لا يعلم بنقص الأهلية فينبغي أن يكون له الحق في الاحتجاج بذلك وفقاً للقواعد العامة^(١).

وقد اختلف الفقه المصري في تفسير هذه الفقرة، فاعتد البعض بظاهر عبارتها وحرّم الكفيل من التمسك بالإبطال لمجرد علمه وقت الكفالة بنقص أهلية المدين، وأن كان يتحلل من التزامه إذا قضى بإبطال الالتزام المكفول بناء على طلب المدين، لبطلان كفالته تبعاً له^(٢). وأجاز البعض الآخر^(٣) للكفيل، الذي يعلم بنقص أهلية المدين، أن يتمسك بإبطال الكفالة، ولو لم يتمسك المدين بنقص أهليته^(٤) ولا يسقط حقه في التمسك^(٥) إذا أجاز المدين التصرف بعد زوال نقص أهليته، أو أجاز له أو وصيه أو القيم عليه.

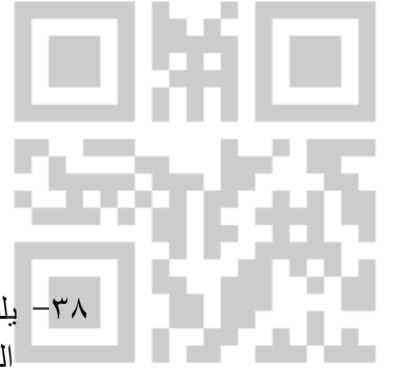
والرأى الذي نفضله^(٦) أن الشارع لم يقصد في المادة ٢/٧٨٢ وضع حكم يختلف عما قرره في المادة ٧٧٧، فلا يمتنع على الكفيل التمسك بنقص أهلية المدين إلا إذا كانت الكفالة «بسبب نقص الأهلية» حين يصبح مديناً أصلياً لا مجرد كفيل، ويكون تمسك المدين بنقص أهليته غير ذي أثر على الكفالة. أما في غير هذه الحالة فيبقى للكفيل حقه في التمسك بنقص أهلية المدين، ولو كان يعلم به «وقت التعاقد» حتى لو أجاز المدين تصرفه.

(١) الأعمال التحضيرية ج ٥ ص ٤٦٨.

(٢) د/ منصور مصطفى منصور: المرجع السابق ص ٦٠، توفيق فرج: ص ٥١.

(٣) د/ السنهوري الوسيط ج ١٠ ص ١٠٠.

(٤) د/ جمال زكي: التأمينات ص ٩٠٤.



المطلب الثانى

الدفع المتعلقة بالتزام الكفيل

٣٨- يلتزم الكفيل على أساس عقد الكفالة. ولهذا فإنه يستطيع التمسك بالدفع الناشئة عن هذا العقد. فله أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة ببطلان هذا العقد نفسه لعدم توافر ركن من أركانه أو بإبطاله لعيب فى الرضا أو نقص فى الأهلية، طبقاً للقواعد العامة فى العقود.

وإلى جانب ذلك فإن الكفيل أن يتمسك بالأوصاف التى تلحق التزامه بعدم تحقق الشرط الواقف الذى علق عليه الكفالة، أو تخلف الشرط الفاسخ المقترن بها، أو عدم حلول الأجل.

وإذا ما نشأت الكفالة صحيحة، فإن للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته لانقضاء التزامه بصفة مستقلة عن الالتزام الأسمى، وهو يتمسك بالانقضاء طبقاً للقواعد العامة. وفى كل هذا لا تخلف الكفالة باعتبارها عقداً، عن غيرها من العقود الأخرى، فللكفيل أن يتمسك بكل دفع يتعلق بانقضاء الكفالة أو يتعلق بما قد يلحق التزامه من أوصاف، أو يتعلق ببراءة ذمته لانقضاء التزامه بصفة مستقلة.

المطلب الثالث

الدفع المترتبة على عقد الكفالة

2024/2025

2024/2025

تقسيم
2024/2025

٣٩- إلى جانب الدفع التى ينشئها العقد نفسه، توجد دفع أخرى تترتب على قيام الكفالة صحيحة مستندة إلى التزام صحيح. فالكفالة إذا ما قامت صحيحة وثبت حقوقاً للكفيل يستطيع التمسك بها قبل الدائن، وقد يؤدى التمسك بها إلى تأجيل مطالبة الدائن أو تقرير براءة ذمته أو تأجيل التنفيذ مؤقتاً على أمواله.

ومن الدفع التى تترتب على عقد الكفالة إمكان الدفع بتأخر الدائن فى اتخاذ إجراءات المطالبة تأخراً ضاراً بالكفيل كما خول القانون الكفيل أن يتمتع عن الوفاء حتى يقوم الدائن بما يفرضه عليه القانون من إجراءات قد يؤدى عدم القيام بها إلى تهديد الكفيل فى الحصول على حقه من المدين، مثل عدم تسليم مستندات الدين. ثم أن الكفيل قد يهدف من وراء تمسكه بدفع من الدفع إلى براءة ذمته كلها أو بعضها، كالدفع بإضاعة التأمينات. وللکفيل أن يتمسك بتأجيل التنفيذ مؤقتاً للتأكد من كافية أو عدم كفاية أموال المدين للوفاء بالدين قبل التنفيذ على أموال الكفيل، هو الدفع بالتجريد وسنعرض فيما يلى لهذه الدفع المختلفة.



عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن

2024/2025

ولكى تبرأ ذمة الكفيل فى هذه الحالة يتعين أولاً أن يقوم بإصدار الدائن باتخاذ الإجراءات، إلا أنه ينبغي أن يتم هذا الإنذار فى وقت يكون فيه الدائن



إمكان مباشرة هذه الإجراءات ويكون ذلك وقت حلول أجل الالتزام الأصلي لا قبله، بصرف النظر عما يمنحه الدائن من أجل للمدين بعد ذلك، لأن للكفيل أن يتجاهل امتداد الأجل. كما يتعين كذلك أن يقعد الدائن عن اتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من الإنذار، إذ يعتبر ذلك خطأ من جانب الدائن، وهو خطأ يفترض بمجرد عام اتخاذ الإجراءات خلال تلك المدة.

إذ لم تتخذ الإجراءات على هذا النحو ضد المدين عن طريق رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التنفيذ إذا كانت الكفالة من سند رسمي، كان للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته، هذا ما لم يقدم المدين ضماناً كافياً للكفيل.

٤١- ولما كان من المتعين أن يقوم الدائن بمطالبة المدين في وقت مناسب، فقد طبق القانون هذا المبدأ في حالة إفلاس المدين، إذ أوجب على الدائن التقدم بالدين إلى التفليسة، لأن الإفلاس يسقط الأجل، فإذا لم يقيم الدائن بهذا اعتبر مقصراً وسقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر. وهذا وجه آخر لحماية الكفيل، لأنه لا يستطيع الدخول في تفليسة المدين قبل أن يفي للدائن. ولهذا حماه القانون فأوجب على الدائن التقدم إلى التفليسة، وإلا كان للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته بمقدار ما كان يحصل عليه لو أنه تقدم في التفليسة.

وإذا كانت المادة ٧٨٦ مدني قد عرضت لهذا الحكم في حالة الإفلاس ²⁵ ~~المادة ٧٨٦~~ ^١ يرى ~~المادة ٧٨٦~~ في حالة الإعسار بالنسبة لغير التجار 2024/2025 على أساس أن الدائن يلتزم إزاء الكفيل بمطالبة الدين في الوقت المناسب ويعتبر الدفع الذي نعرض له من الدفع الموضوعية ومفاد ذلك أنه يجوز أن يبدى في أية حالة تكون عليها الدعوى وإلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف كما يسقط بإبدائه حق التمسك الدفع الشككية.

ثانياً: الدفع بالامتناع عن الوفاء إلى أن يقوم الدائن بما يفرضه عليه القانون.

٤٢- تنص المادة ١/٧٨٧ مدني على أنه (يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين. المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع).

يفصح هذا النص عن الالتزام وعن الهدف من تنفيذه. فالكفيل حين يضطر إلى الوفاء بالدين فإن من حقه أن يرجع على المدين بما دفعه. لذلك من مصلحته أن يتسلم من الدائن المستندات اللازمة للممارسة حقه في الرجوع.

(١) أ. د/ توفيق فرج، التأمينات ص ٥٥، د/ أحمد سلام، التأمينات، ص ٦٣.

ويعتبر نص المادة ١/٧٨٧ مدنى تطبيقاً لما ورد فى المادة ٣٤٩ الخاصة بالإيداع القضائى والتي تقضى بأن

٢- فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.

وينبنى على هذه الأحكام أن للكفيل أن يختار بين أحد أسلوبين للحصول على المستندات من الدائن. الأول أن يتمسك بحقه في الدفع بعدم التنفيذ إلى أن يتسلم المستندات، أى يمتنع عن الوفاء أصلاً. والثانى أن يتخذ طريق الإيداع القضائى. والأسلوب الأول هو الأكثر فائدة وفعالية بالنسبة للكفيل. وعلى الدائن – فى حالة ما إذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس أن يتخلى عنه ^{2016/2015} ذلك أنه يجب على الدائن أن يقوم بما يلزم ليحل الكفيل محله فى استيفاء حقه عند الرجوع على المدين.

وإذا كان الدين مضموناً بتأمين عقارى، يلتزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين، على أن يتحمل الكفيل مصروفات النقل ويرجع بها على المدين.

وفى جميع الحالات السابقة يكون للكفيل أن يطالب الدائن بتنفيذ ما يوجبه عليه القانون، وإلا كان له أن يدفع مطالبته بالامتناع من الوفاء حتى يقوم الدائن بما يوجبه عليه القانون. وهذا الدفع من الدفوع الموضوعية، وهو يعد تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ.

ثالثاً: الدفع بإضاعة التأمينات

٤٣- قد يكون الدين الأصلي مضموناً بتأمينات أخرى، ولهذا يكون على الدائن المحافظة على تلك التأمينات حتى يتسنى للكفيل أن يحل محله فيها بعد الوفاء. فإذا لم يقم الدائن بالمحافظة عليها، وبذل العناية اللازمة - وهي

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالي



عناية الشخص المعتاد - كان مسئولاً عما ضاع بتقصيره، وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضرعه الدائن، لأنه فوت عليه فرصة استيفاء حقه منها، ويكون للكفيل أن يتمسك قبل الدائن ببراءة ذمته بقدر ما أضرعه الدائن من تأمينات خاصة.

وقد نصت المادة ٧٨٤ مدنى على:

- ١- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضرعه الدائن بخطئه من الضمانات.
- ٢- ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.
- ولكى يستطيع الكفيل أن يتمسك بهذا الدفع ينبغى أن تتوافر شروط معينة.
- الشرط الأول: أن يكون الدائن قد أضرع تأميناً خاصاً.**

التأمين الذى يعينه القانون فى هذا الصدد ينصرف إلى أى نوع من أنواع التأمينات، شخصية كانت أم عينية، طالما كانت مخصصة لضمان الدين، فيصح أن يكون هذا التأمين كفالة أخرى، أو تضامنياً أو وسيلة أخرى من وسائل الضمان كالحق فى الحبس. كما قد يكون رهناً أو حق اختصاص أو حق امتياز. ولا يهم مصدر هذا التأمين، فقد يكون اتفاقياً أو قضائياً أو مقررراً بحكم القانون، كما لا يهم تاريخ نشوئه، سواء كان قبل الكفالة أم بعدها^(١). كما لا يهم فى النهاية ما إذا كان التأمين مقدماً من المدين نفسه وعلى ماله، أم مقدماً من غير المدين وعلى مال هذا الغير كالكفيل العينى، كل ما يهم فى هذا الصدد أن يكون هناك تأمين يضيفه الدائن.

فإذا لم يكن هناك تأمين على النحو الذى يتطلبه القانون، ولكن الدائن أهمل فقط فى اكتساب تأمين خاص، فلا ينطبق حكم المادة ٧٨٤ مدنى. وعلى هذا إذا أهمل المؤجر فى إلزام المستأجر بوضع منقولات فى العين المؤجرة تأميناً للوفاء بدين الأجرة طبقاً لما تقضى به المادة ٥٨٨ مدنى، فلا يبرأ الكفيل الذى يكفل المستأجرين دين الأجرة، لأن امتياز المؤجر، وهو التأمين الذى يقرره له القانون، لا يقوم إلا إذا وجدت المنقولات فعلاً فى العين. فلكى تنطبق المادة ٧٨٤ مدنى يجب أن يوجد التأمين الخاص ثم يضيعه الدائن، وفى مثل هذه الحالة لم يوجد التأمين، إذ أنه لا يوجد إلا بدخول المنقولات إلى العين بالفعل.

هذا بالنسبة للمقصود بإضرعة تأمين بفعل الدائن، لكن إلى جانب هذا يلزم أن يكون التأمين خاص. ويقصد بذلك أنه إذا ترتب على فعل الدائن أضعاف

(١) د/ جمال زكى: التأمينات، ص ١٠٠، د/ توفيق فرج: التأمينات، ص ٥٦.

الضمان العام لمدينه، فلا يستفيد الكفيل من ذلك وبالتالي لا تبرأ ذمته. وعلى ذلك إذا لم يقر الدائن بمباشرة دعوى عدم نفاذ التصرفات، فإن فعله - إذ لم يترتب عليه إضاعة تأمين خاص - لا يكون له أثره، حتى ولو أدى ذلك إلى إضعاف الضمان العام. فلا يكون للكفيل أن يستند إلى إضعاف الضمان العام لكي يدفع بإضاعة التأمينات، اللهم إلا إذا كون فعل الدائن خطأ سبب ضرراً للكفيل فيلزم الدائن بالتعويض طبقاً للقواعد العامة.

الشرط الثاني: أن تكون إضاعة التأمينات بخطأ الدائن

هذا الخطأ قد يكون بفعل إيجابي كإبراء أحد الكفلاء أو التنازل عن الرهن أو امتياز أو عن حيازة مال محبوس، أو نزول للدائن المتأخر عن مرتبته في الرهن. وقد يكون خطأ الدائن واقعة سلبية كثيراً ما تتجسم في إهماله في المحافظة على التأمينات التي له، كعدم قيده الرهن، أو عدم تجديد قيده، أو تركه العقار المرهون تنزع ملكيته، ويرسو مزاده بثمان بخس دون إخطار الكفيل، فيفوت عليه فرصة التقدم للمزايدة والعمل بذلك على أن يرسو المزاد بقيمته الحقيقية أو يرسو عليه.

ويعتبر الدائن مخطئاً في جميع الحالات متى خرج في سلوكه عن سلوك الشخص المعتاد، وعلى الكفيل أن يثبت أن ضياع التأمين الخاص كان بخطأ الدائن والخطأ في هذه الحالة يقع على الدائن شخصياً أو يقع ممن يسأل الدائن

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويلزم أن تكون إضاعة التأمينات بخطأ الدائن أو من يسأل عنه، وعلى هذا إذا كانت إضاعة التأمينات بسبب آخر، كما إذا هلك الشيء، محل الرهن مثلاً بسبب القوة القاهرة أو بفعل المدين أو الكفيل فلا يكون الدائن مسؤولاً وبالتالي لا يكون للكفيل أن يدفع بإضاعة التأمينات وقد يكون إضاعة التأمين ناتجة عن خطأ مشترك بين الدائن والكفيل.

وقد ذهب رأى إلى أنه في حالة التقصير المشترك لا تبرأ ذمة الكفيل ولو جزئياً إذ لا يصح له أن يتأذى من عمل اشترك في إيقاعه أو على الأصل كان يمكن تلافيه. بينما ذهب الاتجاه الآخر إلى أن المسؤولية توزع على قدر خطأ كل من الدائن والكفيل، وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما وقع من الدائن من تقصير.

وهذا الرأي الآخر هو ما يرجحه الفقه^(١). وهو فى الواقع ما يتفق والقواعد العامة فى الخطأ المشترك.

الشرط الثالث: الإضرار بالكفيل

يلزم أن يترتب على إضاعة التأمينات الخاصة بالإضرار بالكفيل. وهذا يعنى أنه إذا لم يترتب على إضاعته إضرار بالكفيل، فلا تبرأ ذمته ولا يكون له أن يدفع قبل الدائن بإضاعة التأمينات. ولهذا يلزم أن يكون التأمين الذى أضاعه الدائن ذا قيمة. فإذا لم تكون له قيمة. كما إذا كان رهناً مقررًا على عقار ومتأخرًا عن غيره من رهون تستغرق قيمته. فإن ضياعه لن يؤثر على مركز الكفيل، ومنعاً لذلك لا يكون له أن يدفع بإضاعة التأمينات، وإنما يلزم لكى يستفيد من هذا الدفع أن يكون التأمين ذا قيمة وإلا يقوم الدائن بتقديم تأمين غيره يساويه فى قيمته ويتفق الفقه على أنه كفى أن يضع الدائن تأميناً خاصاً ذا قيمة، حتى تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما ضاع من تأمينات، حتى ولو كان المدين موسراً يستطيع الوفاء إذا ما رجع عليه الكفيل، وحتى لو كانت هناك تأمينات أخرى تضمن للكفيل حقه عند رجوعه على المدين. ذلك أن من شأن هذا الضياع أن يقلل من فرص حصول الكفيل على حقه عند رجوعه على المدين ولا يمكن للدائن أن يحتج عندما يتمسك الكفيل بإضاعة التأمينات، بيسار المدين أو بوجود تأمينات أخرى، إذ لو صح هذا فلا تكون له مصلحة فى التمسك ببقاء الكفالة.

2024/2025

2024/2025

٢٥/٤/٢٠٢٥

٤٤- إذا توافرت الشروط التى يستلزمها القانون يستطيع الكفيل التمسك قبل الدائن بإضاعة التأمينات عن طريق الدفع، كما أن له فضلاً عن ذلك أن يتمسك ببراءة ذمته على هذا الأساس بطريق الدعوى، يرفعها ضد الدائن مطالباً ببراءة ذمته بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من تأمينات وسواء تمسك الكفيل ببراءة ذمته على هذا النحو، عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع، فإنه يقوم بإثبات توافر الشروط السابقة، فيثبت إضاعة الدائن بخطئه لتأمين وجد، فإذا ما أثبت ذلك افترض الضرر فى جانبه ويكون على الدائن نفى وقوع ضرر للكفيل، كما إذا كان التأمين الذى ضاع غير ذى قيمة، أو كما إذا قدم له تأميناً آخر يساويه.

والدفع بإضاعة التأمينات من الدفوع الموضوعية، للكفيل أن يتمسك به فى أية حاله كانت عليها الدعوى ولو أمام الاستئناف، ويتعين على الكفيل أن يتمسك

(١) أ. د/ السنهورى الوسيط ص ١٠، د/ جمال زكى، التأمينات ص ١٠٤، د/ توفيق فرج، التأمينات، ص ٥٨، أ. د/ حمدى عبد الرحمن، الكفالة طبعة ١٩٩٣ ص ٨٢.

به فلا تبرأ ذمته بقوة القانون. ولما كان هذا الدفع خاصاً بالكفيل فإن له أن يتنازل عنه، لأنه لا يتعلق بالنظام العام. وإذا ما تمسك به على هذا النحو، فإنه لا يحكم ببراءة ذمته إلا بقدر ما ضاع من تأمينات. ولهذا تبرأ ذمته من الدين كله إذا كان ما ضاع من تأمينات يساوى قيمة الدين كله.

رابعاً: الدفع بالتجريد

التعريف به

٤٥- يترتب على صفة التبعية التي تلحق بالتزام الكفيل أن الكفيل لا يلزم بالوفاء إلا إذا تخلف وفاء الدين من المدين الأصلي، ويقتضى هذا المعنى أنه إذا ما شرع الدائن في التنفيذ على أموال الكفيل، فإن لهذا الأخير أن يدفع إجراءات التنفيذ بضرورة التنفيذ على أموال المدين أولاً ثم تبين عدم كفايتها للوفاء بالدين.

والدفع بالتجريد مكنه تخول الكفيل الحق في أن يمنع التنفيذ على أمواله وفاء للدين المكفول، سواء كان هذا المنع نهائياً أو مؤقتاً. والاعتبار الذي صدر عنه المشرع في الاعتراف للكفيل بهذا الحق منطقي، ويستمد من صميم الكفالة وكونها أداة تابعه. فالمفروض أن الكفيل لا يجبر على الوفاء إلا إذا تعذر استيفاء الدين المكفول من المدين الأصلي، فضلاً عن إنه خطوة منطقية تأتي بعد الدفع بضرورة سبق مطالبة المدين قبل مطالبة الكفيل.

ومن ناحية أخرى فإن الاعتراف^{2024/2025} للكفيل بهذا الدفع فيه توفير للوقت^{2024/2025} والمصروفات، ذلك أن وفاء الكفيل للدائن يخول للكفيل أن يرجع على المدين بما دفع، فلا داعي إذن لتكرار الرجوع متى أمكن للدائن أن يستوفي حقه من مدينه الأصلي.

وقد نصت المادة ٢/٧٨٨ مدني على الدفع بالتجريد فقرت «أنه لا يجوز للدائن أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.

والدفع بالتجريد يقتضى بالضرورة أن يشرع الدائن في اتخاذ الإجراءات وبالتالي فلا يجوز للكفيل أن يتمسك بهذا الدفع قبل مرحلة التنفيذ. فلا يجوز له أن يتمسك به مثلاً لمجرد أن الدائن قد وجه إليه مطالبة قضائية بالوفاء، بمجرد هذه المطالبة لا تواجه بالدفع بالتجريد، ولكنها قد تواجه بالدفع بوجوب سبق مطالبة المدين.

ويثبت الدفع بالتجريد للكفيل، ولو تقاضى من المدين مقابلاً للكفالة إنما «لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد» م ٧٩٣ مدنى ولما كانت الكفالة القانونية والكفالة القضائية تستلزمان التضامن مع المدين، فلا يمكن للكفيل فى كليهما أن يطلب التجريد. وليس للكفيل العينى كذلك أن يدفع بالتجريد، لأن الكفيل الذى تعنيه نصوص القانون فى عقد الكفالة، هو الذى يلتزم شخصياً، وفى جميع أمواله، بوفاء الالتزام. وقد نص فى المادة ١٠٥٠ على هذا الحكم صراحة، منعاً لأى شك فيه حيث قضت «إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من المال، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك».

شروط التمسك بالدفع بالتجريد

يبنى الدفع بالتجريد على مفهوم وفكرة الكفالة ذاتها باعتباره نظام ضمان يحمى الدائن من عدم قدرة المدين على الوفاء بالدين، وإن العدالة - فضلاً عن النية المشتركة للطرفين (الدائن والكفيل) - تقتضى عدم البدء بصاحب الالتزام التابع قبل تجريد المدين الأصلي.

والدفع مقرر لمصلحة الكفيل فيجب أن يتمسك به. غير أن غاية الدفع لا تتحقق إلا إذا كان لدى المدين من الأموال ما يكفى للوفاء بالدين وقد ترتب على هذا المنطق إلزام الكفيل بإرشاد الدائن عن أمواله المدين الكافية للوفاء حتى

2024/2025

2024/2025 طبع ذلك الكفيل أن يتمسك بالدفع

وعلى ذلك تتبلور شروط التمسك بالدفع بالتجريد فى:

الشرط الأول: ألا يكون الكفيل قد تنازل عن الدفع بالتجريد

البدء بتجريد المدين الأصلي هو ميزه قررها المشرع للكفيل وله بالتالى أن ينزل عنها أو أن يتمسك بها حسب تقديره واختياره. وقد يكون التنازل عن هذا الدفع مسبقاً، أى بناء على شرط فى عقد الكفالة ذاته أو فى ملحق بين الدائن والكفيل. وقد يكون تنازل لاحقاً عند البدء فى إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل.

والتنازل عن الدفع بالتجريد قد يكون صريحاً وقد يكون ضمناً والتنازل الصريح يكون عادة عند انعقاد الكفالة حيث يتفق عليه مع الدائن تسييراً له فى استيفاء حقه. والتنازل الضمنى يكون بكل ما يدل عليه، غير أن التنازل الضمنى غالباً ما يرد بعد إبرام الكفالة وعلى وجه الخصوص عند شروع الدائن فى التنفيذ على أموال الكفيل، دون سيق التنفيذ على أموال المدين ومع ذلك يسكت الكفيل بغير اعتراض على استمرار البدء فى التنفيذ على أمواله. غير أن هناك حالة لا

يكون سكوت الكفيل تنازلاً ضمنياً بصفة نهائية^(١)، فقد يحدث إلا يكون للمدين مال يمكن التنفيذ عليه يستمر الدائن في التنفيذ على أموال الكفيل مباشرة ويسكت الكفيل عن الدفع بالتجريد لعلمه بحاله المدين وعدم جدوى الدفع بالتجريد، ثم يطرأ بعد ذلك ما يثبت مع أن للمدين أموالاً دخلت ذمته بعد بدء التنفيذ على الكفيل، في هذه الحالة يستفيد الكفيل مكنه الدفع بالتجريد ويفقد التنازل الضمني معناه، لأنه كان تنازلاً في ضوء حالة كانت مؤكدة ثم تغيرت.

وسواء كان التنازل صريحاً أو ضمنياً، فإنه يلزم أن يكون قاطعاً في الحالتين، وإذا ما قام الشك حول حصول التنازل من عدمه فسر هذا الشك لمصلحة الكفيل وأن يحمل على أنه لم يتنازل عنه. وتقدير ما إذا كان قد حصل تنازلاً من الأمور الموضوعية. وإذا ما ثبت حصول، فلا يكون للكفيل أن يتمسك بالدفع بعد ذلك.

ويراعى أنه إذا ما تنازل الكفيل عن الدفع بالتجريد، فإن هذا لا يمنع كفيل الكفيل عن التمسك به، ويكون له إلى جانب حقه في تجريد الكفيل أن يطلب تجريد المدين نفسه لأن دفعه مستقلة عن دفع الكفيل، وتنازل أحدهما لا يسرى بالنسبة للآخر.

الشرط الثاني: أن يتمسك الكفيل بالدفع بالتجريد في الوقت المناسب:

لكي يستفيد الكفيل من الدفع بالتجريد يجب عليه التمسك به. فالتجريد حق محوّل للكفيل ولصالحه. ولهذا يكون^{2023/4/2025} أن يتمسك به وأن يتنازل عنه للكفيل^{2024/2025} وحده أن يتمسك به، وليس للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. ولكن متى يكون للكفيل أن يتمسك بهذا الدفع فلم يتعرض القانون صراحة لهذا الموضوع. ولقد كان مشروع تنقيح القانون المدني^(٢) يقضى بأن على الكفيل أن يتمسك بطلب التجريد عند الإجراءات الأولى التي توجه ضده، ولكن هذا حذف دون بيان سبب الحذف. ولهذا اتجه الفقه^(٣) إلى الرأي الذي كان راجحاً قبل صدور القانون المدني الحالي وأقرته محكمة النقض والذي يقضى بأن للكفيل غير المتضامن من الحق في إبداء الدفع بالتجريد في أي وقت مناسب ما لم يصدر منه قول أو فعل أو ترك يدل على تنازل عنه. ثم جاء نص المادة ٧٨٨ مدني ليحدد ويفرق بين مطالبة الكفيل قضائياً وبين التنفيذ على أمواله، وخصص لكل حالة منهما دفعاً

(١) د/ جمال زكي: التأمينات، ص ١١٣، د/ حمدي عبد الرحمن: الكفالة، ص ٩٠.

(٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٥ ص ٤٩٤.

(٣) د/ السنهوري: الوسيط ج ١٠ ص ٧١٨، د/ جمال زكي: التأمينات، ص ١١٧، د/ سمير تناعو:

التأمينات، ص ٧١، د/ توفيق فرج: التأمينات، ص ٦٣، د/ حمدي عبد الرحمن: الكفالة

ص ٩٢: أحمد سلامة: التأمينات، ص ٦٩.

خاصاً، ففي حالة المطالبة القضائية للكفيل أن يتمسك بالدفع بعدم جواز مطالبة وحدة م ١/٨٨٨. وفي حالة الشروع في التنفيذ على أموال الكفيل، يكون له أن يدفع بضرورة تجريد المدين من أمواله قبل التنفيذ على أموال الكفيل م ٢/٧٨٨. ويترتب على هذا الحكم الأخير أن الوقت المناسب للتمسك بالدفع بالتجريد هو اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل.

والواقع أن الدفع بالتجريد يهدف إلى منع التنفيذ مؤقتاً على مال الكفيل، ولهذا فإن تكلم هذا الأخير في الموضوع لا يعنى تنازله عن التمسك بالدفع، فيحق له أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى التنفيذ، ما لم يصدر منه ما يدل على التنازل. فإذا ما طالب الدائن الكفيل كان للأخير أن يدفع بالتجريد وهذا الدفع لا يمنع من إتمام نظر الدعوى حتى يقضى بإلزامه بالدين، وبعدم التنفيذ على أمواله قبل تجريد أموال المدين.

الشرط الثالث: لا يكون الكفيل متضامناً مع المدين:

وهو شرط تتطلبه صراحة المادة ٧٩٣ مدنى إذ تقول «لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد» ذلك أن قبول التضامن ينطوى على التنازل عن هذا الدفع. على أنه ليس هناك ما يمنع الكفيل المتضامن من نفى هذا المفهوم إذا اشترط الدفع صراحة في عقد الكفالة.

والنص يتكلم عن تضامن الكفيل مع المدين. ومن ثم تضامن الكفلاء فيما بينهم لا يعفيهم من طلب التجريد إلا إذا كانوا متضامنين مع المدين. 2024/2025

الشرط الرابع: أن يرشد الكفيل إلى أموال للمدين نفى بالدين كله:

نصت المادة ٧٨٩ مدنى على أنه:

١- إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين نفى بالدين كله.

٢- ولا عبء بالأموال التى يدل عليها الكفيل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضى المصرية أو كانت أموال متنازلاً فيها».

فإذا ما طلب الكفيل تجريد المدين، كان من الواجب أن يقوم على نفقته بالإرشاد إلى أموال المدين. ولا يكفى هذا، بل ينبغى أن تتوفر شروط معينة بالنسبة لما يرشد عنه من أموال.

فيجب أولاً أن تكون الأموال التى يرشد عنها كافية للوفاء بالدين كله، وذلك حتى يكون إرشاده منتجاً. ولا يكفى أن تكون الأموال كافية للوفاء بجزء من الدين، إذ لا يصح إجبار الدائن على قبول جزء من الدين فقط (م ١/٣٤٢ مدنى). كما

أنه إذا ما أستوفى الدائن جزءاً من الدين فسيعود بالباقي على الكفيل، وفي هذا تأخير له في استيفاء حقه، وتعقيد للإجراءات بالنسبة له، ولهذا لا يقبل الدفع بالتجريد إذا لم تكن الأموال كافية للوفاء بالدين كله. وهذه الكفاية من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير القاضي.

ويجب ثانياً أن يكون من الممكن الحجز على الأموال التي يرشد عنها الكفيل. كما يجب كذلك أن تكون غير متنازع فيها، حتى لا تتعقد الإجراءات إلى أن يحصل الدائن على حقه، إذ يتعين الفصل في المنازعة أولاً، ويكفى لاعتبار المال متنازع فيه أن يقوم بشأنه نزاع جدى، حتى ولو لم ترفع بشأنه دعوى.

ويجب أن تكون الأموال التي يرشد عنها الكفيل داخل الأراضى المصرية فلا عبوة بما يرشد عنه الكفيل خارج الأراضى المصرية، حتى لا يكون هناك إرهاق للدائن ولكن يتلافى بذلك التعقيد فى الإجراءات الذى يؤخر حصوله على حقه.

وأخيراً فإن عبء إثبات كفاية الأموال للوفاء بكل الدين يقع على عاتق الكفيل وعليه أن يتحمل نفقات الإرشاد كنفقات استخراج الشهادات العقارية أو المستندات أيأ كان نوعها والدالة على ملكية المدين للأموال وللکفيل أن يرجع بتلك النفقات فيما بعد على المدين.

أما نفقات تجريد المدين من أمواله فلا يلتزم الكفيل بدفعها للدائن بل على 2024/2025 أن يتحمل تلك النفقات ثم يعود بها 2024/2025 على المدين من حاصل البيع وله فى 2024/2025 ذلك حق الامتياز المقرر وفقاً للمادة ١١٣٨ مدنى فى شأنه امتياز المصروفات القضائية.

الآثار التى تترتب على قبول الدفع بالتجريد

٤٧- متى توافرت شروط الدفع فقبلته المحكمة، ترتبت نتيجتان، أحدها سلبية - والآخر إيجابية.

النتيجة الأولى: وقف التنفيذ على أموال الكفيل.

يترتب على الدفع بالتجريد، إذا ما توافرت شروطه عدم جواز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله. فإذا ما قام الدائن رغم ذلك بأى إجراء من إجراءات التنفيذ وقع هذا الإجراء باطلاً. بل أن الإجراءات التى ألتخذها الدائن فى سبيل التنفيذ قبل الحكم بالتجريد تقع باطلة كذلك متى حكمت المحكمة بالتجريد.

وعدم جواز التنفيذ لا يترتب عليه منع السير في إجراءات الدعوى التي يكون الدائن قد رفعها على الكفيل للمطالبة بالوفاء في الحالة التي لا يكون بيد الدائن فيها سند تنفيذي، إلى أن يحصل على حكم ملزم للكفيل بالوفاء، ولكن لا يجوز تنفيذ هذا الحكم إذا ما قبل الدفع بالتجريد.

ومن ناحية أخرى فإن عدم جواز التنفيذ على أموال الكفيل لا يترتب عليه منع الدائن من اتخاذ الإجراءات التحفظية على أموال الكفيل كتوقيف الحجز التحفظي وطلب وضع الأختام على أموال تركته عند وفاته. كما يرى البعض^(١) أن أخذ الدائن اختصاصاً على أموال الكفيل من قبيل هذه الإجراءات ومن ثم فهو جائز.

النتيجة الثانية: التزام الدائن بالتنفيذ على الأموال التي أرشد الكفيل عنها.

والنتيجة الثانية على قبول الدفع بالتجريد هي التزام الدائن بالتنفيذ على الأموال التي أرشد الكفيل عنها، وحينئذ لا يخلو الأمر من أحد فرضين:

الأول: أن يستوفي الدائن حقه كاملاً وأما ألا يستوفيه، أو ألا يستوفيه كاملاً. وفي الحالة الأولى ينتهي الأمر. أما في الحالة الثانية فيتوقف الأمر على سبب عدم الاستيفاء فإذا لم يكن راجعاً إلى خطأ الدائن، فهو قد بدأ في التنفيذ، وساء في الإجراءات وفق مسلك الرجل المعتاد ولكنه بالرغم من ذلك لم يحصل على حقه لسبب من الأسباب كانخفاض قيمة الأموال، أو ظهور دائنين آخرين شاركوه^{2024/2025} في التوزيع. حينئذ يرجع على الكفيل بما لم^{2024/2025} يستطع الحصول عليه.

أما إذا كان عدم الاستيفاء راجعاً إلى إهمال، كتأخره في التنفيذ حتى أعسر المدين أو أفلس، فلا يستطيع الرجوع على الكفيل إلا بقدر الذي لم يكن يحصل عليه لو أنه لم يقصر. وعلى ذلك نصت المادة ٧٩٠ مدني بقولها «في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين يكون الدائن مسئولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.

صورة خاصة للدفع بالتجريد

٤٨- بعد أن عرض المشرع للدفع بالتجريد بصفة عامة، عرض بصورة خاصة للدفع بالتجريد، وهي حالة ما إذا كان هناك تأمين عيني خصص لضمان الدين ذاته، فأعطى الكفيل الحق في طلب تجريد المدين من الأموال المحملة بهذا التأمين. وقد مضت المادة ٧٩١ مدني على هذه الحالة إذا

(١) د/ أحمد سلامة: التأمينات، ص ٧٢.

كان هناك تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمان الدين، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.

يتبين من هذا النص أنه يلزم للتمسك بهذه الصورة من التجريد أن تتوافر شروط معينة:

١ - يلزم أن يكون هناك تأمين عيني.

هذا التأمين العيني يمكن أن يكون ناشئاً عن الاتفاق كالرهن أو عن القانون كالامتياز. لكن ما الحكم إذا كان مصدره القضاء، كما هو الشأن بالنسبة للاختصاص. ترى غالبية الشراح (١) أنه يدخل في التأمين العيني هنا كذلك الاختصاص، لأن القانون نص بأن يسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمي من أحكام.

وإذا كان هناك تأمين عيني على هذا النحو فلا يهم ما إذا كان وارداً على العقار أو على منقول، كما لا يهم ما إذا كان ضامناً للدين فقط، أو ما إذا كان ضامناً له ولديون أخرى، ولا يهم أخيراً ما إذا كان المال الذي يد عليه الحق العيني يكفي للوفاء بكل الدين أو بجزء منه.

ويثور التساؤل في هذا الصدد حول من يقوم بتقديم التأمين. هل يلزم أن يكون مقدماً من المدين، أم يصح أن يقدم من آخر كالكفيل العيني. جاء نص المادة ٧٩١ خلواً من البيان حول هذا الموضوع. ولكن الرأي الغالب (٢) في الفقه يرى أنه يلزم أن يكون التأمين مقدماً من المدين نفسه، لأن الأمر يتعلق بصورة خاصة من الدفع بالتجريد، فضلاً عن أنه يتفق مع القواعد العامة والتي تقضى بأنه لا يجوز للكفيل الشخصي أن يطلب تجريد الكفيل العيني من أمواله. فإذا كان المال المطلوب تجريده في هذه الحالة مملوكاً لغير المدين، أي للكفيل العيني، ما كان للكفيل أن يطلب التجريد.

٢ - يلزم أن تقدم الكفالة مع التأمين أو بعده

ذلك أنه إذا ما قدمت الكفالة مع التأمين العيني، فإن الكفيل يعتمد عليه وكذلك الحال إذا ما تقدم الكفيل بالكفالة بعد وجود التأمين العيني. أما إذا جاء

(١) د/ توفيق فرج: التأمينات، ص ٦٨. د/ منصور مصطفى، ص ٩٣.

(٢) د/ السنهوري الوسيط ج ١٠ ص ١٣٣، د/ منصور مصطفى، ص ٩٤، د/ توفيق فرج: ص ٦٩، د/ سمير تناغو، ص ٨٠، د/ جمال زكي، ص ١٢٣.

التأمين بعد الكفالة، فلا مجال لاعتماد الكفيل عليه ولهذا لا يغنى عن الدفع الذى نصت عليه المادة ٧٩١ مدنى، وإن كان له أن يدفع بالتجريد طبقاً للقواعد العامة متى توافرت شروطه.

٣- يلزم ألا يكون الكفيل متضامناً مع المدين

ذلك أن الكفيل المتضامن لا يستطيع الدفع بالتجريد طبقاً للقاعدة العامة، كما لا يستطيع ذلك أيضاً فى حالة ما إذا كان هناك تأمين عيني طبقاً للمادة ٧٩١، لأن التضامن يعنى تنازله عن هذا الدفع.

٤- ويلزم فى النهاية أن يتمسك الكفيل بهذا الدفع. ذلك أن الحق الثابت بالمادة ٧٩١ ما هو إلا نوع من التجريد، ولهذا يتعين، فضلاً عن حق الكفيل فى التمسك بالتجريد طبقاً للقواعد العامة، أن يتمسك الكفيل به، لأن مقرر لمصلحته ولهذا لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها كما أن يكون للكفيل أن يتنازل عنه.

وإذا توافرت الشروط السابقة، كان على المحكمة قبول الدفع، ويترتب على ذلك ما يترتب على الدفع بالتجريد من آثار. ومعنى ذلك أنه لا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لضمان الدين. فإذا كانت هذه الأموال كافية لنقض التزام الكفيل. أما إذا لم تكن كافية، نفذ بالباقي على أموال الكفيل. وفى هذا الصدد يفترق الدفع بالتجريد هنا عنه طبقاً للقواعد العامة،²⁵ 2024/2025 كان يلزم طبقاً للقواعد العامة²⁵ 2024/2025 أن يرشد الكفيل عن أموال للمدين تفى أصلاً²⁵ 2024/2025 بالدين كله، فإنه لا يلزم للتمسك بالتجريد طبقاً للمادة ٧٩١ أن يكون التأمين العيني كافياً للوفاء بالدين كله.

الفصل الثانى

آثار تنفيذ الكفالة

(علاقة الكفيل بالمدين)

تمهيد:

٤٩- إذا ما رجع الدائن على المدين مباشرة، وقام هذا الأخير بالوفاء انتهى التزامه وانتهى التزام الكفيل تبعاً له، ولا تثار صعوبة ما. لكن قد لا يوفى المدين أو قد يرجع الدائن مباشرة على الكفيل ويقوم هذا الأخير بالوفاء. فإذا قام الكفيل بالوفاء كان له أن يرجع على المدين أو المدينين عند تعددهم وتخول القواعد العامة للكفيل المدنى فى هذه الحالة الحق فى الرجوع على المدين بقدر ما دفعه باعتباره من الغير وقام بوفاء الدين على

أساس الدعوى الشخصية م ٣٢٤ مدنى. كما يكون للكفيل كذلك الرجوع طبقاً للقواعد العامة على أساس الحلول محل الدائن طبقاً للمادة ٣٢٦ مدنى وإلى نقض بأنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه، إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين، أو ملزماً بوفائه عنه.

ولكن المشرع إلى جانب ذلك أعطى الكفيل، فى صدد تنظم الكفالة، دعوى شخصية لا تعتبر مجرد تطبيق لما جاءت به المادة ٣٢٤ مدنى ولكنها تخول حقوقاً أكثر ما تخوله القواعد العامة، وتختلف عنها من حيث شروطها وأحكامها. كما طبق المشرع كذلك حكم المادة ٣٢٦ فى شأن الكفالة إذ نص فى المادة ٧٩٩ على حق الكفيل الذى وفى الدين فى الحلول محل الدائن فى جميع الأحوال.

وسوف نعرض لهاتين الدعوتين، وهما الدعوى الشخصية ودعوى الحلول. وكانت أحكام رجوع الكفيل على المدين تختلف بحسب ما إذا كان المدين شخصاً واحداً أو عدة أشخاص فإننا نعرض لرجوع الكفيل على المدين إذ كان واحداً، ثم نعرض بعد ذلك لرجوعه ف حالة تعد المدينين.

المبحث الأول

رجوع الكفيل على المدين الواحد

2024/2025

2024/2025

2024/2025

إلى جانب القواعد العامة التى تخول للكفيل الرجوع على المدين، فإن القانون قد نظم له دعويتين هما الدعوى الشخصية، ودعوى الحلول ونعرض لكل منهما:

أولاً: الدعوى الشخصية: (دعوى الكفالة)

٥٠- يوفى الكفيل بمقتضى الكفالة التزاماً فى ذمة المدين، فتكون له بداهة أن يرجع بما دفع على هذا الأخير. «للكفيل الذى وفى بالدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه (م ١/٨٠٠ مدنى) ويستوى فى ذلك جميع الكفلاء على اختلاف مراكزهم القانونية، أى سواء كان الكفيل شخصاً أو عيناً متضامناً أو غير متضامن، يتقاضى أجراً أو لا يتقاضى.

غير أن هذه القاعدة تقتضى ألا يكون المدين قد أعترض على الكفالة فقد نصت المادة ٨٠٠ مدنى على أن للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه. والنص حين يتحدث عن علم



المدين يفترض بداهة أن يكون ذلك برضائه الصريح أو الضمني. وبالتالي لا يدخل في منطقة هذا النص أن تكون الكفالة قد عقدت رغم اعتراض المدين، ففي هذه الحالة الأخيرة لا تنطبق المادة ٨٠٠ في شأن الرجوع بالدعوى الشخصية ولكن يكون للكفيل أن يرجع على المدين وفقاً للقواعد العامة في الإثراء بلا سبب ويختلف نطاق الرجوع في هذا الفرض الأخير عن فرض الرجوع بالدعوى الشخصية (١) فقواعد الإثراء بلا سبب لا تسمح للكفيل ألا أن يرجع بمقدار ما دفع عن المدين إذا كانت ذمة المدين قد برئت بهذا المقدار. ولذلك فلو وفي الكفيل ديناً وكان للمدين دفع يبطل المديونية كلها من الأصل فليس له الرجوع، وإذا في الكفيل الدين قبل حلول أجله فليس له الرجوع إلا عند حلول الأجل، كما أنه ليس للكفيل أن يرجع بالمصروفات لأن المدين لم يغبى بمقدارها رغم افتقار الكفيل بهذا القدر. وليس له أن يرجع بالفوائد غلا من وقت المطالبة القضائية وفقاً للقواعد العامة وتطبيق قواعد الرجوع هنا في إطار أحكام الإثراء بلا سبب أيضاً في حالة ما إذا كانت الكفالة قد عقدت لمصلحة الدائن دون مصلحة المدين، كما لو أبرمت الكفالة بعد نشأة المديونية لمجرد تأمين الدائن دون أن تكون للمدين أية مصلحة في ذلك.

وبالتالي فإن الرجوع بالدعوى الشخصية - في حالة عدم اعتراض المدين على الكفالة - يكون في حالة ما إذا أبرمت الكفالة لمصلحة المدين وحده أو لمصلحة الدائن والمدين في ذات الوقت.

2024/2025

2024/2025

شروط الدعوى الشخصية: 2024/2025

٥١- لكي يستطيع الكفيل الرجوع على المدين يجب أن يكون قد قام بالوفاء عند حلول أجل الدين. وأن يكون قد تم لصالح المدين ودون معارضته كما يلزم في النهاية ألا يكون الوفاء بتقصير من الكفيل سبب ضرراً للمدين ونعرض لكل من هذه الشروط:

الشرط الأول: وفاء الكفيل عند حلول الأجل

لكي يستطيع الكفيل الرجوع على المدين يجب أن يكون قد وفى الدين، وهذا واضح من نص المادة ١٠٠/٨٠٠ مدنى. ولا يقصد بذلك أن يقوم الكفيل بالوفاء فقط وإنما يكون له الرجوع إذا كان هناك ما يقوم مقام الوفاء كالمقاصة أو غيرها متى ترتب على ذلك براء ذمة المدين. فإذا كان الكفيل قد قام بوفاء كل الدين رجع به، وأن كان قد أوفى وفاء جزئياً رجع بقدر ما أوفى.

(١) د/ السنهورى: الوسيط ج ١٠ ص ١٧٩، د/ منصور مصطفى، ص ٩٨، د/ جمال زكى، ص ١٣٢. د/ حمد عبد الرحمن، الكفالة، ص ١١٦، د/ سمير تناعو، ص ١١٥.



كما يجب أن يكون أجل الدين قد حل بالنسبة للمدين، وإلا لأمكن الكفيل أن يجبر المدين على الوفاء قبل أن يكون في استطاعة الدائن ذلك على أن المقصود بالأجل هنا هو الأجل الأصلي. وعلى ذلك إذا كان المدين قد نزل عن الأجل أمكن للكفيل أن يرجع، أما لو أمتد الأجل برضاء الدائن أو بحكم المحكمة فإن هذا الأجل الإضافي لا يدخل في الأجل الأصلي ويحق للكفيل أن يرجع قبل انقضائه.

الشرط الثاني: أن تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة المدين دون معارضة.

لم يرد هذا الشرط صراحة ضمن نصوص القانون المدنى الخاص بالكفالة، غير أن شرط مستتب من أحكام الكفالة منطوقها. وقد سبق أن أشرنا إلى أن الكفالة قد تعقد لمصلحة المدين والدائن في أغلب الأحوال. وقد تعقد لمصلحة الدائن وحده في فروض نادرة، فإذا كانت الكفالة قد عقدت لمصلحة الدائن وحده فلا يستطيع الكفيل الرجوع على المدين. ولكن الغالب أن تتم الكفالة بناء على طلب المدين أو على الأقل بعلمه.

وبالرجوع للمادة ٨٠٠ مدنى يتبين أن الدعوى الشخصية يمتد استخدامها إلى حالات إبرام الكفالة جميعاً فيما عدا إبرامها رغم معارضة المدين. وبالتالي فإن انتفاء هذا الاعتراض يعد شرطاً من شروط استخدامها في الرجوع على المدين. وهو شرط مفهوم ويتسق مع أهمية الدعوى الشخصية وما تخول للكفيل من إمكانات في الرجوع، حيث تشمل الرجوع بأصل الدين وبال فوائد والمصروفات التي دفعها وقت إخبار المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده، وكذلك الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.

وهذه الإمكانيات أوسع مدى مما تقرره القواعد العامة للأخرى الذى يفى دين غيره والذى يتحدد رجوعه على المدين بقدر ما دفعه وفقاً للمادة ٣٢٤ مدنى (إلى جانب حالات الحلول التي نصت عليها المادة ٣٢٦. مدنى فى شأن الوفاء من غير المدين).

أما بالنسبة لاشتراط أن تكون الكفالة لمصلحة المدين فهو قائم على شرط عدم الاعتراض، بمعنى أنه إذا أبرمت الكفالة بغير اعتراض المدين فيفترض أنها عقدت لمصلحة. غير أن هذا الافتراض قابل لإثبات العكس. إذ يجوز للمدين رغم عدم اعتراضه على إبرام الكفالة مسبقاً أن يقيم الدليل على أن الكفالة قد أبرمت لمصلحة الدائن وحده، ومن ذلك أن يضمن الكفيل ديناً فى ذمة المدين ولم يكن أجل الدين قد حل بعد، دون أن يحصل من الدائن على أية ميزة جديدة لمصلحة المدين. فإذا أثبت ذلك أمتنع الرجوع بالدعوى الشخصية، وإن كان له أن يرجع وفقاً للقواعد العامة أو بناء على دعوى الحلول.

الشرط الثالث: أن يقوم الكفيل بإخطار المدين قبل الوفاء وإلا يعترض هذا الأخير على الوفاء.

نصت المادة ١/٧٩٨ مدنى على أنه:

١- يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو انقضائه.

٢- إذ لم يعارض المدين فى الوفاء، بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه.

يتبين من هذا النص أن الكفيل يجد نفسه مضطراً إلى الوفاء بالدين عن المدين فقد يدفع بالتجريد وينتهى الدفع إلى غير نتيجة، وقد يكون متضامناً فلا يجوز لد الدفع بالتجريد، وقد يجد نفسه أدبياً ملزماً بالوفاء بوصفه كفيلاً حفاظاً على سمعته. فى جميع الحالات يتعين عليه أن يخطر المدين بعزمه على الوفاء بالدين، ويستوى فى ذلك أن يكون الوفاء تلقائياً من جانب الكفيل أو كان استجابة لدعوى قضائية رفعها الدائن ضد هذا الكفيل.

وتعود الحكمة من انقضاء هذا الإخطار إلى أن المدين قد يرى الاعتراض على الوفاء، فقد تقوم لديه مبررات تستوجب هذا الاعتراض فقد يكون المدين قد أوفى الدين مثلاً ويترتب على عدم الإخطار قيام المدين بالوفاء مرة ثانية. وقد تنوافر للمدين أسباب يطعن بها على سند المديونية أو على استمرار بقائها قائمة فى ذمته، وقد أشارت إلى هذا المعنى المادة ٧٩٨ صراحة.

وتطبيقاً لذلك فإن المدين - إذا ما تم أخطاره - يكون من حقه أن يبدي اعتراضاً مفاده أنه سبق أن أوفى بالدين مثلاً، أو أن المديونية قد أنقضت بسبب من أسباب الانقضاء القانونية وقد يبدي اعتراضاً يتمثل فى الإدعاء ببطلان سند الدين ذاته. ولكن يلاحظ فى هذا الصدد أنه لا يجوز للمدين أن يبدي اعتراضاً يتعلق بالتزام الكفيل إذ لا شأن للمدين فى ذلك.

وإذا قام الكفيل بإخطار المدين فاعترض هذا الأخير على الوفاء، فإن على الكفيل أن يمتنع عن الوفاء على مسئولية لمدين. وفى هذه الحالة قد يقوم الدائن باتخاذ إجراءات المطالبة ضد الكفيل، وهنا يحق للكفيل أن يدخل المدين جبراً فى الدعوى لكى يبدي ما كان له من دفعات تساند اعتراضه. وقد لا يبدي الكفيل بالاعتراض المدين يستمر فى الوفاء بالدين فإنه يقوم بذلك على مسئوليته فى هذا الفرض، بمعنى أنه يكون معرضاً لأن يفقد كل حقه أو جزء من هذا الحق فى

الرجوع على المدين. وتتوقف هذه النتيجة على مدى صحة أسباب الاعتراض، وهل كان يترتب عليها براءة ذمة المدين كلياً أو جزئياً.

ويطبق ذات الحكم السابق إذا لم يقم الكفيل بالإخطار أصلاً بمعنى أن الأمر يتوقف على مدى الفائدة التي عادت على المدين من الوفاء، فإن انعدمت الفائدة انعدم الرجوع وإن كانت الفائدة جزئية كان الرجوع بقدرها، وإن كانت الفائدة كاملة كان الرجوع كاملاً وحاصل ذلك أن الكفيل إذ لم يخطر فإنه يفى على مسؤوليته.

ومن ناحية أخرى فإن الكفيل قد يخطر المدين ولكن هذا الأخير يلتزم الصمت وعدم الرد، وفي هذه الحالة من حق الكفيل أن يعتقد في عدم وجود أسباب للاعتراض، وللکفيل بالتالى أن يفى بالدين ثم يرجع على المدين بالدعوى الشخصية حتى لو تبين فيما بعد أن هذا المدين كانت له أسباب تتعلق بانقضاء المديونية أو ببطانها. وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٧٩٨ مدنى على هذا الحكم صراحة.

ولا يشترط في اعتراض المدين شكل خاص، فيجوز أن يكون بورقة رسمية، كإعلان على يد محضر، أو بورقة عرفية، ككتاب مسجل أو غير مسجل، كما يجوز أن يكونا شفهيًا، ويقع عبء إثبات الأخطار على الكفيل، وإثبات الاعتراض على المدين، وفقاً للمبادئ العامة في الإثبات.

2024/2025

2024/2025

٢٠٢٤/٢٠٢٥ **الدعوى بالرجوع بالدعوى الشخصية**

الدين الذى يرجع به الكفيل على المدين يتكون من عدة عناصر حددتها المادة ٨٠٠ مدنى وهى:

١- كل المبالغ التى تكون دين الدائن قبل المدين، والتى وفى بها الكفيل لإبراء ذمة هذا الأخير. وهذه المبالغ هى أصل دين الدائن قبل مدينه وفوائد هذا الدين التى استحققت إلى يوم الوفاء. كما يرجع بالمصروفات سواء تلك التى أنفقها الدائن فى الإجراءات ضد المدين وأضطر الكفيل إلى دفعها لدخولها فيما يكفله أن التى أنفقها الدائن ضد الكفيل ودفعها له الكفيل، أو تلك التى أنفقها الكفيل نفسه مثل مصروفات الإرشاد عن أموال المدين عند الدفع بالتجريد على أنهب النسبة للمصروفات التى أنفقها الكفيل وأنفقها الدائن فى مواجهته لا يستطيع الرجوع إلا بما دفعه من وقت أخباره المدين الأصلي بالإجراءات التى اتخذت ضده (م ٢/٨٠٠ مدنى) ذلك أنه إذا قام الدائن باتخاذ الإجراءات ضد الكفيل كان على هذا الأخير أن يخبر المدين بهذه

٣- إذا كان للكفيل أن يرجع بما دفعه، على النحو السابق من أصل الدين والفوائد والمصروفات، فإن الأمر يثار بعد ذلك عن إمكان رجوعه على المدين بالتعويض إذا لحقه ضرر بسبب وفائه للدائن، كما إذا تعطلت أعماله مثلاً بسبب بيع أمواله. لم تتعرض المادة ٨٠٠ لذلك، وقد كان نص المشروع التمهيدى^(٢) يقضى بأن للكفيل - علاوة على المبالغ التى يرجع بها على المدين - أن يرجع بالتعويض. ولكن حذف هذا الحكم اكتفاء بالقواعد العامة، وبالرجوع للمادة ٢٣١ مدنى نجدها تقضى بأنه «يجوز للدائن أن يطالب

(٢) مجموعة الأعمال التحضيرية، ج٥، ص٥٤٧.

بتعويض تكميلي مضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

واستناداً إلى هذا النص يكون للكفيل أن يرجع على المدين بتعويض تكميلي إذا أثبت أن الضرر يجاوز الفوائد، وأنه يرجع إلى سوء نية المدين كأن يثبت مثلاً أن المدين أخفى ما لديه من أموال ولم يقدّرته عليه. مما أدى إلى التنفيذ على أموال الكفيل وسبب له ضرر يجاوز قيمة الفوائد.

ثانياً: دعوى الحلول

نصت المادة ٧٩٩ مدنى على أنه إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين. ولكن إذا لم يوف إلا ببعض الدين فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين».

ويعتبر هذا الحكم تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة ٣٢٦ مدنى والتي تنص على أنه «إذا قام شخص بالوفاء غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الآتية: إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه».

وعلى ذلك فإن الأساس القانونى لدعوى الحلول هو تلك النصوص، ولم تتحفظ هذه النصوص فى شأن صفة الكفيل، بحيث أنه يستفيد منها الكفيل العادى والكفيل المتضامن، والكفيل العيى، يستوفى فى كل ذلك أن تكون الكفالة بأجر أو بلا أجر. كما يستوفى الرجوع بدعوى الحلول للكفيل سواء أكانت الكفالة قد عقدت لمصلحة المدين بالاتفاق معه أو حتى رغم معارضته، كما تثبت إذا كانت الكفالة قد عقدت لمصلحة الدائن.

شروط الرجوع على المدين بدعوى الحلول

هناك شرطان، وفاء الكفيل ثم حلول أجل الدين الأصلى.

١- وفاء الكفيل للمدين

وفاء الكفيل بالدين هو شرط بديهى أفصحت عنه المادة ٧٩٩ مدنى بوضوح تام بقولها «إذا وفى الكفيل الدين...» فلكى يثبت للرجوع على المدين عن طريق حلوله محل الدائن يتعين أن يكون قد وفى الدين فعلاً، سواء كان هناك وفاء أو ما يقوم مقام الوفاء كالمقاصة. ويفرق فى هذا الصدد بين ما إذا أستوفى الدائن حقه كاملاً، وبين ما إذا لم يستوف إلا جزءاً من حقه فقط. فإذا أستوفى الدائن حقه كاملاً، سواء كان ذلك من الكفيل وحده، أم من الكفيل ومن غيره، كان للكفيل الرجوع على المدين. أما إذا لم يستوف حقاً كاملاً فلا يستطيع الكفيل الرجوع على المدين بدعوى الحلول حتى لا يزاحم الدائن فى رجوعه على

المدين. إذ لا ينبغي أن يترتب على الحلول الإضرار بالدائن. ولهذا يتعين على الكفيل أن ينتظر حتى يستوفى الدائن حقه كاملاً.

هذا ويراعى أنه إذا كان الكفيل لا يستطيع الرجوع بدعوى الحلول إلا بعد أن يستوفى الدائن حقه كاملاً، إلا أن هذه القاعدة يمكن الاتفاق على خلافها (م ٣٣٠/١مدنى) إذ يصح الاتفاق على منح الكفيل الحق في الرجوع بدعوى الحلول، حتى ولو لم يكن الدائن قد أستوفى حقه كاملاً، لأن الأمر يتعلق بحماية مقررة لمصلحة الدائن، وله أن يتنازل عنها.

٢- حلول الأجل:

يتعين للرجوع بدعوى الحلول أن يكون أجل الوفاء قد حل عند وفاء الكفيل بالدين، فإذا ما سارع الكفيل بالوفاء قبل الأجل فإن عليه أن ينتظر حلول الأجل الأصلي لإمكان الرجوع بدعوى الحلول وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون^(١) إلى الحكمة من ذلك بالقول فإن كان الوفاء قبل الأجل قد تم بغير رضا المدين، فإن الكفيل يعرض نفسه لخطر ضياع حقه في الرجوع على المدين والحلول محل الدائن إذ كان الدين قد أنقضى في المدة بين الوفاء وحلول الأجل بسبب المقاصة أو اتحاد الذمة مثلاً، أو كانت لدى المدين دفع تبرئ ذمته من الدين». ومعنى ذلك أنه في مثل هذه الاحتمالات فإن للمدين أن يدفع رجوع الكفيل بدعوى الحلول كما لو كان يدفع في مواجهة الدائن نفسه من دفع.

الآثار التي تترتب على حلول الكفيل محل الدائن

٢٠٢٤/٢٠٢٥ إذا ما قام الكفيل بالوفاء، فإنه يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين. وهذا ما نصت عليه المادة ٧٩٩. ولما كان هذا النص تطبيقاً خاصاً للقواعد العامة من الحلول فإنه يكون للكفيل الحلول في حقه، بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفع. مع مراعاة أن يكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه الكفيل من ماله.

أولاً: فالكفيل يحل محل الدائن في حقه بماله من خصائص وما يلحقه من توابع. وهذا يعنى أن حق الدائن ينتقل إلى الكفيل بما يلحق به من صفات. فإذا كان الدين تجارياً كان للكفيل التمسك بهذه الصفة وما يترتب عليها من آثار سواء من حيث الإثبات، أم من حيث سعر الفائدة أو غير ذلك من الآثار التي تترتب على اعتبار الدين تجارياً^(٢)، فإذا رجع الكفيل على المدين كان له أن يثبت حقه

(١) المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى، ج٥، ص ٥٥٠.

(٢) من هذا نصت محكمة النقض «وكان القرض - المكفول - عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه فإن الكفيل للمدين يحل محل الدائن الأصلي فيما بماله من خصائصه ومنها صفة التجارية

بكافة الطرق باعتبار أن الإثبات في الدين التجارى مطلق من كل قيد.... وإذا كان لحق الدائن مدة تقادم خاصة - كما إذا كان من الحقوق الدورية المتجددة كأجرة المبانى والأراضى الزراعية - سرى هذا على الكفيل أيضاً، على أن يدخل في الاعتبار ما سرى في مواجهة الدائن. وإذا كان السند المثبت لحق الدائن واجب التنفيذ، كان للكفيل أن يستعمل هذا السند قبل المدين، ولو لم يكن له هو سند من هذا النوع.

ومن ناحية أخرى ينقل حق الدائن إلى الكفيل بما يلحقه من توابع كالفوائد فإذا كان الدين منتجاً لفوائد لمصلحة الدائن ظلت هذه الفوائد سارية لمصلحة الكفيل بالسعر نفسه. وإذا لم يكن منتجاً لفوائد ما حق للكفيل المطالبة بها، وله فقط المطالبة بأصل الدين والفوائد القانونية طبقاً للقواعد العامة.

ثانياً: وينقل الحق إلى الكفيل مع ما يكفله من تأمينات كانت موجودة وقت الوفاء وتنتقل التأمينات إلى الكفيل بحالتها عند الوفاء، فالرهن مثلاً ينتقل بمرتبه، ولا يهم ما إذا كانت تلك التأمينات موجودة وقت انعقاد الكفالة أم وجدت بعد ذلك، كما لا يهم مصدرها، فيد يكون الاتفاق أو القضاء أو القانون، كما لا يهم نوعها شخصية أو عينية.

وبالنسبة للتأمينات الشخصية قد تكون كفالة أخرى، كما قد يكون تضامناً بين المدينين في حالة تعددهم، وقد يكون الدين غير قابل للانقسام. ويستفيد ²⁵الكفيل من هذه التأمينات بحلوله محل الدائن. وللکفيل أن يحل أيضاً محل الدائن ^{2024/2025} بالنسبة للتأمينات العينية ويستفيد منها، سواء كانت هذه التأمينات مقدمة من المدين نفسه أم من الغير.

وأياً كان الأمر فإنه يتعين - لکی يستفيد الكفيل من حلوله محل الدائن - أن تتخذ الإجراءات اللازمة لجعلها تسرى في مواجهة الغير. ويلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. وإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، كان على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل كما يلتزم أن يتخذ الإجراءات اللازمة لنقل التأمين العقارى.

ثالثاً: الدفع: إذا كان للكفيل أن يرجع بما للدائن من حقوقه، فإن المدين يستطيع الاحتجاج قبل الكفيل بالدفع التي كانت له قبل الدائن. فكل ما كان المدين يستطيع الدفع به في مواجهة الدائن، يستطيع الدفع به كذلك في مواجهة الكفيل، كالدفع ببطان الالتزام الأصلی أو بانقضائه أو بغير ذلك من الدفع

وبالتالى يكون للكفيل أن يرفع دعواه على المدين أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها، نقض ١٩٦٨/١/٢٥ طعن رقم ٢٨٩ س ٣١ ق.

الأخرى. ومن هذا قضت محكمة النقض^(١) «للمدين في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول القانوني أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدني القائم لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ومن ثم للمطعون ضده (التابع) أن يتمسك قبل الطاعنة (المتبوع) بهذا التقادم متى انقضت على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدني القائم الذي استمدت هذا التقادم دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض، وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع كما لا يعتبر الحكم الذي يصدر في تلك الدعوى حجة عليه إذا لم يختصم منها».

ثالثاً: مقارنة الدعوى الشخصية بدعوى الحلول

من استعراضنا السابق لكل من الدعوى الشخصية ودعوى الحلول يتضح لنا الفارق بينهما، ونبين في إيجاز ما يفرق بين الدعويين، سواء كان ذلك بالنسبة لشروطها، أم بالنسبة لما يرجع به الكفيل على أساس كل منهما^(٢).

١- إذا كان يلزم لمباشرة كل من الدعويين قيام الكفيل بالوفاء، إلا أنه يلزم للرجوع بدعوى الحلول أن يكون الدائن قد أستوفى حقه بتمامه. ولا يلزم ذلك في حالة الدعوى الشخصية أن يكون للكفيل الرجوع على المدين حتى ولو وفي جزءاً

24/2025 من الدين فقط ويتساوى الكفيل²⁵ في رجوعهما على المدين، ما لم يكن 2024/2025 للدائن سبب خاص للامتنياز.

٢- بالنسبة للكفلاء الذين يحق لهم الرجوع بأى من الدعويين، تثبت دعوى الحلول لكل الكفلاء الذين يقومون بالوفاء، سواء أكانت الكفالة بعلم المدين أم بدون علمه، أم رغم معارضته، وسواء كانت لصالح الدائن أم لصالح المدين. أما الدعوى الشخصية فإنها لا تثبت للكفيل إذا كانت الكفالة قد تمت رغم معارضة المدين، لو كانت لصالح الدائن فقط^(٣).

(١) نقض مدني ١٩٦٨/٢/٢٢ طعن رقم ٦٤ س ٣٣ ق.

(٢) د/ السنهاوي: الوسيط ج ١٠ ص ١٨٢، د/ منصور مصطفى، ص ١٠٧، د/ توفيق فرج: ص ٧٨، د/ سمير تناعو: ص ١٢٢، د/ حمدي عبد الرحمن: ص ١٤٠.

(٣) «لما كان المتبوع - وهو في حكم الكفيل المتضامن - لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفاته التعويض للدائن المضرور بالدعوى الشخصية التي قررها القانون في المادة ٨٠٠ من القانون المدني للكفيل قبل المدين وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعة هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده فإنه لا يكون للمتبوع في رجوعه على المدين إلا دعوى

٣- بالنسبة لما يرجع به الكفيل في حالة الحلول يرجع بما للدائن من حق قبل المدين بصفاته وتوابعه، مع مراعاة أنه لا يستطيع الرجوع بالفوائد إلا إذا كان الدين منتجاً لها، وإن كان له المطالبة بالفوائد القانونية من حين المطالبة القضائية. أما بالنسبة للدعوى الشخصية فإن الكفيل يرجع بما أداه لإخلاء ذمة المدين، كما يرجع بالمصروفات وبالفوائد القانونية من وقت الوفاء بصرف النظر عما إذا كان الدين منتجاً لفائدة أم لا. ولا تقتضى الدعوى الشخصية إلا بمضى ١٥ سنة من وقت الوفاء.

٤- بالنسبة للتأمينات، في حالة دعوى الحلول يحل فيها الكفيل محل الدائن. أما في حالة الدعوى الشخصية فلا يستفيد الكفيل من التأمينات التي كانت للدائن، لأن الكفيل يرجع بدعوى خاصة به مستقلة عن حق الدائن.

المبحث الثانى

رجوع الكفيل فى حالة تعدد المدينين

أوضحنا فيما سلف رجوع الكفيل على المدين، مفترضين أن المدين شخص واحد، ولكن قد يحدث أن يتعدد المدينون في نفس الدين. وهنا تتعدد الفروض، فقد يكفلهم الكفيل جميعاً أو يكفل بعضهم فقط، وقد يكون هؤلاء المدينون متضامنين فيما بينهم، وقد لا يكونون كذلك، وندرس هذه الفروض على التوالى.

تعدد المدينين مع عدم تضامنهم

٢٠٢٤/٢٠٢٥ إذا كان المدينون غير متضامنين، وكفلهم الكفيل جميعاً ثم وفى الدائن، فلا يجوز له أن يرجع على أى واحد منهم إلا بقدر نصيبه من الدين، سواء رجع بالدعوى الشخصية أو دعوى الحلول. لأنه في رجوعه بالدعوى الشخصية إنما يرجع أساساً بما وفاه من دين هذا المدين، ونظراً لأن هذا المدين غير متضامن مع غيره من المدينين، فإنه لا يكون مسئولاً إلا بقدر حصته فقط... وإذا رجع بدعوى الحلول، فإن حق الدائن قبل أى مدين غير متضامن لا يتخطى نصيب هذا المدين في الدين. ويسرى نفس الحكم إذا رجع الكفيل بدعوى الإثراء بلا سبب طبقاً للقواعد العامة، لأن إثراء أى مدين غير متضامن لا يزيد عن قدر نصيبه في الدين.

الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ مدنى وهي تطبيق للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ مدنى والتي تنص بأن الموفى يحل محل الدائن الذى أستوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين على المدين. نقض مدنى ١٩٦٨/٢/٢٢ طعن رقم ٦٤ س ٣٣ ق.



أما إذا كان المدينون غير متضامنين، وكفل الكفيل بعضهم فقط، فإنه لا يرجع إلا على من كفله منهم وفي حدود نصيبه في الدين. ولا يرجع على مدين آخر لم يكفله بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية ولكن إذا دفع ما يزيد عن نصيب المدينين الذين كفلهم مما أدى إلى براءة ذمة مدينين آخرين لم يكفلهم، حق له الرجوع على هؤلاء بدعوى الإثراء بلا سبب المقررة في القواعد العامة، ويكون رجوعه أقل القيمتين الافتقار أو الإثراء^(١).

تعدد المدينين وتضامنهم:

إذا كان المدينون متضامنين، وضمنهم الكفيل جميعاً، كان له أن يرجع على أى منهم بكل الدين الذى وفاه وقد نص المشرع على هذا الحكم في المادة ٨٠١ وهى تقرر أنه «إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذى ضمنهم جميعاً أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين».

والحكم الذى قرره المشرع ينطبق سواء رجع الكفيل بدعوى الحلول أو رجع بالدعوى الشخصية. فهو إذا رجع بدعوى الحلول، كان له حق الدائن، وهذا الحق يعطى لصاحبه طبقاً لقواعد التضامن أن يرجع على أى مدين متضامن بكل الدين، وهو إذا رجع بالدعوى الشخصية، فإنما يرجع بما وفاه من دين المدين، وهذا الدين يشمل الدين كله لأن كل مدين متضامن ملزم في مواجهة الدائن بوفاء الدين^{2024/2025} في مجموعة^(٢).

2024/2025

2024/2025

أما إذا كان المدينون متضامنين، وضمن الكفيل بعضهم فقط، فإن الحكم السابق يسرى أيضاً في رجوع الكفيل على من ضمنه منهم، فيحق له أن يطالب أى مدين كفله بكل الدين الذى وفاه، سواء في رجوعه عليه بالدعوى الشخصية أو دعوى الحلول. ولكن هل يجوز للكفيل في هذا الفرض أن يرجع على مدين متضامن لم يكفله.

من الثابت أن الكفيل لا يحق له أن يرجع على مدين متضامن لم يكفله بدعوى الكفالة الشخصية لأن هذه الدعوى خاصة برجوع الكفيل على المدين الذى كفله. وكذلك من الثابت أن الكفيل أن يرجع على أى مدين متضامن لم يكفله بدعوى الإثراء بلا سبب طبقاً للقواعد العامة. وهو لا يرجع في هذه الدعوى إلا بقدر إثراء هذا المدين، أى بقدر نصيب هذا المدين في الدين مضافاً إليه نصيبه

(١) د/ منصور مصطفى منصور، ص ١٠٨.

(٢) د/ السنهورى: الوسيط، ج ١٠، ص ١٩٤، د/ منصور مصطفى: ص ١٠٩.



في حصة المعسر من المدينين المتضامنين. لأن هذه هي حدود مسئولية أى مدين متضامن في علاقته بغيره من المدينين المتضامنين، وعلى أساس هذه العلاقة تتخذ درجة إثراءه.

ومن الثابت أيضاً أن للكفيل أن يرجع على مدين متضامن لم يكفله بالدعوى غير المباشرة مستعملاً حقوق المدين الذى كفله. لأن الكفيل بالوفاء أصبح دائماً للمدين الذى كفله، وهذا المدين يصبح دائماً للمدينين الآخرين المتضامنين معه، ونظراً لأن حقوق أى مدين متضامن قبل غيره من المدينين لا تتخطى نصيب المدين الذى يرجع عليه مضاف إليه نصيبه في حصة المعسر منهم، فلا يجوز للكفيل الذى يرجع باسم المدين الذى كفله أن يتخطى حدود هذا القدر (م ٢٩٧ مدنى).

يخلص مما سبق أنه إذا كان لا يجوز للكفيل أن يرجع على مدين متضامن لم يكفله بدعوى الكفالة الشخصية، فإنه يجوز له الرجوع عليه بدعوى الحلول وأن يطالبه بكل الدين.

الفصل الثالث

علاقة الكفيل بغيره من الكفلاء

تمهيد:

إذا ما تعدد الكفلاء، فإما أن يلتزم كل منهم بجزء من الدين، وأما أن يلتزم بالدين كله. وإذا ما قام أحدهم بالوفاء ينثر البحث عن الآثار التى تترتب على هذا الوفاء من حيث مدى ما يرجع به الموفى على غيره من الكفلاء الآخرين، وذلك بطبيعة الحال إذا ما كان وفاؤه مفيداً للآخرين، أى يترتب عليه براءة ذمتهم قبل الدائن متى كانوا قد ظلوا ملتزمين إلى حين الوفاء. ونعرض فيما يلى لحالة التزام الكفيل بجزء من الدين فقط وحالة ما إذا التزم بكل الدين.

أولاً: حالة التزام الكفيل بجزء من الدين

إذا تعدد الكفلاء وكان كل منهم ملزماً بجزء من الدين، فإنه يكون لكل منهم حق التقسيم، ولا يلتزم إلا بنصيبه فقط من الدين، متى توافرت شروط التقسيم. وعلى ذلك إذا قام الكفيل بالوفاء انتهى الأمر، فلا يكون ملزماً بالوفاء، بما على الكفلاء الآخرين.

أما إذا أوفى بنصيبه وبأنصبة الباقيين، أى بالدين كله، فى هذه الحالة يكون له الرجوع على كل منهم بدعوى شخصية أساساً للإثراء بلا سبب طبقاً للقواعد العامة، فيرجع على كل منهم بقدر ما أثرى به، وهو نصيب كل منهم فى الدين.

وإذا ما أعسر أحدهم تحمل الموفى حصة هذا المعسر، ولا يكون له الرجوع على غيره من الكفلاء.

ثانياً: حالة التزام الكفيل بالدين كله

قد يكون الكفيل ملتزماً بالدين كله، سواء كان ذلك لتضامنه مع غيره من الكفلاء، أو لأنهم قد التزموا بعقود متوالية، لم يحتفظ الكفيل لنفسه بحق التقسيم.

١- إذا كان سبب التزام الكفيل بالدين كله هو التضامن مع غيره من الكفلاء، وقام بالوفاء عند حلول الأجل، كان له الرجوع على الكفلاء الآخرين، وهو يرجع إما على أساس دعوى الإثراء أو على أساس دعوى الحلول محل الدائن^(١).

أما بالنسبة لدعوى الإثراء، فإن أساسها هو أن وفاء الكفيل بالدين كله ترتبت عليه براءة ذمة الكفلاء الباقين في مواجهة الدائن، يترتب على ذلك أن كلا منهم يثرى بالقدر الذى برئت ذمته بسبب هذا الوفاء. ولما كانت ذمته تبرأ في علاقته مع المتضامنين الآخرين بقدر نصيبه وحصته في نصيب المعسر من الكفلاء المتضامنين، فإن هذا هو ما يتحقق به الإثراء. وهو ما يستطيع الكفيل الموفى الرجوع به. فالكفيل الموفى يرجع على كل من الكفلاء الآخرين بقدر نصيبه وحصته في نصيب المعسر. وإنما يلزم بطبيعة الحال أن تكون براءة ذمة كل من الكفلاء الآخرين بسبب هذا الوفاء. فإذا كان التزامه قد أنقضى من قبل^{2024/2025} لا يوجب كالتقادم أو الإبراء أو^{2024/2025} لا يكون للكفيل الذى وفى الدين كله^{2024/2025} الرجوع على من أنقضى الالتزام بالنسبة له من الكفلاء.

أما بالنسبة لدعوى الحلول فإن مقتضاها أن يحل الكفيل الموفى محل الدائن ويكون له أن يرجع على أى من الكفلاء الآخرين بالدين كله. ولكن لما كان هذا يؤدي إلى الوقوع في حلقة مفرغة لأنه إذا رجع الكفيل بالدين كله على أحد الكفلاء، كان لهذا الأخير الرجوع بالدين كله على غيره وهكذا. ولما كان الكفلاء

(١) متى كان رجوع الكفيل المتضامن - بما أوفاه وفاءً صحيحاً لدين ما تم - فإنه يحق له أن يرجع على باقى الكفلاء المتضامنين معه كل بقدر حصته في الدين الذى أوفاه للدائن. ويكون هذا الرجوع أما بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية التى أساسها النيابة التبادلية المفترضة قانوناً بين المتعهدين المتضامنين في الدين على ما تقررته المادة ١٠٨ من القانون المدنى الملغى.

وإذا كانت الدعوى الشخصية تقدم على الوكالة المفترضة بين الكفلاء المتضامنين فإنه يتعين في شأن تقادمها، أعمال قواعد التقادم المقررة في شأن الوكالة واعتبار مدة التقادم بالنسبة لتلك الدعوى خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ وفاء الكفيل المتضامن إذ هذا التاريخ فقط ينشأ حقه في الرجوع على المتعهدين المتضامنين معه ويصبح هذا الحق مستحق الأداء. نقض مدنى ١٠/٢/١٩٦٦ طعن رقم ٣٩٢ س ٣١ ق.

المتضامنون متساوين في المسؤولية، فإن الكفيل الموفى لا يكون له الرجوع بدعوى الحلول إلا بحصة كل كفيل فقط ونصيبه في حصة المعسر. وقد نص المشرع في باب التضامن على أنه «إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقيين - إلا بقدر حصته في الدين ولو كان بماله من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن» م ١/٢٩٧ مدنى. كما تقرر المادة ٧٩٦ في باب الكفالة أنه «إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقيين بحصته في الدين ونصيبه في حصة المعسر منهم».

٢- أما إذا كان سبب التزام الكفيل بالدين كله هو أن الكفلاء قد التزموا بقيوم متوالية، فإنه إذا قام أحدهم بالوفاء بالدين كله، كان له الرجوع على غيره من الكفلاء، على أساس الإثراء أو على أساس الحلول محل الدائن. وهو يرجع على كل منهم بقدر نصيبه في الدين ونصيبه في حصة المعسر، كما هو الشأن في حالة التضامن.

الباب الثالث انقضاء الكفالة

تمهيد:

الكفالة عقد تابع يقوم لضمان الوفاء بالتزام أصلى، مع ما يترتب على علاقة التبعية من آثار، سواء بالنسبة لانعقاد الكفالة أم للآثار المترتبة عليها. وهذا الأمر يبدو كذلك فى انقضاء الكفالة، إذ يترتب على انقضاء الالتزام الأصلى انقضاء الكفالة بالتبعية.

ولكن لما كانت الكفالة عقداً ينظر إليه فى ذاته بصفة مستقلة عن الالتزام الأصلى، فإنه ينظر إلى انقضائه بصفة مستقلة.

الفصل الأول

انقضاء الكفالة بصفة تبعية

متى انقضى الالتزام الأصلى، انقضت الكفالة بالتبعية، لأنها تستند إلى الالتزام الأصلى، وبانقضائه لا يكون لها محل. وقد نصت المادة ١/٧٨٢ مدنى على أنه «يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين....» والالتزام الأصلى ينقضى بأسباب الانقضاء العامة الواردة فى القانون وهى الوفاء، كما ينقضى بما يعادل الوفاء عن طريق الوفاء بمقابل، التجديد، والمقاصة، واتحاد الذمة، وينقضى الالتزام كذلك بغير الوفاء به عن طريق الإبراء، وإستحالة التنفيذ والتقدم المسقط. ونعرض لكل من ذلك:

أولاً: الوفاء

إذا قام المدين بالوفاء كلاً أو بعضاً انقضى التزام الكفيل كذلك كله، وبعضه بحسب الأحوال^(١). ولكى يبرأ الكفيل على هذا النحو يتعين أن يكون الوفاء صحيحاً، بأن يكون الموفى مالكاً للشيء الذى وفى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف. فإذا كان الوفاء باطلاً لا يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلى وبالتالي انقضاء الكفالة.

ويقوم العرض الحقيقى بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع أو أى إجراء مماثل متى قبله الدائن أو حكم نهائياً بصحة العرض (م ٣٣٩ مدنى). فإذا استوفى العرض الحقيقى الأوضاع ترتب عليه براءة ذمة المدين، ويبرأ الكفيل

(١) قضت محكمة النقض «ورثة الضامن يستفيدون من الاستئناف الوقوع من ورقة المدين عن الحكم الابتدائى فمتى ثبت فى استئنافهم أن الدين المطالب به وفى من مال المدين أمتنع الرجوع على ورثة الضامن» نقض مدنى ١٩٥١/٤/٥ طعن رقم ٥٧ س ١٩ ق.

بالتبعية، بشرط ألا يحصل رجوع قبل قبول الدائن أو قبل الحكم النهائي بصحة العرض. فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن هذا الرجوع، لا يكون لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات.

ثانياً: انقضاء الالتزام الأصلي بما يعادل الوفاء:

١- **الوفاء بمقابل:** قد يقبل الدائن شيئاً غير المتعهدين، فينقضى الالتزام الأصلي، وتنقضى الكفالة بالتبعية (م ٣٥٠ مدنى). والواقع أنه يترتب على قبول الدائن شيئاً في مقابل الدين تجديد الالتزام بتغيير محله، مما يترتب عليه انقضاء الالتزام القديم بتأميناته ومنها الكفالة، ويحل محله دين جديد هو ما تم الوفاء به (١). وإذا ما استحق الشئ الموفى به كان للدائن أن يرجع على الموفى طبقاً لأحكام الاستحقاق في البيع، ولا يرجع على الكفيل الذى تبرأ ذمته بانقضاء الدين الأصلي وقد طبق المشرع هذا الحكم عند كلامه عن عقد الكفالة إذ نصت المادة ٧٨٣ مدنى على أنه «إذا قبل الدائن أن يستوفى في مقابل الدين شيئاً آخر، حتى ولو استحق هذا الشئ، ولا يكون للدائن الرجوع طبقاً لأحكام لاستحقاق في البيع».

ولكن إذا لجأ الدائن إلى طلب الحكم بفسخ الوفاء بمقابل ذاته، وقضى له به، عاد التزام الكفيل من جديد، لأن النص يتكلم عن براءة ذمة الكفيل لو استحق الوفاء وهذا لا يمنع من عودة التزامه بطلب الدائن الحكم بالفسخ.

2024/2025

٢- **للتجديد والإنابة:** يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه، ونشوء التزام جديد مكانه. ولا تنتقل التأمينات إلى الالتزام الجديد ما لم ينص القانون أو يتبين من اتفاق المتعاقدين أو من الظروف انصراف النية إلى ذلك (م ٣٥٦ مدنى).

ومع ذلك فإن الكفالة - عينية كانت أو شخصية - لا تنتقل إلى الالتزام الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك. فلا يكفى إذن لانتقال الكفالة أن يتفق الدائن والمدين على انتقالها إلى الالتزام الجديد، بل لابد من رضا الكفيل بضمان هذا الالتزام الجديد.

أما بالنسبة للإنابة، فالأصل أنها لا تضمن تجديداً للالتزام المناسب به، إلا إذا اتفق المتعاقدون على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاماً جديداً، وفي هذه الحالة تبرأ ذمة المنيب (المدين) قبل المناب لديه (الدائن) ويحل المناب محل المدين.

(١) د/ توفيق فرج: التأمينات، ص ٨٥.



ويترتب على براءة ذمة المدين الأصلي، براءة ذمة الكفيل ما لم يرضى هذا الأخير أن يكفل المدين الجديد (المناب).

فإذا لم يتفق على هذا الاستبدال قام التزام المناب إلى جانب التزام المنيب، وصار للدائن مدينان، ولما كان التزام المنيب وهو المدين الأصلي قائماً، فإن الكفيل لا يبرأ.

٣- **المقاصة:** إذا ما انقضى الالتزام الأصلي بالمقاصة، ترتب على ذلك القضاء الكفالة بالتبعية. وللکفيل باعتباره صاحب مصلحة، أن يتمسك بالمقاصة سواء كان متضامناً أم غير متضامن، وله أن يتمسك بها حتى ولو لم يتمسك بها المدين، بل وحتى لو تنازل عنها، إذ القانون يخول للكفيل التمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين منها المقاصة.

٤- **اتحاد الذمة:** إذ أنقض الدين باتحاد الذمة، ترتب على ذلك انقضاء التزام الكفيل بالتبعية. فاتحاد الذمة يبرئ الكفيل في الدين. ولكن لما كان اتحاد الذمة ليس في حقيقته سبباً من أسباب انقضاء الالتزام وإنما هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة بالدين، ترتب على ذلك أنه إذا زال اتحاد الذمة لأي سبب من الأسباب، عاد الدين مضموناً بتأميناته ومنها الكفالة.

ثالثاً: انقضاء الالتزام الأصلي دون وفاء:

١- الإبراء إذا أنقض الالتزام الأصلي بالإبراء ليستلزم فيه التبرع، فإن الإبراء 2024/2025 2024/2025 2024/2025
الحاصل نتيجة الصلح مع المفلّس لا يعد إسراء حقيقياً، إذ يرمى الدائن من وراء هذا الصلح إلى ترك بعض دينه خشية أن يؤدي استمرار إجراءات الإفلاس إلى زيادة مركز المدين سوءاً، وبذلك يضعف احتمال حصول الدائن على حقه. ويظل الكفيل في هذه الحالة ملتزماً بكل الدين المكفول حتى بالنسبة للجزء الذي تصالح الدائن على تركه للمفلّس.

٢- **استحالة التنفيذ:** ينقضى الالتزام الأصلي إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه أن استحالة التنفيذ كانت راجعة إلى سبب يسأل عنه المدين، فلا ينقضى الالتزام، وإنما يتحول إلى التزام بالتعويض، وتظل الكفالة قائمة لضمان الوفاء به.

٣- **التقادم المسقط:** إذا ما انقضى الالتزام الأصلي بالتقادم، أنقضى التزام الكفيل بالتبعية. وهذا الالتزام الأخير ينقضى في هذه الحالة، حتى ولو لم تكن المدة



اللازمة لانقضائه بصفة مستقلة قد أنقضت^(١) وللكفيل أن يتمسك بالتقادم ولو لم يتمسك به المدين، بل ولو تنازل عنه.

الفصل الثاني

انقضاء الكفالة بصفة أصلية

إذا كان التزام الكفيل التزاماً تابعاً، وينقضى تبعاً لذلك بانقضاء الالتزام الأصلي، إلا أن له مع ذلك كياناً مستقلاً. ولهذا فإنه ينقضى كذلك بصفة مستقلة. وفي هذا الصدد ينقضى التزام الكفيل بالأسباب العامة التي تنقضى بها الالتزامات عموماً، كما ينقضى بأسباب خاصة ينص عليها القانون.

أولاً: انقضاء التزام الكفيل بالأسباب العامة للانقضاء

أما بالنسبة للأسباب العامة فإن التزام الكفيل ينقضى بوفاء الكفيل، سواء بالشئ نفسه أو بمقابل. كما ينقضى التزام الكفيل كذلك بالتجديد بأن يتفق على أن يستبدل بالكفالة التزام أصلي، فيصبح الكفيل مديناً أصلياً بدلاً من كونه كفياً. أو على تقديم رهن بدلاً من الكفالة.

وينقضى كذلك بالمقاصة متى صار الكفيل دائناً للدائن. وباتحاد الذمة ويمضى المدة. على أن يراعى بالنسبة لهذا السبب الأخير أن التقادم المقصود هنا ينظر فيه إلى التزام الكفيل بصفة مستقلة عن الالتزام الأصلي، وأن وقف التقادم أو انقطاعه بالنسبة للمدين لا يؤثر في التقادم الخاص بالتزام الكفيل حتى ولو كان متضامناً مع المدين. مما قد يقال معه أن التزام الأخير ينقضى قبل التزام الكفيل، إذ في مثل هذه الحالة ينقضى التزام الكفيل أيضاً لا بصفة مستقلة، بل لصفة تبعية^(٢).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) قضت محكمة النقض «أن الموفى حين يرجع على المدين بدعوى الحلول إنما يرجع بنفس الحق الذي انتقل إليه من الدائن، فإذا كان هذا الحق هو رسم المستحق لصندوق دعم صناعة الغزل والنسيج القطنية، فإنه يتقادم بخمس سنوات عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ الذي عدل بالمادة ٣٧٧ مدني، نقض مدني ١٩٦٨/٢/٢٩، طعن رقم ٢٦٩ س ٣٤ق.

(٢) فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزام الطاعن بالدين أسس قضاءه على أن الدين المطالب به حق وفاؤه في ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٤٣ وأن الدعوى رفعت على الضامن المتضامن في ١٠ أكتوبر سنة ١٩٤٤ أي قبل سقوط حق المطعون عليها الأولى في المطالبة به وعلى أن رفع الدعوى على الضامن المتضامن يقطع مدة التقادم بالنسبة له وللمدينين على السواء لأن مطالبته بالدين تعتبر مطالبة لهم يترتب عليها أثرها، فتنتقطع المدة بالنسبة إليهم جميعاً عملاً بالمادة ١١٠ مدني قديم، فإن ما قرره هذا الحكم بكون خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه في هذا الخصوص، نص مدني ١٩٥٢/٢/٢٤ طعن رقم ١٤٣ س ٤٠ ق.

انقضاء التزام الكفيل بأسباب خاصة:

أما عن الأسباب الخاصة لانقضاء التزام الكفيل فإنها ترجع إلى طبيعة هذا الالتزام. ذلك أن الكفيل إذا كان يلتزم بالوفاء عن المدين، فإنه يكون له الحق إذا ما وفى، أن يرجع على المدين. ولهذا يجب ألا يصدر من الدائن عمل يهدد احتمال رجوع الكفيل على المدين^(١).

فإذا صدر من الدائن مثل هذا العمل كان مخطئاً وترتب على ذلك براءة ذمة الكفيل بقدر ما ناله من ضرر من جراء موقف الدائن. ويكون ذلك فى حالة ما إذا أضرع الدائن بخطئه التأمينات^(٢)، وحالة عدم اتخاذ الإجراءات ضد المدين بعد إنذار الكفيل له بوجوب اتخاذها، وحالة عدم التقدم فى تفليسة المدين.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) نصت محكمة النقض «لا وجه لما يقوله الطاعن الثالث من أن كفالته قد انقضت لتأخر الدائن فى اتخاذ الإجراءات ضد المدين ذلك أن قوام هذا النفي التمسك بتطبيق المادة ٧٨٥ مدنى وهو دفاع قانونى يخالطه دافع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها، من ثم فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض».

نقض ١٩٧٥/٣/١٧ طعن ١٨٩ س ٤٠ ق.

(٢) نقض مدنى ١٩٦٩/٦/٢٤ طعن رقم ٧٨ س ٣٥ ق.

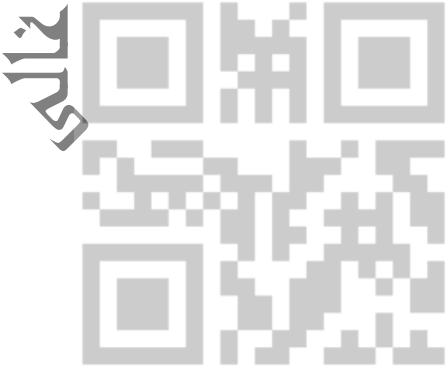


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025





القسم الثاني
التأمينات الحينية

2024/2025

2024/2025

2024/2025

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن خالي



عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالدي

الباب الثالث: الرهن الحيازي.

(٢) الأعمال التحضيرية للقانون المدني ج ٧ ص ٣.

(٢) الأعمال التحضيرية للقانون المدني ج ٧ ص ٣.



الباب الأول الرهن الرسمي

تقسيم:

نتولى الكلام عن الرهن الرسمي طبقاً للترتيب الذى عالج به القانون المدنى. فنتكلم أولاً عن إنشائه، ثم عن آثاره، ثم عن انقضائه. وسنعرض لهذا فى فصول ثلاثة. وذلك بعد أن نتكلم فى فصل تمهيدى عن التعريف به وخصائصه.

فصل تمهيدى تعريف الرهن وبيان خصائصه

التعريف بعقد الرهن الرسمي^(١).

عرفت المادة ١٠٣٠ الرهن الرسمي بقولها «الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أية يد يكون».

وبلاحظ أن هذا النص عرف الرهن بأنه عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً. ومعنى هذا أن المادة حينما عرفت الرهن الرسمي بأنه عقد فهي عرفت بالأداة العينية لإنشاء الرهن. كما يعرف الرهن بالأداة العينية ~~لأنه يطلق أيضاً على الحق العيني~~ الذى ينشأ بواسطة العقد. بل أن كلمة الرهن قد تطلق أحياناً على الشئ الذى يرد عليه حق الدائن المرتهن. وفى جميع الحالات يتحدد المعنى بسياق العبارة التى ورد فيها لفظ الرهن^(٢).

والعقد الرسمي للرهن ينشئ للدائن حقاً عينياً تبعياً على عقار مخصص لوفاء دينه. فمحل الرهن الرسمي هو عادة عقار. أما جوهر الرهن الرسمي هو حق الدائن المرتهن فى الأفضلية فى استيفاء دينه من قيمة العقار المرهون. والدائن المرتهن يباشر حقه فى الأفضلية حتى ولو انتقلت ملكية العقار إلى شخص آخر، ويعتبر التنفيذ فى مواجهة المتصرف إليه فى هذه الحالة تتبعاً للعقار المرهون وهذا هو حق الدائن فى التتبع.

(١) إصلاح الرهن الرسمي الذى أختاره القانون المدنى المصرى أفضل المصطلحات للتعبير عن أبرز خصائص الرهن. ذلك أن تسمية بالرهن العقارى لا تختص به حده، إذ يمكن أن يكون هذه التسمية للرهن الحيازى لإمكان وروده على عقار، والحال كذلك لتسميته بالرهن التأمينى، نجد أنه لا يستقل بهذا الوصف، إذ أن كل رهن يمكن أن يسمى بالرهن التأمينى لأنه تأمين للوفاء بدين أنظر فى ذلك د/ بعد الفتاح عبد الباقي: التأمينات، ط٢، ص ٢٨٣ هامش ١.

(٢) د/ أحمد سلامة: التأمينات، ص ١٠٠.

أما الطريق العادى لاستيفاء الدائن حقه أن يستوفيه من ثمن العقار، أو من أية مبالغ نقدية تحل محل العقار^(١) كالتعويض أو مبلغ التأمين أو مقابل نزع ملكية العقار للمنفعة العامة^(٢).

وعلى ضوء ما تقدم نستطيع أن نعرف الرهن الرسمى بأنه «حق عيني تبعى يتقرر على عقار بمقتضى عقد رسمى بين الدائن والراهن لضمان الوفاء بحق الدائن مع بقاء الحياة للراهن، وبمقتضاه يكون للدائن أن يستوفى حقه بالأفضلية من القيمة المالية لهذا العقار فى أية يد يكون.

من هذا التعريف تتضح لنا أهم خصائص الرهن الرسمى.

خصائص الرهن الرسمى.

يتميز الرهن الرسمى بعدة خصائص نوجزها فى الآتى:

١- **الرهن الرسمى حق عيني:** وقد أورده القانون المدنى ضمن الحقوق العينية التبعية كما نصت المادة ١٠٣٠ صراحة على أنه حق عيني وهو بمقتضى هذه العينية يخول صاحبه حق التتبع الأفضلية، أى تخول له سلطات معينة بالنسبة لما يرد عليه. هذه السلطات تتمثل فى إمكان تتبع العين واستيفاء الدين المضمون بالأفضلية. ومن المعلوم أن التتبع والتقدم من خصائص الحقوق العينية، كما أن الرهن الرسمى إذا ما قام صحيحاً وتم شهره صار حجه على الكافة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢- **الرهن الرسمى حق تبعى:** حق الرهن الرسمى حق عيني تبعى، ومعنى ذلك أنه يقدم تبعاً لالتزام أصلى، ضماناً للوفاء به. والأصل أنه لا يتصور قيام الرهن دون الحق المتصل به والذى يقوم الرهن لضمان الوفاء بتنفيذه. وتترتب على فكرة التبعية فى الرهن أنه لكى يقوم الرهن يجب أن يكون الالتزام المضمون صحيحاً، فإذا كان معيباً أمتد العيب إلى الرهن كذلك، كما إذا كان الالتزام الأصلى باطلاً فإن الرهن يبطل كذلك، ولا يقتصر معنى التبعية على نشوء الرهن فقط، بل أن الارتباط بين الرهن والدين المضمون يمتد إلى ما وراء ذلك، فإذا انقضى الحق الشخصى نتيجة الحكم بالبطلان أو البطلان، أو بسبب الوفاء أو ما يعادله، أو حتى بدونه، انقضى الرهن أيضاً. وكذلك إذا انتقل الحق المضمون انتقل معه الرهن كقاعدة عامة.

(١) نصت المادة ١٠٥٦ على أن الدائنين المرتهنيين يستوفون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذى حل محل هذا العقار.

(٢) د/ منصور مصطفى منصور: التأمينات، ص ١٧.

على أن هناك استثناءين على هذه التبعة المطلقة في التشريع المصري الأول خاص بقاعدة عدم تجزئة الرهن، والثاني إمكان نشوء الرهن، قبل نشوء الدين، إذ يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين يستقبل أو دين احتمالي (مادة ١٠٤٠ مدني)، وواضح أن هذه الديون ديون غير موجودة، بل ربما توجد فيما بعد. وقد راعى المشرع في هذا الاستثناء الخضوع للضرورات العملية، والتيسير على المدين في الحصول على الائتمان الذي يحتاج إليه.

٣- **الرهن الرسمي حق عقارى:** وقد أفصحت عن هذا المعنى الفقرة الأولى من المادة ١٠٣٥ من القانون المدني حيث جاء نصها «لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك».

ويترتب على ذلك أنه لكي يمكن إنشاء الرهن ينبغي أن تتوفر الأهلية اللازمة للتصرف في العقار، كما أنه لكي يمكن التصرف في الرهن يجب أن تتوفر في المنصرف الأهلية اللازمة للتصرف في العقارات. كما يترتب على كون الرهن الرسمي حقاً عقارياً أنه لا يرد إلا على العقارات التي يجوز التصرف فيها، لذلك لا يرد الرهن على عقار موقوف أو على عقار مشروط عدم التصرف فيه، أو على عقار يدخل في إطار الأموال العامة للدولة، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون محلاً للتأمين العيني إلا ما يجوز التصرف فيه وبيعه بالمزاد العلني.

٤- **الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة:** وقد نصت على هذه الخاصة المادة ١٠٤١ من القانون المدني ~~حيث جاء نصها~~ ^{2024/2025} «كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامنة لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، ما لم ينص القانون أو يقضى بالاتفاق بغير ذلك».

وعدم القابلية للتجزئة ترد في جانبين، الأول هو جانب العقار أو العقارات المرهونة والجانب الثاني هو جانب الدين ذاته، فالرهن الرسمي في كلا الجانبين غير قابل للتجزئة. وهذا لا شك في مصلحة الدائن، إذ فيه تقوية للضمان. فبالنسبة للعقار أو العقارات المرهونة، فإنه إذا كان المرهون عقاراً واحداً وقسم هذا العقار، كان كل جزء منه ضماناً للدين كله، وللدائن أن يتبعه في يد المشتري للتنفيذ عليه بكامل حقه. كما يكون للدائن كذلك أن ينفذ على الجزء الباقي من العقار في يد المدين بكامل حقه كذلك. فتجزئة العين المرهونة لا تلزم الدائن بتوزيع مطالبته بحقه تبعاً لانقسام العقار، وإلا كان في هذا إضعافاً لحقه في الضمان. أما إذا كان المرهون ضماناً للدين ذاته عدة عقارات، فإنه يكون للدائن أن يتتبع أيّاً من تلك العقارات لاستيفاء حقه بكامله حسباً يترأى له، وأن كان يراعى في هذا الصدد عدم التعسف في استعمال حقه.

أما بالنسبة لمعنى عدم التجزئة بالنسبة للدين المضمون فإن مفادها أن كل العقار أو العقارات المرهونة تبقى خاضعة للرهن وفاء لكل جزء من الدين مهما قل. فإذا ما أوفى المدين بجزء من الدين أو بمعظم أجزائه فإن ذلك لا يؤدي إلى تخليص أى عقار أو جزء من عقار من عبء الرهن الرسمى، بل يظل الرهن قائماً على كل العقارات إلى أن يتم الوفاء بكل الدين. أى أن الوفاء بجزء من الدين أياً ما كان لا يترتب عليه تخليص جزء مقابل من العقارات المرهونة. وتطبق القاعدة ذاتها إذا كانت تجزئة الدين لا بسبب الوفاء المسقط بل بسبب انتقاله إلى عدة ورثة، كل حسب نصيبه، ففي هذه الحالة من حق كل وارث أن يتمسك بالرهن على كل العقارات وفاء لنصيبه فى الدين.

على أن قاعدة عدم التجزئة ليست من مستلزمات الرهن أو من جوهره. فهي قاعدة مقررة لصالح الدائن المرتهن، وهي ليست من النظام العام. فمن المتصور أن ينقضى الرهن تدريجياً ويحرر العقار أو العقارات المحملة به كلما تم الوفاء بجزء من الدين بما يقابل ما تم الوفاء به. وقد يكون ذلك بتنازل من الدائن نفسه، وقد يكون بحكم القانون.

وتتنازل الدائن عن قاعدة عدم التجزئة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمناً، التنازل الصريح يتفق عليه وقت إنشاء الرهن، أما التنازل الضمنى فإنه قد يبدو من سلوك الدائن بما يدل على قبوله تجزئة الرهن وقد ينص القانون على التجزئة كما هو الحال فى تجويز التطهير بالنسبة لمن آل إليه جزء من العقار المرهون (الحائز).

2024/2025 2024/2025 2024/2025

الفصل الأول

إنشاء الرهن الرسمي

ينشأ حق الرهن الرسمي بمقتضى عقد الرهن. ويتطلب القانون لانعقاد هذا العقد، بالإضافة إلى الشروط الموضوعية لانعقاده وصحته، شرطاً شكلياً هو الرسمية. وسنعرض أولاً للشروط الموضوعية لصحة انعقاد الرهن، ثم للرسمية.

المبحث الأول

الشروط الموضوعية

تقسيم:

يلزم لقيام الرهن الرسمي، فضلاً عن شرط الرسمية، أن يقوم الرضا صحيحاً وأن يصدر عن ذى أهلية لإنشاء الرهن، كما يلزم أن يستند الراهن إلى محل يتوافر فيه الشروط التى يتطلبها القانون، وإلى سبب صحيح. وسنعرض فيما يلى للشروط الموضوعية للرهن، مكثفين بما يتطلبه القانون فى شأنه لصفة خاصة، ومتلافين الكلام عن الأحكام التى تقررها القواعد العامة بالنسبة للرضا والحل والسبب.

المطلب الأول

الرضا

2024/2025 يتحقق الرضا بمجرد أن يتبادر طرفاً العقد - مع مراعاة الرسمية - التعبير 2024/2025 عن إرادتين متطابقتين. وطرفا عقد الرهن الرسمي هما الدائن المرتهن والراهن والغالب عملاً أن يكون الراهن هو المدين بالالتزام الذى يراد ضمانه بإنشاء الرهن، ولكن قد يكون الراهن شخصاً آخر غير المدين ويسمى عندئذ «الكفيل العينى» وقد نصت المادة ١/١٠٣٢ على أنه: «يجوز أن يكون الراهن هو نفسه المدين، كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً لمصلحة المدين».

وتطبيقاً للقواعد العامة يجب لانعقاد العقد وجود أردتين حديثتين تتجهان إلى إنشاء حق الرهن وأن تتطابق الإرادتان. ويجب لانعقاد العقد صحيحاً غير قابل للإبطال أن تكون الإرادة خاليتين من العيوب، وأن يكون كل من طرفى العقد أعلاً لمباشرة عقد الرهن الرسمي. وليس هناك خروج عن القواعد العامة سوى أن المشرع قد حرص على إيراد أحكام خاصة بالأهلية فى شأن الرهن. ولهذا نقف لدى الأهلية لنبين ما يقرره القانون بشأنها عند الكلام عن الرهن.

الأهلية:

الرهن الرسمي فيما يتعلق بالأهلية يفرق فيه بين أهلية الدائن المرتهن وأهلية الراهن. فلم يعرض المشرع لأهلية الدائن المرتهن ومن ثم وجب أن تطبق بشأنها القواعد العامة، فيعتبر الرهن وفقاً للرأى الغالب فى الفقه (١) من التصرفات النافعة نفعاً محضاً لأنه لا يلزمه بشئ، ولهذا يعتبر العقد صحيحاً غير قابل للإبطال إذا عقدت الصبى المميز أو من فى حكمه أى المحجور عليه للسفه أو الغفلة. وفى رأى آخر (٢) أن الرهن الرسمي - كالرهن الحيازى - يعتبر حتى بالنسبة للدائن المرتهن من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وذلك على أساس أن «الارتهان استيفاء للدين من وجه، ولا يستوفى الدين إلا من توافرت فيه أهلية المعارضة» ويترتب على ذلك أنه يجب أن تتوفر فى المرتهن، وفقاً لهذا الرأى، الأهلية بالنسبة إلى التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فيكون العقد قابلاً للإبطال إذا كان صيباً مميزاً أو من فى حكمه.

هذا بالنسبة للدائن المرتهن، أما بالنسبة للراهن فقد عرض المشرع لأهليته فنص فى المادة ١/١٠٣٢ على أنه «يجب أن يكون أهلاً للتصرف فى العقار المرهون. فالرهن الرسمي يعتبر، بالنسبة للراهن، من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة، لأنه وإن كان لا يخرج العقار المرهون من ذمة الراهن، إلا أنه يثقل هذا العقار بما ينقض من صلاحيته باعتباره عنصر من عناصر الانتماء من قدرة الراهن على الافتراض، وبالتالي يعتبر تصرفاً جزئياً فى العقار.

2024/2025

ويترتب على ذلك أنه لا يكفى لصحة الرهن أن يكون للراهن أهلية إدارة العقار المرهون، فلا يصح الرهن الصادر من الصبى الذى بلغ الثامنة عشر وأذن له فى إدارة أمواله ومنها العقار (٣). فارهن إذن يعتبر بالنسبة للراهن من أعمال التصرف. ولكن هل يعتبر من التصرفات الضارة محضاً أم من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. يفرق فى هذا فرضين:

الفرض الأول: أن يكون الراهن هو المدين، وهنا يعتبر الرهن من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، لأن الراهن برهن العقار إما وفاء للالتزام عليه بإعطاء الرهن، وإما ليحصل على قرض أو على مد أجل الالتزام الذى يضمنه الرهن. وفى

(١) د/ منصور مصطفى منصور: التأمينات، ص ١٩، د/ جمال الدين زكى: التأمينات، ص ١٦٩، د/ توفيق فرج: ص ١٠٥، د/ أحمد سلامة: ص ١١٤.

(٢) د/ شفيق شحاتة النظرية العامة للتأمين العينية طبعة ١٩٥٢ ص ٣٥، د/ لبيب شنب: التأمينات العينية والشخصية طبعة ١٩٧٣ ص ٤٣، سمير تناغو: التأمينات العينية طبعة ١٩٦٧، ص ٦٣، د/ السنهورى الوسيط، ج ١٠، ص ٢٩١.

(٣) د/ منصور مصطفى منصور: ص ٢٠.

هذا الفرض يعتبر الرهن الصادر من الصبي المميز أو من في حكمه قابلاً للإبطال وليس باطلاً.

الفرض الثاني: أن يكون الرهن مقدماً من غير المدين، وهنا يعتبر - بحسب الأصل - من التصرفات الضارة ضرراً محضاً لأن الراهن - وهو كفيل - يعتبر بحسب الأصل متبرعاً. وعلى ذلك يكون رهن الصبي المميز ومن في حكمه باطلاً بطلاناً مطلقاً، إلا إذا تبين أنه قدم الرهن بمقابل فيكون الرهن عندئذ من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وبالتالي قابلاً للإبطال وليس باطلاً.

وفي جميع الحالات، سواء بالنسبة للدائن المرتهن أو بالنسبة للراهن، إذ كان يصح لأى منها أن يعقد الرهن بنفسه، فإنه يصح أن يعقده من ينوب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية. مع ضرورة إتباع الإجراءات اللازمة لذلك في حالة النيابة القانونية بحيث تتوفر لدى النائب السلطة اللازمة لذلك. هذا فضلاً عن أنه ينبغي أن يراعى أن الوكالة الصادرة من الراهن في عقد الرهن، يجب أن تكون وكالة خاصة، وأنها يجب أن تتم في الشكل الرسمي.

المطلب الثانى

محل الرهن (الشئ المرهون)

تمهيد:

يشترط في محل الرهن أن يكون من الأموال التى يجوز رهنها رسمياً، بأن يكون عقاراً يصح التعامل فيه وبيعها بالمزاد العلنى، وأن يكون معيناً تعيناً دقيقاً وموجوداً. كما يشترط لصحة الرهن أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن. وسنعالج أولاً: الأموال التى يجوز رهنها رسمياً، ثم نتكلم بعد ذلك عن ملكية الراهن للشئ المرهون.

الفرع الأول

الأموال التى يجوز رهنها رهنأ رسمياً

النص القانونى

نصت المادة ١٠٣٥ مدنى على أنه:

١- لا يجوز أن يرد الرهن الرسمى إلا على عقار، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

٢- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى، وأن يكون معيناً بالذات تعيناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعيين أما فى عقد الرهن ذاته، أو فى عقد رسمى لا حق، وإلا وقع الرهن باطلاً.

من هذا النص يتبين أن الرهن الرسمي لا يرد في الأصل إلا على عقار، وينبغي أن يكون هذا العقار مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، كما يجب أن يكون معيناً تعييناً دقيقاً ويتصل بهذا الشرط الأخير شرط آخر هو أن يكون العقار موجوداً، فلا يصح رهن الأموال المستقبلية.

وسنعرض للشروط الواجب توافرها بالنسبة لما يجوز رهنه، ثم نعقب ذلك بتحديد مشتملات الرهن.

أولاً: شروط الأموال التي يجوز رهنها:

هناك شروط خمسة يتعين توافرها في الأموال التي يجوز رهنها

الشرط الأول: يجب أن يكون المرهون عقاراً.

تنص المادة ١/١٠٣٥ على أنه «لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك». والحكمة من قصر الرهن الرسمي، بحسب الأصل، على العقارات وحدها هي التوفيق بين القاعدة المقررة وهي أن الرهن الرسمي لا يترتب عليه نقل حيازة الشيء المرهون إلى المرتهن بل تبقى الحيازة للراهن، وبين ما يجب تحقيقه من شهر للرهن حماية لصالح الغير، فنظراً إلى أن الراهن يستبقى حيازة الشيء المرهون فلا يتيسر الشهر إلا بالقيد في سجلات تعد لذلك على أن يتضمن القيد البيانات التي تمكن الغير من التعرف على الشيء المرهون، وهو ما لا يتيسر بالنسبة للمنقولات التي لا تستقر في مكان معين.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وإذا كان الرهن الرسمي لا يرد بحسب الأصل على المنقولات إلا أنه يجوز استثناء وبمنص من القانون رهن بعض المنقولات رهنًا رسمياً، من ذلك ما نصل عليه القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٦ من جواز رهن الطائرات رهنًا رسمياً، وما نص عليه القانون ٣٥ لسنة ١٩٥١ من جواز رهن السفن البحرية رهنًا رسمياً، وما قضى عليه القانون ١١ لسنة ١٩٤٠ من جواز رهن المحل التجاري رهنًا رسمياً. والحكمة من هذا الاستثناء أن هذا المنقولات لها نظام لشهرها كما أنها لا تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز. الأمر الذي يمكن معه المحافظة على حقوق الدائن المرتهن والغير عليها، ويقع باطلاً كل رهن رسمي ورد على منقول في الأحوال غير المنصوص عليها قانوناً.

ويترتب على عدم جواز رهن المنقولات رهنًا رسمياً، عدم جواز رهن العقار بالتخصيص مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته واستقلاله، لأن العقار بالتخصيص يستمد صفته العقارية من إلحاقه بالعقار بطبيعته. فإذا ورد التصرف عليه مستقلاً عادت إليه صفة المنقول.



الشرط الثاني: يجب أن يكون العقار مما يجوز بيعه بالمزاد العلنى.

وهذا الشرط تقتضيه الحكمة من الرهن. لأنه إذا لم يكن من الممكن بيعه بالمزاد العلنى، فإنه لا يمكن تحقيق الغرض من الرهن من حيث إمكان استيفاء الدائن لحقه من ثمن العقار بعد بيعه. إذ أن العقار المرهون يضمن الوفاء بالدين الأصلي إذا لم يقدّم به المدين. ولكي يتحقق ذلك، يجب أن يكون مما يمكن بيعه حتى يستوفى الدائن حقه.

وتطبيقاً لذلك لا يجوز رهن حق الاستعمال وحق السكنى الوارد بين على عقار، لأن هذين الحقين من الحقوق الملاصقة للشخصية والأصل أنه لا يجوز النزول عنها إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى (م ٩٩٧ مدنى).

ولا يجوز على الرأى السائد فى الفقه^(١) رهن الحقوق العينية التبعية الواردة على العقار مستقلة عن الالتزام الذى تقوم ضماناً للوفاء به، إذ لا يمكن وجودها إلا مستنده إليه، كما لا يمكن بيعها مستقلة عنه. ولهذا لا يصح رهن الرهن الرسمى، ولا رهن حق الاختصاص، أو الرهن الحيازى أو حقوق الامتياز.

الشرط الثالث: يجب أن يكون العقار مما يمكن التعامل فيه.

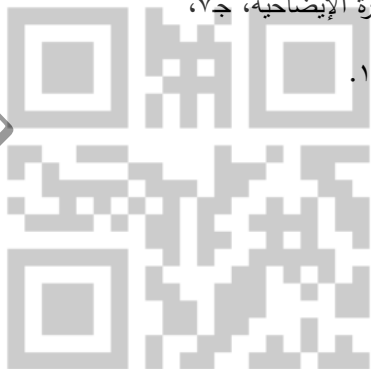
يجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه، وعلى هذا لا يصح رهن الأموال العامة، لأنه لا يجوز التعامل فيها، كما لا يصح رهن الأموال الموقوفة، لأن الوقف بحسب العين الموقوفة عن التداول. ولا يصح - على الرأى^{2024/2025} الغالب فى الفقه - رهن الأموال التى^{2024/2025} اشترط بالنسبة لها المنع من التصرف^(٢) أن يقرر القانون بطلان التصرف فى المال الذى حصل شرط المنع بالنسبة له، متى كان هذا الشرط صحيحاً (م ٨٢٣، ٨٢٤ مدنى). فإذا كان هناك شرط يمنع الراهن من التصرف بصفة عامة فى المال الذى حصل شرط المنع بالنسبة له، متى كان هذا الشر صحيحاً (م ٨٢٣، ٨٢٤ مدنى). فإذا كان شرط يمنع الراهن من التصرف بصفة عامة فى العقار أو يمنعه من الرهن، فإن الرهن الذى يرتبه على العقار يقع باطلاً.

ومع ذلك فإن جانباً من الفقه^(٣) يرى أنه لا يؤخذ بهذا الحكم الأخير على إطلاقه بل ينظر إلى الحكمة من تقرير شرط المنع من التصرف، فإذا لم يتعارض

(١) د/ شفيق شحاتة: التأمينات: ص ٢١، د/ منصور مصطفى منصور: التأمينات، ص ٢٣، د/ أحمد سلامة: التأمينات، ص ١٣١، د/ توفيق فرج: التأمينات، ص ١٠٩.

(٢) د/ شفيق شحاتة: ص ٢٨، د/ سليمان مرقس: التأمينات، ص ٣٦، المذكرة الإيضاحية، ج ٧، ص ٢٢.

(٣) د/ منصور مصطفى منصور: التأمينات، ص ٢٤، د/ توفيق فرج: ص ١٠٩.



الرهن معه كان صحيحاً. فقد يشترط البائع مثلاً عدم التصرف في العقار الذي لم يستوف ثمنه لكي يتفادى تتبعه - بماله من امتياز البائع - في يد الغير الذي يتصرف إليه المشتري، ولكن تحقيق هذا الغرض الذي قصده البائع لا يقتضى أن يحرم على المشتري رهن العقار، لأن الدائن المرتهن إذا ما اتخذ إجراءات التنفيذ، فإنه يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية بما فيها من امتياز البائع. ويستوفى البائع حقه من الثمن حسب مرتبة امتياز، دون أن يلجأ إلى مباشرة حق التتبع الذي أراد أن يتفاداه باشتراطه على المشتري المنع من التصرف.

الشرط الرابع: أن يكون العقار معيناً تعيناً دقيقاً. مبدأ تخصيص الرهن.

بعد أن أوصت المادة ١٠٣٥ أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، أوجبت كذلك أن يكون معيناً بالذات تعيناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعين أما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً.

ومن الواضح أن المشرع يتشدد في تعيين محل الرهن بحيث يكون محدداً تحديداً دقيقاً منذ البداية خلافاً لما تقضى به القواعد العامة من أن يكفي أن يكون المحل قابلاً للتعيين. ذلك أن الرهن يجب أن يخصص بمحل معين بذاته منذ تقريره كما يجب أن يكون مقصوراً على ضمان دين معين بالذات ومحدد المقدار،
2024/2025 2024/2025

ويهدف المشرع من وراء تخصيص الرهن إلى حماية الراهن حتى يقدم من عقاراته ما يكفي لضمان الدين، ويحتفظ بالباقي من أمواله خالية من الرهن، نستطيع الافتراض عليها بسهولة إذا لزم الأمر. كما يرمى إلى حماية من يتعاملون مع الراهن فيما بعد بتمكينهم من معرفة حقيقة مركز عقاراته، وما يتقل كل منها من ديون وما يمكن أن نتحمله بعد ذلك.

وإذا رجعنا النص المادة ١٠٣٥ نجد المشرع يتطلب تعيين العقار تعيناً دقيقاً من حيث طبيعته فيجب أن يذكر في العقد إن كان أرضاً زراعية أو أرضاً مبنية أو بناء معيناً، ويذكر أن كان البناء منزلاً أو مصنعاً. ومن حيث موقعه فبالنسبة للأرض الزراعية، يجب أن يتعين البلدة وأسم الحوض ونمره القطعة وحدود الأرض. وبالنسبة للمباني يبين اسم البلدة والشارع ورقم المنزل.

وعلى الجملة يجب أن يكون البيان نافياً للجهالة دالاً على ذاتية العقار بحيث يسهل تمييزه عن غيره وهذه مسألة موضوعية متروكة لتقدير القاضي.

نصت المادة ١٠٣٣/٢ على أنه «يقع باطلاً رهن المال المستقبل» فما هو المقصود بمال المستقبل في هذا الصدد ؟ تقضى القواعد العامة بأنه «يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً» (م ١٣١/٢ مدنى). والمقصود من هذا أن محل الالتزام يمكن أن يرد على شئ مستقبل غير موجود أصلاً وقت العقد ولكنه سيوجد فيما بعد كمنزل لم يبدأ بعد فى بنائه، هذا هو معنى أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً وهو ما ينبغى أن يتصرف إليه معنى رهن المال المستقبل^(١)، فالرهن الذى يرد على مال غير موجود فعلاً وقت إبرام العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً. فإذا كان المال موجود فعلاً عند إبرام العقد، ولكنه كان مملوكاً للغير، وقام الراهن برهنه على أساس أنه سيملكه فى المستقبل، سرى عليه حكم رهن ملك الغير، لأرض الأموال المستقبلية وهناك فارق بين الحالتين، إذ رهن المال المستقبل - وهو المال غير الموجود أصلاً وقت العقد - باطل، أما رهن ملك الغير وهو المال الموجود فعلاً فى ملك الغير، فإنه قابل للإبطال م ١٠٣٣/١.

هذا هو معنى رهن المال المستقبل، فما هي علة بطلانه بطلاناً مطلقاً؟
الرأى السائد، وهو الذى ورد بالمذكرة الإيضاحية، أن الرهن يبطل لأنهي تعارض
لنا هذا الشرط بسابقه، فرهن المال المستقبل غير الموجود أصلاً باطل، لأنه غير
معين بالذات، أى أن سبب البطلان هو عدم تعيين محل الرهن.

2024/2025

نظراً لأن العقار المرهون يتعين بإرادة طرفي العقد، فلهما أن يتفقا على ما شمله الرهن من ملحقات هذا العقار وما لا يشملها فإذا اتفق على شيء من هذا وجب أعمال هذا الاتفاق.

فإذا لم يتفقا طبقات القاعدة المكلمة الواردة بالمادة ١٠٣٦ مدنى ونقض بأنه «يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك، ما لم يتفق على غير ذلك، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليها فى المادة ١١٤٨ مدنى).

(١) د/ منصور مصطفى منصور: التأمينات، ص ٢٨، د/ شفيق شحاتة ص ١٠٧، د/ توفيق فرج: ص ١١٠.

من هذا يتضح أن الرهن يشمل - إلا إذا اتفق على خلاف ذلك - ملحقات العقار. يستوى في هذا أن تكون هذه الملحقات موجودة وقت العقد أو ألحقت بالعقار بعد ذلك. كما يستوى أن تكون قد وجدت بفعل الراهن أو بفعل شخص آخر، أو وجدت دون تدخل شخصي ما. ولكن يشترط لشمول الرهن هذه الملحقات أن تكون من العقارات، سواء بطبيعتها أو - بالتخصيص. وذلك طبقاً للقاعدة التي تقضى بأن الرهن لا يرد إلا على العقار. وعلى ذلك لا يشمل الرهن ما يعتبر من ملحقات العقار فتتولا كالسيارات والعربات المخصصة لركوب الراهن، والمواشي والآلات التي يستأجرها الراهن لخدمة العقار واستغلاله.

وإذا كان المشرع قد وضع القاعدة العامة من شمول الرهن للملحقات التي تعتبر عقارات، فقد ذكر أهم هذه الملحقات على سبيل المثال، وهي حقوق الارتفاق، والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود منفعتها على المالك. بالإضافة إلى نص المادة ١٠٣٦ فقد نص المشرع في المادتين ١٠٣٧، ١٠٩٧ على إلحاق الثمار بالعقار لا من وقت الرهن وإنما من تاريخ معين يختلف بحسب ما إذا كان العقار في يد الراهن أم في يد الغير الذي يسمى الحائز. ونعرض لهذه الأمثلة.

١- **حقوق الارتفاق:** يقصد بحقوق الارتفاق التي تعتبر من الملحقات فيشملها الرهن تلك الحقوق المقررة لمصلحة العقار المرهون على عقار آخر، كما لو كان لهذا العقار حق المرور ^{على أرض الجار} ^{2024/2025} ^{2024/2025} ويستوى أن يكون حق الارتفاق قد تقرر قبل الرهن أو بعده.

٢- **العقارات بالتخصيص:** هي المنقولات التي يضعها صاحبها في العقار الذي يملكه رهنًا على خدمة هذا العقار واستغلاله (م ٢/٨٢ مدنى) كآلات المخصصة لرى الأرض، والماكينات الموجودة بالمصنع، إذا توافرت فيها الشروط. هذه العقارات بالتخصص الملحقة بالعقار يشملها رهن هذا العقار، سواء رصدت لخدمته وقت الرهن أو بعد ذلك^(١)، وذلك دون حاجة إلى نص صريح عنها بعقد الرهن، فإذا انتهى رسدها ولم يعترض الدائن المرتهن على ذلك، أو تصرف فيها مالكها لشخص حازها يحسن فيه، انتهى رهنها.

٣- **التحسينات والإنشاءات:** يشمل الرهن التحسينات والإنشاءات أيًا كان نوعها، سواء كانت بفعل الطبيعة أم بفعل الإنسان، كما لو زادت الأرض بفعل الطمي، أو شيد المالك بناء على الأرض المرهونة أو بنى طابقاً جديداً على

(١) د/ السنهورى الوسيط ١٠ ص ٣٥٧، د/ منصور مصطفى: ص ٣١، د/ أحمد سلامة: ص ١٧٩.



المنزل المرهون. هذا بالإضافة إلى أن الدائن المرتهن يستفيد مما يطرأ على قيمة العقار من زيادة نتيجة تغير الظروف كارتفاع الأسعار بصفة عامة، أو إنشاء طريق جديد أو عمل ميدان. وإلى جانب ما سبق فإن الرهن يشمل التحسينات والإنشاءات أيًا كانت قيمتها، حتى ولو كانت قيمتها تزيد عن قيمة العقار المرهون ذاته.

فإذا أقام المالك على الأرض المرهونة بناء كبير تفوق قيمته بكثير قيمة الأرض المرهونة أصلاً، شمله الرهن كذلك.

والرهن يشمل التحسينات والإنشاءات التي تطرأ على العقار المرهون، سواء كانت موجودة عند الرهن. أم وجدت بعده، إنما يلزم لكي يشملها الرهن، أن تعود منفعتها على المالك، وعلى ذلك إذا أذن صاحب الأرض المرهونة للمستأجر مثلاً بإقامة بناء عليها، فإن الرهن لا يشمل هذا البناء الذي أقامه المستأجر طالما ظل مملوكاً لهذا الأخير، فإذا زالت ملكية المستأجر وأصبحت المبنى مملوكة لصاحب الأرض المرهونة شملها الرهن من وقت تملك صاحب الأرض لها^(١).

ولا يترتب على إلحاق التحسينات والإنشاءات، كما ينص المشرع، الإضرار باحتجاز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين، فإذا عهد الراهن إلى مهندس أو مقاول بإقامة أبنية أو منشآت إحدى أو عمل إصلاحات في العقار المرهون، فإن ما يستحقه كل من المهندس والمقاول من أجير يعتبر ديناً ممتازاً في حدود ما نص عليه القانون^{٢٠٢٤/٢٠٢٥} في قيمة المقاول وقت بيعه، وعندئذ يفضل المهندس^{٢٠٢٤/٢٠٢٥} والمقاول على الدائن المرتهن برغم تأخر قيد الامتياز على قيد الرهن.

ويلاحظ أن التحسينات والإنشاءات التي يشملها الرهن هي التي تعتبر من ملحقات العقار وتوابعه، فلا يشمل الرهن ما يكسبه الراهن من عقارات محاورة كما لو أشتري قطعة أرض ملاصقة للأرض المرهونة.

٥- الثمار: لا يترتب على الرهن الرسمي تخلي الراهن عن حيازة المال المرهون أو عن ملكيته، ويكون له تبعاً لذلك الحق في استغلاله والحصول على ثماره. ومع ذلك فقد ألحق المشرع الثمار بالعقار المرهون، ومن ثم فإن الرهن يمتد بشملها. وهذا هو ما تنص عليه المادة ١٠٣٧ مدني بقولها «يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل، ويجرى في توزيع هذه الغلة ما يجرى في توزيع ثمن العقار».

(١) د/ السنهاوري: الوسيط ١٠ ص ٣٥٩، د/ منصور مصطفى: ص ٣١، د/ توفيق فرج: ص ١١٤.





فإذا كان العقار المرهون لا يزال في يد الراهن، فإن ثماره تلحق به من الوقت الذي يجرى فيه تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإما قبل ذلك فإن الثمار تكون للراهن والثمار قد تكون طبيعية أو مدنية. وتتميز الثمار عن المنتجات في أن الأولى دورية ومتجددة، ولا يترتب على اقتطاعها الإنقاص من أصل الشيء ذاته. ويعتبر الثمار الطبيعية مقبوضة من يوم فصلها عن الأصل (م/٩٧٨ مدني)، أما عن الثمار المدنية فإنها تعتبر مقبوضة يوماً فيوم (م/٩٧٨ مدني)، ولا يثور صعوبة بالنسبة لها. أما بالنسبة للثمار الطبيعية فإنها تعتبر كما أسلفنا مقبوضة من يوم فصلها، ومع ذلك فإنه لا ينبغي إغفال المدة السابقة على ذلك، فإذا كما بصدد محصول زراعي وتم تسجيل تنبيه نزع الملكية بعد زراعته وقبل نضج المحصول، فلا تلحق كل الثمار بالعقار المرهون^(١)، ولكن يلحق منها القدر الذي يخص المدة اللازمة لنضج المحصول. فإذا كان نضج المحصول يستغرق بقاءه في الأرض ثمانية أشهر وسجل تنبيه نزع الملكية بعد أربعة شهور من زراعته، فإن الذي يلحق من الثمار بالعقار المرهون ليس المحصول كله بل نصفه فقط.

أما إذا كانت ملكية العقار المرهون قد انتقلت إلى يد حائز له، فهنا تنص المادة ١٠٧٩ مدني على أنه «على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخليه، فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد. فثمار العقار تلحق به من الوقت الذي يسجل فيه تنبيه نزع الملكية إذا كان العقار في يد الراهن. وأما إذا كان العقار في يدها تزله فإن الثمار تلحق بالعقار من الوقت الذي ينذر فيه الحائز بالدفع أو التخليه.

الفرع الثاني

ملكية الراهن للشيء المرهون

لكي ينعقد الرهن صحيحاً، يلزم أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن. وقد نصت على ذلك المادة ١٠٣٢/٢ فقضت بأنه «...يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون...» سواء كان الراهن هو المدين نفسه أو كان شخصاً آخر يقدم رهنًا لمصلحة المدين.

ونعرض فيما يلي لرهن ملك الغير، ثم لحالة ما إذا كان الراهن مالكاً تحت شرط، أو مالكاً زالت ملكيته بأثر رجعي. كما نعرض لحالة الرهن الصادر من المالك الظاهر، وحالة رهن المباني المقامة على أرض الغير. ثم لحالة رهن العقار المملوك على الشيوع.

(١) د/ السنهاوري: الوسيط ١٠ ص ٣٦٥، د/ جمال زكي: التأمينات، ص ٢٠٧، د/ منصور مصطفى: ص ٣٤، د/ توفيق فرج: ص ١١٦، د/ أحمد سلامة: ص ١٨٢.



أولاً: رهن ملك الغير:

نصت المادة ١/١٠٣٣ من القانون المدنى «إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيح إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصح فيه العقار مملوكاً للراهن».

وقد علقت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى على النص بقولها «فإن كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن الرهن المعين غير المملوك للراهن باطلاً بطلاناً نسبياً أن يوحد الحكم ما بين بيع ملك الغير، ورهن ملك الغير رهناً رسمياً، ورهن ملك الغير حيازة، لوحدة العلة وتحقيقاً لأنساق التشريع. وفى هذه الفروض الثلاثة يجيز العقد من نقرر البطلان لمصلحته، كما يجيزه المالك الحقيقى أو انتقال الملكية إلى البائع أو الراهن».

ورغم هذا التوضيح من المذكرة الإيضاحية، فإن البطلان المذكور لا يتفق مع النظرية العامة للبطلان فى القانون المدنى، فهو بطلان من نوع خاص، وقد أوردت هذا التحديد المذكرة الإيضاحية ذاتها^(١) لذلك ذهب بعض الفقه^(٢) إلى العدول عن استخدام تعبير البطلان فى شأن بيع ملك الغير أو رهن ملك الغير واستخدام فكرة العقد الموقوف التى يعرفها فقه الشريعة الإسلامية. فالعقد لا يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً أو نسبياً. العقد يعتبر فى هذه الفترة عقداً موقوفاً. والعقد الموقوف يتوقف أثره على الإقرار من المالك، فإذا أقره المالك أنتج أثره^(٣) فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى المالك، وإذا لم يقره المالك فالعقد يظل معدوم الأثر كما كان. وقد أنعقد هذا رأى على أساس أن العقد الموقوف له فى الفقه الإسلامى معنى وأحكام لا تتفق مع معنى وأحكام القانون المدنى المصرى^(٤).

وقد حاول جانب آخر من الفقه^(٥) تأصيل الأحكام التى وصفها المشرع فى هذا الخصوص على أساس فكرة تحويل عقد بيع ملك الغير أو رهن ملك الغير الباطلين بسبب استحالة محلها إلى عقد غير مسمى منشئاً للالتزامات شخصية فقط ينقل الملكية أو بإنشاء حق الرهن إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى هذا العقد لو علموا بطلان العقد الذى انصرفت إليه نيتهما الأصلية «إلا أن هذا رأى لم يلق قبولاً من جانب الفقه».

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤ ص ١٩٣.

(٢) د/ شفيق شحاتة: النظرية العامة للتأمين العينى ص ٨٤.

(٣) د/ السنهورى: الوسيط ج ١٠ ص ٣٠٦.

(٤) د/ سليمان مرقس: التأمينات العينية، طبعة ١٩٥٩ ص ٦٥.

لذلك نرى مع الغالبية من الفقه^(١) أن البطلان النسبي في بيع أو رهن ملك الغير هو بطلان على غير مقتضى المفهوم العادى للبطلان. فالبطلان مطلقاً كان أو نسبياً له أسباب، وليس من بينها عدم ملكية المتصرف للشئ الذى تم التصرف فيه. لذلك فإن نصوص القانون المدنى هى التى أوجدت هذا النوع من البطلان النسبى. فهذه النصوص هى التى أنشأت الإبطال ولم تكشف عنه، ولو لم يوجد النص لما أمكن القول بأن رهن ملك الغير قابل للإبطال. فلا بد إذن من القول بأن جواز إبطال رهن ملك الغير كجواز إبطال ملك الغير، هو إبطال خاص لا يستمد من القواعد العامة، وقد أنشأه نص تشريعى صريح واستند فى إنشائه إلى علة معقولة.

حكم رهن ملك الغير بالنسبة للمالك:

بالنسبة للمالك الحقيقى يعتبر العقد غير نافذاً فى حقه حتى يجيزه، وهو ما يتفق مع اعتباره من الغير بالنسبة لعقد الرهن، فإذا لم يقر المالك الحقيقى العقد لم ينشأ الرهن.

إذا أقر المالك الحقيقى العقد ففى هذه الحالة ينفذ العقد فى حقه وينشأ الرهن، وبالتالي يسقط حق الدائن المرتهن فى طلب إبطال العقد. ويشترط أن يتم إقرار المالك الحقيقى للعقد فى ورقة رسمية. والحكمة فى ذلك أن هذا الإقرار ينشأ الرهن به، والرهن الرسمى لا ينشأ إلا بورقة رسمية فوجب أن يحرر هذا الإقرار بورقة رسمية.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

والإقرار ليس له أثر رجعى، فهوأثره إلا من تاريخ صدوره. ويجب شهر هذا الإقرار عن طريق القيد،.....كان الرهن قد قيد فيجب التأشير بإقرار المالك على هامش القيد، ولا ينتج على الغير بالرهن إلا من وقت شهر إقرار المالك، وتتحدد مرتبة..... من وقت قيد الإقرار، لا من وقت قيد عقد الرهن الرسمى.

حكم رهن ملك الغير فيما بين طرفيه

يعد العقد فيما بين طرفيه قابلاً للبطلان، غير أن هذا الجزء لا يستقيم مع منطق القواعد العامة إلا إذا كان كل المتعاقدين أو أحدهم يجهل مشكلة ملكية الغير للعقار المرهون، ففى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن بالذات، مصلحة فى إبطال العقد للغلط.

(١) د/ منصور مصطفى: ص ٤٠، د/ أحمد سلامة: ص ١٣٧، د/ توفيق فرج: ص ١١٦. د/ جمال زكى: ص ١٩١، د/ حمدى عبد الرحمن: التأمينات، طبعة ٨٩، ص ٣٢.

وقد يتنازل الدائن المرتهن عن حقه في التمسك بالإبطال، وقد ينقض هذا الحق بالتقادم. وفي الحالتين يستمر العقد قائماً بين طرفيه لكنه لا ينشئ رهناً وإنما ينشئ مجرد التزامات شخصية أهمها التزام الراهن بإنشاء حق الرهن. وإذا اكتسب الراهن ملكية العقار فإنه يكون قد أوفى بالتزامه وينشأ الرهن من وقت اكتساب الملكية وفقاً للمادة ١٠٣٣ مدنى.

أما إذا كان طرفا العقد على علم بعدم ملكية الملتزم بالرهن للمال المراد رهنه، فإن العقد لا يكون قابلاً للإبطال، ويمكن اعتباره عقداً غير مسمى ينشئ التزاماً شخصياً على عاتق الملتزم بالرهن، التزاماً يمكن تنفيذه أما بالحصول على ملكية العقار المرهون، وأما بالحصول على إقرار من المالك للرهن.

ثانياً: رهن المالك الذى زالت ملكيته بأثر رجعى

الرهن الصادر من غير مالك لا يكون له أى أثر بالنسبة للمالك ما لم يقره، والأصل أن هذا الحكم يسرى سواء كان الراهن غير مالك ابتداءً أى وقت الرهن أو كان مالكا ثم زالت ملكيته بأثر رجعى، لأن مقتضى الأثر الرجعى أن يعتبر الراهن كأنه لم يكن مالكا وقت إبرام الرهن، سواء كان الدائن المرتهن حسن النية أو سيئ النية (١).

ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل حماية للدائن المرتهن حسن النية ونص في المادة ١٠٣٤ على «يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أو نسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخر، إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن» ويشترط لتطبيق هذا النص:

أولاً: أن يكون الرهن صادراً عن مالك العقار المرهون وقت الرهن وزالت هذه الملكية عن الراهن بأثر رجعى. فإذا لم يكن الراهن وقت الرهن مالكا للعقار فلا ينطبق النص، كما لو كان الراهن مستنداً فى كسب الملكية على عقد باطل بطلاناً مطلقاً، أو على عقد صحيح لم يسجل.

وتزول الملكية بأثر رجعى إذا زال سند الملكية نفسه كما لو كان الراهن قد اشترى بعد قابل للإبطال وقضى بإبطاله، أو كان العقد صحيحاً وقضى بنسخة، أو كان الراهن موهوباً له ورجع الواهب فى الهبة.

ثانياً: يشترط كذلك أن يكون الدائن المرتهن حسن النية وقت الرهن. وحسن نية الدائن هو الذى يبرر لحماية بالإبقاء على الرهن رغم زوال ملكية الراهن.

(١) د/ منصور مصطفى منصور: التأمينات، ص ٤٦.

2024/2025

ثالثاً: أن يكون الرهن مقيداً قبل زوال سند ملكية الراهن. وشرط هو بصفة عامة شرط أساسي حتى يمكن أن يحتج بالرهن على من عادت إليه الملكية بأثر رجعي يعتبر أجنبياً عن الراهن في يحتج عليه بالرهن إلا إذا كان مقيداً قبل زوال الملكية.

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالي



أثر توافر الشروط السابقة:

إذا توافرت الشروط السابقة فإن الرهن يبقى قائماً وينفذ في حق من عادت إليه الملكية. وهو حكم روعيت فيه مصلحة الدائن المرتهن حسن النية ونتيجة لهذا النفاذ يكون من حق الدائن، إذا لم يتم الوفاء بالدين المضمون اختباراً أن يتخذ إجراءات التنفيذ على العقار المرهون في مواجهة المالك الذي عادت إليه الملكية (وليس في مواجهة المدين الراهن حيث انقطعت صلته بالعقار المرهون) وذلك رغم أن هذا المالك لم يكن له يد في تقرير الرهن وليس مديناً بالدين المضمون، وليس حائزاً وفقاً للمادة ١٠٦٠ من القانون المدني حتى يتم تتبع العقار تحت يده. وفي هذا جاء في المذكرة الإيضاحية^(١) للقانون أنه على كل حال يجب اعتبار المالك الحقيقي للعقار، لا الشخص الذي صدر منه الرهن، هو الراهن، وهو الذي يتخذ الدائن المرتهن ضده إجراءات نزع الملكية، أو يستمر في اتخاذها إذا كان قد بدأ هذه الإجراءات في مواجهة من صدر منه الرهن.

ثالثاً: رهن المالك تحت شرط:

إذا كان الراهن مالكاً للعقار المرهون ولكن ملكيته مشروطة بشرط فاسخ، فإن مصير الرهن يتوقف على تخلف الشرط أو تحققه، فإذا تخلف الشرط استقرت ملكية الراهن نهائياً وكذلك الرهن نفسه. وإذا تحقق الشرط فزالت ملكية الراهن بأثر رجعي اعتبر الرهن وارداً على ملك الغير، فلا يسرى في حق من تستقر له الملكية²⁵، إلا إذا كان الدائن حسن النية²⁶ حيث يسرى نص المادة ١٠٣٤ وقد 2024/2025 عرضنا لها.

أما إذا كان الشرط واقفاً، فإن تحقق الشرط فتأكدت ملكية الراهن استقر الرهن، وإن تخلف الشرط وبالتالي اعتبر الراهن كأنه لم يمتلك العقار أصلاً، فيعتبر الرهن وارداً على ملك الغير ويطبق في هذه الحالة حكم المادة ١٠٣٣ مدني.

رابعاً: رهن البناء المقام على أرض الغير

قد يبني شخص على أرض غيره باتفاق مع هذا الغير على أن يمتلك الباني مبانيه لمدة معينة، وفي هذه الحالة قد يطلب مالك الأرض بعد انتهاء المدة المتفق عليها - إزالة المباني، وقد يستبقها نظير دفع تعويض للباني، وفقاً لأحكام الالتصاق. فإذا كان الباني قد رهن البناء خلال المدة التي كان فيها مملوكاً له، فإن رهنه يصح وينفذ فإذا استحق الدين كان للدائن أن ينفذ على البناء ويستوفي

(١) الأعمال التحضيرية للقانون المدني ج٧ ص ٢٠.



حقه من ثمن بيعه جبراً عن المدين الراهن، وله أن يتتبع البناء في أى يد يكون إذا تصرف البانى فيه^(١).

أما إذا زالت ملكية البانى بهدم البناء أو بتملك صاحب الأرض له بالالتصاق فإن الدائن المرتهن يتمتع عليه أن يتتبع العقار المرهون لأنه أنهدم أو انتقل إلى مالك الأرض وهو لا يضار من الرهن لأنه لم يعط البانى غير ملكية مؤقتة، لكن يظل للدائن المرتهن حق التقدم على ثمن البناء وأيضاً على ثمن الأنقاض إذا أزيل البناء أو على التعويض الذى يستحقه البانى الراهن لدى مالك الأرض نتيجة الالتصاق. وهذا ما قضت به المادة ١٠٣٧ مدنى التى نصت على أنه: «يجوز لمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها. وفى هذه الحالة يكون للمرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى ومن التعويض الذى يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المبانى وفقاً للأحكام الخاصة بالالتصاق».

ومن الواضح أن هذا الحكم يمحى الدائن المرتهن و يضر كلا من الراهن وصاحب الأرض، ولا يتعارض مع أحكام الالتصاق^(٢). على أنه إذا آل المبنى إلى صاحب الأرض دون مقابل تنفيذاً لاتفاق البناء السابق، أنقضى الرهن وأصبح الدائن المرتهن دائناً عادياً.

أما إذا بنى شخص فى أرض غيره بغير اتفاق معه، وتملك صاحب الأرض²⁵ البناء بالالتصاق، وكان التمسك^{2024/2025} رهن البناء فإن رهنه يعتبر رهنأ لملك 2024/2025 الغير فلا ينفذ فى مواجهة صاحب الأرض إلا بإقراره.

خامساً: رهن المالك الظاهر:

المالك الظاهر ليس هو المالك الحقيقى ولكنه أمام الناس ظهر بمظهر المالك الحقيقى، كالوارث الظاهر وهو شخص آلت إليه التركة أو نصيب فيها ثم بعد أن تصرف فيها تبين أن هناك وارثاً حقيقياً يحجبه. وكالمالك بسند صورى. فإذا رهن المالك الظاهر العقار لدائن له، فإن تطبيق القواعد العامة يقتضى اعتبار رهنه صادراً من غير مالك فتسرى عليه أحكام رهن ملك الغير، فلا ينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا إذا أقره أو آلت ملكية العقار المرهون إلى الراهن.

ومع ذلك أتجه جمهور الفقه إلى حماية الوضع الظاهر إذا تعامل شخص معه بحسن نية، كما أتجه القضاء وواضح القانون إلى ذلك فى بعض التطبيقات

(١) د/ السنهورى: الوسيط ج١ ص ٣٦٧، د/ منصور مصطفى ص ٤٥.

(٢) د/ منصور مصطفى منصور: التأمينات، ص ٤٤.



عملاً بقاعدة الغلط الشائع يولد الحق، حماية لاستقرار المعاملات وتقدير الحسن نية المتعاقد.

المالك بسند صوري: قد يملك الشخص عقار بعقد صوري، فما هو الحكم إذا قام مثل هذا الشخص برهن العقار، لاشك أن الدائن المرتهن يعتبر خلفاً خاصاً للراهن (المالك الظاهر)، ولهذا يكون له (الدائن) التمسك بالعقد الظاهر، متى كان حسن النية وقت التصرف، أى متى كان يجهل أن الراهن يملك العقار بعقد صوري. والقانون بذلك يحمي الدائن المرتهن باعتباره خلفاً خاصاً للراهن. لأنه اعتمد على الوضع الظاهر ولم يكن فى وسعه معرفة حقيقة الأمر.

وقد نصت المادة ١/٢٤٤ مدنى على أنه «إذا أبرم عقد صوري فلدائن المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسن النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري» وإذا ما تعارضت مصلحة الدائن المرتهن الذى يتمسك بالعقد الصوري، أى الوضع الظاهر، مع مصلحة دائن مرتهن آخر من المالك الحقيقى، فإن القانون يفضل من يتمسك بالوضع الظاهر، ويقدم الدائن المرتهن من المالك الظاهر، حتى ولو كان المرتهن من المالك الحقيقى قد سبقه فى القيد، لأن كلا من الدائنين المرتهنين قد اكتسب حقه من راهن مختلف، وقد نصت المادة ٢/٢٤٤ على أنه «إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين».

2024/2025 **الوارث الظاهر:** قد يظهر شخص ~~شخص~~ أمام الناس أنه الوارث الحقيقى للتركة، ثم يتبين بعد ذلك أنه ليس كذلك نظراً لوجود شخص آخر يحجبه، مما لاشك فيه أنه إذا كان الدائن المرتهن سيئ النية. أى يعلم أن الوارث الظاهر ليس هو الوارث الحقيقى، فإنه لا يكون للرهن أثره بالنسبة للوارث الحقيقى.

أما إذا كان الدائن المرتهن حسن النية أى يعتقد أن الوارث الظاهر الذى قام بالرهن هو الوارث الحقيقى، فإن القانون لم يصنع حلاً فى هذا الصدد، ولم يبين ما إذا كان مثل هذا الرهن يسرى فى مواجهة الوارث الحقيقى أم لا. لذلك ذهب البعض^(١) أن الرهن الذى يصدر من الوارث الظاهر لا أثر له بالنسبة للوارث الحقيقى حتى ولو كان الدائن المرتهن حسن النية، لأنه هو صادر من غير مالك.

(١) د/ سليمان مرقس: التأمينات، ص ٧٤.

ولكن الغالبية ترى^(١) غير ذلك، وأن الرهن الصادر من الوارث الظاهر يسرى في مواجهة الوارث الحقيقي متى كان الدائن المرتهن حسن النية، عملاً بقاعدة الغلط الشائع يولد الحق. ويكفي المرتهن من الوارث الظاهر التمسك بهذه القاعدة أن يثبت أنه اعتقد بحسن نية أن الراهن هو المالك وأن هذا الاعتقاد يوجد لدى غيره من الأشخاص العاديين، وإذا رهن الوارث الحقيقي العقار إلى آخر كان رهنه كذلك صحيحاً وناظراً وعند التعارض يفضل الدائن المرتهن من الوارث الظاهر قياساً على ترجيح الرهن الصادر لدائن المالك بسند صوري على الرهن الصادر لدائن المالك الحقيقي.

سادساً: رهن العقار المملوك على الشيوع:

قد تكون الملكية مفرزة وقد تكون شائعة، والمالك على الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات طالما لا يلحق ضرر بحقوق غيره من الشركاء (م ٨٢٣٦ مدني). وبالتالي يجوز رهن العقار المملوك على الشيوع من جميع الشركاء، كما يجوز لأي منهم رهن حصته الشائعة فيه، وقد يحدث أن يرهن أحد الشركاء حصة مفرزة أو يرهن العقار كله. ونبين بيان حكم ذلك.

١- الرهن الصادر من جميع الشركاء:

تنص المادة ١/١٠٣٩ مدني على أنه «يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الشركاء لعقار شائع، أي كانت النتيجة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته».

ويؤخذ من النص السابق أن الرهن الصادر من جميع الشركاء رهن صحيح ونافذ، لأنه صادر من مالك. كذلك يصح وينفذ الرهن الصادر من الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وأعلنوا قرارهم إلى باقي الشركاء فلم يعترض أحد منهم. أما إذا أعترض باقي الشركاء خلال شهرين من إعلانهم بقرار الأغلبية، فإن الرهن لا ينفذ إلا إذا قدرت المحكمة أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء وأن رهن العقار تصرف واجب (م ٨٣٢ مدني). وإذا تمت قسمة العقار المملوك على الشيوع فتأخذ كل شريك حصة مفرزة من هذه العقار كما لو كانوا ثلاثة شركاء رهنوا ستة أفدنة ثم أختص كل منهم بفدانين بعد القسمة، ففي هذه الحالة يظل العقار كله (الستة أفدنة) ضامناً للوفاء بالدين كله وفقاً لمبدأ عدم تجزئة الرهن.

(١) د/ السنهوري: الوسيط، ج ١٠، ص ٣١٠، د/ منصور مصطفى، ص ٥٠، د/ أحمد سلامة: ص ١٤٧، د/ سمير تناغو: ص ١٩٢.



أما إذا اختص أحد الشركاء بالعقار كله نتيجة هذه القسمة، فقد كان مقتضى القواعد العامة إلا يكون الرهن صحيحاً ونافاً إلا بنسبة حصته التي كانت شائعة في هذا العقار لأنه لمي رهن غير هذه الحصة، ولأن للقسمة أثراً كاشفاً ظهر به أن الشركاء الآخرين قد رهنوا ملك غيرهم فلا ينفذ رهنهم في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره. غير أن المادة ١/١٠٣٩ مدني قررت على خلاف هذه القواعد العامة أن الرهن يظل صحيحاً ونافاً بكل العقار المرهون أي كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد.

وإذا بيع العقار بعد رهنه من الشركاء جميعاً لأحد الشركاء كان الرهن صحيحاً، ونافاً، كحكم قسمته ووقوعه في نصيب أحد الشركاء إذا بيع العقار بعد رهنه من الشركاء جميعاً إلى مشتر من غير الشركاء، ظل الرهن صحيحاً ونافاً وانتقل العقار إلى المشتري مثقلاً به^(١).

٢- رهن الشريك حصته شائعة.

يكون الرهن في هذه الحالة صحيحاً، فهو رهن صادر من مالك له سلطة التصرف وفقاً للمادة ١/٨٢٦ مدني والتي تنص على «أن كل شريك يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً، له أن يتصرف فيها». ويجوز للدائن، مادام الشروع قائماً، أن ينفذ على الحصة المرهونة عند حلول أجل الدين، وأن يتخذ إجراءات بيعها بالمزاد العلني، يحل الراسي عليه المزاد محل الشريك المشتاع في حقوقه.

2024/2025 أما إذا تمت قسمة المال الشائع قبل حلول أجل الدين، ففي هذه الحالة 2024/2025
نفرق بين عدة فروض:

١- أن يختص الراهن بجزء مفرز من العقار يعادل لحصته المرهونة، وعندئذ يتركز الرهن في هذا الجزء المفرز.

٢- أن يختص الراهن بجزء مفرز من العقار أكبر من حصته أو يؤول له العقار كله، وعندئذ يتركز الرهن فيما أختص الراهن به ويبقى في حدود قيمة الحصة الشائعة السابق رهنها فحسب.

٣- أن يختص الراهن بعقار آخر أو بجزء من عقار آخر، وفي هذه الحالة يحل الرهن حلاً عينياً بمرتبة فيما اختص به الراهن ويقدر قيمة حصته الشائعة السابق رهنها، فقد نصت المادة ٢/١٠٣٩ مدني على أنه «إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزء مفرزاً من هذا العقار، ثم وقع في

(١) د/ السنهوري: الوسيط ج. ١٠، ص ٣٢٥، د/ منصور مصطفى: ص ٥٠، د/ جمال زكي: ص ١٢٧، د/ توفيق فرج، ص ١٢٧.





نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها، انتقل الرهن بمرتبه إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل. ويعين هذا القدر بأمر على عريضة. ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة. وواضح أن يشترط لحلول الرهن من العقار الجديد، أن يعين القدر الذي انتقل إليه الرهن بأمر على عريضة من القاضي، بناء على طلب الدائن حتى يمكن له قيده من جديد.

٤- إذا لم يختص الراهن بعد القسمة إلا بمنقول، فإن تطبيق القواعد العامة يقتضى أن يفقد الدائن رهنه لأن الرهن الرسمى لا يرد إلا على عقار فلا ينتقل إلى المنقول^(١). ويؤدى انقضاء الرهن إلى سقوط أجل الدين لضياح التأمين الذى كان يضمنه فيكون للدائن أن يطالب المدين بالوفاء بدينه فوراً أو بتقديم ضمان آخر كاف (م ٢٧٣/٢ مدنى).

بينما يذهب رأى آخر^(٢) وتفضله إلى القياس على المادة ١٠٣٩/٢ مدنى ينتقل الرهن إلى المنقول ويتحول إلى رهن حيازى، لأن واضع القانون وقد نص على الحلول العينية إذا أسفرت القسمة على اختصاص الراهن بعقار آخر قمن باب أولى يقوم هذا الحلول العينية إذا أسفرت القسمة على اختصاص الراهن بمنقول حتى لا يفقد الدائن رهنه.

2024/2025 يبقى أن يختص المرتهن بحكم 2024/2025 حق التقدم فى استيفاء دينه من المبلغ. 2024/2025 وذلك إذا كان أصل دينه قد حل. أما إذا كان أجل الدين لم يحل بند القسمة، فيرى البعض أن حق الدائن المرتهن ينتقل إلى المبلغ الذى يستحقه الشريك، وفى هذه الحالة نكون بصدد صورة من صور رهن الدين^(٣).

بينما يرى آخر اعتبار عدم أيلولة شئ من عقار فى نصيب الراهن نوع من أضعاف التأمين يسقط به الأجل الممنوح للدين ما لم يقدم تأميناً آخر^(٤).

٣- رهن الشريك لجزء مفرز:

إذا رهن الشريك جزءاً مفرزاً من العقار لا ينفذ هذا الرهن فى مواجهة الشركاء الآخرين، لأن حق كل منهم يتعلق بهذا الجزء، ولا يختص الشريك الراهن

(١) د/ السنهورى الوسيط ج ١٠ ص ٣٢١، د/ سمير تتاغو، ص ٢٠٨.

(٢) د/ منصور مصطفى: ص ٥٥، د/ أحمد سلامة: ص ١٦٧.

(٣) د/ منصور مصطفى، ص ٥٥.

(٤) د/ أحمد سلامة: ص ١٦٦، د/ حمدى عبد الرحمن: ص ٥٢.



من دونهم بسلطة التصرف فيه، فإذا كان المرتهن لا يعلم بحالة الشيوخ فله أن يطلب إبطال التصرف للغلط.

أما إذا كان يعلم بحال الشيوخ كان الرهن صحيحاً لأنه صادراً من مالك ولكن يظل نفاذه موقوفاً على حدوث القسمة. فإذا كانت نتيجة القسمة وقوع الجزء المرهون في نصيب الراهن أصبح الرهن نافذاً في مواجهته. وإذا وقع الجزء المرهون في نصيب شريك آخر لم ينفذ هذا الرهن في مواجهته ومع ذلك إذا انتقل إلى الراهن بمقتضى القسمة مال آخر فإن هذا المال هو الذى يصبح مثقلاً بالرهن بمقتضى فكرة الحلول العينية وهذا ما نص عليه المشرع فى القواعد العامة للتصرف فى الملكية الشائعة، فى المادة ٢/٨٢٦ «إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المنصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المنصرف فيها مفرزة، الحق فى إبطال التصرف». وقد طبق المشرع هذه القاعدة بنص خاص فى الرهن هو نص المادة ٢/١٠٣٩ مدنى، وهذا النص يوجد فى الحكم بين رهن الجزء المفرز ورهن الحصة الشائعة فى الفترة اللاحقة على القسمة من حيث تطبيق فكرة الحلول العينية.

المطلب الثالث

الالتزام المضمون

2024/2025 لى ينقذ الرهن صحيحاً، يجب أن يستند إلى التزام صحيح، إذ الرهن حق 2024/2025

عينية تبعي، لا يوجد، مستقلاً بل يوجد مستنداً إلى الالتزام المضمون. ولهذا يجب أن يوجد الالتزام المضمون، وأن يكون ميعناً فى عقد الرهن نفسه.

وجود الالتزام المضمون.

لكى يقوم الرهن يجب أن يستند إلى التزام صحيح. فإذا لم يوجد هذا الالتزام أو كان باطلاً، أو وجد صحيحاً ثم أنقضى لأى سبب من الأسباب، فإن الرهن يأخذ مصيره فلا يوجد أصلاً أو يقع باطلاً، أو يوجد صحيحاً ثم ينقضى. فالرهن إذن يرتبط بالالتزام المضمون ويتبعه فى وجوده وصحته وانقضائه وعلى ذلك تقضى المادة ١/١٠٤٢ مدنى «لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعاً له فى صحته وفى انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذلك».

وارتباط الرهن بالدين المضمون يسرى، سواء كان الراهن هو المدين أو الكفيل العينية. ولهذا يكون للمدين أن يتمسك بأى دفع من الدفع المتصلة بالالتزام المضمون، للكفيل العينية كذلك أن يتمسك بكل الدفع الخاصة بالالتزام المضمون ذاته من حيث وجوده وصحته وانقضائه، وله التمسك بهذه الدفع حتى

ولو نزل المدين عن التمسك بها. هذا فضلاً عما للكفيل من التمسك بالدفع الخاصة به هو، الناتجة عن عقد الرهن وقد نصت المادة ١٠٤٢/٢ مدنى على هذا بقولها «إذا كان الراهن غير المدين كان له، إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به، أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين. ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين».

وإذا كان المشرع لم ينص على حرمان الكفيل العينى من التمسك بنقص أهلية المدين لأبطال العقد المنشئ للالتزام المضمون متى كان عالماً لهذا النقص وقت التعاقد، فإنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق هذا الحكم^(١)، دون تفرقة بين الكفيل العينى والكفيل الشخصى (م ٧٨٢/٢ مدنى). كما أنه إذا قدم الرهن من الكفيل العينى لضمان التزام بمبلغ من النقود إلا أنه لا يوجد ما يمنع من عقد الرهن لضمان التزام بعمل آخر أو امتناع عن عمل وينتهى الحال فى مثل هذه الأحوال إلى أن يضمن الرهن الوفاء بالتعويض الذى يستحق الدائن بسبب الإخلال بالالتزام. وكما يجوز أن يكون الالتزام المضمون ناشئاً عن العقد يجوز أن يكون ناشئاً عن مصدر آخر كالعمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب أو نص القانون ويصح الرهن ضماناً للالتزام معلق على شرط، سواء كان الشرط واقفاً أو ناسخاً، وعندئذ يتوقف مصير الرهن على مصير الالتزام المضمون، كما يصح الرهن كذلك ضماناً لدين مستقبل أو دين احتمالى، مع مراعاة تحديد مبلغ الدين المضمون أو على الأقل تحديد الحد الأقصى له (م ١٠٤٠ مدنى).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وقد أثير التساؤل عما إذا كان من الجائز إنشاء الرهن ضماناً للوفاء بالالتزام طبيعى، فذهب رأى إلى عدم جواز ضمان الرهن له، لأنه لا جبر فى تنفيذه^(٢)، ومذهب يرى تعهده بالوفاء به^(٣)، وبهذا التعهد يتحول الالتزام الطبيعى إلى التزام مدنى، وبالتالي يتحول الرهن من ضمان للالتزام الطبيعى إلى ضمان التزام مدنى، فيجبر المدين على الوفاء به.

تعيين الالتزام المضمون

يجب أن يتعين الالتزام المضمون من حيث قدرة ومصدرة، ولتعيين الالتزام المضمون من حيث قدرة أهمية بالنسبة للغير الذين يهمهم معرفة الدين المضمون ومقداره حتى يعرف مدى ما يمكن أن يعطيه العقار من ائتمان. ولهذا ينبغى أن يعين قدر الدين فى عقد الرهن ويستفاد هذا الحكم من المادة ١٠٤٠ التى تستلزم

(١) د/ منصور مصطفى منصور: التأمينات، ص ٣٥، د/ توفيق فرج: التأمينات، ص ١٢٩.

(٢) د/ السهورى: الوسيط، ج ١٠، ص ٢٧٢ هامش ٦.

(٣) د/ منصور مصطفى: ص ٣٧، د/ سليمان مرقس: ص ١٠٤، د/ توفيق فرج: ص ١٢٩.

فى رهن الديون الاحتمالية والمستقبلية تحديد مبلغ الدين المضمون، أو على الأقل تحديد الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين. وإذا كان هذا الحكم قد ورد بشأن الديون الاحتمالية المستقبلية، فإنه يسرى أيضاً - ومن باب أولى - على الديون المحققة الوجود إذ يجب تعيينها تعيناً كافياً، وهذا التقنين هو ما يقتضيه مبدأ تخصيص الرهن بالنسبة إلى الالتزام المضمون.

ولا يكفى تعيين الدين المضمون من حيث مقداره، وإنما يلزم تعيينه كذلك من حيث مصدره تعيناً كافياً، خاصة إذا كان الرهن قد تقرر بعقد مستقل أما إذا تقرر الرهن وقت نشأة الالتزام المضمون، فإن هذا يقتضى بالضرورة تعيين مصدره. ولتعيين الالتزام المضمون من حيث مصدره أهمية، لكى تتحدد ذاتيته ويتاح لكل ذى مصلحة معرفة ما يطرأ على هذا الدين ويؤثر فى الرهن نفسه، كما إذا كان هذا الرهن باطلاً مثلاً أو كان قد انقضى، وقد نص قانون تنظيم الشهر العقارى على وجوب ذكر مصدر الدين ضمن البيانات الواجب ذكرها فى قائمة القيد.

المبحث الثانى الشروط الشكلية

تقسيم:

لا يكفى لقيام الرهن توافر الشروط الموضوعية طبقاً للقواعد العامة، لأن العقد المنشئ له ليس من العقود الرضائية^{2024/2025}، ولكن لا بد من أن يفرع فى الشكل^{2024/2025} الرسمى، كما يتعين أن يشتمل على بيانات معينة سواء بالنسبة للعقار المرهون أم بالنسبة للدين المضمون. وهذا ما يعرف بتخصيص الرهن. ونعرض فيما يلى للرسمية، ثم لمبدأ تخصص الرهن.

المطلب الأول الرسمية

الرسمية شرط لانعقاد الرهن:

إذا كان الأصل فى العقود بوجه عام هو الرضائية حيث ينعقد العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين. إلا أن عقد الرهن الرسمى يعتبر من العقود الشكلية، والشكلية المطلوبة هى الرسمية، وقد نصت على ذلك المادة ١/١٠٣١ مدنى بقولها «لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية». والورقة الرسمية حسب تعريف القانون فى المادة ١/٣٩٠ «التي يثبت فيها موظف عام أو

شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه».

ومع ذلك فهناك إجماع من الفقه على أنه ليست كل ورقة رسمية تصلح لإبرام الرهن، فالاتفاق على الرهن الثابت فى محضر أمام القضاء لا يكفى لإنشاء الرهن الرسمى^(١).

بل لابد أن يتم الرهن فى عقد رسمى. فالمقصود بالورقة الرسمية التى ينعقد بها الرهن هى العقد الرسمى، والعقد الرسمى لا يكون كذلك إلا إذا قام بتحريره موظف مختص بتحرير العقود، وهذا الموظف هو الموثق الذى يجب أن يحرر العقد وفق الإجراءات التى نص عليها قانون التوثيق (القانون ٦٨ لسنة ١٩٤٧).

والحكمة من اشتراط الرسمية، وفقاً للرأى التقليدى والسائد^(٢)، هى حماية الراهن من تسرعه فى إبرام العقد دون أن يدرك خطورته، إذ يترتب على تطلب الرسمية بما تقتضيه تحرير العقد أمام موظف رسمى من وقت وإجراءات تنبيه الراهن إلى خطورة العقد.

كما أن الرسمية تحقق فائدة للدائن المرتهن، لأنها تزوده عند إبرام العقد بسند تنفيذى يغنيه عن إجراءات التقاضى إذا امتنع المدين الراهن عن الوفاء بدينه عند حلول الأجل. وهذه فائدة عملية لا سبيل إلى إنكارها، بل أن الرسمية تحقق فائدة للرهن ذاته، وللاتئمان العقارى بصفة عامة، لأنها تضمن إلى حد كبير أن يبرم العقد الشروط اللازمة^{2024/2025} لصحته من شروط الأهلية، وملكية الراهن^{2024/2025} وتخصيص الرهن^(٣).

حدود العنصر الشكلى فى عقد الرهن:

الشكلية ولاشك لازمة بالنسبة إلى رضاء الراهن، ذلك لأن الرسمية قد تقررت لحمايته، فالغرض منها هو تنبيه الراهن إلى خطوة التصرف (عقد الرهن) المقدم عليه، وأما عن رضاء الدائن المرتهن، فلا مشكلة فى الأمر إذا عبر كل من الراهن والدائن المرتهن عن إرادته فى وقت واحد، وصنع العقد فى ورقة واحدة، إذ يتضمن العقد الرسمى عندئذ رضاء كل من الاثنين.

(١) د/ شفيق شحاتة: التأمينات، ص ٤٨، د/ منصور مصطفى: ص ٥٢، د/ أحمد سلامة، ص ١٩٠، د/ توفيق فرج: ص ١٣٢.

(٢) ينتقد بعض الشراح القاعدة التى تستلزم الرسمية كشرط لانعقاد الرهن دون التصرفات الأخرى. أنظر فى ذلك د/ شفيق شحاتة: التأمينات ص ٥٢.

(٣) د/ السنهورى: الوسيط ج ١٠ ص ٢٨١، د/ منصور مصطفى: ص ٥٣.

أما إذا كان رضا الراهن فى ورقة رسمية فهل يجب أن يقابل هذا الرضاء، رضا الدائن المرتهن فى ورقة رسمية أيضاً.

يذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه الأخذ بظاهر النصوص يؤدى إلى استلزام الرسمية بالنسبة لرضاء كل من الراهن والدائن المرتهن، ذلك لأن الرهن لا ينعقد إلا بورقة رسمية ويضيف هذا الاتجاه بأن الشكلية كما هى مقررة لمصلحة الراهن، فهى مقررة أيضاً لمصلحة الدائن المرتهن، ذلك لأن الدائن المرتهن يجد نفسه فى حاجة إلى التثبت من أصل ملكية الراهن ومن أهليته للتعاقد، والتجأؤه إلى الرسمية يجعله فى مأمن من ذلك. كما أن من شأن الرسمية أن تجعل فى يد الدائن المرتهن سنداً قابلاً للتتفيذ، فلا يحتاج إلى حكم إذا حل الأجل المحدد للوفاء بالدين ولم يوف به المدين الراهن^(١).

ويذهب جانب آخر من الفقه^(٢) إلى القول بأن الشكلية قد تقرر فى الرهن حماية للراهن فقط. ومن ثم فهى لازمة فى التعبير عن رضا الراهن فقط دون الدائن المرتهن الذى يجوز أن يكون فى ورقة رسمية أو فى ورقة عرفية، كما يستخلص رضا الدائن المرتهن أيضاً من قيامه بقيد الرهن مثلاً والرأى الأول فى نظرنا هو الأولى بالإتباع، ذلك أن المشرع ينص على وجوب انعقاد الرهن فى ورقة رسمية، وانعقاد الرهن لا يتم إلا بإيجاب وقبول مما يؤدى إلى القول بضرورة إفراغ رضا طرفى العقد فى الشكل الرسمى. هذا فضلاً عن أنه لما كان تطلب الرسمية هنا وثيق الصلة بمبدأ تخصيص الرهن، فإنه يجب أن يتم رضا الراهن والمرتهن معاً فى ورقة رسمية تتضمن البيانات اللازمة بشأن العقار المرهون الالتزام المضمون، حتى يكتسب هذا الرضا الحجية التى تكفل تقادى ما قد يثور من منازعات احتمالية.

الجزاء على تخلف الرسمية

لا جدال فى أن الرسمية ركن فى العقد لا يقوم بدونها، فإذا تخلفت كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، لا يترتب عليه أى أثر باعتباره عقد رهن. وعقد الرهن الذى لم يستكمل الشكل المطلوب لا يمكن أن ينشأ عنه التزام ما على عاتق المدين الراهن، فعقد الرهن الباطل لعدم استيفاء الشكل المطلوب لا يمكن اعتباره وعداً بالرهن^(٣)، فهو لم يشتمل على بيان المدة التى يجب إجراء القيد فى خلالها،

(١) د/ السنهورى: الوسيط ج ١٠ ص ٢٨٢، د/ منصور مصطفى منصور، ص ٥٤. د/ أحمد

سلامة: ص ١٩٢، د/ سمير تتاغو: التأمينات، ص ١٤٠.

(٢) د/ سليمان مرقس: التأمينات، ص ١٠٩.

(٣) يذهب إلى هذا الرأى د/ سليمان مرقس: التأمينات، ص ١١٣.

ثم أنه لم يفرع هو نفسه في الصورة الرسمية والأصل كما تقضى بذلك المادة ٢/١٠١ مدنى أنه إذا تطلب القانون شكلاً خاصاً لانعقاد العقد وجب توافر هذا الشكل في الوعد الذى يؤدى إلى إنشائه^(١).

الوكيل فى الرهن:

لما كان القانون يستلزم لانعقاد الرهن أن يتم بورقة رسمية، فإن التوكيل به ينبغى أن يكون رسمياً كذلك. فإذا أناب المدين وكيلاً عنه فى الرهن، تعين أن تكون هذه الوكالة فى ورقة رسمية. ولما كان الرهن من أعمال التصرف. فإن الوكالة العامة لا تكفى، بل لابد من أن تكون الوكالة به خاص. والوكالة الخاصة فى هذه الحالة تصح، حتى ولو لم يعين محل الرهن على سبيل التحديد. ذلك أن هذا التعين يرد فى عقد الرهن نفسه الذى يتم بين الوكيل والدائن المرتتهن إعمالاً لمبدأ تخصيص الرهن (م ٧٠٠، ٧٠٢ مدنى).

هذا يراعى أنه إذا كان القانون يستلزم أن يتوافر فى الوكالة الشكل الرسمى فى هذه الحالة، فإن الرسمية هنا لا تغنى عن الرسمية فى عقد الرهن نفسه الذى يبرمه الوكيل مع الطرف الآخر لحساب الأصيل.

الوعد بالرهن:

ينعقد الوعد بالرهن الرسمى إذا تضمن تعيين المسائل الجوهرية فى الرهن والعقار المرهون فيها (م ١/١٠١ مدنى)، وضرورة الوعد فى ورقة رسمية تطبيقاً للمادة ٢/١٠١^{2024/2025} التى تنص على أنه «إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل يجب مراعاته أيضاً فى الإنفاق الذى يتضمن الواعد بإبرام هذا العقد».

فإذا استوفى الوعد بالرهن الرسمى شروطه الموضوعية والشكلية أصبح وعداً ملزماً، بحيث إذا نكل الواعد عنه وقاضة المتعاقد الآخر طالباً بتنفيذ الوعد بإبرام الرهن الرسمى، تعين الحكم بإلزام الواعد بتنفيذه ويقوم هذا الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى فيه مقام عقد الرهن الرسمى والحكمة من اشتراط الرسمية فى الوعد بالرهن الرسمى هى الحيلولة دون تحايل المتعاقدين على الشروط الشكلية للرهن بإبرام وعد به غير رسمى ثم استصدار حكم به يفيد أن يقوم مقام الرهن الرسمى، فهذا الحكم لا يصدر إلا إذا استوفيت فى الوعد الشروط اللازمة لتمام العقد الموعود به وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل.

(١) د/ شفيق شحاتة: التأمين العينى ص ٥٩، د/ منصور مصطفى: ص ٥٨.

فإذا لم يستوف الوعد بالرهن الشكل الرسمي بأن حرر مثلاً في ورقة عرفية فإنه يكون وعداً باطلاً، فلا يلزم الواعد فيه بتنفيذه ولا يستطيع الدائن أن يستصدر به حكماً يقوم مقام الرهن الرسمي. لكن إذا لم يستوف الوعد بالرهن الشكل الرسمي المطلوب فهل يكون خلواً من كل أثر قانوني؟ أوردت المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد أن الوعد بإبرام عقد رسمي لا يكون خلواً من أى أثر قانوني إذ لم يستوف ركن الرسمية. فإذا صح أن مثل هذا الوعد لا يؤدي إلى إتمام التعاقد المقصود فعلاً، فهو بذاته تعاقد كامل يترتب التزامات شخصية طبقاً لمبدأ سلطان الإرادة. وهو بهذه المثابة قد ينتهي عند المطالبة بالتنفيذ إلى إتمام عقد الرهن، أو على الأقل إلى قيام دعوى بالتعويض، بل وإلى سقوط أجل القرض الذي يراد ترتيب الرهن لضمان الوفاء به^(١).

في حين يذهب رأى آخر^(٢) أن الوعد الذي لا يستكمل شرط الرسمية يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يترتب عليه أى أثر، فهذا هو مقتضى اشتراط الرسمية في عقد الوعد نفسه، وإذا جاز للدائن المرتهن أن يسعى للحصول على حق اختصاص فذلك يكون بناء على حكم بالدين الذي أريد ضمانه بالرهن.

المطلب الثانى

تخصيص الرهن

التعريف به والغاية منه

2024/2025 لا يكفى أن يتم عقد الرهن أمام موظف رسمي مختص حتى يقوم الرهن، 2024/2025 بل لابد أن يتضمن العقد بيانات معينة، غير البيانات العامة التي ترد في العقود، فيجب أن يتضمن بياناً للعقار المرهون والدين المضمون. وهذا ما يعرف بتخصيص الرهن.

ويقصد من هذا التخصيص حماية الراهن، حتى يكون على بينة من العقارات التي يرهنها، فلا يرهن منها إلا ما يكفى لضمان الدين، كما تكون لديه الفرصة التي تمكنه من أن يفيد من القيمة الائتمانية للعقار.

(١) وهذا هو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ج٧ ص٧٥، هو رأى غالبية الفقه، د/ السهورى: الوسيط ١٠، ص٢٨٣، د/ سليمان مرقس ص١١٦، د/ أحمد سلامة: ص١٩٣، د/ سمير تناعو، ص١٤٧.

(٢) د/ شفيق شحاتة: ص٦٠، د/ منصور مصطفى منصور. ص٦١، د/ جمال زكى: التأمينات، ص٢٢٨.



ومن ناحية أخرى فإن التخصيص يحمي الدائنين، إذ يمكنهم من معرفة العقارات المرهونة والديون المضمونة فيتعاملون مع الراهن على بينة من الأمر ولا يتزاحمون على عقارات مرهونة قد تكون قيمتها مستغرقة بالديون.

كيف يحصل التخصيص

هذا التخصيص أما أن يرد في عقد الرهن ذاته، وهذا هو الوضع العادى، وأما أن يتم في محرر لاحق، وفي هذه الحالة الأخيرة يلزم أن يكون في محرر رسمى. وسواء ورد التخصيص في العقد ذاته أو في محرر لاحق، فإن الرهن لا يقوم صحيحاً إلا من الوقت الذى يتم فيه التخصيص. وهذا الحكم يسرى سواء بالنسبة للعقار المرهون أم بالنسبة للدين المضمون.

تخصيص العقار المرهون

يوجب القانون أن يكون العقار معيناً بالذات تعيناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه، بحث يستدل عليه بطريقة كافية لا تقبل الشك، فإذا لم يكن العقار محدداً تحديداً كافياً لا يتحقق التخصيص، وبالتالي يقع الرهن باطلاً. وتقدير كفاية هذا التحديد يترك للقاضى، فهو الذى يقرر ما إذا كان كافياً أو غير كاف. وفي هذه الحالة الأخيرة يحكم بالبطلان.

تخصيص الالتزام المضمون

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ومن ناحية أخرى يجب أن يحدد الدين المضمون في عقد الرهن تحديداً دقيقاً سواء من حيث مصدره أو من حيث مقداره وما إذا كانت منتجاً لفائدة وسعر هذه الفائدة وتاريخ سريانها، إلى غير ذلك. وإذا كان ديناً مستقبلاً أو ديناً احتمالياً، فإنه يجب أن يبين الحد الأقصى الذى ينتهى إليه الدين. وهذا هو الواجب أيضاً في الحالات الأخرى التى لا يكون فيها الدين مضمون محدداً منذ البداية، كما إذا كان محل الالتزام المضمون عملاً أو امتناعاً عن عمل أو تعويضاً لم يتحدد مقداره بعد، إذ يجب في جميع هذه الحالات ذكر الحد الأقصى الذى يضمه الرهن.

أثر عدم تخصيص الرهن

إذا تم العقد أمام موظف رسمى مختص واشتمل على البيانات الخاصة بالعقار المرهون والالتزام المضمون، قام الرهن صحيحاً، متى توافرت الشروط الأخرى. فإذا تخلف تخصيص الرهن سواء من حيث العقار المرهون أو الدين

المضمون فلا يقوم الرهن، ويقع باطلاً، وإذا جاء هذا التخصيص في عقد رسمي لاحق فإن الرهن لا ينعقد إلا من الوقت الذي يتم فيه التخصيص. ويثور التساؤل في حالة ما إذا لم يخصص العقار المرهون أو الدين المضمون ووقع الرهن باطلاً، هل يخلو هذا العمل من أى أثر قانونى. الرهن الذى ينقصه التخصيص يمكن أن يعتبر عقداً صحيحاً يرتب فى ذمة الراهن التزاماً بعمل هو تقديم تأمين عينى للمرتهن، فإذا لم يتم الرهن بتقديم هذا التأمين، وهو الرهن فى الشكل المطلوب من حيث الرسمية والتخصيص، اعتبر مخالفاً بالتزام بعمل التزم به، وألزم بالتعويض، هذا فضلاً عن سقوط أجل الالتزام المراد ضمان الوفاء به.

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الفصل الثانى آثار الرهن

تقسيم:

إذا توافرت شروط انعقاد الرهن الرسمى، ترتبت عليه إثارة فيما بين المتعاقدين. ولكن أهم آثار الرهن تترتب فى مواجهة الغير. ولا يتحقق هذا إلا بالشهر. وسنعرض أولاً آثار الرهن فيما بين المتعاقدين ثم لآثاره بالنسبة للغير.

المبحث الأول

أثر الرهن فيما بين المتعاقدين

عقد الرهن الرسمى إذا نظرنا إليه فى ذاته، يلزم الراهن دون المرتهن فيلزم الراهن بإعطاء حق الرهن، وإذا ما قدم الرهن يلزم بالامتناع عن القيام بأى عمل يكون من شأنه إضعاف هذا التأمين، فيقع عليه التزام بضمان سلامة الرهن.

ولا يترتب على قيام الرهن صحيحاً ونشوء حق عيني للدائن المرتهن على العقار المرهون أى تجرد الراهن من ملكيته لهذا العقار، بل تظل له الملكية، كما تظل له كذلك السلطات التى تخولها من استعمال واستقلال وتصرف، إلا ما يتعارض مع ذلك من التزامه بسلامة الرهن.

وسنعرض أولاً لآثار الرهن بالنسبة للراهن ثم لآثاره بالنسبة للمرتهن.

المطلب الأول

2024/2025

2024/2025

أثر الرهن بالنسبة إلى الراهن

التزامات الراهن وحقوقه:

يلزم الراهن بإعطاء حق الرهن، كما يلتزم - بعد قيام الرهن صحيحاً - بعدم القيام بما يضر بسلامة العقار المرهون حتى لا ينتقص ضمان المرتهن. ونظراً لأن ملكية العقار المرهون تظل للراهن، وبالتالي يثبت له ما تخوله الملكية من سلطات مع عدم الإضرار بحق الدائن المرتهن.

أولاً: التزامات الراهن:

الالتزام بإعطاء حق الرهن:

يلزم الراهن بمقتضى عقد الرهن بإنشاء حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن على العقار موضوع الاتفاق. وهذا الالتزام ينتج أثره فى الحال وبحكم القانون تطبيقاً لنص المادة ٢٠٤ من القانون المدنى التى تقرر أن «الالتزام بنقل الملكية أو حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً



معيناً بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل. ونظراً لأن الرهن الرسمي - كحق عيني تبعي - لا يخضع للتسجيل (حيث يخضع للقيد فقط بالنسبة لأثره في حق الغير). وعلى هذا إذا كان الراهن مالاً للعقار المرهون، وهذا شرط لصحة عقد الرهن، فإن حق الدائن المرتهن ينشأ بمجرد العقد. ولا تتوقف نشأته على أى إجراء لاحق.

والدليل على صحة هذا القول أنه إذا بيع العقار المرهون قبل القيد فإن الدائن المرتهن يستطيع أن ينفذ على العقار المرهون بوصفه دائناً مرتهناً وليس بوصفه مجرد دائن عادى، وهو ما يظهر بوضوح حينما يكون الراهن غير المدين (الكفيل العيني). ففي هذه الحالة ليس للدائن المرتهن إلا أن ينفذ على المال المرهون وبصفته دائناً مرتهناً، ولا يستطيع أن ينفذ على أى مال آخر للراهن، لأن الكفيل العيني تتحدد مسؤوليته بالمال المرهون دون غيره من أموال الضمان العام، وقد ذهب رأى إلى أن المصدر الحقيقي للرهن هو واقعة القيد، أما عقد الرهن فلا يرتب الحق العيني التبعي بما يستتبعه من حق التقدم والتتبع، فمناطق التقدم والتتبع هو القيد، وبغيرها لا فائدة من وجود الرهن^(١) والرأى الأول هو الأرجح فى الفقه، خاصة وأن ما آثاره الرأى الثانى من خلاف ليس له أثر عملى^(٢).

الالتزام بضمان سلامة العقار المرهون وأحكام هلاكه أو تلفه

عرض المشرع لالتزام الراهن بضمان سلامة الرهن فى المادة ١٠٤٧ ثم ٢٠٢٥/٢٠٢٥ فى المادة ١٠٤٨ مدنى أثر ٢٠٢٥/٢٠٢٥ العقار المرهون أو تلفه، سواء بخطأ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ الراهن، حيث تكون بصدد إخلال بالالتزام الضمان أو بسبب آخر وكذلك لحق الدائن فى طلب وقف الأعمال التى من شأنها أن تهدد بهلاك العقار أو تلفه أو تجعله غير كاف للضمان، وأخيراً عرض فى المادة ١٠٤٩ لانتقال حق الدائن المرتهن إلى ما يستبدل بالعقار المرهون فى حالة الهلاك أو التلف.

الالتزام بالضمان :-

تنص المادة ١٠٤٧ مدنى علي أنه " يلزم الراهن بضمان سلامة الرهن وللدائن المرتهن أن يعترض علي كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً ، وله فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية و أن يرجع علي الراهن بما ينفق فى ذلك "

(١) د/ شفيق شحاتة: التأمين العيني، ص ٤٦.

(٢) د/ منصور مصطفى منصور: ص ٦٣، د/ سليمان مرقس: ص ١٢٠، د/ توفيق فرج: ص ١٤٤، د/ سمير تناغو، ص ٢١٦، د/ جمال زكى، ص ٢٥٩.



ومن التعرض المادي أن يقوم الراهن بهدم جزء من العقار ، أو بتجريف الأرض بما ينقص من قيمتها ، أو أن يأتي أي عمل من شأنه تخريب العقار المرهون بصفة عامة ، كأن ينزع الأبواب أو النوافذ أو المفروشات ، كما يدخل في نطاق مسئولية الراهن أن يترك الغير يخرب العقار ماديا ، بأن يتخذ موقفا سلبيا متقاعسا .

أما ضمان تعرض الغير القانوني ، فيقتضي إلزام الرهن بدفع كل إيداع للغير بحق لو ثبت لترتب عليه المساس بحق الدائن المرتهن ، كأن يدعي الغير أنه يملك العقار المرهون ، أو أن له عليه حق انتفاع أو حق ارتفاق إذا كان الرهن قد تم علي هذا أساس عدم وجود مثل هذه الحقوق ، أو أنه هو المالك للمنفولات المخصصة لخدمة العقار إذا كان الرهن قد تم علي اعتبار أنها عقارات

(١) الأعمال التحضيرية للقانون المدني ج ٧، ص ٤٩.

بالتخصيص ، ففي جميع هذه الحالات يتعين على الراهن أن يدفع التعرض الصادر من الغير ، بحيث يتحقق الهدف وهو ضمان سلامة الرهن .

و إذا أخل الراهن بالالتزام السابق بحيث أدى التعرض سواء كان شخصياً أو من جانب الغير إلى إنقاص الضمان إنقاصاً كبيراً ، فإن للدائن المرتهن أن يطالب بإصلاح النقص لبقاء الرهن محققاً لأغراضه ، بأن يلزمه برد الشيء إلى أصله ، أو استبدال أشياء أخرى بالأشياء التي سبق نزعها أو تخريبها .

كما أن المشرع قد خول الدائن في المادة ١٠٤٧ مدنى سلطة اتخاذ الإجراءات التحفظية في حالة الاستعجال ضماناً لعدم تدهور العقار المرهون وتوصلاً إلى الحفاظ عليه ، كأن يطلب تعيين حارس أو أن يستأذن القضاء المستعجل إجراء الترميمات العاجلة واللازمة ، على نفقة الراهن.

ضمان هلاك العقار المرهون أو تلفه:

نصت المادة ١٠٤٨ مدنى على أنه:

١- إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار أو تلفه كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضى تأميناً كافياً أو أن يستوفى حقه فوراً.

٢- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب حتمى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفى بالدين فوراً قبل حلول الأجل وفي حالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصاً منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول أجل الدين.

٣- وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرف العقار المرهون للهلاك أو تجعله غير كاف للضمان كان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.

واضح أن النص السابق يتعرف لحالة هلاك العقار المرهون ، أو تلفه بما لا يفي معه بالهدف المقصود وهو الضمان ففي هذه الحالة لا مناص من الخيار بين أمرين:

أما أن يقوم المدين بتقديم تأمين كاف ، وأما سقوط أجل الدين ووجوب الوفاء به فوراً. غير أن تبني أحد الخيارين يتوقف على سبب الهلاك والتلف وهل هو خطأ الراهن أم أنه بسبب أجنبى.

١- إذا كان سبب الهلاك هو خطأ الراهن فإن الاختيار ينعقد للدائن فله أن يطلب تأميناً كافياً أو أن يطلب استيفاء حقه حالاً ، أى أن يتمسك بسقوط الأجل.

2024/2025 عقار آخر غير العقار الموهون كما في حالة قيام جار بإقامة بناء 2024/2025

قد يستحق الراهن مالاً من الغير بسبب هلاك العقار المرهون، كتعويض ممن تسبب في هلاكه أو مبلغ تأمين إذا كان مؤمناً عليه، أو الثمن الذي يتقرر عند نزع ملكيته للمنفعة العامة. وقد نصت المادة ١٠٤٩ مدنى على أنه «إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان، انتقل الرهن بمرتبه إلى الحق الذى يترتب على ذلك، كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة، أو ثمن الأنقاض أو ثمن المنقولات التى كانت مخصصة لخدمة العقار وباعها الراهن إلى مشتر حسن النية، طالما كان هذا الثمن أو ذاك لم يدفع بعد».

بعد.»

زيد المنعم حسن زيد المنعم حسن

خالد



وانتقال الرهن في هذه الحالة إنما هو تطبيق لنظرية الحلول العينية^(١)، أي أن المال المستحق عن هلاك العقار المرهون أو تلف يحل حلولاً عينياً محل هذا العقار، وحتى يحتفظ المرتهن بحقه على المستحق عن الهلاك عليه أن يخطر المسئول عن دفع هذا المستحق بالرهن، ويطالبه بعدم الوفاء به للرهن، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ثانياً: سلطات الراهن على العقار

تقسيم:

لا يقتضى الرهن تخلي الراهن عن حيازة العقار المرهون، بل يبقى الراهن مالكا للعقار المرهون، وتبقى له حيازته، ويكون له ما تخوله الملكية من سلطات التصرف والاستعمال والاستغلال. ومع ذلك تنقيد هذه السلطات بالحق العيني الذي نشأ للمرتهن على العقار المرهون، بمعنى أن مالك العقار المرهون لا يستطيع إضراراً بحقوق الدائن المرتهن، أن يأتي تصرفاً، قانونياً أو مادياً، يكون من شأنه مباشرة أو بطبيعته نفسها، أن ينقص ضمانات الدائن مساساً بقيمة العقار. فالأصل أن يحتفظ الراهن بحيازة عقاره، وبكل مزايا حق ملكيته، ولا يحد من نشاط إلا بقدر ما يتعارض ذلك النشاط وتحقيق ضمان الدائن المرتهن.

ونبحث على التوالي، أثر الرهن على سلطة التصرف في العقار المرهون، وعلى سلطة استعماله واستغلاله.

2024/2025

١- أثر الرهن على سلطة الراهن في التصرف في العقار^{2024/2025}

تنص المادة ١٠٤٣ مدني على أنه «يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، وأى تصدر يصرف منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن». هذا النص يقرر مبدأ سلطة الراهن في التصرف في العقار المرهون ومن نفس الوقت يحد من هذا التصرف بعدم التأثير في حقوق الدائن المرتهن. والتصرف في العقار المرهون أما أن يكون تصرفاً قانونياً أو تصرفاً مادياً، أما بالنسبة للتصرف القانوني، وهي ما يبدو أن النص يتجه إليها^(٢)، للراهن أن يجري كافة التصرفات القانونية في العقار المرهون بعد أن يقيد المرتهن حقه، كأن ينقل الراهن ملكية العقار المرهون لآخر، بيع أو هبة، أو بنقله بحث عيني آخر كحق انتفاع أو حكر أو ارتفاق أو رهن آخر، ذلك أن أى تصرف قانوني من الراهن لا أثر له في حق الدائن المرتهن طالما قيد رهنه قبل شهر هذا التصرف، لأن القيد يجعل الرهن

(١) د/ السنهوري: الوسيط، ج. ١٠، ص ٣٩١، د/ منصور مصطفى منصور: ص ٦٨.

(٢) د/ منصور مصطفى منصور: ص ٧٢، د/ توفيق: ص ١٤٠.

ويلاحظ أن المادة ١٠٤٣ مدني وهي تجيز تصرفات الرهن في العقار المرهون تقتصر على تصرفاته بعد أن يقيد الدائن المرتهن حقه، لأن تصرفاته قبل أن يقيد المرتهن تعتبر تعرضاً يمس سلامة حق الرهن فيضمنه بمقتضى المادة ١٠٤٣ مدني.

(١) د/ السنهوري: الوسيط، ج ١٠ ص ٢٩٧١، د/ منصور مصطفى، ص ٧٥، د/ توفيق فرج: ص ١٤١، د/ سليمان مرقس: ص ١٣٩، د/ أحمد سلامة: ص.....

(٢) الأعمال التحضيرية ج ٧ ص ٣٩.

(٣) د/ شمس الدين الوكيل: التأمينات، ص ٢٤٩، د/ عبد الناصر العطار: ص ٩٦.

(٤) د/ وديع فرج: أثر الرهن الرسمي في حقوق مالك العقار المرهون. مجلة القانون والاقتصاد س ٧ ص ٢٤١٧.

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن

خالد



إذا كان بناء، أو ينقل منه أثره إذا كان أرضاً، أو ينزع منه ما فيه من عقارات بالتخصيص كآلات المصنع، إن كان نزعها تجاوز لأعمال الإدارة العادية. ويجوز للدائن المرتهن، أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة لوقف إنقاص العقار المرهون، كأن يطلب تعيين حارس فوراً للمحافظة على العقار المرهون، إلا أن المشرع قد قيد حق المرتهن في اتخاذ الوسائل التحفظية بمقتضى المادة ١٠٤٧ منه بأن يكون من شأن العمل «إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً».

٢- سلطة الرهن فى استغلال المرهون

تضمنت هذا الموضوع المواد ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٦ من القانون المدنى حيث عرضت المادة الأولى لحق الرهن فى الإدارة وقبض الثمار، وتعرضت الثانية لحقه فى إيجار العقار ونفاذه، وتعرضت الثالثة لقبض الأجرة والحالة بها ونفاذ ذلك فى حق الدائن، وتعرض لكل من هذه المسائل الثلاث على حدة.

أولاً: حق الرهن فى إدارة العقار وقبض الأجرة

نصت المادة ١٠٤٤ مدنى على أن «للرهن الحق فى إدارة العقار المرهون وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار».

ويضع هذا النص مبدأ سلطة الإدارة، ومن مقتضاها أن الرهن يستقل بها، حيث يجوز له أن يختار وجه الاستغلال المناسب للعقار المرهون، فللرهن أن يحول الأرض الزراعية إلى أرض حدائق، أو إلى أرض للمصانع، أو أن يقيم عليها مبان لأغراض تجارية أو سكنية. أى أن له الحرية فى تحديد وجه الاستقلال ولا تقييد فى هذه الحرية إلا بالقيد العام منعدم الإضرار بالمال المرهون، وإلا اعتبر ذلك إضعافاً للتأمين يستوجب المسؤولية.

ومن مقتضيات سلطة الاستغلال أن يقبض الرهن ثمار العقار المرهون، وعلى هذا يكون للرهن أن يقبض الثمار المدينة ويجنى الثمار الطبيعية، غير أن هذه الملكية محددة زمنياً بحلول أجل معين هو تاريخ تنبيه نزع الملكية، فمن هذا التاريخ تصبح الثمار ملحقه بالعقار المرهون «يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل، ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمار العقار».

ثانياً: حق الرهن فى إيجار العقار:

نصت المادة ١٠٤٥ مدنى على أنه:

١- الإيجار الصادر من الرهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ

على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة، فلا يكون نافذاً إلا إذا أمكن اعتباره داخلاً في أعمال الإدارة الحسنة.

٢- وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن».

ويضع هذا النص قواعد ثلاثة لحكم إيجار الراهن ونفاذه في حق الدائن المرتهن:

القاعدة الأولى: أن الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ أساساً إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. ولكن هذا الإيجار قد يكون ثابت التاريخ ومع ذلك يثبت أنه أبرم إضراراً بالدائن المرتهن وبأجرة بخس، وإذا ثبت ذلك جاز للمرتهن أن يطلب رفع الأجرة إلي الحد المناسب أو أن يتمسك - رغم ثبوت التاريخ- بعدم السريان علي أساس أن الإيجار وقد أبرم غشاً تعين رد غرض الراهن عليه، فلا ينفذ في حق المرتهن (١).

القاعدة الثانية: أن الإيجار غير ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية لا ينفذ في حق الدائن المرتهن كقاعدة عامة علي نحو ما سبق، ولكنه ينفذ إذا أمكن اعتباره من أعمال الإدارة الحسنة (٢). بمعنى أن يكون محدود المدة، و أن يكون قد أبرم بأجرة المثل، و ألا تكون الأجرة قد عجلت إلا في الحدود المألوفة. والشرط الأخير يستهدف منع تحايل الراهن بقبض الأجرة مقدماً علي نحو غير مألوف، بما يضر بمصلحة الدائن المرتهن.

القاعدة الثالثة: أن الإيجار ثابت التاريخ ينفذ في حق الدائن المرتهن علي نحو ما سبق إيضاحه بشرط ألا تزيد مدته عن تسع سنوات، ولا يسري فيما يجاوز التسع سنوات إلا إذا كان مسجلاً.

فقد قرر المشرع أن الإيجار الذي تزيد مدته عن تسع سنوات يثقل العقار بما ينتقص من قيمته الاقتصادية لذلك فرض لنفاذه فيما يجاوز التسع سنوات قيد التسجيل وليس مجرد إثبات التاريخ، بل أن المشرع اشترط حدوث التسجيل لا قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ولكنه اشترط أن يكون عقد الإيجار مسجلاً قبل قيد الرهن.

(١) د/ السنهوري، الوسيط الجزء العاشر ص ٤٠١.

(٢) المادة ١٠٤٥ / ١ مدني / مادة ٤٠٨ مرافعات.

فإن لم يكن مسجلاً قبل قيد الرهن فإنه يسري لمدة تسع سنوات فقط بشرط أن يكون ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . وتحسب المدة من تاريخ العقد في جميع الحالات .

ثالثاً : حق الراهن في قبض الأجرة وحوالتها:-

نصت المادة ١٠٤٦ / مدني علي أن " ١- لا تكون المخالصة بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .

٢- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد علي ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن، و إلا خفضت المدة إلي ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة " .

و قد أجازت المادة ٤٠٩ / مرافعات الاحتجاج بالمخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها " متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات واجبة الشهر ، فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة " . و أوجبت المادة ١١ من قانون الشهر العقاري تسجيل المخالصات و الحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً و إلا كانت غير نافذة في حق الغير مما زاد علي أجرة ثلاث

2024/2025

2024/2025

2024/2025

و يؤخذ من النصوص السابقة أن المخالصة بالأجرة أو الحوالة بها تنفذ في حق الدائن المرتهن ، إذا كانت مسجلة قبل قيد الرهن ، وذلك أياً كانت مدتها ، أي لو زادت علي ثلاث سنوات . فإذا لم تكن المخالصة أو الحوالة بالأجرة مسجلة قبل قيد الرهن ولكنها كانت ثابتة التاريخ مثل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإنها تنفذ في حق الدائن المرتهن لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات من تاريخها .

فإذا لم تكن المخالصة بالأجرة المعجلة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فظاهر نص المادة ١٠٤٦ مدني علي عدم نفاذها في حق الدائن المرتهن، بينما تجيز المادة ٤٠٩ مرافعات الاحتجاج بها لمدة سنة. ولما كان قانون المرافعات قد صد بعد القانون المدني فإن المادة ٤٠٩ مرافعات تنسخ ما يتعارض معها من أحكام المادة ١٠٤٦ مدني. وبالتالي تنفذ المخالصة بالأجرة المعجلة أو الحوالة بها إذا كانت عن أجره سنة حتى لو كانت غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

ثالثاً: سلطة الراهن في استعمال العقار المرهون

أسلفنا أن للراهن سلطة إدارة العقار المرهون واستغلاله، فالرهن لا ينتقص من الملكية. لذلك فإنه من الطبيعي أن يستبقى الراهن سكنه الاستعمال، وبناء على هذا الأساس فإن للراهن مثلاً أن يسكن العقار المرهون إن كان داراً مخصصاً للسكنى، كما له أن يستعمل العقار بما يتفق مع طبيعته والغرض المخصص له.

غير أنه على الراهن أني لتزم في استعماله حدود المحافظة على المال المرهون فلا يأتي من الأعمال ما ينتقص من قيمته، وإلا كان للدائن أن يعترض على أوجه الاستعمال الضارة وله أن يطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، كما أن له أن يطلب وضع العقار تحت الحراسة.

المطلب الثاني

أثر الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن

تمهيد:

للدائن المرتهن أن ينفذ على المال المرهون عند حلول أجل الدين دون الوفاء به، كما أن له أن ينفذ على غير المال المرهون بما له من حق الضمان العام على ذمة مدينه. وعند التنفيذ يتعين إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات. غير أن الراهن قد يكن كفيلاً عينياً، وفي هذه الحالة تقتصر سلطة الدائن المرتهن على المال المرهون دون غيره من أموال الضمان العام. ومن ناحية أخرى فإن سلوك الدائن طريق التنفيذ على العقار المرهون مقيد ببعض المحاذير هي عدم جواز اشتراط أن يمتلك الدائن العقار المرهون عند عدم الوفاء، فضلاً عن بطلان شرط البيع دون إتباع الإجراءات القانونية. ونعرض للمسائل السابقة كل على حدة.

أولاً: حق الدائن في التنفيذ على أموال المدين الراهن

إذا أصبح حق الدائن المرتهن مستحق الأداء كان له التنفيذ على العقار المرهون وقد نصت المادة ١/١٠٥١ مدنى على أن «للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أني نفذ بحقه على العقار المرهون، ويطلب بيعه في المواعيد ووفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات».

ويؤخذ من هذا النص أن للدائن المرتهن بصفته صاحب حق عيني تبعي هو حق الرهن أن ينبه على المدين بالوفاء بدينه عند حلول أجل استحقاقه، فإذا وفاه المدين به انقضى حق الرهن تبعاً لانقضاء الدين المضمون. أما إذا امتنع المدين عن الوفاء أو تأخر فيه بعد حلول أجل استحقاقه جاز للدائن المرتهن



التنفيذ بحقه على العقار المرهون بأن يطلب بيه بالمزاد واستيفاء حقه من ثمنه، يتم ذلك وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون المرافعات. وعادة يقوم الدائن بالتنفيذ بمقتضى عقد الرهن الرسمى نفسه، لأنه ورقة رسمية لا يحتاج معها إلى حكم.

وللدائن المرتهن باعتباره صاحب حق شخصى أن ينفذ بحقه على أموال المدين الأخرى غير العقار المرهون، وله أن يبدأ بها^(١) ويقتسمها مع غيره من الدائنين قسمه الغرماء. غير أنه يبدأ عادة فى التنفيذ على العقار المرهون، لأن له عليه ميزتى التقدم والتتبع فلا يزاحمه فيه الدائنون التالون له فى المرتبة ولا الدائنون العاديون.

- التنفيذ ضد الكفيل العينى - وإذا كان الراهن كفيلاً عينياً، كان للدائن المرتهن، بعد التنبيه على المدين بوفاء دينه المستحق الأداء، الخيار فى التنفيذ على العقار المرهون أو التنفيذ على أموال المدين الأخرى. ولا يملك الكفيل العينى أن يطلب من الدائن المرتهن أن يبدأ بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى قبل التنفيذ على عقار المرهون، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك. كذلك لا يملك الدائن المرتهن أن يقوم بالتنفيذ على أموال الكفيل العينى الأخرى غير العقار المرهون، لأن الكفيل العينى لا يسأل عن الدين إلا فى حدود العقار المرهون. وبهذا نصت المادة ١٠٥٠ مدنى بنصها «إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين، فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا رهن من هذا المال. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك».

2024/2025 2024/2025

وإذا أختار الدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون من الكفيل العينى أعلن التنبيه بنزع الملكية إلى الراهن طالباً ببيع العقار المرهون بالمزاد وفقاً للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات^(٢).

وللكفيل العينى أن يتمسك ضد الدائن المرتهن بالدفع التى تستطيع أن يتمسك بها المدين والتى تودى إلى انقضاء التزامه كالدفع بالوفاء أو المقاصة لأن

(١) سواء كان العقار المرهون يفى بالدين أو لا يفى به، وسواء كانت هذه الأموال أكبر بكثير من حقه أو أقل، على خلاف ما جاء فى المذكرة الإيضاحية ج ٧ ص ٦١. د/ السنهورى، ج ١٠ ص ١٧٤، لأن قانون المرافعات الحالى ألغى ما كان وارداً من القيود فى القانون السابق.

(٢) وتنص المادة ٤٠٩ فقرة أخيره مرافعات على أنه «إذا كان التنفيذ ١ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة ٢٨١ مرافعات، فيتم التنبيه بنزع الملكية وتسجيل التنبيه باسم الكفيل العينى حماية للغير الذى يتعامل فى هذا العقار».



التزامه التزام تابع لالتزام المدين. كذلك للكفيل العيني أن يتفادى إجراءات التنفيذ ضده بالتخلي عن العقار المرهون كما يتخلى على حائز عنه، فقد نصت المادة ٢/١٠٥١ على أنه «إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين، جاز له أن يتفادى أى إجراء موجه إليه، إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار.

ثانياً: بطلان شرط تملك الدائن العقار المرهون أو البيع بغير إجراءات:

يجب للتنفيذ على العقار المرهون أن تتبع الإجراءات التى نص عليها القانون.، وتنص المادة ١/١٠٥١ مدنى على أن للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقاً للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات».

فالدائن المرتهن لا يستوفى إذن حقه من العقار المرهون إلا طبقاً للإجراءات معينة، فتنتهى آخر الأمر إلى بيع العقار جبراً فى المزاد وكل اتفاق على غير ذلك يكون باطلاً لمخالفته عند عدم الوفاء، أو أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التى فرضها القانون، وهو شرط الطريق الممهد، يقع باطلاً.

فإذا كان القانون يستلزم إتباع إجراءات معينة لتنفيذ على العقار المرهون، فإن هذه الإجراءات إنما وضعت لضمان حق كل من الدائن المرتهن والراهن، بما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة، فالإخلال بشئ من ذلك لا يقره القانون، وأنترع منه رضاه فيقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أياً كان، وهذا هو شرط التملك عند عدم الوفاء. كما يقع باطلاً كذلك كل اتفاق يجعل للدائن الحق فى أن يبيع العقار المرهون دون مراعاة للإجراءات التى فرضها القانون وهذا هو شرط الطريق الممهد.

وفى كلتا الحالتين يقع الاتفاق باطلاً، سواء تم فى عقد الرهن ذاته، أم كان هذا الاتفاق قد تم بعد الرهن، مادام أنه قد تم قبل حلول الدين.

أما إذا حل أجل الدين، فقد انعدمت شبهه استغلال الدائن المرتهن لحاجة الراهن، وأصبح هذا على بيئة من الأمر، فيجوز الاتفاق حينئذ، على أن ينزل الراهن للدائن المرتهن عن العقار المرهون وفاء للدين، أو على أن يشتري الدائن العقار بثمن معين أكبر أو أقل من الدين، أو على أن يباع العقار بالممارسة لا بالمزاد العلنى، وقد يكون فى هذه الاتفاقات مصلحة للراهن نفسه، إذ يتجنب المصروفات التى تنجم عن بيع العقار بالمزاد.

وقد نصت على القواعد السابقة المادة ١٠٥٢ مدنى بقولها:

١- يقع باطلاً كل اتفاق يجعل الدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يمتلك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أياً كان، أو فى أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التى فرضها القانون، ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

٢- ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه، الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه.

المبحث الثانى

أثر الرهن بالنسبة إلى الغير

تمهيد:

إذا كان الرهن ينتج آثاره، فى العلاقة بين الدائن المرتهن والراهن بمجرد انعقاده فهو لا ينفذ فى حق الغير إلا بالقيد الذى لا يغنى عنه أن يكون الغير قد علم بالرهن بطريق آخر. هذا فضلاً عن أن هذا القيد أهميته بالنسبة لمن يريد التعامل بشأن العقار المرهون، إذ يستطيع معرفة مدى ما يتحمل به العقار من تكاليف، فيتعامل مع صاحبه وهو على بينة من الأمر. وهذا ما يحققه نظام شهر الحقوق بصفة عامة.

وقبل بيان أثر الرهن بالنسبة للغير، نشير أن هناك فرق بين القيد والتسجيل 2024/2025 2024/2025 فى القانون المدنى وفى قانون الشهر العقارى.

أ - فالقيد إجراء خاص بالحقوق العينية التبعية، بينما التسجيل إجراء خاص بالحقوق العينية الأصلية.

ب - القيد إجراء لنفاذ الحقوق العينية التبعية على الغير (م ١٢ قانون ١٤ لسنة ١٩٤٦، أما التسجيل فهو إجراء لإنشاء الحقوق العينية الأصلية أو تعديلها أو نقلها أو زوالها وذلك فيما بين المتعاقدين بالنسبة إلى الغير.

ج- يتم القيد بنقل بعض بيانات مستخرجة من المحرر المطلوب شهره فى سجل خاص، بخلاف التسجيل فيتم بحفظ المحرر نفسه مع إعطاء صورة مصورة منه.

ومع ذلك يلاحظ أن قانون السجل العينى يجعل القيد إجراء لإنشاء ونقل وزوال الحق العينى الأصلى والتبعية فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير (م ٢٦، ٢٩ من قانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤) فلا يفرق بين القيد والتسجيل. وقد نظم هذا القانون قيد الحقوق العينية التبعية ومن بينها الرهن الرسمى إلا أنه لم يطبق حتى

الآن إلا على عدد محدود من القرى. وعند العمل به يصبح القيد شرطاً لنشوء الرهن إلى جانب شروطه الموضوعية والشكلية حيث نصت المادة ٢/٢٦ منه على أنه «يترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق (العينية العقارية التبعية) لا تكون لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

وبالإشارة إلى ما سبق فإننا سنقتصر في دراستنا على أحكام القيد فى قانون الشهر العقارى، وهى أحكام متعلقة بالنظام العام لحماية للائتمان العقارى. ولهذا لا يجوز التنازل عنها أو الاتفاق على ما يخالفها.

وعلى ذلك سيكون كلا منا فى أثر الرهن بالنسبة للغير عن نفاذ هذا الرهن فى حق الغير (القيد) إذا ما صار هذا الرهن نافذاً فى حق الغير كان للدائن المرتهن أن يفيد من السلطات التى يخولها له القانون من حيث إمكان تتبع العقار فى يد الغير، ومن حيث التقدم على غيره من الدائنين فى استيفاء حقه، وهذا مظهر نفاذه.

المطلب الأول نفاذ الرهن من مواجهة الغير (القيد)

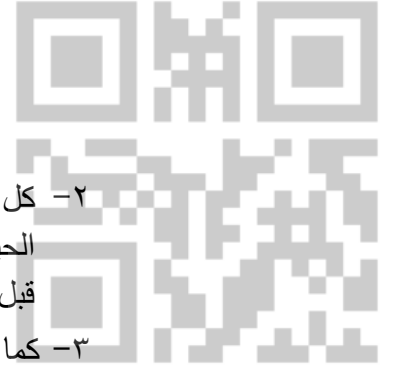
تحديد المقصود بالغير:

تنص المادة ١/١٠٥٣ مدنى «لا يكون الرهن نافذاً فى حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل اكتساب هذا الغير حقاً عينياً على العقار وذلك دون إخلال بالإحكام المقررة فى الإفلاس» كما تنص المادة ١٢ من قانون الشهر العقارى على أنه «يترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير».

وقد يفهم من عبارة النص أن الغير يقتصر على من يكسب حقاً عينياً على العقار، سواء كان الحق أصلياً أو تبعياً، ولكن هذا غير صحيح، فالغير يشمل دون شك الدائن العادى، ذلك أن الغير الذى لا ينفذ الرهن بالنسبة إليه هو كل من يضار من مباشرة الدائن المرتهن للتقدم أو التتبع. وعلى ضوء هذا يشمل الغير^(١).

١- كل من كسب على العقار المرهون حقاً عينياً أصلياً كالملكية أو الانتفاع أو الارتفاق، وهؤلاء لا ينفذ الرهن فى مواجهتهم إلا إذا كان قيده سابقاً على كسبهم لحقوقهم.

(١) السهنورى: الوسيط ج. ١٠، ص ٤٣٦، د/ منصور مصطفى منصور، ص ٨٥. د/ توفيق فرج، ص ١٥٣، وجمال زكى، ص ٢٤١.



- ٢- كل من كسب على العقار المرهون حقاً عينياً تبعياً، كالرهن الرسمي أو الحيازي أو الاختصاص أو الامتياز، وهؤلاء لا ينفذ الرهن إلا إذا كان قد قيل قبل شهر حقوقهم (فيما عدا حقوق الامتياز غير واجه الشهر).
- ٣- كما يشمل الغير الدائن. فلا يستطيع لدائن المرتهن أن يباشر حقه في التقدم في مواجهة الدائنين العاديين إلا إذا كان الرهن مقيداً.

هذا عن الغير في هذا الخصوص، أما لأحكام المتعلقة بالقيد فلم ينظم القانون المدني هذه الأحكام واكتفى بالإحالة بشأنها إلى قانون الشهر العقاري، إذ نصت المادة ١٠٥٤ مدني على أنه «يتبع في إجراءات القيد وتجديده ومحوه وإلغاء هذا المحو والآثار المترتبة على ذلك كله، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري».

ونعرض فيما يلي لإجراء القيد، ثم تجديده، ثم محوه أو شطبه وإلغاء هذا المحو.

أولاً: إجراءات القيد.

القيد هو عبارة عن تدوين بيانات معينة من المحرر الذي يتضمن عقد الرهن في سجل خاص بالشهر العقاري. ولا يكون القيد إلا بالنسبة إلى التصرفات المنشئة أو المقررة للرهن، وكذلك للأحكام النهائية التي يترتب عليها شيء من ذلك، وهو بهذا يجعل حق الدائن يسرى في مواجهة الغير. أما إذا تعلق الأمر بتصرفات وأحكام يترتب عليها نقل الرهن إلى غير المرتهن، مثل حوالة الدين المضمون بالرهن، وحلول الغير محل المرتهن في حقوقه حلولاً قانونياً أو اتفاقياً، والتصرفات والأحكام التي يترتب عليها انقضاء الرهن في ذاته، كالتنازل عنه والتصرفات والأحكام التي يترتب عليها زوال مرتبة كمحو القيد، فإنها لا تشهر بالقيد، ولكن يتم شهرها بالتأشير في هامش القيد الأصلي. فحوالة الحق المضمون بالرهن مثلاً يتم شهرها بالتأشير في هامش القيد الأصلي فإذا لم يحصل هذا التأشير، لا يستطيع من حول إليه الحق التمسك بحقه قبل الغير^(١).

والجهة المختصة بالقيد هي مكاتب الشهر العقاري. ويتم القيد في مكتب الشهر العقاري الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه. فإذا كان الرهن وارداً على عقارات تقع في دوائر مكاتب متعددة أجرى القيد في كل منها بالنسبة للعقار أو العقارات الواقعة في دائرة اختصاص كل مكتب. ولا يكون للقيد الذي يتم في أحد

(١) م ٢/١٠٥٣ مدني، مادة ١٩ من قانون الشهر العقاري.



هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاص هذا المكتب.

ممن و ضد من يحصل القيد:

نص قانون الشهر العقاري على أن إجراءات الشهر تتم في جميع الأحوال، بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم، ويقصد بذوى الشأن في هذا الصدد هو الدائن المرتهن. ولهذا يجب أن يتم القيد بناء على طلب الدائن نفسه. أو من ينوب عنه قانوناً أو إنفاقاً، أو ورثته، كما أن القيد يتم كذلك بناء على طلب دائنى الدائن المرتهن لأنه يعد من الإجراءات التحفظية. ولو كان ناقص الأهلية.

ويقيد الرهن على اسم مالك العقار المرهون وقت الرهن، سواء كان المالك هو المدين أو الكفيل العيني، فإذا مات الراهن قبل إجراء القيد، كان للدائن الخيار بين أن يجرى الرهن على اسم الراهن أو على أسماء الورثة.

والنظام المتبع عندنا في شأن الحقوق عموماً والذي لا زال قائماً هو النظام الشخصى، حيث يجرى القيد على أسم التصرف. فإذا أريد معرفة ما يتحمل به العقار من تكاليف، يطلب من مكاتب الشهر، بيان الحقوق التي ترتبت على العقار من المالك الحالى والمالكين السابقين خلال عشر سنوات على الأقل، ومن المحتمل أن يقع خطأ في هذه البيانات. فقد يغفل ذكر قيود موجودة فعلاً، ثم يتعامل مع صاحب العقار بظهورها وبذلك يتأثر حقه بوجودها.

2024/2025

ولتلافى ذلك أخذت بعض البلاد ومنها مصر بنظام السجلات العينية أو الشهر العيني حيث يخصص لكل عقار صفحة من السجل العقاري تدون فيها جميع التصرفات التي ترد على العقار فيسهل بذلك معرفة ما يتحمل به من تكاليف، ويقل احتمال الخطأ، وأن كان القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ قد أنشئ نظام السجل العيني ولكن لم يبدأ العمل الفعلى به.

متى يتم القيد:

يجوز إجراء القيد في أى وقت بعد إنشاء الرهن، حتى ولو كان الدين المضمون مستقبلاً أو احتمالياً، أو معلقاً على شرط. ولكن الغاية منه لن تتحقق إلا إذا تم قبل أن يخرج العقار من ملكية الراهن، وقبل أن يترتب عليه حق عيني آخر تم قيده على الوجه الصحيح، ذلك أنه إذا تصرف الراهن في العقار أو رتب عليه حقاً آخر وسجل المتصرف إليه أو قيد بمن اكتسب الحق حقه قبل أن يقوم الدائن المرتهن بالقيد، لا يستطيع هذا الأخير تتبع العقار في يد المتصرف إليه، ولا تكون له أفضلية على أصحاب الحقوق الأخرى المقيدة.

وإذا كان الأصل أن القيد يصح في أى وقت بعد الرهن ويترتب عليه أثره، طالما أنه لم يحصل تصرف في العقار وطالما أن الغير لم يكتسب حقاً عيناً عليه، إلا أن القانون يستثنى من ذلك:

١- حالة الإفلاس، فقد نصت المادة ٢٣١ تجارى على أن «حقوق الامتياز والرهن العقارى المكتسبة من المفلس على الوجه المرعى قانوناً، يجوز تسجيلها إلى يوم صدور الحكم بإشهار إفلاسه».

وعلى ذلك لا يصح قيد الرهن بعد الحكم بشهر إفلاس مالك العقار وإذا قيد الرهن بعد هذا التاريخ لا يسرى الرهن فى حق جماعة الدائنين، لأنها تعتبر من الغير بمجرد صدور حكم الإفلاس، فلا تتأثر بالحقوق التى لم تشهر من قبل، وفى هذه الحالة لا يكون للدائن صاحب الرهن إلا التقدم كدائن عادى. وهذا الحكم يسرى فقط بالنسبة للقيد ولا يسرى بالنسبة لتجديد القيد، إذ يصح التجديد بعد حكم الإفلاس لقيد سابق على هذا الحكم، لأن تجديد القيد إجراء يقصد به حفظ قيد سابق تم وترتب عليه أثره من قبل.

القيود فى فترة الريبة: إذا كان القيد يصح إلى حين شهر الإفلاس على النحو السابق، فإن القانون يجيز الحكم ببطلان القيد إذا حصل خلال فترة الريبة. إذ بعد أن نصت المادة ٢٣١ تجارى على ما سبق أضافت «ومع ذلك يجوز الحكم ببطلان ما يحصل من تسجيلات بعد وقت وقوفه عن دفع ديونه أو فى ٢٥ يوماً من هذا الوقت ٢٥ يوماً من خمسة عشر يوماً بين 2024/2025 تاريخ عقد الرهن العقارى أو الامتياز، وتاريخ التسجيل (القيد). ويزاد على المدة المذكورة الميعاد المحدد فى القانون لمسافة الطريق بين الجهة التى اكتسب ذلك الحق والجهة التى حصل منها التسجيل».

وعلى ذلك يجوز الحكم ببطلان القيد حتى قبل صدور حكم شهر الإفلاس إذا تم خلال فترة الريبة أى من وقت التوقف عند الدفع أو فى الأيام العشرة التى تسبق هذا الوقت، بشرط أن تتقضى مدة تزيد على ١٥ يوم بين تاريخ عقد الرهن وتاريخ إجراء القيد مضافاً إليها مواعيد المسافة^(١). والحكم السابق خاص بالتجار فقط متى كان الراهن تاجراً. فإذا كان الراهن غير تاجر، فإن قيد الرهن يصح فى أى وقت حتى ولو بعد إشهار الإعسار ما دامت الملكية لم تنتقل من الراهن، وطالما كان الرهن نفسه قد تم قبل تسجيل صحيفة دعوى الإعسار (م ٢٥٧ مدنى).

(١) قارن د/ السنهورى ج ١٠ ص ٤٥٥ حيث يرى أن على القاضى أن يحكم ببطلان القيد فى هذه الحالة، لرجحان فكرة التواطؤ بين الراهن والدائن المرتتهن.

٢- ويستثنى القانون كذلك من قاعدة جواز حصول القيد فى أى وقت مادامت ملكية العقار للراهن، حالة التنفيذ على العقار المرهون. ويقضى قانون المرافعات بأنه إذا أشهر الراهن بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية لا ينفذ فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين، ولا فى حق الدائنين المقيد حقوقهم قبل تسجيل التنبيه، ولا فى حق من حكم بإيقاع البيع عليه (م ٤٠٥ مرافعات).

هاتان هما الحالتان اللتان لا يصح فيهما قيد الرهن، وفيما عدا ذلك يصح القيد طالما بقيت الملكية للراهن، وإذا مات قبل إجراء القيد، أمكن إجراؤه فى مواجهة الورثة، وبذلك يتقدم المرتب على دائنى التركة.

إجراءات القيد:

أورد قانون الشهر العقارى تفاصيل طويلة فى هذا الصدد يمكننا إنجازها فيما يلى:

يقوم طالب القيد بتقديم طلب مستوف لبيانات نص عليها القانون إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة. وتقوم المأمورية بتدوين الطلب حسب تاريخ وساعة تقديمه فى دفتر أسبقية طلبات الشهر، ثم تفحص وترسل للجهة الهندسية المختصة للتثبت من صحة البيانات الواردة بشأن العقار من حيث المساحة والحدود. وإذا انتهت المأمورية إلى قبول الشهر أعادت صورة من الطلب إلى مقدمه مؤشراً عليها بصلاحيته للشهر.

2024/2025 ثم يعود طالب القيد ثانية 2024/2025 ويقدم مشروع عقد الرهن نفسه ومعه النسخة 2024/2025 المؤشر عليها إلى المأمورية التى تقيد المشروع فى دفتر استيفه مشروعات المحررات بحسب تاريخ وساعة وروده. وبعد أن تتثبت المأمورية من مطابقة البيانات الواردة فى مشروع المحرر للبيانات فى طلب القيد، تؤشر عليه بما يفيد صلاحيته للشهر، ثم تعيد هذا المشروع إلى الطالب. وهنا تنتهى المرحلة الأولى التمهيدية فى مأمورية الشهر.

بعد ذلك يقوم طالب القيد بتقديم عقد الرهن المؤشر على مشروعه بالصلاحيه للشهر إلى مكتب الشهر العقارى المختص، ويرفق معه قائمة تشمل على بيانات معينة مطابقة لما ورد فى عقد الرهن نفسه، وتقدم هذه القائمة من نسخة أصلية محررة بمداد أسود على ورق خاص يطلب من مكاتب الشهر.

ويقوم مكتب الشهر بإثبات البيانات الواردة فى القائمة فى دفتر الشهر برقم متتابع بحسب أسبقية تقديمها مع ذكر تاريخ اليوم والساعة. وهذا الرقم هو الذى يقرر أسبقية القيد. وتسلم صورة فوتوغرافية من القائمة للطالب، وتحفظ الأخرى بالمكتب الرئيسى للشهر.

تشتمل قائمة القيد التى ترفق بعقد الرهن على البيانات الآتية:

- ١- اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل إقامته ومحله المختار فى دائرة المحكمة فإن لم يختار له محلاً صح إعلان الأوراق إليه فى قلم كتاب المحكمة.
- ٢- اسم المدين أو المالك الذى رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
- ٣- تاريخ السند والجهة التى أقامها أو صدر منها، ويقصد بهذا تحديد عقد الرهن أو الحكم الذى قضى به تنفيذ العقد الوعد بالرهن الذى تم فى الشكل الرسمى وذلك للتأكد مما إذا كان صحيحاً أو باطلاً.
- ٤- مصدر الدين المضمون ومقداره كاملاً وميعاد استحقاقه.
- ٥- تعيين العقار الذى رتب عليه الحق تعييناً دقيقاً.

هذه هى البيانات الواجب ذكرها فى قائمة القيد، ويتبين منها أنه يجب ترخيص الرهن كذلك فى القائمة سواء من حيث الدين المضمون أو من حيث العقار المرهون، وهذا البيان لازم لا يغنى عنه التخصيص فى عقد الرهن ذاته. ذلك أنه إذا كان التخصيص فى العقد لازماً لصحة الرهن ذاته، فإن التخصيص فى قائمة القيد لازم لسريان الرهن فى مواجهة الغير.

الجزاء على تخلف البيانات المشترطة فى قائمة القيد:

2024/2025 لا يترتب على إغفال بيان 2024/2025 من البيانات السابقة بطلان القيد بقوة القانون، ولكن يلزم أن ينتج عن هذا الإغفال ضرر للغير. فإذا لم يترتب أى ضرر، فلا يكون للغير أن يتمسك ببطلان القيد. فإذا لم يذكر فى القائمة مثلاً لقب الراهن أو صناعته، ولم يثر أى شك حول تحديد ذاتيته فلا يكون هناك ضرر وبالتالي لا يصح التمسك بالبطلان. وعلى من لحقه ضرر بسبب إغفال بيان من البيانات أو بسبب عدم ضبطها أن يطلب بطلان القيد أو يطلب إنقاص أثره. ويقع عليه إثبات ما لحق من ضرر.

وللمحكمة سلطة تقديرية، فمتى ثبت لديها الضرر، يكون لها - متبعاً لطبيعة الضرر ومداه - أن تبطل أثر القيد أو تنقص من هذا الأثر. فإذا لم تؤد البيانات المتعلقة بالراهن مثلاً إلى تحديده، تحديداً كافياً، وتعامل معه الغير على اعتبار أنه غير الراهن، كان لها أن تبطل القيد. وإذا كان الدين المضمون ١٠٠.٠٠٠ ألف جنيه وذكر فى القائمة أنه ١٠٠٠ فقط فإنها تنقص أثر القيد فلا يسرى على الغير إلا فى حدود ١٠٠٠ فقط وتطبيقاً لهذا ينص قانون الشهر على أن أثر القيد يقصر على المبلغ المبين بالقائمة أو المستحق أيهما أقل.

وإذا وقع القيد صحيحاً رتب أثره من حيث جعل الرهن سارياً على الغير، وتخويل المرتهن سلطاته قبلهم من حيث التتبع والأفضلية. وإذا أبطل القيد، فلا يترتب على ذلك إلا باعتباره كأن لم يكن، ولكن يظل الرهن نفسه قائماً بين التعاقدين، ويمكن قيده من جديد، ويأخذ مرتبته من القيد الجديد متى تم صحيحاً.

وعلى العكس من ذلك لو كان القيد صحيحاً والرهن باطلاً، فلا يصح القيد على أنه ينبغي لكى يترتب على القيد أثره أن يتم فى وقت مناسب، ويكون ذلك طالما بقيت ملكية العقار فى يد الراهن. أما مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن، ما لم يتفق على غير ذلك (م ١٠٥٥ مدنى).

ثانياً: تجديد القيد ومحوه:

نصت المادة ٤٣ من قانون الشهر العقارى على أنه «يسقط القيد إذا لم يجدد فى خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه، على أن للدائن أن يجرى قيداً جديداً أن أمكن ذلك قانوناً تكون مرتبته من وقت إجرائه، وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذى أجرى فيه.

وعلى ذلك إذا بقى الرهن أكثر من عشر سنوات، فيلزم تجديد قيده كل عشر سنوات، لأن قيد الرهن يسقط فلا ينتج أثره إذا لم يجدد فى خلال عشر سنوات من تاريخ إجراء التجديد كما أن لقاضى التوزيع أن يقضى به من تلقاء نفسه غير أنه إذا لم تسبق أثارته أمام محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض^(١).

2024/2025

2024/2025

ويرجع استلزام تجديد قيد الرهن إلى اعتبارين أحدهما تيسير البحث عن الحقوق العينية التبعية المتعلقة بالعقار فى ظل نظام الشهر الشخصى حيث لا تخصص صحيفة للعقار تبين بها حالته. ويتعين البحث عن اسم الراهن وورثته وعندئذ ينبغي أن يقتصر البحث على مدة زمنية قدرها القانون بعشر سنوات، وإذا لم تحدد هذه المدة فإن الأمر قد يستدعى البحث عن حالة العقار خلال أكثر مكن عشر سنوات، وهو أمر ضاق ومعوق للإجراءات، وهذا سوف يتلافى إذا طبق نظام الشهر العينى.

والاعتبار الثانى حماية الملكية العقارية، ذلك أنه إذا أنقضى الدين وأهمل صاحب الشأن فى شطب قيد الرهن، ظهر العقار فى سجلات الشهر العقارى مثقلاً بالرهن حتى يسقط القيد بمضى عشر سنوات على إجرائه، فسقوط القيد يغنى عن شطبه فى الحالات التى ينقضى الرهن فيها.

(١) نقض مدنى ١٩٧٥/٢/١، مجموعة الأحكام س ٢٦، ص ١٦٠٦.



وهناك فرق بين قيد الرهن وتجديده، فقيد الرهن يعطى الدائن المرتهن مرتبته، أما تجديد القيد فهو استمرار للقيد السابق يحفظ مرتبته وذلك إذا أجرى القيد في ميعاده، فإذا فات ميعاد التجديد دون أن يتم فإن القيد يسقط، وعندئذ إذا أعيد القيد مرة أخرى أى بعد سقوطه لم يكن تجديداً وإنما يكون قيداً جديداً فتحتسب مرتبته من وقت إجرائه. وتحتسب مدة العشر سنوات بالتقويم الميلادى وفقاً للقواعد العامة (م ٣ مدنى) ويسرى هذا الميعاد ابتداء من اليوم التالى لإجراء القيد، ويحتسب اليوم الأخير منه ولو كان عطلة رسمية.

إجراءات التجديد:

يقوم بالتجديد من له طلب قيد الرهن، وإذا كان الدين المضمون قد حل، قام المحال إليه بالتجديد. ويقدم طلب التجديد إلى مكتب الشهر العقارى المختص، وهو الذى تم فيه القيد الأسمى، ويحسن أن تذكر البيانات الواجبة فى القيد، كما يذكر كذلك أنه حاصل لتجديد قيد سابق تم من تاريخ معين.

وإذا تكرر التجديد تجب الإشارة إلى القيد السابق. فإذا لم يذكر أنه تجديد لقيد سابق، بطل هذا باعتباره تجديداً، وإن أمكن اعتباره قيداً جديداً متى كانت شروط القيد من جديد متوافرة فى هذا الوقت على أن تحتسب مرتبة القيد من هذا التاريخ.

ثالثاً: محو القيد وإلغاء المحو

2024/2025 محو القيد أو شطبه يعنى التأسير على 2024/2025 هامش القيد بما يقيد رفعه، ويقصد 2024/2025 من المحو رد اعتبار العقار وإظهاره بدون التكاليف التى كان يتحمل بها، فيسترد قيمته الائتمانية. ويمحى القيد:

(أ) - لسبب يرجع إلى الدين المضمون، كما لو انقضى هذا الدين ينقضى الرهن تبعاً له ولا يكون لقيد جدى.

(ب) - السبب يرجع إلى الرهن، كما لو كان الرهن باطلاً أو قابلاً للإبطال وقضى بطلانه، أو قضى بزواله لتحقيق الشرط الفاسخ ولو بقى الدين، فعندئذ لا جدى كذلك من بقاء القيد.

(ج) - أو لسبب يتعلق بالقيد، كما لو كان غير صحيح فيجب محوه.

(د) - أو لرغبة الدائن المرتهن فى رفع القيد مع بقاء الرهن لتمكين الراهن من الحصول على ائتمان جديد.

وللمحو صورتان: محو اختياري ومحو قضائي، فقد نصت المادة ٤٥ عقارى على أنه «لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائى أو برضاء الدائن

بتقرير رسمي منه. ومع ذلك يكتفى في إجراء المحو في حالة رهن الحيابة العقارى وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفى مصدق على التوثيق فيه.

المحو القضائى: ويكون في الحالات التى لا جدوى فيها من القيد لسبب يرجع إلى الدين المضمون أو إلى الرهن أو إلى القيد ذاته، حيث يجوز لكل ذى مصلحة كالراهن^(١) أو مشتري العقار الذى سجل عقده أو دائن مرتته متأخر أو دائن عادى أن يطلب من القضاء محو القيد. وترفع الدعوى إلى المحكمة الكائن بدائرتها العقار المرهون، وينعقد نصابها بسبب مقدار الدين المضمون بالرهن، كما ترفع ضد الدائن المرتته أو ضد خلفائه، ولا ترفع ضد المدين وحده ولا ضد أمين الشهر العقارى.

ولا يجوز المحو إلا إذا صدر الحكم به وأصبح نهائياً لا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية وإن جاز الطعن فيه بالطرق غير العادية.

المحو الاختيارى: فيتم برضاء الدائن مفرغاً في تقرير رسمي، أى يتم بإرادة الدائن المنفردة، دون حاجة إلى قبول الراهن، أو برضاء من ينوب عن الدائن المرتته كوكيله أو وصيه، أو برضاء ورثته جميعاً إلا إذا حصلت القسمة بينهم فيكون برضاء من وقع الدين المضمون في حصته، أو برضاء المحال إليه الدين المضمون.

ويشترط أن يكون هذا الرضا صادراً من أهل لذلك، والأهلية المطلوبة هي الأهلية^{2024/2025} للتصرف في الدين المضمون^{2024/2025} فإذا كان سبب رفع القيد يرجع إلى استيفاء الدين كانت الأهلية المطلوبة هي أهلية مباشرة الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، وإذا كان سبب رفع القيد لا يرجع إلى استيفاء الدين أى كان تبرعات كانت أهلية المطلوبة هي أهلية الأعمال الضارة ضرراً محضاً، كما يشترط أن يصدر الرضا خالياً من العيوب، وأن يفرغ كذلك في محرر رسمي وإلا كان باطلاً.

وطريقة المحو هي التأشير على هامش قيد الرهن بما يفيد رفعه، ويتولى مكتب الشهر العقارى الذى حصل فيه قيد الرهن هذا التأشير مع الإشارة إلى سند رفع القيد أى الحكم النهائى الصادر بالمحو أو رضاء الدائن أو من ينوب عنه إذا أفرغ في محرر رسمي وتاريخ ذلك. ويجوز محو قيد الرهن جزئياً، وذلك إذا دفع للدائن المرتته جزء من الدين واتفق الراهن معه على تخليص بعض العقار من الرهن، ويؤشر بالمحو الجزئى على هامش القيد بما يفيد ذلك.

(١) د/ السنهورى: الوسيط، ج ١٠ ص ٤٨٤، د/ توفيق فرج: ص ١٦٢.

(٢) د/ السنهورى: الوسيط، ج ١ ص ٤٨٥، د/ جمال الدين زكى: ص ٢٤٥.

ويترتب على محو القيد رفعه أى زوال أثره بالتالى، فلا ينفذ فى حق الغير، لكن الرهن ذاته أو انقضاء الدين المضمون أو تنازل الدائن المرتهن عن الرهن، ويجب أن يكون هذا التنازل واضحاً لأنه عند الشك يفسر لصالحه فيقتصر على التنازل عن القيد لا عن الرهن.

إلغاء المحو:

يجوز إلغاء المحو وذلك إذا ألغى الحكم النهائى الصادر بالمحو نتيجة الطعن فيه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر، أو حكم ببطلان المحو الاختيارى لعيب شاب رضاء من قام به أو لنقص فى أهليته أو لعدم إفراغه فى محرر رسمى أو لصدوره من غير ذى صفة.

ولا يتم إلغاء المحو إلا إذا صدر حكم ضد الراهن من المحكمة الكائن بدائرتها العقار وأصبح هذا الحكم نهائياً، وتأشّر بهذا الحكم فى هامش القيد الذى أشّر عليه بالمحو. ويتم هذا التأشير بواسطة مكتب الشهر العقارى الذى أجرى المحو، وذلك بناء على طلب ذى المصلحة مع الإشارة إلى الحكم الصادر بإلغاء المحو. وتكون مصروفات إلغاء المحو على الراهن، ما لم يتفق على غير ذلك، وهى مضمونة بالرهن لأن إلغاء المحو بمثابة قيد وتجديد للقيد.

فإذا ألغى المحو، فهل يعود الرهن إلى مرتبته السابقة بالنسبة للغير فيعتبر إلغاء المحو بمثابة تجديد للقيد، أم لا يحتج على من كسب حقاً على العقار المرهون بعد المحو بهذا الإلغاء، فيعتبر إلغاء المحو بالنسبة له قيداً جديداً. 2024/2025 2024/2025

فى الحل الأول لا يضار الدائن المرتهن الذى محى قيد رهنه دون حق وفى الحل الثانى لا يضار الغير الذى أطمأن إلى محو القيد كما تتوافر الثقة فى سجلات الشهر العقارى لا تضار حركة الائتمان، وقد حاولت المادة ٤٦ من قانون الشهر العقارى الجمع بين الحالتين فنصت على أنه «إذا ألغى المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية. ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالنسبة للقيد والتسجيلات التى أجريت فى الفترة ما بين المحو والإلغاء».

وعلى ذلك يترتب على إلغاء المحو أن تعود للرهن مرتبته الأصلية فى مواجهة من كان الرهن سارياً فى حقهم قبل المحو فيعتبر إلغاء المحو فى هذه الحالة بمثابة تجديد للقيد، أما من اكتسب حقاً بعد المحو وقبل إلغائه فلا يكون لإلغاء المحو أثر رجعى بالنسبة له ويعامل كما لو كان المحو موجوداً، فيعتبر إلغاء المحو فى هذه الحالة بمثابة قيد جديد فإذا كان العقار قد بيع بعد المحو وسجل البيع قبل إلغاء المحو، فلا جدوى من إلغاء المحو، لأنه لن يجعل الرهن نافذاً فى حق المشتري ولا يستطيع صاحبه أن يتتبع العقار المرهون فى يده.



أما بالنسبة للدائنين المرتهنين الآخرين فلا صعوبة في تطبيق هذه القاعدة إذا كان ثمن بيع العقار كافياً لوفاء جميع الديون.

المطلب الثانى

حق التقدم وحق التتبع

تقسيم:

ينتج الرهن آثاره الجوهرية فى مواجهة الغير، الذى يكون إما دائناً عادياً، أو دائناً ذا حق مقيد على العقار المرهون، يتأثر بميزة التقدم، وإما شخصاً انتقلت إليه ملكية العقار المرهون، يسمى الحائز، يتأثر بميزة التتبع. وعلى ذلك ينقسم هذا المطلب إلى جزئين، الأول فنخصصه لميزة التقدم، ونكرس الثانى لميز التتبع.

أولاً: حق التقدم:

يتمتع الدائن المرتهن فى كل الأحوال بميزة التقدم، سواء باشر إجراءات التنفيذ على العقار المرهون فى مواجهة الراهن، أم باشر هذه الإجراءات بعد تتبع العقار، فى مواجهة الحائز، أو فى مواجهة الحارس الذى يتخلى له هذا الأخير عن العقار المرهون. على أن يستلزم لمباشرة ميزة التقدم أن يكون الرهن مقيداً.

وتفترض ميزة التقدم تنازاعاً بين الدائن المرتهن ودائنين آخرين للمدين ويقتضى البحث فيها تحديد معنى التقدم الذى يخوله الرهن للدائن المرتهن، والمال الذى يقع عليه ميزة التقدم، والحق الذى يتقدم به الدائن المرتهن.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

معنى التقدم:

تحدد معنى التقدم فى المادة ١٠٥٦ مدنى «يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذى حل محل هذا العقار، بحسب مرتبة كل منهم، ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد ويتضمن المبدأ الوارد فى المادة ١٠٥٦ قاعدتين بحسب ما إذا كان التنازع قائماً بيد الدائن المرتهن ودائنى عاديين، أو بين دائنين مرتهنين متعددين.

القاعدة الأولى: إذا تنازع الدائن المرتهن مع دائنين عاديين للراهن، كان للدائن المرتهن فى استيفاء حقه، أولوية على هؤلاء الآخرين أجمعين، مهما كان تاريخ ترتيب حقوقهم فى ذمة المدين، بحيث لا ينالون شيئاً من ثمن العقار المرهون إلا بعد أن يستوفى المرتهن كل حقه منه. وهذا هو الأثر الجوهرى لميزة التقدم.





فإذا تعدد الدائنون المرتهنون، يتأخر عنهم الدائنون العاديون، بحيث لا يقسم هؤلاء الآخرون فيما بينهم، إلا ما يتبقى من ثمن العقار المرهون بعد أن يستوفي الدائنون المرتهنون جميع حقوقهم منه.

القاعدة الثانية: إذا تعدد الدائنون المرتهنون، فضل في التنازع بينهم على ثمن العقار المرهون بحسب «مرتبة كل منهم»، كما يحددها قيد رهونهم، بحيث يكون ترتيبهم في استيفاء حقوقهم من ثمن العقار المرهون وفق ترتيب قبودهم، دون اعتبار لتاريخ عقد الرهن، «فيتقدم الأسبق قيداً على من يليه في ترتيب القيد ولو كان تاريخ عقده متأخراً عن عقود الآخرين وقد أكد المشرع هذه القاعدة في المادة ١٠٥٧ «بحسب مرتبة الرهن من وقت قيده».

ولا يستلزم، لتطبيق هذه القاعدة، أن يقع قيد الرهن في أيام مختلفة بل تطبق ولو أجرى قيد الرهن في يوم واحد حيث تحدد مرتبة كل منها بحسب ساعة قيده.

وتحتسب مرتبة الرهن من وقت قيده حتى ولو كان الدين المضمون بالرهن معقلاً على شرط، أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً (م ١٠٥٧) وإذا كان المشرع قد بين في هذه الصدد مرتبة الرهن وحددها بوقت القيد. فإنه لم يتعرض لما قد يثيره كيفية مباشرة التقدم عند توزيع الثمن أو المال الذي حل محل العقار قبل أن يتحقق الشرط أو قبل أن يوجد الدين المستقبلي^(١).

2024/2025 وإذا كانت مرتبة الرهن تتحدد بوقت القيد، فإن المشرع قد خرج على هذا 2024/2025 بالنسبة لحالة ما إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزاً منه، ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها، إذ ينتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان. متى قيد خلال ٩٠ يوماً على النحو الذى بينه القانون. إنما لا يضر انتقال الرهن على هذا النحو بالرهن الصادر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين (م ١٠٣٩ مدنى).

وإذا كان التزام بين الدائن المرتهن وأصحاب حقوق الاختصاص والرهن الحيازي فإن الأفضلية تكون كذلك للأسبق في القيد. أما التزام بينه وبين أصحاب حقوق الامتياز فإن الأمر يختلف بحسب نوع الامتياز. فحقوق الامتياز العامة لا تخضع لإجراء القيد ويتقدم أصحابها على الدائنين المرتهنين، أما حقوق الامتياز الخاصة العقارية فإنها تخضع للقيد ويرتب أصحابها كالدائنين المرتهنين حسب تواريخ القيد.

(١) د/ منصور مصطفى منصور: ص ١٠٨، د/ جمال زكى: ص ٢٨٢.



موضوع التقدم:

يباشر الدائن المرتهن حقه فى التقدم على ثمن العقار المرهون وما يشملته الرهن بصفة عامة، أى على مشتملات الرهن، وذلك إذا بيع ما يشملته الرهن. كما يباشر الدائن المرتهن حقه فى التقدم كذلك على المبالغ التى تحل محل العقار مثل مبالغ التأمين والتعويض، وذلك تطبيقاً لقاعدة الحلول العينية. وقد قضت المادة ١٠٥٦ على هذا بقولها «يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون، أو من المال الذى حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم، ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحداً.

ويتقدم الدائن المرتهن فى استيفاء حقه الأصلي المضمون بالرهن أو ما بقى له من هذا الحق. كما يتقدم كذلك بالنسبة للملحقات حقه التى يضمنها القيد الأصلي. وهذه الملحقات تشمل:

- ١- **المصرفوات:** ويقصد بها مصرفوات عقد الرهن والقيد والتجديد وتتص المادة ١/١٠٥٨ مدنى على أنه «يترتب على قيد الرهن إدخال مصرفوات العقد والقيد والتجديد إدخالاً ضمناً فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها». ذلك أن القانون يقضى فى هذا الصدد بأن المصرفوات أصلاً على الراهن^(١)، فإذا دفعها الدائن كان له الرجوع بها على الراهن، ويضمنها القيد الأصلي حتى ولو لم تذكر فى القائمة، أى أنها تدخل فيما يضمنه الرهن بقوة القانون ولها

2024/2025

2024/2025

2024/2025 مرتبة الرهن.

وفيما عدا ما ذكر من مصرفوات أو ملحقات «كشروط جزائى أو تعويض» فلا يضمنها الرهن إلا إذا ذكرت صراحة فى القيد الأصلي، وإلا لابد من إجراء قيد خاص بها وتكون مرتبتها من تاريخ قيدها.

- ٢- **الفوائد:** نصت المادة ٢/١٠٥٨ مدنى على أنه «إذا ذكر سعر الفائدة فى العقد، فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين، وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية، والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزداد، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضماناً لفوائد أخرى قد استحققت، والتى تسحب مرتبتها من وقت إجرائها. وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائل الدائنين بهذا التسجيل.

(١) المادة ٢/١٠٣١، المادة ١٠٥٥.

فالفوائد التي تستحق عن الدين المضمون، يضمنها القيد الأصلي، بقوة القانون، وتستوفي بالتقدم في مرتبة الرهن نفسها هي:

أ - فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية، متى ذكر في عقد الرهن أن الدين منتج لفوائد وسعر الفائدة. فإذا لم يذكر ذلك في العقد لا يضمنها القيد.

ب- الفوائد التي تستحق بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم رسو المزداد وذلك متى كان قد ذكر أن الدين منتج لفوائد وسعر الفائدة في عقد الرهن. وفي الحاليتين السابقتين إذا قام أحد الدائنين بتسجيل تنبيه نزع الملكية استناد الدائنين بهذا التسجيل.

هذه هي الفوائد التي يضمنها القيد بقوة القانون، وهو يضمنها حتى ولو لم تذكر في قائمة القيد. أما عدا ذلك من فوائد فلا يضمنها القيد بقوة القانون، بل يتعين بالنسبة لها إجراء قيد خاص، وتكون مرتبتها من وقت قيدها، بشرط أن تكون قد استحققت.

نزول الدائن المرتهن عن مرتبته:

قد ينزل الدائن المرتهن عن مرتبته لدائن آخر مقيد على العقار نفسه، وقد وضع المشرع حكم هذا النزول في المادة ١٠٥٩ التي تنص «للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبه رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن لآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً للتنازل عن المرتبة».

هذا النص يعرض للنزول عن مرتبه الرهن، وهو يفترض في النزول عن مرتبه الرهن تعدد الدائنين المرتهنين للعقار، ينزل دائن متقدم عن مرتبة لدائن مرتهن آخر متأخر عنه، فلا يجوز النزول لدائن عادي لأن الفرض أن النزول يكون عن المرتبة وحدها فلا يشمل الرهن، وتدل عبارة النص أن النزول لا يكون إلا لدائن مرتهن مقيد^(١).

ويختلف سبب نزول الدائن عن مرتبته بحسب الأحوال، فقد يكون النزول بمقابل يحصل عليه من ينزل عن مرتبة ممن يكون النزول لصالحه، وقد يكون

(١) يرى البعض إمكان التنازل في غير حالات الرهن الرسمي، لصاحب حق الاختصاص، والمرتهن حيازياً، وصاحب الامتياز الخاص العقاري، سواء حصل النزول عن المرتبة منه أو لصالحه، وذل لاتخاذ العلة في هذه الحقوق جميعاً. د/ عبد الفتاح عبد الباقي: ص ٤٨٢.

النزول على سبيل التبوع. وإذا كان المشرع قد أجاز هذا النزول فيجب ألا يترتب عليه ضرر للدائنين الذين في مرتبة وسطى بين الممتاز والمنتازل إليه. فإذا كان (أ) في المرتبة الأولى، (ب) في المرتبة الثانية، و (ج) في المرتبة الثالثة، ثم نزل (أ) عن مرتبة رهنه إلى (ج) فيجب ألا يضر ذلك بمركز (ب). ويترتب على ذلك (١).

١- أن النزول لا يكون إلا في حدود دين الممتاز، فإذا كان دين (أ) ١٠٠٠ جنيه ودين (ج) ١٥٠٠ جنيه، فلا يستفيد (ج) من المرتبة الأولى التي حل فيها محل (أ) إلا لضمان ١٠٠٠ جنيه فقط، وإلا لترتب على النزول الإضرار بالدائن (ب).

٢- يكون للدائنين أصحاب المرتبة المتوسطة (ب) في المثال السابق أن يتمسكوا في مواجهة الممتاز له أي (ج) بكافة الدفع التي كانت لهم في مواجهة الممتاز كالدفع ببطان دين (أ) أو بطلان رهنه أو قيد هذا الرهن، وكذلك الدفع بانقضاء الدين إذا كان الانقضاء سابقاً على النزول.

أما إذا كان دين الممتاز قد انقضى بعد النزول عن المرتبة، فلا يجوز لهم التمسك بالدفع بانقضائه إذ أن الدائن الممتاز له إذ يحتل مرتبة الممتاز يكسب حقه في هذه المرتبة ولا يجوز أني تأثر هذا الحق بعد ذلك بسبب يتصل بدين غيره.

ويلاحظ في النهاية أن النزول على مرتبة الرهن لا يكون نافذاً في مواجهة الغير إلا إذا حصل التأشير به في هامش قيد الرهن الذي حصل النزول عن مرتبته (م ١٠٥٣ مدنى).

ثانياً: حق التتبع:

لا يظهر ما يسمى بحق التتبع ما بقى العقار في ذمة الراهن. إذا ما انتقل العقار المرهون من يد الراهن، كان للدائن المرتهن الذى قيد حقه قبل ذلك أني تبعه في يد من أنتقل إليه العقار، وهو الحائز، وينفذ عليه تحت يده. وإذا كان القانون يعطى الدائن المرتهن حق التتبع في يد الحائز، فإنه يدخل في الاعتبار وجود هذا الأخير، ويمنحه حقوقاً لم تكن للراهن، فيوجب على الدائن اتخاذ إجراءات خاصة في التنفيذ قصد من ورائها التوفيق بين مصلحة المرتهن ومصلحة الحائز ومصلحة الدائنين المرتهنين جميعاً.

(١) د/ منصور مصطفى منصور: ص ١١٠، د/ توفيق فرج: ص ١٦٨.



وفى صدد الكلام عن حق التتبع نبدأ أولاً بتعريف من هو الحائز الذى يتم تتبع العقار بين يديه، ثم نعرض بعد ذلك لمباشرة الدائن المرتهن لحق التتبع، ثم ما يخوله القانون للحائز من حقوق، وأخيراً نعرض للآثار المترتبة على بيع العقار.

من يعتبر حائزاً للعقار:

نصت المادة ٢/١٠٦٠ مدنى على أنه «يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عيني آخر قابل للرهن، دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن».

يتضح من هذا النص أنه لكى يعتبر الشخص حائزاً يجب أن تتوافر شروط معينة:

١- أن تكون قد انتقلت إليه ملكية العقار المرهون أو أى حق عيني آخر قابلاً للرهن، فمن انتقلت إليه ملكية العقار يعتبر حائزاً. ولا يهم سبب انتقال الملكية، إذ يكفى أن يصير مالكاً بأى سبب، سواء كان تصرفاً قانونياً كالبيع والوصية، أو واقعة مادية كالنقادم. ولا يلزم أن يكون الحائز قد انتقلت إليه الملكية الكاملة لجميع العقار، فيكفى أن ينتقل إليه جزء منه فقط، إنما يلزم أن يكون انتقال الملكية قد تم فعلاً وأنتج أثره.

2024/2025 ويعتبر حائزاً كذلك من انتقل إليه حق عيني على العقار بشرط أن يكون 2024/2025 من الحقوق القابلة للرهن، أى من الحقوق التى تقبل البيع مستقلة بالمزاد العلنى، وذلك كحق الانتفاع وملكية الرقبة.

ويترتب على ما سبق أنه لا يعتبر حائزاً من لم تنتقل إليه الملكية فعلاً كالمشتري بعقد غير مسجل، كالمستأجر. كما لا يعتبر حائزاً من انتقل إليه حق عيني غير قابل للرهن كحق الاستعمال أو السكنى أو حق من حقوق الارتفاق أو أى حق عيني تبعى كالرهن لأن جميع هذه الحقوق غير قابلة للرهن.

٢- ولكى يعتبر الشخص حائزاً يلزم أن يكون انتقال الملكية أو أى حق من الحقوق العينية القابلة للرهن، قد تم بعد قيد الرهن وقبل تسجيل نزع الملكية. وعلى هذا إذا انتقلت الملكية أو أى حق قابل للرهن قبل القيد، ما كان للدائن أن يتبع العقار المرهون، لأن الرهن لا يكون نافذاً قبل من انتقل إليه العقار أو أى حق عيني عليه.



ومن جهة أخرى إذا انتقلت الملكية أو الحق بعد تسجيل التنبيه فلا يكون على الدائن إنذاره، بل له المضي في الإجراءات في مواجهة من كان مالكا قبل تسجيل التنبيه متجاهلاً من آلت إليه الملكية، وتكون إجراءات الدائن سليمة. وهذا ما يفهم من نص المادة ٤١١ مرافعات جديدة إذ تقضى بأنه «إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه، وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته».

وإذا كان يفهم من المادة ٤١١ مرافعات أنه يلزم اكتساب الحق بعقد، مسجل قبل تسجيل التنبيه، فما هو الحكم إذا لم يكن كسب الملكية بعقد، ولكنه تم عن طريق التقادم، هنا يجب إعمال المادة ١٠٦٠ مدنى التى تعرف الحائز بأنه «من انتقلت إليه الملكية أو أى حق عيني...بأى سبب من الأسباب». فالنص لم يشترط التسجيل.

٣- ولكى يعتبر الشخص حائزاً، يلزم كذلك ألا يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن. ذلك أن للحائز من الحقوق ما يتنافى مع اعتباره مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين فى كافة أمواله، إذ يخوله القانون الحق فى تطهير العقار أو أن يتخلى عنه. ولهذا لا يعتبر حائزاً من اكتسب ملكية العقار أو حقاً قابلاً للرهن، متى كان مسئولاً عن الدين المضمون بصفة مديناً متضامناً، أو كفيلاً شخصياً للدين.

2024/2025 أما بالنسبة للوارث، فهل يعتبر مسؤولاً شخصياً عن الدين المضمون بالرهن 2024/2025 أم أنه لا يعتبر كذلك، الواقع أننا إذا أخذنا بقاعدة أن لا تركه إلا بعد سداد الديون. أدى بنا هذا إلى أن ملكية العقار لا تنتقل إلا بعد سداد الدين المضمون بالرهن، أو بعبارة أخرى أن ما ينتقل إلى الوارث هو ما زاد عن قيمة الدين، ولهذا فإنه ينتقل غير محمل برهن فلا محل إذن لأن يكون الوارث حائزاً لعقار مرهون.

هذه هى الشروط التى يستلزمها القانون لى يكون الشخص حائزاً إنما يلزم لاعتباره كذلك أن يظل الرهن قائماً رغم انتقال الملكية، فإذا ترتب على انتقال الملكية زوال الرهن، فلا محل للكلام عن وجود حائزاً، كما فى حالة نزاع الملكية للمنفعة العامة وأيلولة العقار للدولة. كذلك حالة بيع العقار بالمزاد العلنى وفقاً لأحكام قانون المرافعات، وانتقال الملكية إلى الراسى عليه المزاد (المادة ٤٥٠ مرافعات).

كيفية مباشرة التتبع (شروطه وإجراءاته):

يباشر الدائن حقه فى التتبع باتخاذ إجراءات نزاع ملكية العقار فى يد الحائز، ولا يجوز له ذلك إلا إذا حق أجل دينه (م ١/١٠٦٠ مدنى) لأن التنفيذ

يقتضى أن يكون الدين مستحق الأداء، معنى ذلك أنه لا مجال للتنفيذ إذا كان الدين مؤجلاً.

غير أن مباشرة التتبع تفترض شرطاً ثانياً يتعلق بنفاذ الرهن في مواجهة الغير، وهذا الشرط يقتضى أن يكون الرهن قد تم قيده وفقاً للقانون، وأن يكون القيد مازال قائماً عند مباشرة التتبع، فإذا كان القيد قد سقط بعدم التجديد فلن يحتج بالرهن في مواجهة الغير الذى اكتسب حقوقاً على العقار قبل إجراء القيد الجديد.

أما عن إجراءات التتبع، فقد نصت المادة ١٠٧٢ مدنى على أنه «إذا لم يختار الحائز سداد بعض الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد».

يتضح من هذا النص أنه يجب على الدائن الذى يسعى في مباشرة التتبع أن يقوم بإجراءين: التنبيه والإنذار، أولهما يوجه إلى المدين ويوجه الثانى إلى الحائز، فضلاً عن وجوب تسجيلهما.

أ - التنبيه ومن مقتضاه التنبيه على المدين بالدفع، ويتم التنبيه بإعلان على يد محضر يتضمن البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات^(١). والحكمة من توجيه التنبيه إلى المدين هو^{2024/2025} أن المتصور أن يسارع المدين بالوفاء بالدين، فإن فعلت الإجراءات عند هذا الحد ولم يعد للتتبع فائدة أو معنى. فضلاً عن التنبيه يضع المدين في موضع التقصير عند عدم الوفاء به وهو ما يكون سنداً للحائز في رجوعه على المدين إذا أوفى بالدين أو نزعت ملكيته العقار من تحت يده.

ب - الإنذار يتعين على الدائن المرتهن أن يوجه إنذار إلى الحائز أما أن يقضى الدين أو أن يتخلى عن العقار. وهذا الإنذار هو إجراء ضرورى يسبق ممارسة إجراءات نزع الملكية، حيث لا يجوز الشروع في هذه الإجراءات إلا بعد تمام إنذار الحائز بالوفاء أو التخليه. فإذا لم يستجب الحائز لأى من هذين الخيارين شرع الدائن في ممارسة إجراءات نزع الملكية.

ويجب أن يكون إنذار الحائز مصحوباً بصورة من أصل التنبيه الذى سبق توجيهه إلى المدين وإلا وقع الإنذار باطلاً. ولذلك فلا يجوز توجيه الإنذار إلى

(١) راجع مادة ٤٠١ مرافعات.

الحائز قبل التنبيه على المدين، وإن أجازت المادة ١٠٧٢ مدنى أن يكون التنبيه والإنذار فى وقت واحد.

ج- تسجيل التنبيه والإنذار. استوجب قانون المرافعات ضرورة تسجيل التنبيه وكذلك الإنذار. وقد نصت المادة ٤١٢ من هذا القانون على أنه يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه.

متى بدأت إجراءات نزع الملكية فى مواجهة الحائز بعد إنذاره إنذاراً صحيحاً كان له من الوسائل ما يمكنه من التخلص من دعوى الرهن ذاتها بإنكار حق الدائن فى التتبع، فإذا لم يستطع ذلك، خوله القانون أحد أمور أربعة له أن يختار بينها.

وعلى ذلك نبحت أولاً فى دفع الحائز، ثم خيارات الحائز.

دفع الحائز:

إذا أراد الحائز أن ينكر حق الدائن المرتهن فى تتبع العقار المرهون فى يده كان له أن يطعن فى الرهن من حيث صحته أو نفاذه، أو أن يطعن فى الدين المضمون. ويتم الطعن عن طريق المعارضة فى إنذاره بالدفع أو التلخيه، أو بدعوى مبتدأه. وله هذا الطعن إلى أن يصبح الحكم بنزع الملكية نهائياً.

والطعن فى الرهن، قد يكون بالدفع ببطالته أو بعدم قيده أو ببطلان القيد أو بعدم تجديده، أو بقيده أو تجديده بعد تسجيل التصرف الذى كسب الحائز به ملكية العقار المرهون. 2024/2025 2024/2025

أما الطعن فى الدين المضمون، فيتم بالطعن فى وجود الدين أو سلامته بجميع أوجه الدفع التى للمدين أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن المرتهن، وذلك إذا كان الدين المضمون ثابتاً فى ورقة رسمية يتم التنفيذ بها أما إذا كان الدين المضمون ثابتاً فى حكم يتم التنفيذ به، فإن حجية الأمر المقضى به تمنع الحائز من التمسك ببعض الدفع، وذلك على النحو الوارد بالمادة ١٠٧٣ مدنى وتنص على أنه:

١- يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفاً فى الدعوى التى حكم بها على المدين بالدين أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها إذا كان الحكم بالدين لاحقاً لتسجيل سند الحائز.

٢- ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن يتمسك بالدفع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها.

يؤخذ من هذا النص الآتى:

(أ) إذا حكم بالدين قبل تسجيل سند الحائز كان لهذا الحكم حجية الأمر المقضى فيه، بالنسبة للحائز باعتباره خلفاً خاصاً للمدين المحكوم عليه بالدين وعندئذ لا يتمسك الحائز إلا بالدفع التى تستجد بعد الحكم والتى يمكن للمدين أن يتمسك بها كالدفع بانقضاء الدين بعد صدور الحكم بأسى سبب من انقضائه كالمقاصة أو التقادم، لأن هذه الدفع لا تمشى حجية الأمر المقضى.

(ب) إذا حكم بالدين بعد تسجيل سند الحائز، ففي هذه الحالة إذا كان الحائز قد أختصم فى الدعوى أو تدخل فيها كان الحكم حجة عليه، فقد كان له أن يطعن فى الدين حتى صدور الحكم. أما إذا لم يختصم الحائز فى الدعوى ولم يتدخل فيها، فلا يكون الحكم بالدين حجة عليه وإنما يكون حجة على المدين الصادر ضده الحكم. وبالتالي يستطيع الحائز أن يتمسك فى مواجهة الدائن بجميع أوجه الدفع الخاصة بالدين المضمون، سواء تلك الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها قبل صدور الحكم وامتنع عليه التمسك بها بعد صدوره أو تلك التى للمدين أن يتمسك بها بعد صدور الحكم.

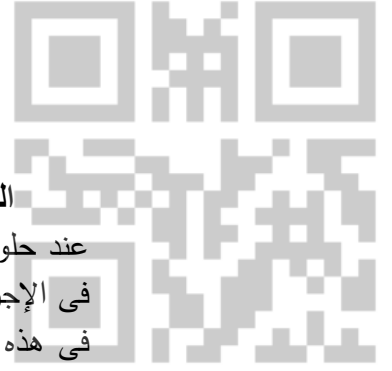
خيارات الحائز:

2024/2025 حينما يباشر الدائن المرتهن إجراءات التتبع، فى مواجهة الحائز فإن هذه 2024/2025
الأخير، إذ لم تكن لديه دفع على النحو السابق، يملك عدة خيارات هى، قضاء الدين، تطهير العقار المرهون، تخلية العقار، تحمل إجراءات نزع الملكية ونعرض لكل منها.

أولاً: قضاء الدين:

يمثل قضاء الدين أهمية كبيرة بالنسبة للحائز فى بعض الحالات، فمن المتصور أن يكون الحائز قد أشتري العقار المرهون بثمن مساو لقيمة الدين ولم يكن قد سدد هذا الثمن بعد للبائع. وهنا يقوم بدفع المبلغ للدائن بدلاً من دفعه للبائع. وفى فرض آخر قد يكون الدين مضموناً برهن على عقار آخر مملوك للمدين فيقوم الحائز بالوفاء ويحل محل الدائن المرتهن فى هذا الرهن الأخير وأخيراً قد تكون قيمة العقار قد ارتفعت بما يجاوز بكثير الدين المضمون فيفضل الحائز قضاء الدين على أن يعود على المدين بما دفعه فيما بعد.

وقضاء الدين قد يكون اختيارياً وقد يكون إجبارياً.



القضاء الاختياري: وقد نصت عليه المادة ١٠٦١ مدنى «يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذاره ويبقى حقه هذا قائماً إلى يوم رسو المزداد، ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين، وعلى المالك السابق للعقار المرهون، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى أستوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

ويتضمن قضاء الدين كما ورد فى المادة السابقة الوفاء بأصل الدين وكذلك الملحقات والمصاريف. والوفاء هنا هو الوفاء بكامل الدين عملاً بقاعدة عدم التجزئة وعملاً بمنطق الوفاء الاختياري ذاته. فإذا لم يلتزم الحائز بالوفاء بكل الدين كان للدائن المرتهن أن ينزع ملكية العقار استيفاء لما لا يتم الوفاء به.

والملحقات تشمل الفوائد، وهى فوائد سنتين قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وكذلك الفوائد المستحقة بعد هذا التسجيل وحتى يوم رسو المزداد. أما غير هذا من الفوائد الأخرى فلا يلتزم بها الحائز إلا بما يكون الدائن قد قيده منها بحيث يحتج به عليه. وبالنسبة للمصروفات فهى تشمل كل ما ينفقه الدائن فى إجراءات نزع الملكية من وقت إنذار الحائز حتى قيامه بقضاء الدين (م ١٠٦١ مدنى).

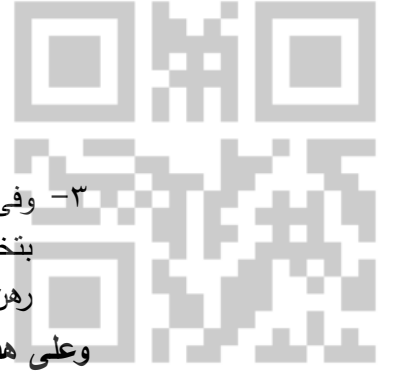
ويتم قضاء الدين عند حلول أجله، ويلاحظ فى هذا الشأن أن الحائز يستفيد من الأجل الذى منح للدين سواء كان هذا الأجل اتفاقياً أو قضائياً وبالتالى لا يتخذ أية إجراءات ضد الحائز للأجل قائماً.

2024/2025

القضاء الإجبارى: الأصل أن قضاء الدين هو أمر اختياري بالنسبة للحائز ومع ذلك فهناك حالة جعل فيها المشرع قضاء الدين إجبارياً، وهى حالة وردت فى نص المادة ١٠٦٢ مدنى «١- إذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل».

٢- فإذا كان الدين فى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالاً أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغاير لها جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ويكون الدفع طبقاً للشروط التى التزم بها الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها، وفى الأجل المتفق على الدفع فيه.





٣- وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصاً من كل رهن ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود.
وعلى هذا فهناك حالتان يجبر فيها الحائز على قضاء الديون:

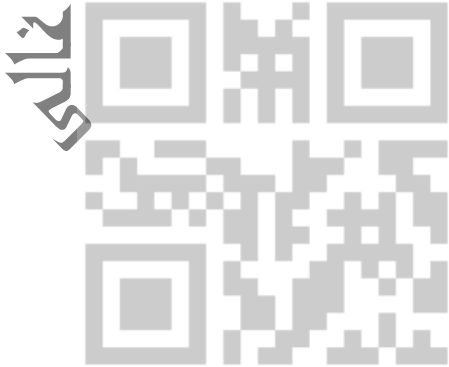
الأولى: لا تمثل أية مشكلة وتستند فى حكمها إلى اعتبارات منطقية ومعادله. فإذا كان المستحق فى ذمة الحائز مبلغاً يكفى الوفاء بجميع الديون المقيدة رهنها قبل تسجيل سند الحائز وجب عليه أن يعرض على كل دائن ما يوفيه حقه وأن يمتنع عن الوفاء بأى شئ من هذه المبالغ للراهن، بل أنه لا مصلحة له فى ذلك.

ويشترط لتطبيق حكم هذه الحالة أن تكون المبالغ كافية تماماً للوفاء بالديون، وأن تكون هذه المبالغ مستحقة فى ذمة الحائز بسبب أيلولة العقار المرهون إليه وأن تكون المبالغ مستحقة الأداء حالياً.

الثانية: وفى هذا الفرض ما فى ذمة الحائز أقل من قيمة الديون المضمونة بالرهن، ولكن اتفق الدائنون المرتهنون على مطالبة الحائز بالدفع فى هذه الحالة يجب عليه قضاء الديون. ويطبق ذات الحكم فى فروض أخرى أشار إليها النص وهو فرض أن يكون ما هو مستحق فى ذمة الحائز ديناً مغايراً لجنس الديون المضمونة أو ديناً غير مستحق الأداء.

واتفاق الدائنون على النحو السابق يغلق أمام الحائز باب أى خيار آخر. 2024/2025
فلا يكون أمامه إلا الوفاء. ولكن الحائز يلتزم بالدفع فى حدود الشروط والأوضاع التى سبق أن اتفق عليها مع سلفه (البائع) فهو يفى مقسطاً أو مؤجلاً حسب الاتفاق الأصل الذى تلقى العقار بمقتضاه. وإذا كان الأمر على هذا النحو السابق فإن الحائز لا تصح له مصلحة فى الامتناع عن قضاء الديون، بل على العكس يحقق له هذا الوفاء أن يطلب بعد إجراءاته محو ما على العقار من قيود.

ويترتب على توافر إحدى حالتى القضاء الإجبارى السابقتين أن يفقد الحائز صفته كحائز بمعنى أنه لا تصح له من بعد خيارات الحائز الأخرى. حيث يجب عليه قضاء الدين ولا يملك أن يسلك إجراءات تطهير العقار أو إجراءات التخليه، بل أنه يصبح مسئولاً مسئولية شخصية عن الوفاء بالديون فإن تقاعس جاز للدائنين أن ينفذوا على أمواله الأخرى بما نشأ لهم من حض الضمان العام فى مواجهته.



ما يترتب على قضاء الدين:

إذا تم قضاء الدين سواء إجباراً أو اختياراً زالت عن العقار المرهون القيود التي تنقله. ولذلك يصبح من حق الحائز أن يطلب محو ما يكون من قيود على العقار.

كما أن للحائز الذي أوفى بالدين حق الرجوع على المدين. وفي هذا الشأن تنص المادة ١٠٦١ مدني على أن يكون للحائز أن يرجع بكل ما يوفيه على المالك السابق للعقار المرهون. كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما يكون منها متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين».

يبين من هذا النص أن للحائز الذي يقضى الدين أن يرجع بما أوفاه.

فأولاً: للحائز أن يرجع بما وفاه على المدين بدعوى شخصية على أساس الإثراء بلا سبب. ويتحقق إثراء المدين بقدر ما برئت ذمته منه بسبب وفاء الحائز لدائنه. أما افتقار الحائز فلا يتحقق إلا إذا كان قد وفى دون أن يكون مديناً للمدين أو كان ما فى ذمته للمدين أقل مما وفاه.

ثانياً: دعوى الضمان وللحائز كذلك أن يرجع على المالك السابق سواء كان هو المدين أو غيره بدعوى شخصية هي دعوى الضمان إن كان سنده يسمح بهذا الرجوع^(١). فإذا كان الحائز قد تلقى حقه بعقد معاوضة كالبيع أو المقايضة، فيرجع على سلفه على أساس المادة ٤٤١^{2024/2025} التي تقضى بأنه «إذا توفى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات». وبديهي أن الحائز لا يرجع على المالك السابق إلا بما يزيد عما بقى فى ذمته من الثمن. أما إذا كان الحائز قد تلقى حقه بدون مقابل عن طريق الهيئة أو الوصية فلا رجوع له على الواهب أو ورثة الموصى.

ثالثاً: دعوى الحلول: للحائز الموفى يحل محل الدائن فيما له من حقوق فيكون له حق الدائن بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفع، وذلك فى حدود ما أداه. على أنه يجب أن نفرق هنا بين نوعين من التأمينات.

(١) د/ منصور مصطفى منصور: ص ١٢١، د/ عبد الفتاح عبد الباقي ص ٤٧٧.

الأول: هو التأمينات التي قدمها غير المدين وهي الكفالة الشخصية والكفالة العينية، وهذه لا يستفيد منها الحائز الذي وفي الدين (مادة ١٠٦١ مدني)، وقد راعى المشرع في هذا الحكم أنه لو بقي العقار المرهون في يد المدين ولم ينتقل إلى الحائز، لما كان لهذا المدين أن يرجع على الكفيل في حالة التنفيذ عليه، فلا يصح أن يسوء مركز الكفيل لمجرد قيام المدين بالتصرف في العقار للحائز.

الثاني: النوع الثاني من التأمينات هو التأمينات التي قدمها المدين كرهن على عقار آخر والرهن الذي للدائن على العقار الذي كسبه الحائز، وهذه يستفيد منها الحائز الموفى.

ولا تظهر فائدة حلول الحائز محل الدائن الرهن المقرر على العقار الذي بحوزة إلا إذا كانت هناك قيود أخرى على هذا العقار متأخرة على العقار كان للحائز أن يتمسك عند توزيع الثمن بحلوله محل الدائن الذي وفاه فيستوفى حق هذه الأخير قبل أن يحصل الدائنون المتأخرون على ما يخصهم وهذا مشروط بقيددين:

الأول: أن يكون قيد الرهن الذي حل فيه الحائز قائماً منتجاً لأثره، ولهذا نص المشرع في المادة ١٠٦٢ مدني على أنه «يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وأن يحدده عند الاقتضاء، وذلك إلى أن تمحي القيد»^{٢٥} التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند الحائز».

2024/2025

الثاني: إذا كان الحائز يستفيد من الرهن المقدمة من المدين، فهو مقيد في هذا بما ورد في المادة ٣٣١ من أنه «إذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هذا الحل أن يرجع على حائز العقار المرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار».

فإذا رهن المدين عقارين ضماناً لدين واحد ثم تصرف في أحدهما لشخص وتصرف في الثاني لشخص آخر، أو كان العقار المرهون واحداً ثم بيع جزء منه إلى شخص والجزء الباقي لشخص آخر، فيكون بصدد تعدد الحائزين، فإذا وفي حائز بكل الدين فلا يرجع بمقتضى الحل على الحائز الآخر بكل الدين بل يوزع الدين على الحائزين بنسبة قيمة كل عقار إلى مقدار الدين. فإذا افترضنا مثلاً أن قيمة ما يحوزه الموفى مساوية لقيمة ما يحوزه الحائز الآخر، فلا يرجع الحائز الموفى على الحائز الآخر إلا بنصف الدين فقط، والعلة في هذا أن مركز كل



حائز يماثل لمركز الآخر فلا يصح أن يستفيد أحدهما لمجرد أنه وفي الدين للدائن.

ثانياً: تطهير العقار:

التطهير حق يخوله القانون لحائز العقار المرهون، يستطيع بمقتضاه أن يتقى أو يقف إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائن المرتهن على هذا العقار بما له من ميزة التتبع، بان يعرض، وفقاً لإجراءات معينة، المبلغ الذي يمثل قيمة العقار المرهون، فلا يؤدي التطهير بطريقة مباشرة إلى انقضاء الرهن الرسمي، بل إلى تخليص الرهن من ميزة التتبع للعقار المرهون ليقع حق الدائن المرتهن على ثمنه. ويوفر التطهير للحائز ميزة هامة وهي الاحتفاظ بالعقار خالصاً من الرهن الذي يتقله بغير أن يفى بكل الدين المضمون به، بل في مقابل أن يدفع مبلغاً يمثل قيمة العقار المرهون، وقد يقل عن مبلغ هذا الدين والغالب أن يكون الحائز مشترياً للعقار المرهون، فيخلص له هذا العقار دون أن يدفع ما يزيد على الثمن الذي اشترى به إذا كان العقار لا يساوي أكثر منه. ولا يظل الحائز، بفضل نظام التطهير، مهتماً خلال سنوات طويلة، فيتبع الدائن المرتهن للعقار الذي آلت إليه ملكيته.

وقد نصت على التطهير المادة ١٠٦٤ مدنى:

١- يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن ثم قيده مثل
2024/2025 2024/2025 2024/2025
تسجيل هذا السند.

٢- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحق قائماً إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع.

ونعرض فيما يلي لأحكام التطهير ببيان من له حق التطهير، وما هو قدر المبلغ الذى يتم عرضه على الدائنين ثم إجراءات التطهير.

من له حق التطهير:

لا يجوز التطهير إلا لحائز العقار الذى سجل سند ملكيته، فيجب فى طالب التطهير:

١- أن يكون مالكاً للعقار المرهون أو صاحب حق عيني عليه قابل للبيع بالمزاد العلنى.

٢- ويجب من ناحية أخرى أن يكون أجنبياً عن الدين المضمون بالرهن.

٣- وأجنبياً عن إنشاء الرهن.





القيد الأول: ويظهر في قصر التطهير على حائز العقار المرهون ولا يتوافر وصف الحائز إلا لمن انتقلت إليه ملكية العقار المرهون، أو اكتسب على هذا العقار حقاً عينياً يجوز بيعه بالمزاد العلني. لذلك لا يجوز لمن اكتسب حقاً عينياً تبعياً على العقار المرهون أن يطهره، كدائن مرتتهن لذات العقار. كما لا يجوز التطهير لمن كسب على العقار حقاً عينياً أصلياً لا يجوز بيعه بالمزاد العلني كحق ارتفاق أو استعمال.

وعلى هذا النحو يكون التطهير لمشتري العقار المرهون والمقايض والموهوب له والموصى له والشفيع ولصاحب حق انتفاع على العقار المرهون فهؤلاء أصحاب حقوق تقبل الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني.

وأستخلص الفقه نتيجة لهذا الشرط، أن المالك تحت شرط واقف لا يجوز له، قبل تحقق الشرط أن يطهر العقار المرهون، في حين يجوز للمالك تحت شرط فاسخ أن يلجأ إليه قبل تخلف الشرط، ويكون أثر التطهير نهائياً وفقاً للمادة ١٠٨٣ «إذا نمت إجراءات التطهير انقضت حق الرهن الرسمي نهائياً ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار».

ويجب نتيجة لهذا الشرط أيضاً أن يكون سند الحائز مسجلاً، إذا كان واجب التسجيل، حيث لا يعتبر مالكاً للعقار المرهون ألا بتسجيله^(١).

أما القيد الثاني: فهو وجوب أن يكون طالب التطهير أجنبياً عن الدين المضمون^{2024/2025}، أما إذا كان مالك هذا العقار^{2024/2025} مسؤولاً عن الدين، قبل الدائن المرتتهن لا يمكن أن يقوم بتطهير رهن هذا الأخير، وعلى ذلك، لا يجوز للمدين المتضامن، ولا للكفيل، أن يطهر العقار المرهون ضماناً للوفاء بالدين، إذا آلت إليه أحدها ملكيته.

أما القيد الثالث: فإنه لا يجوز التطهير إلا لمن كان أجنبياً عن إنشاء الرهن، حيث يكون في غير هذه الحالة ملتزماً بالضمان قبل الدائن المرتتهن ويمتنع عليه، من ثم أن يأتي عملاً أو تصرفاً، يترتب عليه تعطيل ميزة التتبع التي تنشأ من الرهن لمصلحة هذا الأخير. وعلى ذلك ليس للكفيل العيني أن يطهر العقار من الرهن الذي رتبته على عقاره، ولو أن له، وفقاً للمادة ٢/١٠٥١ تخليه هذا العقار، ليتفادى توجيه إجراءات التنفيذ عليه.

(١) الأعمال التحضيرية، ج٧، ص١١٨.



المبلغ الذى يعرضه الحائز للتطهير:

يقدر الحائز مبلغاً من المال يعتبره معادلاً لقيمة العقار المرهون والحائز ليس مطلق الحرية فى هذا التقدير فيجب أن يراعى من تلقاء نفسه أن تكون القيمة معادلة للقيمة الحقيقية للعقار حتى يكون فى عرضه اقتناعاً لمجموعة الدائنين المرتهنيين بما يؤدى بهم إلى العزوف عن سلوك طريق التنفيذ الجبرى. وإلى جانب ذلك قيد المشرع تقدير الحائز بعدة قيود هى:

١- إذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير كل جزء على حده «ومعنى ذلك أنه يجب على الحائز أن يقدر قيمة كل جزء على حدة وأن يجرى تطهير كل جزء باعتباره عقاراً مستقلاً. وقد يقبل الدائنون التطهير بالنسبة للثمن المعروض لجزء دون آخر. وفى هذه الحالة يقبل لتطهير بالنسبة للجزء الأول ومن المبيع بالمزاد بالنسبة للآخر»^(١).

٢- يجب أن لا تقل القيمة المعروضة عن القيمة الباقية فى ذمة الحائز من ثمن العقار (إذا كان التصرف مبيعاً). فإذا كان ثمن العقار عشرين ألف جنيه ولم يدفع منها شيئاً فإن ما يعرضه على الدائنين لا يجوز أن يقل عن هذه القيمة. وإذا كان قد دفع للبائع جزءاً منها فيجب ألا يقل ما يعرضه عن الباقي فى ذمته.

٣- يجب ألا تقل القيمة المعروضة للتطهير عن السعر الذى يتخذ أساساً لتقدير ثمن العقار فى حالة نزع الملكية^{2023/2024} (٣/١٠٦٥ مدنى). وهذا الثمن يقدر بدوره^{2024/2025} على أساس الضريبة التى تدفع عن العقار، ويمكن الاستهداء فى ذلك بما يتبع فى تقدير الرسوم القضائية ورسوم التوثيق.

إجراءات التطهير:

نصت المادة ١٠٦٥ من القانون المدنى على أنه «إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد إعلانات تشتمل على البيانات الآتية:

(أ) خلاصة من سند ملكية الحائز يقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وأسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيناً دقيقاً ومحل العقار مع تعيينه وتحديد بالذقة وإذا كان التصرف بيعاً يذكر أيضاً الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءاً من هذا الثمن.

(ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل.

(١) مادة ١٠٦٥ مدنى. فقرة (ج).

(ج) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعاً ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساساً لتقدير الثمن فى حالة نزاع الملكية، ولا أن يقل فى أى حال عن الباقي فى ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان الثمن بيعاً.

قائمة بالحقوق التى قسمت على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.

وتستهدف ذكر هذه البيانات أن يكون كل دائن مرتهن على بينه من القيمة المعروضة، والحقوق المقيدة على العقار، والثمن المعروض، وما بقى فى ذمة الحائز من ثمن، وما سيحصل عليه حسب ترتيب أولويات القيد. كل ذلك بحيث يستطيع الدائن المرتهن أن يقدر موقفه وما إذا كان يقبل التطهير أو يرفضه ويطلب البيع بالمزاد.

ولم يبين المشرع الجزاء المترتب على إغفال بعض البيانات السابق الإشارة إليها. ويمكن قياس الحكم على حالة إغفال بعض بيانات قيد الرهن وذلك بالقول بأن الأمر يتوقف على ما إذا كان البيان جوهرياً وترتب عليه ضرر لأحد الدائنين من عدمه. فمثلاً إذا أغفل الحائز ذكر أحد الحقوق المقيدة على العقار بحيث لم يأخذ فى اعتباره الدائن التالى فى المرتبة فقبل العرض، فإن الجزاء يكون بطلان العرض بالنسبة له ولا ينتج أثره فى حقه ويكون له الحق فى التنفيذ على العقار إلا

2024/2025

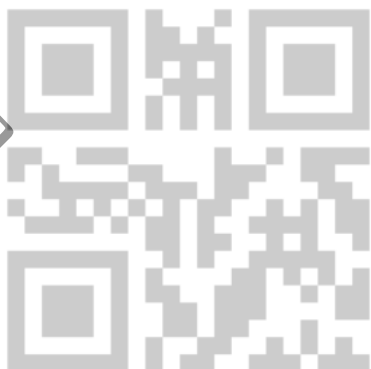
2024/2025

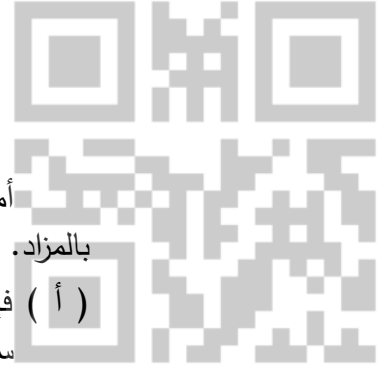
ويقدر القاضى فى كل حالة ما إذا كان البيان جوهرياً أو قانونياً ويكفى أخيراً أن يعرض الحائز فى الإعلان استعداده للوفاء بالديون المقيدة إلى القدر الذى تم تقويم العقار به. ولا يلتزم الحائز أن يعرض المبالغ عرضاً حقيقياً، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً بل يحضر العرض فى إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أياً كان ميعاد الديون المقيدة (م ١٠٦٦ مدنى).

الآثار التى تترتب على العرض

إذا تم العرض صحيحاً، ترتب على ذلك آثار بالنسبة للحائز نفسه وبالنسبة إلى الدائنين.

بالنسبة للحائز فإنه يلتزم به على أساس إرادته المنفردة، ويظل ملتزماً طيلة المدة التى يكون فيها للدائنين أن يظهروا رغبتهم خلالها، وهى مدة ٣٠ يوماً من وقت إعلان العرض.





أما بالنسبة للدائنين فلمم الخيار بين قبول العرض أو رفضه وبيع العقار بالمزاد.

(أ) فإذا وافق الدائنون جميعاً على العرض الذى تقدم به الحائز صراحة، أو سكتوا عن طلب بيع العقار خلال مدة ٣٠ يوماً وهى المدة التى نص عليها القانون من تاريخ إعلان العرض، مضافاً إليها مواعيد المسافة، اعتبر العرض قبولاً، وفى هذه الحالة يجب على الحائز أن يدفع المبلغ المعروض للدائنين أصحاب الحقوق الذى مرتباتهم باستيفاء حقوقهم، أو يودع هذا المبلغ خزانة المحكمة، ويقبول الدائنين ما عرضه الحائز صراحة أو ضمناً يصير هذا الأخير ملتزماً بدفع القيمة المعروضة التزاماً شخصياً، ويقتصر حق الدائنين على المبلغ المعروض فقط، حتى ولو بيع العقار بأكثر من ذلك.

وإذا ما قام الحائز بدفع القيمة المعروضة للدائنين المقيدى حسب مراتبهم أو بإيداعها خزانة المحكمة ترتب على ذلك تطهير العقار من الحقوق التى كانت تنقله وتستقر ملكية العقار نهائياً للحائز، خالصة من كل حق مقيد.

(ب) أما إذا لم يوافق الدائنون أو كفلاؤهم على العرض الذى تقدم به الحائز، بيع العقار المطلوب تطهيره، ويجوز القانون لكل دائن قيد حقه، ولكل كفيل لحق مقيداً أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويلزم أن يحصل طلب البيع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان رسمى، ويضاف إلى هذه المدة 2024/2025 مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار، على إلا تزيد هذه المواعيد على ثلاثين يوماً أخرى (م ١٠٦٧ مدنى).

ومدة الثلاثين يوماً - مضافاً إليها مواعيد المسافة - تسرى بالنسبة إلى كل دائن على حدة ولكن العرض الذى تقدم به الحائز لا يصير نهائياً ويرتب أثره إلا إذا انقضت المدة بالنسبة لجميع الدائنين، لأنه إذا طلب أحدهم بيع العقار، فإنه يباع ولو وافق باقى الدائنين على العرض.

وقد بين القانون ما يجب إجراؤه إذا ما طلب بيع العقار فقرر أن يكون طلب البيع بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق للعقار المرهون، وهو الذى آلت منه الملكية إلى الحائز، وبذلك تتاح لهذا المالك الفرصة لمعرفة ما يعرضه الحائز وأنه لا يقل عما هو ملتزم به بسبب تملك العقار.

ويجب أن يكون طلب البيع الموجه إلى الحائز أو إلى المالك السابق، موقعاً من الطالب أو ممن يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً، كما يجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يكون له



أن يسترد ما أنفق من هذه المصروفات إلا إذا رسا المزايد بثمن أعلى من الثمن الذى عرضه الحائز، وهو يسترد هذه المصروفات من الراسى عليه المزايد. أما إذا لم يرسى المزايد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز، فلا يجوز لطالب البيع أن يسترد ما أنفق. وإذا لم يستوف طلب البيع الشروط السابقة وقع هذا الطلب باطلاً. وإذا ما طلب أحد الدائنين أو الكفلاء بيع العقار على النحو السابق وأستوفى الطلب الشروط المطلوبة، التزم الطالب بطلبه، فلا يجوز له أن يتحى عنه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين، وجميع الكفلاء، واستلزام موافقة هؤلاء على تتحى الطالب عن طلبه بيع العقار، هو أن امتناعهم عن طلب البيع، قد يكون اعتماداً على الطلب الذى قام به أحدهم.

أثر طلب البيع:

متى تقدم أحد الدائنين أو الكفلاء بطلب البيع، فإنه يجب طرح العقار فى البيع بالمزاد. ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو حائز، ويوجب القانون إتباع الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات فى البيوع الجبرية. وهى إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى، ويجب على مكن مباشر الإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار.

وإذا عرض العقار للبيع بالمزاد، ولم يتقدم أحد بمبلغ أكبر مما عرضه الحائز رسا المزايد على هذا الأخير، وفى هذه الحالة لا يلتزم الحائز إلا بدفع المبلغ الذى عرضه ويتحمل طالب البيع المصروفاته.

2024/2025

أما إذا تقدم أحد المزايد بمبلغ يزيد عما عرضه الحائز، رسا المزايد على صاحب أكبر عرض، ويلزم من رسا عليه المزايد بأن يدفع المبلغ الذى رسا به المزايد، كما يلزم بأن يرد إلى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته، وفى تسجيل هذا السند، وفيما قام به من إعلانات، كما يلزم كذلك بالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير. هذا فضلاً عن التزامه بأن يدفع لطالب البيع المصروفات التى أنفقها لإجرائه (م/١٠٦٩/٢).

والمبلغ الذى يرسو به المزايد، أى يتم به البيع، يدفع للدائنين حسب مراتبهم أو يودع خزانة المحكمة، وإذا ما تم ذلك، وسجل حكم مرسى المزايد انتقلت الملكية إلى الراس عليه المزايد خالصة من الرهون الرسمية والحيازة وحقوق الاختصاص وحقوق الامتياز.

آثار التطهير:

إذا قبل الدائنون العرض الذى تقدم به الحائز أو طلب أحدهم بيع العقار بالمزاد، ولم يتقدم مزايد بعباء أكبر من العرض الذى تقدم به استقرت ملكية

العقار نهائياً له - الحائز - خالصة من كل الحقوق المقيدة. متى قام بدفع المبلغ الذى قوم به العقار أو بإيداعه خزانة المحكمة، سواء كانت آجال الديون قد حلت أم لم تحل بعد، وسواء استوفى الدائنون حقوقهم كاملة أم لا، وفى هذه الحالة الأخيرة يكون لمن لم يستوف حقه كاملاً أن يرجع بالباقي على مدينه.

وإذا رسا المزاد على غير حائز، فإن الملكية تخلص له مطهرة من الحقوق المقيدة، وإنما يكون ذلك لا نتيجة للتطهير، ولكن نتيجة لحكم مرسى المزاد. ويراعى أن التطهير لا يحرر العقار إلا من الحقوق التى كانت منتقلة قبل تسجيل سند الحائز، أما الحقوق التى تم قيدها بعد هذا التسجيل، سواء كانت هذه الحقوق قد ترتبت من الحائز نفسه، أو ترتبت فى مواجهته، فلا تزول إلا إذا بيع العقار بالمزاد ورسا المزاد على غير حائز. ولا تزول هذه الحقوق الأخيرة نتيجة التطهير، بل نتيجة لرسو المزاد.

ثالثاً: تخليه العقار:

الخيار الثالث الذى منحه القانون للحائز هو تخليه العقار المرهون ويقصد بالتخليه ترك الحيازة العرضية للعقار لشخص آخر يعين حارساً فتنفذ ضده إجراءات نزع الملكية.

الحكمة من إعطاء الحائز حق التخليه هى أولاً تمكينه، وهو شخص غير مسئول شخصياً عن الدين المضمون، من تفادى ظهور أسمه فى إجراءات نزع الملكية الأمر الذى قد يسئ إلى سمعته المالية، إذ أن نزع ملكية عقار مملوك له 2024/2025 2024/2025 قد يشعر باضطراب مركزه المالى مع أنه ليس مدينياً بالدين الذى ينفذ الدائن من أجله^(١) ومن ناحية أخرى يتمكن الحائز بالتخليه من التخلص من مسئولية إدارة العقار المرهون فى الفترة التى تتخذ فيها إجراءات نزع الملكية، وثمار العقار تلحق به فتدخل فيما يتضمنه الرهن من وقت إنذاره بالدفع أو التخليه.

وسنعرض أولاً لمن تجوز تخليه العقار، ومتى تجوز التخليه، وإجراءاتها وأثر هذه التخليه.

لمن تجوز التخليه:

لا تجوز التخليه إلا للحائز على المعنى الذى حددناه من قبل، كما تجوز أيضاً للكفيل العينى فقط دون الكفيل الشخصى، لأن التخليه لا تتنافى مع التزام الكفيل العينى ببقاء الرهن. وهذا ما نصت عليه المادة ٢/١٠٥١ مدنى بقولها «إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين جاز له أن يتفادى أى إجراء موجه إليه إذا

(١) د/ منصور مصطفى منصور، ص ١٣٧، د/ جمال زكى، ص ٣١٨.

هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار».

وإذا كانت التخليه تجوز للحائز، فإنه يلزم ألا يكون ملزماً التزاماً شخصياً بالدين. ولهذا لا تجوز التخليه للكفيل الشخصى ولا للمدين المتضامن الذى اشترى العقار المرهون ضماناً للوفاء بالدين. ولا تجوز التخليه لمن اشترى العقار وكان فى ذمته مبلغ مستحق الأداء يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، أو إذا أكتفى الدائنون بما هو مستحق فى ذمته لسداد ديونهم طبقاً لما بينا من قبل بصدد الوفاء الإيجابى بالدين.

ولا تجوز التخليه كذلك للحائز الذى قام بعرض قيمة العقار على الدائنين بقصد تطهيره وقبل منه هذا العرض صراحة أو ضمناً، لأنه يلتزم شخصياً بالقيمة المعروضة. ولا يجوز التخليه للحائز الذى يلتزم بدفع ثمن العقار لمرتهنيه. وسواء التزم قبلهم مباشرة أو تعهد بذلك لمن باع له قبل الدائنون ذلك. وفى كل الأحوال يلزم ألا يكون الحائز الذى يرغب فى تخليه العقار، ملتزماً شخصياً بالدين.

متى تجوز التخليه وإجراءاتها

يكون للحائز أن يتخلى عن العقار من وقت أن يوجه إليه الإنذار بالدفع أو التخليه ويظل لهذا الحق إلى حين رسو المزداد، ذلك أن الغرض من التخليه هو تفادى توجيه إجراءات التنفيذ إلى الحائز، وهذا ما يظل قائماً إلى حين تمام إجراءات ورسو المزداد.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وتكون تخليه العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة، ثم يجب على الحائز أن يطلب من مكتب الشهر العقارى التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية وعليه بعد ذلك أن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخليه فى خلال خمسة أيام من تاريخ التقرير بها.

هذه هى الإجراءات التى نص عليها القانون (م ١/١٠٧١ مدنى) فإذا لم تستوف هذه الإجراءات وقت التخليه كانت باطلة، وجاز للدائنين مباشرة إجراءات التنفيذ فى مواجهة الحائز. وإذا وقعت التخليه صحيحة فإنه يجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية، ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك، لأن ظهور اسمه فى الإجراءات كحارس، لا يسئ إلى سمعته بقدر ما يسئ إليه باعتباره مالكاً تنزع ملكيته.

ولا يترتب على التخليه إلا أن تباشر إجراءات التنفيذ في مواجهة حارس أو أمين تعينه المحكمة. إنما لا يترتب عليها منع التنفيذ على العقار أو وقفه، كما لا يترتب عليها تنازل الحائز عن ملكه، بل يظل مالكا للعقار، وبالتالي يكون له أن يوقف إجراءات التنفيذ على العقار عن طريق الوفاء بجميع الديون المقيدة والمصروفات التي أنفقت في الإجراءات من وقت إنذاره بالدفع أو التخليه.

رابعاً: تحمل إجراءات نزع الملكية

إذ لم يختار الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار، يتخذ الدائن المرتهن في مواجهته إجراءات نزع الملكية، وفقاً لأحكام قانون المرافعات.

فإذا لم يكن للحائز وجه من أوجه المعارضة أو سبيل يدفع به دعوى الدائن المرتهن، تسير إجراءات نزع الملكية في مواجهته وفقاً للأوضاع المقررة حتى يتم بيع العقار بالمزاد، يحق للحائز أن يدخل في المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمناً أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه. وينتهى الأمر برسو المزاد أما على الحائز نفسه وأما على غيره.

أولاً: رسو المزاد على الحائز:

تنص المادة ١٠٧٥ مدنى على أنه «إذا نزع ملكية العقار المرهون، ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير والتخليه، ورسا المزاد على الحائز نفسه ^{2024/2025} اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى ^{2024/2025} سند ملكيته الأصلي، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة ويؤخذ من هذا النص أنه يترتب على رسو المزاد على الحائز أثاران هما:

الأثر الأول: يظل الحائز مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي، ليس بمقتضى حكم رسو المزاد وإيقاع البيع له. ومبنى على ذلك أنه:

(أ) لا محل لتسجيل حكم رسو المزاد على الحائز، وإنما يكفى التأشير بهذا الحكم على هامش تسجيل سند ملكية الحائز على هامش تسجيل إنذاره^(١). وذلك لإعلام الغير بما تم بشأن العقار وأن ملكيته قد استقرت للحائز.

(ب) إذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على حقوق الدائنين المقيدين كانت الزيادة للحائز لأنه مالك العقار، حتى لو زاد هذا الثمن على ثمن شراء الحائز للعقار. وإذا قل الثمن الذى رسا به المزاد عن ثمن شراء الحائز للعقار، ظل

(١) م ٤٤٨ مرافعات.

الحائز ملزماً بأن يدفع للبائع له الثمن الذى أشتراه به، أو ما بقى منه لأن حكم رسو المزاد لا يفسخ سند ملكية الحائز.

(ج) إذا رتب الحائز حقوقاً عينية على العقار بعد اكتساب ملكيته وحتى رسو المزاد كحق ارتفاق، بقيت هذه الحقوق على العقار، وإذا رتب رهناً عليه كان للدائن المرتهن من الحائز أن يستوفى حقه من ثمن العقار بعد استيفاء الدائنين المتقدمين عليه.

الأثر الثانى: يتطهر العقار من الحقوق المقيدة عليه، وذلك من وقت أن يدفع الحائز للدائنين الثمن الذى رسا المزاد عليه أو عند إيداعه هذا الثمن خزانة المحكمة. ويوزع هذا الثمن على الدائنين المقيدى بحسب ترتيبهم، فإن بقى لأحد منهم شئ رجع به على المدين. ويشمل التطهير جميع الحقوق المقيدة على العقار سواء رتبها المالك الأصلى أو رتبها الحائز، وسواء كانت هذه الحقوق ضامنة لديون حلت آجالها أو لم تحل، استوفاه أصحابها كامل أو ناقصة أو لم يستوفوا شيئاً منها. ويتم التطهير بقوة القانون وللحائز طلب محو القيود الواردة على العقار.

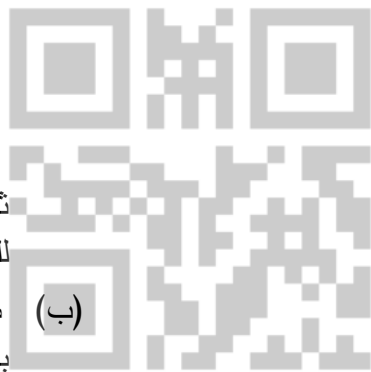
رسو المزاد على غير الحائز:

يترتب على رسو المزاد على غير الحائز أثران:

الأثر الأول: خلافه غير الحائز للحائز فى ملكية العقار. فتنص المادة ١٠٧٩ مدنى على أنه «إذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد» ويؤخذ من هذا النص أنه إذا رسى المزاد على غير الحائز، فإنه يتلقى الملكية عن الحائز. فالراسى عليه المزاد يعتبر خلفاً خاصاً ويترتب على ذلك الآتى:

(أ) إذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد عن حقوق الدائنين المقيدى كانت الزيادة للحائز باعتباره مالك العقار عند رسو المزاد، بحيث يوزع ثمن العقار على الدائنين المقيدة حقوقهم قبل اكتساب الحائز ملكية العقار، وما يزيد فهو للحائز ولدائنيه المقيدة حقوقهم فلا حق فيه للراهن ولا للدائنين العاديين (م ١٠٧٧ مدنى).

وإذا نقص الثمن الذى رسا به المزاد من حقوقهم الدائنين المقيدة على العقار أستوفى هؤلاء حقوقهم من ثمار العقار وهى تلحق به من وقت إنذار الحائز بالدفع أو التخليه وبشرط ألا تترك إجراءات نزع الملكية مدة



ثلاث سنوات (م ١٠٧٩ مدنى) ويسلم الحائز العقار مع ما تبقى من ثمار للراسى عليه المزداد.

(ب) سند ملكية الحائز لا يفسخ عند رسوا المزداد على غير الحائز، وبالتالي بحكم العلاقة بينه وبين سلفه، فإذا كان هذا السند بيعاً مثلاً كان للبائع أن يطالب الحائز بالحقوق الناشئة عن البيع ومنها ثمن البيع إذا كان لم يدفع له، وسواء زاد ثمن المبيع المتفق عليها بينهما عن الثمن الراسى به المزداد أو نقص، ولا يجوز لسلف الحائز أن يرتب حقوقاً على العقار بعد انتقال ملكيته للحائز وإلا كانت هذه الحقوق غير نافذة فى حق الحائز وغير نافذة كذلك فى حق الراسى عليه المزداد.

(ج) ما رتبه الحائز من الحقوق على العقار بعد تسجيل سند ملكية له يقع صحيحاً باعتباره صادراً من مالك، ولكنه لا يضر بحقوق الدائنين المقيدى قبل تسجيل سنده. فلو رتب الحائز حق ارتفاق أو استعمال أو سكنى على العقار، وكان هذا الحق صحيحاً إذا تم بعد تسجيل سند ملكية لكنه لا يسرى فى حق الدائنين المقيدى قبل تسجيل سنده على العقار.

وإذا باع الحائز العقار أو حق الارتفاق به فلا يسرى تصرفه فى حق الدائنين قبل تسجيل سنده، غير أنه إذا سجل الحائز الجديد سنده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية كان على هؤلاء الدائنين تتبع العقار فى يد الحائز

2024/2025

2024/2025

2024/2025 الجديد.

(د) تنتقل الملكية من الحائز إلى الراسى عليه المزداد بحكم مرسى المزداد عند تسجيل هذا الحكم. ويقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره. ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من وقع البيع عليه، على أنه لا ينتقل إليه سوى ما كان للمدين أو الحائز الكفيل العينى من حقوق على العقار المبيع^(١).

(هـ) قد يدون للحائز حقوق على العقار اكتسبها قبل انتقال ملكيته إليه، كحق انتفاع أو استعمال أو سكنى أو رهن أو اختصاص أو امتياز، وعند تسجيل الحائز لسند ملكيته تنقضى هذه الحقوق باتحاد الذمة، ولكن عند رسو المزداد على غير الحائز تعود هذه الحقوق من جديد، لأن السبب فى زوالها قد زال ولم يعد الحائز مالاً للعقار المرهون.

(١) م ٤٤٧ مرافعات.



الأثر الثانى: تطهير العقار عند تسجيل حكم رسو المزاد:

يتطهر العقار عند تسجيل حكم رسو المزاد. يتطهر العقار المرهون من جميع الحقوق العينية التبعية، بشروط معينة عند رسو المزاد على غير الحائز، سواء كانت هذه الحقوق مقيدة باسم الدائنين أو باسم الحائز، حتى تلك التى عادت إلى الحائز عند رسو المزاد، لأن عودتها إليه تعنى أن له التقدم بئمنها بحسب مرتبته.

ويتطهر العقار من جميع الحقوق العينية التبعية سواء كانت هذه الحقوق مرتبه من المالك السابق أو من الحائز، وسواء كانت هذه الحقوق ضامنة لديون حلت آجالها أو لم تحل، استوفاه أصحابها كاملة أو ناقصة أو لم يستوفوا شيئاً منها، ويكون لمن بقى من دينه شئ الرجوع به على مدينه.

أما الحقوق العينية الأصلية كحق الارتفاق أو الانتفاع تنتقل مع العقار إلى الراسى عليه المزاد إذا كانت مقيدى قبل الرهن، لأنها عندئذ تكون نافذة فى حق الدائنين المرتنين فتتخذ فى حق الراسى عليه المزاد.

وشروط تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية عند رسو المزاد على غير الحائز هى أن يكون أصحاب الحقوق التى يرد عليها التطهير قد أخبروا بإيداع قائمة شروط البيع وبتاريخ جلسته، حتى يشرفوا على إجراءاته^(١).

(ب) أن يسجل حكم رسو المزاد، وهو لا يسجل إلا بعد دفع الثمن الذى رسى به المزاد بالكامل والمصاريف ورسوم التسجيل.^{2024/2025}

2024/2025

علاقة الحائز بالدائنين المرتنين:

قد لا يفى الثمن بحقوق الدائنين المقيدى ويتبين أن نقص ثمنه يرجع إلى تلفه وأن هذا التلف كان سببه خطأ الحائز، وعندئذ يكون للدائنين الرجوع عليه بتعويض الضرر الناشئ عن هذا الخطأ^(٢) فقد نصت المادة ١٠٧١ مدنى على أن «الحائز مسئول شخصياً قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه» ويقع على من يدعى هذه المسئولية من الدائنين المقيدى عبء إثباتها. ولا يسأل الحائز إلا عن خطئه الذى أدى إلى تلف العقار المرهون، فلا يسأل عن خطأ المالك السابق (الراهن) ولا عن التلف بسبب أجنبى أو بسبب القدم أو الاستعمال العادى. ويقدر التعويض بمقدار ما نقص من قيمة العقار بسبب التلف. ويلحق هذا التعويض بثمن العقار المرهون ويوزع على الدائنين المقيدى بحسب مراتبهم.

(١) مادة ٤٥٠ مرافعات.

(٢) د/ السنهورى: الوسيط ١٠ ص ٦٠٩، د/ منصور مصطفى: ص ١٤٠.

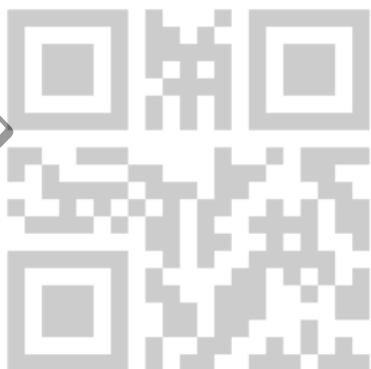


ويسترد الحائز المصروفات الضرورية التي أنفقها على تحسين العقار المرهون حتى لا يثرى الدائنون على حسابه بلا سبب. وإذا أنفق مصروفات نافعة على العقار المرهون أسترده أقل القيمتين. ولا يسترد الحائز المصروفات الكمالية. ويسترد الحائز ما نفقه من مصروفات للحصول على ملكية العقار المرهون كمصروفات سند ملكية ورسوم تسجيل هذا السند ومصروفات إعلان التطهير والتخليه، وكذلك المصروفات التي أنفقها الحائزون السابقون ودفعها عند حيازته للعقار، ويتقدم الحائز بطلب هذه المصروفات لقاضى التنفيذ فى جلسة البيع لتقديرها وإعلان هذا التقدير قبل افتتاح المزادة.

رجوع الحائز على المالك السابق وعلى المدين وعلى الحائزين دون الكفيل:

إذا نزع الدائنون ملكية العقار المرهون من الحائز، كان لهذا الحائز أن يرجع على المالك السابق بدعوى الضمان إذا كان سند ملكيته يخوله ذلك. فقد نصت المادة ١/١٠٨٠ مدنى على أن «يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبعاً». فإذا كان الحائز قد تملك العقار بعقد بيع رجع بضمان الاستحقاق المقرر فى أحكام البيع. وإذا كان الحائز قد تملك العقار بعقد هبه فلا يرجع إلا إذا كانت الهبة بعوض (م ٤٩٤ مدنى). ويرجع الحائز على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب وبدعوى الحلول وقد يرجع بدعوى الضمان، ذلك أنه يترتب على نزع ملكية العقار ^{٢٠٢٥} ~~٢٠٢٤~~ ^{٢٠٢٥} ~~٢٠٢٤~~ ثمنه على الدائنين المقيدين ^{٢٠٢٥} ~~٢٠٢٤~~ وفاء الحائز بديونهم أن تنقضى ديون المدين كلها أو بعضها (م ٢/١٠٨٠ مدنى). ويرجع الحائز على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب بقدر ما أنقضى من الديون مما يزيد على ما كان فى ذمته للمدين، وله الرجوع بدعوى الحلول محل من وفاة من الدائنين وبوجه خاص فيما قدمه المدين من تأمينات أخرى غير العقار المبيع. وإذا كان المدين هو المالك السابق كان له أن يرجع عليه كذلك بدعوى الضمان.

وإذا رهنّت عدة عقارات ضماناً لدين واحد وانتقلت ملكيتها إلى عدة حائزين وبيع أحدها وفاء للدين واحد وانتقلت ملكيتها إلى عدة حائزين وبه أحدها وفاء للدين، رجع حائزه على باقى الحائزين بنسبة قيمة العقار الذى بحوزة كل منهم فقد نصت المادة ٣٣١ مدنى على أنه «إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بسحب قيمة ما أخذه من عقار.



ولا يرجع الحائز على الكفيل الشخصى أو العينى بشئ^(١) ذلك أن الحائز كان يمكن أن يدفع ديون الدائنين مما هو مستحق فى ذمته من ثمن العقار فيخلص نفسه والكفيل من هذه الديون بمقدار ما هو مستحق فى ذمته، ولما لم يغفل فلا يرجع على الكفيل بشئ لكن الكفيل إذا وفى الدين حق الرجوع على الحائز.

الفصل الثالث

انقضاء الرهن الرسمى

الرهن الرسمى حق عينى تبعى، ولهذا فإنه ينقضى بصفة أصلية كما ينقضى بصفة تبعية.

أولاً: انقضاء الرهن الرسمى بصفة تبعية:

إذا انقضى الدين المضمون بالرهن بأى سبب من أسباب الانقضاء ترتب على ذلك انقضاء الرهن باعتباره تابعاً للالتزام الأسمى، وذلك تطبيقاً لقاعدة أن الرهن لا ينفصل عن الدين المضمون، بل يكون تابعاً له فى صحته وفى انقضائه.

ولا ينقضى الرهن بالتبعية إلا إذا انقضى الدين المضمون بتمامه، فإذا بقى جزء من هذا الدين، بقى الرهن قائماً لضمان الوفاء به تطبيقاً لقاعدة عدم تجزئة الرهن.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وانقضاء الرهن بالتبعية فى هذه الحالة يعنى أن ينقضى الالتزام المضمون كله وبصفة نهائية. لكن إذا زال السبب الذى انقضى به الدين المضمون، كما إذا كان قد أنقضى بالوفاء ثم أبطل الوفاء بسبب نقص أهلية الموفى أو لأن الشئ الذى تم به الوفاء غير مملوك للموفى، فإن هذا الدين يعود، ويعود الرهن معه. ولكن يلزم لى يعود الرهن فى هذه الحالة إلا تضر عودته بالحقوق التى يكون الغير قد اكتسبها بحسن نية فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته (م ١٠٨٢ مدنى).

وعلى ذلك إذا أشتري شخص حسن النية العقار فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته، أى فى فترة زوال الرهن، أو إذا أرتهن العقار فى خلال هذه الفترة، فإنه يترتب على ذلك أن عودة الرهن، متى عاد الدين المضمون، لا ينبغى أن تضر بحقوق كل من المشتري أو المرتهن أى أنه لا يحتج بالرهن على كل

(١) م ٧٩١، ١٠٦١، ١٠٨٠/٢ مدنى.

منهما، إنما يلزم أن يكون كل منهما حسن النية، أى يجهل العيب الذى يشوب سبب انقضاء الرهن.

هذا ما نصت عليه المادة ١٠٨٢ مدنى فى خصوص انقضاء الرهن. وإلى جانب ذلك فهناك أحكام تتعلق بأسباب انقضاء الدين وأثرها فى انقضاء حق الرهن أو بقاءه^(١).

ثانياً: انقضاء الرهن بصفة أصلية:

عرض المشرع عند الكلام عن انقضاء الرهن لسببين ينقص بها الرهن بصفة أصلية وهما تطهير العقار، وبيعه بيعاً جبرياً بالمزاد العلنى. وإلى جانب ذلك فقد كان المشروع التمهيدى للقانون ينص على أسباب أخرى هى النزول عن الرهن وإتحاد الذمة والهلاك والتقادم ونعرض فيما يلى لهذه الأسباب.

١ - تطهير العقار:

نصت المادة ١٠٨٣ مدنى على أنه «إذا تمت إجراءات التطهير أنقضى الرهن الرسمى نهائياً ولو زالت لأى سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى طهر العقار». فالرهن ينقضى بالتطهير حتى ولو لم يستوف الشخص إلا بعض حقه بشرط أن تكون إجراءات التطهير قد وجهت إلى المرتهن.

٢ - بيع العقار بالمزاد العلنى:

إذا بيع العقار بيعاً جبرياً بالمزاد العلنى ينقضى الرهن، أى كان من أئخذ الإجراءات، وأياً كانت من اتخذت الإجراءات فى مواجهته، وأياً كان من رسا عليه المزداد. وينقضى الرهن فى هذه الحالة متى سجل حكم مرسى المزداد أو تم التأشير به، بحسب ما إذا رسى المزداد على غير الحائز أو على الحائز نفسه وبشرط أن يودع الثمن الذى رسا به المزداد أو يدفع إلى الدائنين المقيدى الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن. ويراعى أن تحرير العقار من الرهن يكون بالنسبة لأصحاب الحقوق المقيدة الذين أعلنوا بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته (م ٤٥٠ مرافعات).

٣ - النزول عن الرهن:

ينقضى الرهن بالنزول عنه. ويتم ذلك برضاء المرتهن الصريح أو الضمنى ويعتبر اشتراك الدائن المرتهن مع الدائنين الآخرين فى تبادل الرأى بشأن الصلح مع المفلس نزولاً عن الرهن حتى ولو لم يتم الصلح^(٢). وهذا تطبيق تشريعى لفكرة

(١) أنظر المواد ٣٢٩، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٩ من القانون المدنى فى انقضاء الالتزام.

(٢) م ٣١٨ تجارى.

ولا يلزم للنزول عن الرهن شكل خاص، فيصح بورقة عرفية لكن يلزم لمحو القيد إذا ما انقضى الرهن بالنزول أما تقرير رسمي أو حكم نهائي. والنزول عن الرهن يقتضي أن تتوافر في الدائن المنازل أهلية التصرف في الدين المضمون به، إذ قد يترتب عليه عدم إمكان الدائن استيفاء حقه وقد يكون النزول عن الرهن كلياً وقد يكون جزئياً، وإن كان يراعى بالنسبة لهذه الحالة الأخيرة أن قاعدة عدم تجزئة الرهن تؤدي إلى جعل الباقي من العقار ضماناً لكل الدين. هذا ويراعى أن النزول عن الرهن يختلف عن النزول عن مرتبته لدائن آخر، فالنزول عن المرتبة لا يعني انقضاء الرهن بل يظل قائماً.

ينقضى الرهن باتحاد الذمة متى اجتمعت فى الشخص صفتا المرتهن المالك للعقار المرهون، كما إذا انتقلت إلى الدائن المرتهن ملكية العقار المرهون، أو إذا أنقل حق الرهن إلى مالك العقار وقد يحدث أن تجتمع الصفتان السابقتان فى شخص واحد كالحائز الذى يحل محل الدائن، ولكن الرهن لا ينقضى رغم ذلك، متى كانت هناك رهون أخرى على العقار ويكون على الحائز، حتى يحتفظ بمرتبة رهنه على عقار فى يد نفسه، أن يجدد قيده. ولما كان اتحاد الذمة ليس إلا طبيعياً من استعمال الحق، فإنه يوجب على زوال هذا المانع عودة الحق من جديد. فإذا زال سبب انتقال الحق، كما لو فسخ العقد الذى انتقلت به الملكية إلى الدائن مثلاً، يعود الرهن الرسمى، لأن الدائن لا يكون مالكاً للعقار، وتكون عودة الرهن بأثر رجعى.

ينقضى الرهن بهلاك العقار هلاكاً تاماً، وإذا ما هلك العقار المرهون وحل محله مقابل نقدي كـمبلغ تأمين أو تعويض، فإن الحق في الرهن ينتقل إلى هذا المبلغ بمرتبته. وانتقال الرهن الرسمي بمرتبته إلى مبلغ التعويض أو التأمين لا يعني بقاءه، إذ لا يتقرر الرهن الرسمي على مبلغ من النقود. ويأخذ حكم الهلاك انقضاء الحق المرهون. فإذا رهن شخص حق انتفاع ثم انقضى نظراً لانتهاء المدة المحددة للانتفاع انتهى الرهن.

إذا ما أنقضى الدين المضمون بالرهن وأنقضى الرهن بالتبعية، لكن هل يمكن أن ينقضى الرهن بصفة أصلية عن طريق التقادم.



يفرق بين ما إذا كان العقار فى يد الراهن نفسه وبين ما إذا انتقل إلى الحائز. فإذا كان العقار فى يد الراهن لا ينقضى الرهن بالتقادم، لأنه يلزم بالضمان. فهو ملزم بالإبقاء على الرهن لحين الوفاء، وهذا أمر لا خلاف فيه.

أما إذا كان العقار فى يد الحائز، فقد ثار الخلاف حول ما إذا كان الرهن يسقط بالتقادم لمصلحة الحائز أم لا. والفقهاء^(١) يسلم بأن الرهن لا ينقضى بالتقادم حتى ولو كان العقار فى يد الحائز. وذلك أن التقادم هنا لا يتسق مع أنواع التقادم التى يقررها القانون. فلا يمكن اعتباره تقادماً مسقطاً لأن هذا التقادم خاص بالحقوق الشخصية فقط. كما لا يمكن اعتباره تقادماً مكسباً لأن الحائز لا يهدف إلى اكتساب حق بل إلى التخلص من عبء. ولا يمكن اعتباره تقادماً محرراً أو مبرئاً وهو التقادم الذى ينتهى به الحق بعدم الاستعمال المدة الطويلة كحق الإنفاق والارتفاق. لأن الغرض أن الدائن المرتهن لم يسكت عن استعمال حقه، سواء بقبض الفوائد أو بتجديد القيد. هذا فضلاً عن أن القول بالتقادم فى هذه الحالة لا يتفق مع العدالة، لأن المرتهن الذى يقوم بقبض الفوائد ويحدد قيده فى المواعيد، ويقوم بكل ما يجب عليه للحفاظ على حقه، قد يرى نفسه، وقد سقط حقه لمصلحة شخص (الحائز) من المحتمل أن يجهل أنه تحلل بالتقادم وهذا لا يتفق وقصد المشرع الذى يرمى إلى جعل الرهن وسيلة لضمان لحق الدائن.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د/ منصور مصطفى منصور: ص ١٥٤، د/ توفيق فرج: ص ٣٠٠.

الباب الثانى حقوق الامتياز

نظم المشرع حقوق الامتياز فى الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدنى، وذلك فى المواد ١١٣٠ وما بعدها إلى المادة ١١٤٩. وقد عرض فى فصل أول للأحكام العامة المتعلقة بحقوق الامتياز، وفى فصل ثانٍ تكلم عن أنواع الحقوق الممتازة. ولهذا ندرس ما يتعلق بحقوق الامتياز على الترتيب الذى جاء به القانون، فنخصص الفصل الأول للأحكام العامة، والفصل الثانى للحقوق الممتازة كل على حده، لبيان ما يختص به كل منهما من أحكام.

الفصل الأول أحكام عامة

تقسيم :

بينت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى أهمية وضع أحكام عامة لحقوق الامتياز، فذكرت أن هذه الأحكام هى التى تجعل من حقوق الامتياز موضوعاً متماسكاً تنظمه فكرة نسخه متناسقة. وقد أورد القانون فى الأحكام العامة تعريفاً لحق الامتياز، وقسم حقوق الامتياز إلى عامة وخاصة، ميز فى الخاصة منها بين حق امتياز يقع على المنقول وآخر يقع على العقار، وبين أحكام كل من النوعين، ثم ذكر كيف ينتهى حق الامتياز.

2024/2025 2024/2025 2024/2025

ولهذا نقسم دراستنا فى هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة، نتكلم أولاً عن تعريف حق الامتياز مع بيان خصائصه، ثم نعرض بعد ذلك لتقسيم حقوق الامتياز، ثم لآثارها وانقضائها.

المبحث الأول تعريف حق الامتياز وخصائصه

التعريف به :

عرفت المادة ١/١١٣٠ الامتياز بأنه «أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته، فالامتياز طبقاً لهذا التعريف أولوية يقررها القانون للحق، مراعاة منه لصفة هذا الحق. وعلى هذا فإن الامتياز وما يعنيه من أولوية إنما ترتبط بالحق ذاته وليس بصاحبه (الدائن). فالحق هو الممتاز لا الدائن، لأن الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق. فالمشرع يعمد إلى اختيار بعض الحقوق نظراً لأهميتها من زاوية أو أخرى ويجعل منها حقوقاً ممتازة. وتختلف الأولوية التى من أجلها تتقرر هذه الميزة من حالة إلى أخرى، ففى بعض الحالات يتقرر الامتياز

لا اعتبارات إنسانية كما في دين النفقة، وفي حالات أخرى يتقرر الامتياز على مال معين لأن الدائن هو الذى أدخل هذا المال في ذمة المدين (امتياز بائع المنقول)، ومن الحقوق الممتازة ما يقوم على فكرة الرهن الضمنى (امتياز المؤجر وصاحب الفندق).

واعتبار بعض الحقوق ممتازة على هذا النحو هو أمر حكر على المشرع فالقانون وحده هو الذى يملك إضفاء هذا الوصف وتقرير هذه الأولوية، كما أن القانون وحده هو الذى يحدد مرتبة الامتياز الذى يُنشئه. لذلك فلا امتياز بغير نص قانونى، وإذا أضفى القانون صفة الامتياز على حق معين فإن هذه الصفة تظل له حتى ولو تغير صاحبه. فإذا تغير الدائن بسبب ما، كحوالة الحق أو بسبب الوفاء مع الحلول، فإن صفة الامتياز تظل، رغم تغير الدائن، ملازمة للدين ذاته.

والتعريف الذى أورده المشرع تعريف عام جامع، فتعريف الامتياز بأهه أولوية يصدق على جميع الحقوق الممتازة، سواء كانت عامة أم خاصة، واردة على عقار أم منقول، إلا أنه قد لوحظ على هذا التعريف أنه لم يذكر أن الامتياز يخول حق التتبع، كما هو الشأن بالنسبة للحقوق العينية التبعية الأخرى وهى الرهن بنوعيه الاختصاص، ولكن الواقع أن بقاء التعريف على نحو ما جاء به المشرع دون أن يشار فيه إلى أن الامتياز يخول حق التتبع، يجعل هذا التعريف التشريعى يشمل جميع حقوق الامتياز من بين حقوق الامتياز، وهى حقوق 2024/2025 2024/2025 الامتياز العامة ما لا يخول حق التتبع.

خصائص الحق الممتاز :

على ضوء التعريف السابق يمكننا أن نسن خصائص الحق الممتاز وهى:

١- الامتياز أولوية :

لا شك أن جميع حقوق الامتياز تخول لمن تقرر لصالحه أولوية، وهذا ما عنى المشرع بالنص عليه فى تعريفه للامتياز فى المادة ١/١١٣٠، فهذا النص يبرز أهم أثر للامتياز وهو ما يخوله من أولوية أو تقدم. وتشارك الحقوق الممتازة فى هذا مع الحقوق العينية التبعية الأخرى.

لكن هل يقتصر أثر الامتياز على هذه الأولوية فقط، أم أنه يخول كذلك حق التتبع، أم أن الخلاف فى الفقه هو نوع من حقوق الامتياز، وهى حقوق الامتياز العام؟ وهل تعتبر حقوقاً عينية أم لا، باعتبار أنها لا ترد على مال معين من أموال المدين، والحق العينى يرد على مال معين بالذات. وإن كان المشرع قد

نص على أن حق التتبع لا يثبت لهذا النوع من الامتياز، إلا أن أغلبية^(١) الفقه يقرر أن حقوق الامتياز سواء كانت حقوقاً عامة أو حقوقاً خاصة وقعت على عقار أو على منقول، هي في جميع الحالات حقوق عينية، وهي دائماً تخول لصاحبها حق التقدم وحق التتبع. ذلك أن المشرع المصري قد أكد هذه الحقيقة حين أودع حقوق الامتياز الباب الرابع من الكتاب الرابع والذي ينظم فيه الحقوق العينية التبعية. غير أن حقوق الدائن في التتبع والتقدم تتأثر بالضرورة حين ترد على منقول، بقاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية، وبالتالي فإذا وقع الامتياز على منقول فإنه لن يحتج به على من حاز هذا المنقول بحسن نية.

٢- حقوق الامتياز لا تنشأ إلا بناء على نص

من أهم خصائص حقوق الامتياز أن مصدرها دائماً هو القانون، والقاعدة أنه لا امتياز إلا بنص. وقد نصت المادة ٢/١١٣٠ على هذا بقولها «لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون».

وعلى ذلك لا يجوز أن يتقرر الامتياز للحق بالإنفاق، كما هو الشأن بالنسبة للرهن بنوعيه، ولا بأمر القاضى كما هو الشأن بالنسبة لحق الاختصاص. لك أن حقوق الامتياز يترتب عليها الإخلال بمبدأ المساواة بين الدائنين، فهي بذلك تعد استثناء من هذا المبدأ، لا يتقرر إلا بالنص.

2024/2025 وطالما أنه يلزم النص عليها، فإنه ينبغي مراعاة عدم التوسع في تفسيرها 2024/2025 أو القياس عليها. فلا يصح التوسع في تفسير النصوص التي تخول امتياز للحقوق، كما لا يصح القياس عليها، وإنما يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً.

ولكن هذا لا يعنى أن وعاء الأفضلية أو ما يرد عليه حق الامتياز لا يضمن إلا الحق الممتاز فقط مجرداً عن توابعه، بل أن الامتياز ضمن فضلاً عن أصل الحق، توابعه كمصروفات للمطالبة بالدين وفوائده، وما قد يكون هناك من تعويضات بسببه. هذا من ناحية الحق الممتاز، أما من ناحية وعاء الأفضلية فإن الفكرة الاستثنائية للامتياز تؤدي كذلك إلا يمتد وعاء الأفضلية إلى خارج ما نص عليه القانون.

(١) د. السنهورى، الوسيط، ج ١ ص ٩٦٨، د. منصور مصطفى: ص ٢٣٥، وتوفيق فرج، د. سليمان مرقص: ص ٥١٦.

٣- الامتياز صفة للحق

يتقرر الامتياز لصفة في الحق، لا في صاحب الحق، فالمشرع يدخل في اعتباره عند تقريره بأن حقاً من الحقوق يعتبر ممتازاً، طبيعة هذا الحق، لا شخص الدائن. وهذا ما حرص المشرع على النص عليه، ولهذه الفكرة أهميتها، ذلك أن إعطاء الامتياز للحق لا لصاحب الحق يترتب عليه أن يظل الامتياز حتى ولو تغير صاحبه عن طريق تحويله إلى الغير، أو حلول آخر محله فيه، كما يستطيع دائنوه أن يفيدوا منه عن طريق الدعوى غير المباشرة.

على أن هذه الأفضلية التي يقرها القانون للحق مراعاة منه لصفته، إنما تتقرر لأهداف معينة، ذلك أن كل امتياز يعتبر تأمينا قانونياً يستند إلى ما يبرره من اعتبارات خاصة مبناها الصالح العامة العدالة، فالمشرع لا يهتم شخص الدائن، وإنما تهمه صفة الدين. فقد يثبت الامتياز للحق لأن الصالح العام يقتضي ذلك، كما هو الشأن بالنسبة لامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة، وقد يثبت الامتياز لأن العدالة تستلزم ذلك، كما إذا كان الدائن قد أنفق نفقات استفاد منها باقي الدائنين، وهو ما يكون في حالة امتياز المصروفات القضائية، لأن الدائن قد أضاف شيئاً جديداً إلى ذمة المدين يستفيد منه باقي الدائنين، كما هو الشأن بالنسبة لامتياز البائع إلى غيره من الاعتبارات بالنسبة لبقية حقوق الامتياز.

والاعتبارات التي يقوم عليها تقرير الامتياز لحق من الحقوق، هي نفسها التي تملئ عليه الترتيب الذي يجب مراعاته بالنسبة لحقوق الامتياز.

٤- عدم القابلية للتجزئة

عدم القابلية للتجزئة مبدأ قائم بالنسبة للرهن الرسمي والحيازي وحق الاختصاص، فهل يمكن إعمال هذا المبدأ بالنسبة لحقوق الامتياز، بمعنى أن كل جزء من المال المحمل بالامتياز يعتبر ضامناً للحق الممتاز كله. وأن كل جزء من الحق مضمون بالمال الذي يرد عليه الامتياز جميعه.

يرى الفقه إعمال هذا المبدأ بالنسبة لحقوق الامتياز كذلك، هذا ما لم يوجد سبب يدعو إلى التجزئة، كما إذا نشأ الامتياز على حصة شائعة من العقار المملوك كله للمدين ثم باع المدين جزءاً مفرزاً من العقار، فلا يجوز للدائن أن يدعى الامتياز على الجزء المبيع مادام الباقي لا يقل عن الحصة الشائعة التي يرد عليها الامتياز، وكذلك إذا شمل البيع منقولات وعقارات بثمن واحد، فإن الامتياز لا يتجزأ، فلا يضمن امتياز بائع العقار وامتياز بائع المنقول كل الثمن، ويتعين قصر الامتياز العقاري على ما يقابل العقار، إذ هناك امتيازان مستقلان،

أحدهما على العقارات والآخر على المنقولات. والواقع أن التسليم بمبدأ عدم القابلية للتجزئة يرتبط بالنظر إلى الامتياز على أنه حق عيني يخول لصاحبه حق التتبع، فإذا سلم بذلك، فإن حق الامتياز لا يتجزأ كالرهن والاختصاص.

المبحث الثانى

تقسيم حقوق الامتياز

تنقسم حقوق الامتياز من حيث الأموال التى ترد عليها إلى قسمين، حقوق الامتياز العامة، وحقوق الامتياز الخاصة. وهذا ما عرض له المشرع فى المادة ١١٣٢ حيث نص «ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

أولاً: حقوق الامتياز العامة :

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار، فلا يتحدد وعاء الأفضلية بمال معين بالذات من أموال المدين، وإنما يتحدد بما لدى المدين من أموال عند التنفيذ، بصرف النظر عما ما لديه وقت نشوء الحق الممتاز. فأهمية هذا النوع من الحقوق الممتازة يبدو وقت التنفيذ، حيث تظهر الأولوية التى يقرها القانون للحق. من هذا النوع من الحقوق المبالغ المستحقة للإجراء النفقة.

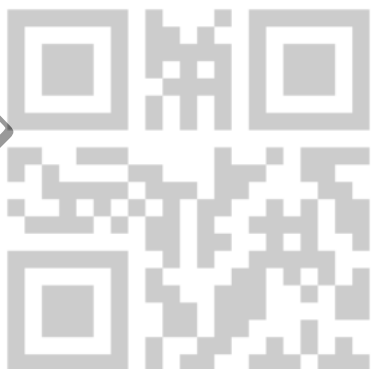
2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويقتصر أثر هذا النوع من الحقوق الممتازة على منح صاحبها أفضلية على غيره من الدائنين، فلا يخضع لقاعدة المساواة بين الدائنين. وإذا كان أثرها يقتصر على ذلك، فإنه لا يخول لصاحبها سلطة تتبع الأموال التى يرد عليها الحق فى يد من تصرف إليه المدين. وعلى ذلك يستطيع المدين المحملة أمواله بامتياز عام أن يتصرف فى أمواله فينقضى بذلك ما عليها من امتياز على ما هو موجود فى ذمة مدينه وقت التنفيذ فقط. ذلك أن حقه لا يرد على مال معين بالذات مع أموال المدين. وهذا ما يفرق بين هذا النوع من الحقوق الممتازة وبين التأمينات العينية الأخرى التى لا يقتصر أثرها على منح الأفضلية فقط بل تخول كذلك حق التتبع مما دفع الفقه^(١) إلى القول بأن حق الامتياز العام، إنما هو وصف يلحق بالدائن يخول الدائن أفضلية على غيره من الدائنين فى استيفاء حقه، وبالتالي فإنه لا يعد حقاً عينياً تبعياً.

(١) د منصور مصطفى منصور، ص ٢٣٩، د سليمان مرقص، ص ٢٧.



على أنه إذا كان أثر هذا النوع من الحقوق الممتازة يقتصر على تخويل الدائن أولوية في استيفاء حقه، فإن هذه الأولوية يقرها القانون قبل الدائنين الآخرين، دون حاجة إلى شهر الحق، حتى ولو كانت الأموال التي يرد عليها الامتياز عقارية. وقد نصت المادة ١١٣٤ في فقرتها الثانية على أن «حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً، لا يجب فيها الشهر، ولا يثبت فيها حق التتبع» كما نص المشرع كذلك على أنه «لا حاجة للشهر أيضاً في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة».

وقد حدد النص السابق كذلك مرتبة هذا النوع من الحقوق الممتازة فبين أن «هذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون أسبق في المرتبة على أى حق امتياز عقارى أخرى، أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة».

ثانياً: حقوق الامتياز الخاصة :

ترد حقوق الامتياز الخاصة إما على منقول معين أو منقولات معينة، وإما على عقار معين أو عقارات معينة، ولكل منها أحكام خاصة بها تتفق وطبيعة ما يرد عليه حق الامتياز.

١ - حقوق الامتياز الخاصة المنقولة:

٢٠٢٤/٢٠٢٥ قد ترد حقوق الامتياز على منقول معين أو منقولات معينة، وذلك مثل ٢٠٢٤/٢٠٢٥ امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة، وامتياز بائع المنقول.

وحقوق الامتياز في هذه الحالة تعتبر حقوقاً عينية تبعية تخول لمن تثبت له حق التقدم والتتبع، فللدائن صاحب الحق الممتاز أن يتقدم على ثمن المنقول المحمل بالامتياز، هذا فضلاً عما يكون له من ضمان عام على أموال المدين الأخرى باعتباره دائناً عادياً، ولكنه في هذه الحالة يتزاحم مع سائر الدائنين العاديين ويخضع لقسمة الغرماء.

كما أن لصاحب الحق الممتاز أن يتبع الشئ الذى يرد عليه الامتياز في يد من يكون ليستوفى حقه بأولوية. إلا أن هذا الحق قد يتعطل بسبب أعمال قاعدة الحيابة في المنقول، فقد يحوز شخص المنقول الذى تقرر عليه حق الامتياز مستنداً إلى سبب صحيح، ففي هذه الحالة ليس لصاحب حق الامتياز الاحتجاج بحقه على هذا الحائز، متى كان هذا الأخير حسن النية، أى يجهل أن

هناك امتياز عليه، وعلى هذا تنص المادة ١/١١٣٣ مدني «لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية».

وقد اعتبر المشرع حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه. وعلى هذا يحق لمؤجر العقار وصاحب الفندق، التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز بالنسبة للمنقولات المشار إليها في النص، إذ المشرع يعتبرهما حائزين لتلك المنقولات. ولهذا لا يصح لمن كان له حق امتياز على تلك المنقولات الاحتجاج بحقه قبلها، فإذا كان المستأجر قد اشترى منقولاً لم يدفع ثمنه، وأدخله في العين المؤجرة، وكان المؤجر حسن النية، أى لا يعلم بامتياز البائع، فإن هذا الامتياز الأخير لا يحتج به على المؤجر وكذلك الأمر لو كان المنقول لم يدفع ثمنه ودخل في أمتعة نزيل الفندق، فلا يحتج بامتياز البائع على صاحب الفندق.

على أنه إذا كان لصاحب حق الامتياز أن يتبع المنقول ليمارس عليه أولوية في أى يد يكون، فإنه قد لا يتسنى له مباشرة هذا الحق والإفادة من امتياز، مما دعا المشرع إلى تخويله الحق في طلب وضع المنقول تحت الحراسة، متى خشى تبديده، وكانت هناك أسباب معقولة. وقد نصت المادة ٣/١١٣٣ مدني على هذا بقولها «إذا خشى الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول بحق امتياز المستحقة، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة» ذلك أنه لما كان حق الامتياز الخاص على منقول عرضة للضياع فقد أجاز القانون، إذا خشى الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق الامتياز، أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

٢- حقوق الامتياز الخاصة العقارية :

ترد حقوق الامتياز الخاصة العقارية على عقار أو عقارات معينة وهي امتياز بائع العقار، وامتياز المقاول والمهندس المعماري، وامتياز المتقاسم في العقار. وهي تشبه الرهن الرسمي خاصة من حيث ما ترتبه من آثار ولا تختلف إلا من حيث المصدر، إذ أن مصدرها القانون والرهن مصدره الاتفاق. أما ماعدا هذا من أحكام، فإنها واحدة. وتنص المادة ١/١١٣٤ على أنه «تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق، وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيود وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو».

وحق الامتياز الخاص على العقار حق عيني، لا جدال بشأنه كما هو الحال بالنسبة لحقوق الامتياز الأخرى - العامة والخاصة - على المنقول، ولا شك أنه يترتب على قيامه ما يترتب على الرهن الرسمي من آثار، سواء من حيث التقدم أم من حيث التتبع وذلك متى تم شهره.

المبحث الثالث

آثار حقوق الامتياز وانقضاؤها

إذا ما تقرر أن حقاً ما من الحقوق الممتازة، فإنه يصير كذلك بمجرد تقريره، سواء فيما بين صاحب الحق والمدين، أم بالنسبة إلى الغير، إلا أنه قد يلزم الشهر في بعض الأحيان للاحتجاج به على الغير. فإذا ما اتخذ هذا الإجراء، ترتبت على الامتياز آثاره من حيث تخويل صاحبه التقدم والتتبع، ونعرض أولاً لشهر حقوق الامتياز، ثم للتقدم والتتبع، ثم أخيراً لانقضاء هذه الحقوق.

أولاً: شهر حقوق الامتياز :

تنقسم حقوق الامتياز من حيث خضوعها للشهر إلى طائفتين: طائفة لا يجب فيها الشهر، وطائفة أخرى يجب شهرها حتى يمكن الاحتجاج بها على الغير.

أما بالنسبة للطائفة الأولى، التي لا يجب فيها الشهر، فإنها تشمل حقوق الامتياز العامة، حتى ولو كانت ^{2024/2025} على عقار. وكذلك لا يلزم الشهر بالنسبة ^{2024/2025} لحقوق الامتياز الخاصة الواردة على المنقول، كما لا تخضع للشهر كذلك حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة.

بالنسبة للطائفة الثانية، من حقوق الامتياز، وهي التي يجب شهرها، فهي حقوق الامتياز الخاصة الواردة على العقار، وهذا النوع من الحقوق تنطبق عليه أحكام الرهن الرسمي من حيث ضرورة قيدها للاحتجاج بها على الغير وتأخذ مرتبتها من وقت القيد. وتسرى أحكام القيد من آثار وتجديد ومحو، كما يجوز تطهيرها.

وقد نصت المادة ١/١١٣٤ على هذا بقولها «تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق، وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد، وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو».

وإذا كان يتضح من هذا النص سريان أحكام القيد على حقوق الامتياز الواقعة على عقار بصفة عامة، إلا أن المشرع عاد في الفقرة الثانية من المادة واستثنى من ذلك حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً، وكذلك حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة، على ما بينا سالفاً.

ثانياً: حق التقدم :

لا خلاف أن جميع حقوق الامتياز تخول لمن تقررت لصالحه أولوية في استيفاء حقه، سواء كان حق الامتياز عاماً أو خاصاً، وبالنسبة لما يرد عليه التقدم، فإن المشرع يبين بالنسبة لحقوق الامتياز ما يرد عليه التقدم. فلا يكون التقدم إلا في حدود ما يرد عليه الامتياز، بتحويل صاحب الحق الممتاز أولوية على ثمنه أو بصفة عامة على المقابل النقدي لما يرد عليه الامتياز، فإذا هلك الشيء الذي يرد عليه الامتياز أو تلف، انتقل حق الامتياز إلى المقابل النقدي الذي حل محله، وتسرى في هذا الصدد الأحكام المتعلقة بهلاك الشيء المرهون أو تلفه على ما بينا عند التعرض للرهن الرسمي (المادة ١١٣٥ مدني).

وتبدو أهمية هذا الحكم المتعلق بتطبيق أحكام الرهن في حالة الهلاك أو التلف بالنسبة لحقوق الامتياز الخاصة، أما بالنسبة لحقوق الامتياز العامة، فإن حق الامتياز يمتد في حالة الهلاك أو التلف إلى ما يكسبه المدين من حقوق عوضاً عن الشيء بمجرد دخوله في ذمته، لأن هذا النوع من حقوق الامتياز لا يتعلق بحال معين من أموال المدين، بل أنه يتمثل في أولوية للحق الممتاز تبدو عند التنفيذ.

وبالنسبة للمبالغ التي يضمنها الامتياز، فإن القانون يتولى تحديدها كذلك في النصوص المقررة لحق الامتياز، ومع ذلك، فإنه ينبغي أن يراعى أن الامتياز يضمن في الوقت نفسه، فضلاً عن الدين الذي يتقرر الامتياز بصده، ملحقات هذا الدين توابعه الطبيعية، كالفوائد والمصروفات المتصلة بنشأة الحق أو باستيفائه، مع مراعاة ما ينبغي أن تفهم فكرة الملحقات في أضيق الحدود.

أما بالنسبة لكيفية مباشرة حق التقدم، عندما يتزاحم صاحب الحق الممتاز مع غيره من الدائنين أو مع غيره من أصحاب الحقوق الممتازة الأخرى، فإنه يجب أن نفرق بين هاتين الحالتين :

بالنسبة للتزاحم مع دائنين آخرين، لا شك أن صاحب الحق الممتاز يفضل على الدائنين العاديين في حدود وعاء الأفضلية بالنسبة لحقه. وأما بالنسبة

للدائنين الآخرين الذين لهم حق التقدم كذلك بما لهم من رهن أو اختصاص، فإنه يجب أن يفرق بين نوعين من حقوق الامتياز :-

(١) حقوق الامتياز المعفاة من الشهر وهي حقوق الامتياز العامة، ولو كان محلها عقار، وحقوق الامتياز لعقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخرانة العامة، فهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون أسبق في المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر، أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده (م ٢/١١٣٤). وقياساً على الرهن الرسمى، يرى الفقه تقديم هذا النوع من الحقوق الممتازة كذلك على حق الاختصاص مهما كان تاريخ قيده، وبصفة عامة حقوق الامتياز العقارية التى لا تشهر تسبق فى المرتبة كل امتياز عقارى آخر وكل حق مقيد مهما كان تاريخ قيده (١) .

أما فيما بينها، فإن امتياز المبالغ المستحقة للخرانة تسبق فى المرتبة حقوق الامتياز العامة وتستوفى حقوق الامتياز العامة فيما بينها بنسبة كل منها.

(٢) حقوق الامتياز الخاضعة للشهر، وهي حقوق الامتياز الخاصة العقارية، وهذا النوع من الحقوق يأخذ حكم الرهن الرسمى، وتكون الأفضلية بينها وبين الرهن والاختصاص على أساس الأسبقية فى القيد.

وبالنسبة لتزاحم حقوق الامتياز فيما بينها، فإن القانون هو الذى يتولى تحديد مرتبتها، فإذا لم ينص صراحةً فى حق ممتاز على مرتبة امتياز، كان هذا الحق متأخراً فى المرتبة عن كل امتياز أورده القانون المدنى فى الباب المخصص لحقوق الامتياز، بصرف النظر عما إذا كان هذا الحق الممتاز وارد على موضع آخر فى القانون المدنى، أم فى قانون خاص.

على أنه إذا كانت الحقوق الممتازة، فى مرتبة واحدة، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ثالثاً: حق التتبع :

إذا كان من المسلم به أن حق الامتياز يخول لصاحبه الأولوية دائماً. فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لحق التتبع، إذ لا يخول الامتياز دائماً حق التتبع. ذلك أن هناك من حقوق الامتياز ما لا يثبت فيها التتبع، كما أنه قد لا يتسنى التتبع فى بعض الأحيان من حيث الواقع.

(١) المذكرة الإيضاحية، ح ٧، ص ٣١٨.





فهناك من بين حقوق الامتياز ما لا يثبت فيها التتبع بنص في القانون، وهذا هو الشأن بالنسبة لحقوق الامتياز العامة، إذ لا تخول هذه الطائفة من الحقوق لصاحبها حق التتبع (م/١١٣٤ مدنى). وفى بعض الحالات قد لا يتسنى التتبع من الناحية العملية وذلك متى كان الامتياز وارد على منقول، إذ يتعطل حق التتبع نتيجة للتمسك بقاعدة الحيازة فى المنقول، فمتى حاز شخص منقولاً بسبب صحيح، وكان حسن النية، فإنه لا يحتج عليه بحق الامتياز الوارد على هذا المنقول.

وفيما عدا ما سبق بيانه، فإن الامتياز يخول صاحبه حق التتبع. فالتتبع يثبت فى حقوق الامتياز الخاصة على العقار، كما هو الشأن تماماً بالنسبة للرهن الرسمى، وذلك متى قيد حق الامتياز، بل أنه يثبت كذلك للخزانة العامة بالنسبة للعقار الضامن للمبالغ المستحقة لها حتى ولو لم يشهر حق الامتياز فى هذه الحالة (م/١١٣٩/٢). وفى المنقول كذلك، يكون لصاحب الامتياز تتبعه ولو حازه شخص آخر، وذلك إذا لم تتوافر شروط التمسك بقاعدة الحيازة، بأن كان الحائز لا يستند إلى سبب صحيح أو لم يكن حسن النية.

انقضاء الحق :

ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة، وفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك (م/١١٣٦ مدنى). 2024/2025 2024/2025 2024/2025

وعلى ذلك فإن حق الامتياز قد ينقضى بصفة أصلية، كما ينقضى بصفة تبعية، لأنه حق تبعى يتقرر ضماناً لحق أصلى، فإذا كان الامتياز وارد على عقار طبقت الأحكام الواردة بالنسبة للرهن الرسمى، وإن كان وارداً على منقول طبقت الأحكام الخاصة بانقضاء الرهن الحيازى، كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

ويراعى أنه يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقاً لحكم المادة ٤٤٨ مرافعات تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهن الرسمية والحيازية التى أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع، وأخبروا بتاريخ جلسته طبقاً لقانون المرافعات، ولا يبقى لهم إلا حقهم فى الثمن.



الفصل الثانى

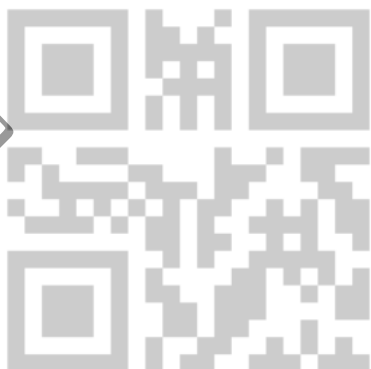
أنواع الحقوق الممتازة

تمهيد:

بين المشرع الحقوق الممتازة فى الباب الخاص بها فى المجموعة المدنية فى نهاية كلامه عن الحقوق العينية. إلا أنه إلى جانب تلك الحقوق، توجد حقوق أخرى ممتازة مقرره بنصوص خاصة، سواء وردت تلك النصوص الخاصة فى المجموعة المدنية نفسها أو فى قوانين خاصة. ومن أمثلة ما جاء فى المجموعة المدنية امتياز القروض التى يمنحها اتحاد ملاك الطبقات للشركاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم (م ٨٦٩). ومن أمثلة ما نص عليه فى المجموعات الأخرى ما جاء من المادة ٨٥ من القانون التجارى من إعطاء الوكيل بالعمولة امتياز على البضائع المرسله أو المسلمة إليه أو المودعة عنده أجل المبالغ المطلوبة له من عملية. ومن أمثلة ما نص عليه فى قوانين خاصة ما نص عليه قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ فى المادة ١١٧ منه على أن «أنعاب المحامى وضمانات الإفراج والكفالات أياً كان دافعها حق امتياز يلى مباشرة حق الخزنة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة الدعوى موضوع الوكالة.

هذه الحقوق الممتازة الواردة فى غير الباب المخصص لحقوق الامتياز فى المجموعة المدنية تقوم إلى جانبه، كما بينت المادة ١١٣٧، وقد ينص القانون على ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مرتبة الحق الممتاز فى النقص ٢٠٢٤/٢٠٢٥ الخاص به، فإذا لم يحدد القانون مرتبة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ الامتياز الذى ينص عليه كان هذا الحق متأخر فى المرتبة عن كل امتياز وارد المشرع فى الباب الخاص بحقوق الامتياز فى المجموعة المدنية (م ١/١١٣١ مدنى).

ولن نعرض لدراسة حقوق الامتياز التى ينص عليها فى مواضع أخرى غير الباب المخصص لحقوق الامتياز، وسنكتفى بدراسة ما أورده المجموعة المدنية فى هذا الباب. وقد قسمها المشرع إلى طائفتين: الأولى تكلم عن حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول الطائفة الثانية تكلم عن حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار. ونعرض لكل من الطائفتين.





المبحث الأول حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول

بيانها وترتيبها:

أورد المشرع هذه الحقوق في المواد ١١٣٨ وما بعدها حتى المادة ١١٤٦. وقد رتبها بحسب درجة امتياز، فجعل امتياز المصروفات القضائية في المرتبة الأولى ثم تلاه امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة، فامتياز المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وترميمه، ثم مقابل آلات الزراعة، ثم امتياز مؤجر العقار وامتياز صاحب الفندق، مع إعطائهما مرتبة واحدة، وعند تراحمهما يقدم الأسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر وأخيراً نص على امتياز بائع المنقول فيه وجعلا في مرتبه واحدة كذلك وعند تراحمهما يقدم الأسبق في التاريخ. ونعرض فيما يلي لأحكام الحقوق الممتازة التي أوردها القانون على النحو السابق، بحسب ترتيبها.

أولاً: امتياز المصروفات القضائية:

نص القانون:

نصت على هذا الامتياز صاحب المرتبة الأولى من بين الحقوق الممتازة

2024/2025

2024/2025

جميعاً، المادة ١١٣٨ مدني بقولها:

2024/2025

١- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال.

٢- وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي، بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم، وتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

ويستند تقرير هذا الامتياز إلى اعتبارات العدالة، فهو يغر المبالغ التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة عن غيرها من الديون ويقرر لها الأولوية في الاستيفاء. ومن قبيل هذه المصروفات نفقات الحجز التحفظية، والحراسة ورفع دعوى غير مباشرة ومصاريف دعوى الاستحقاق لرد الشيء في ذمة المدين والحجز التنفيذي وإجراءات نزع الملكية وتوزيع حصيلة البيع. فكل هذه المبالغ إنما تم إنفاقها للمصلحة المشتركة لجماعة الدائنين وليست لمصلحة خاصة لواحد فقط وتكون الفائدة من ورائها قد عادت إليهم في صورة وحولهم إلى حقوقهم أو جزء



من هذه الحقوق في حالة قسمة الغرماء، ولذلك يتعين على هؤلاء الدائنين أن يسددوا هذه المبالغ لمن أنفقها أولاً قبل أن يقتسموا حصيلة البيع.
شروط تحقق الامتياز:

يتعين لتوافر هذا الامتياز ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن تكون المصروفات قد أنفقت في مجموعة الإجراءات التي تستهدف المحافظة على مال المدين وصولاً إلى بيعه وتقسيم ثمنه بين الدائنين على أي راعى في ذلك أمرين:

الأول: لا يدخل في نطاق هذا الامتياز ما يتفق على حفظ أموال المدين من تلف مادي لترميمها، ذلك أن مثل هذه النفقات تدخل ضمن امتياز آخر هو امتياز الحفظ والترميم. ذلك أن المقصود في امتياز المصروفات القضائية هو تقرير أولوية للديون التي تنشأ عن الحفظ القانوني لأموال المدين في إطار الهدف المشترك لجماعة الدائنين من التنفيذ.

الثاني: أن تعتبر المصروفات القضائية لا ينحصر فقط في الإجراءات القضائية بالمعنى الضيق وهي إجراءات الحجز والبيع، بل يمتد ليشمل مصروفات العمليات غير القضائية الملحقة واللازمة لإجراءات الحجز والبيع والتوزيع، مثل المصروفات اللازمة لوضع الأختام أو تحرير محاضر الجرد لحصر أملاك المدين أو حصر التركة أو إجراءات القسمة، ولا يشترط أن تكون الإجراءات قد اتخذت بناء على طلب أحد الدائنين.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الشرط الثاني: أن يكون الإنفاق قد تم في سبيل المصلحة المشتركة للدائنين الهدف من هذا الشرط هو تحديد أن الامتياز لا ينصرف إلى مصروفات أنفقت في مصلحة خاصة لدائن معين. فإذا رفع أحد الدائنين مثلاً دعوى لتحقيق دينه وحكم له به فإن المصروفات القضائية التي تم صرفها في هذا النطاق ليس ديناً ممتازاً لأنها أنفقت لمصلحة الدائن الخاصة وليس لمصلحة لدائنين جميعاً ولكن الدائن إذا تجاوز مرحلة الحصول على حكم وقام بتوقيع الحجز التنفيذي على أموال المدين وقام بإجراءات البيع فإن هذه المصروفات الأخيرة تعتبر ديناً ممتازاً لأنها تجاوزت مصلحة الدائن الخاصة لكي تصب في مصلحة جماعة الدائنين جميعاً.

ومسألة ما إذا كان لإجراء قد اتخذ لمصلحة خاصة بدائن معين أم أنها انصرفت لمصلحة الجميع هي مسألة يقدرها القاضي في كل حالة وفقاً لما يقدره من ظروف هذه الإجراءات وما انتهت إليه من نتائج ويمكن إثبات المصلحة بكافة الطرق ولو بقرائن الحال.



الشرط الثالث: يجب أن تكون الإجراءات التي تم إنفاق المصروفات في إنجازها قد تمت وفقاً للقانون. ومعنى ذلك أن يكون الإجراء لازماً من الناحية القانونية، فإن لم يكن كذلك قام شخص بإجرائه من قبيل التزيد والتطوع فإن ما ينفقه فيه لا يعد ديناراً ممتازاً. وتطبيقاً لذلك فإن الإجراءات التي يقوم بها المأمور القضائي أو الخبير كل في حدود ما تختص به من إجراءات تكون مصروفاتها حقوقاً ممتازة. أما إذا قام شخص ليست له إحدى الصفتين السابقتين مثلاً بإجراء تصفية ودية لأموال المدين دون أن يحصل على توكيل من كل أصحاب الشأن، فإن ما ينفقه هذا الشخص من مصروفات لا يتمتع بوصف الامتياز.

محل الامتياز:

يقع امتياز المصروفات القضائية على ثمن الأموال التي تم الصرف من أجل المحافظة عليها أو بيعها وهو الثمن الذي يرسو به المزاد نتيجة للتنفيذ عليها. وينحصر الامتياز في ثمن هذه الأموال فقط ولا يتعداها إلى غيرها. ويستوى أن تكون الأموال المشار إليها عقاراً أو منقولاً أو الاثنين معاً لأن الامتياز يرد على الثمن الذي بيعت به تلك الأموال ولا يرد على الأموال ذاتها.

مرتبة امتياز المصروفات القضائية:

يأتى امتياز المصروفات القضائية في المرتبة الأولى، فيتقدم الدائن بالمصروفات على كل حق آخر سواء كان الدائن بهذا الحق دائناً عادياً أو كان ^{2024/2025} ~~مضموناً بتأمين عيني~~ ^{2024/2025} ~~أياً كان التأمين~~. مع ملاحظة أن التقدم يكون في ^{2024/2025} استيفاء دين المصروفات فقط، فإذا كان من أنفق المصروفات هو أحد الدائنين فلا أثر لامتيازه في استيفاء حقه الذي سعى بإنفاق المصروفات إلى الحصول عليه.

أما إذا تعددت المصروفات فتكون الأولوية للمصروفات التي أنفقت في الحفظ والبيع على تلك التي أنفقت في توزيع الثمن. وإذا تعددت المصروفات التي أنفقت في الحفظ والبيع فيتساوى الدائنون بهذه المصروفات بمعنى أن تستوفى قبل أى حق آخر، بنسبة الدائنون بهذه المصروفات بمعنى أن تستوفى قبل أى حق آخر، بنسبة قيمة كل منها، وكذلك إذا تعددت المصروفات التي أنفقت في التوزيع فيتساوى الدائنون بها.



ثانياً: امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة:

تنص المادة ١١٣٩ مدنى على أن:

١- المبالغ المستحق للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن.

٢- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق آخر، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.

وبناء على هذا النص فإن الامتياز فى هذه الحالة يضمن جميع المبالغ المستحقة للخزانة العامة، أياً كان نوع هذه المبلغ، كالضرائب والرسوم. بشرط أن يتقرر امتياز هذه المبالغ فى القوانين والأوامر الخاصة بها، فإذا لم تقرر القوانين والأوامر امتياز للمبالغ التى تستحق للدولة لا تتمتع هذه المبالغ بالامتياز المنصوص عليه هنا. والقوانين والأوامر التى من هذا النوع متعددة منها القانون الخاص بضريبة الأطنان، والقانون الخاص بضريبة البانى، والضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجارية والصناعية....الخ.

محل الامتياز ومرتبته:

محل هذا الامتياز هو ثمن الأموال المنقلة به، والتى تبينها القوانين الخاصة فى كل حالة. فقد يرد على ثمن حق خاص من أموال المدين مثل امتياز ضريبة المبانى الذى يتقرر على الأرض المستحقة عليها الضريبة وعلى ثمارها ومحصولاتها وعلى المواشى والمنقولات التابعة لهذه الأرض. وقد يرد الامتياز عاماً على جميع أموال المدين من منقولات وعقارات، كامتياز المبالغ المستحقة عن الضريبة العامة على الإيراد، فهو لا يرد على مال معين بذاته.

ويأتى امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة فى المرتبة الثانية بعد امتياز المصروفات القضائية. وتفضل هذا المبالغ على أى حق آخر سواء كان هذا الحق ممتازاً أم كان مضموناً بتأمين عيني آخر، أياً كان تاريخ قيده.

هذا ويراعى أن هذا الامتياز يخول حق التتبع بصفة عامة، سواء تعلق الأمر بعقار أو منقول، وفى الحالة التى يتقرر فيها على عقار فإنه يخول حق التتبع دون حاجة إلى الشهر. إلا أنه فى حالة وروده على منقول قد يتعطل حق التتبع نتيجة للتمسك بقاعدة الحيازة فى المنقول.

ثالثاً: امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه:

تنص المادة ١١٤٠ مدنى على أنه:

١- المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه.

٢- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة. أما فيما بينها فيتقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتواريخ صرفها.

والحكمة من تقرير هذا الامتياز أن هذه المصروفات كانت السبب فى حفظ المنقول من الهلاك أو التلف فكانت بذلك سبباً فى تمكين الدائنين من الحصول على ديونهم من الثمن أو فى الأقل سبباً فى رفع قيمة المنقول عند بيعه والغالب أن يكون ارتفاع القيمة مساوياً لقيمة المصروفات إن لم يكن أكثر منها.

الحق الممتاز:

الحق الممتاز هو الحق فى الحصول على المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وترميمه. فلا يضمن هذا لامتياز ما ينفق عليه من حفظ وترميم العقار. ومصروفات الحفظ والترميم هى المصروفات التى أدت إلى منه الهلاك أو التلف، فلا تشمل المصروفات النافعة التى لم يحفظ المنقول بل كان الغرض منها تحسينه. وقد تدق التفرقة بين مصروفات الترميم ومصروفات التحسين، ويكون الأمر متروكاً لتقدير قاضى الموضوع.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويضمن الامتياز المصروفات التى أدت إلى حفظ المنقول أو ترميمه سواء كان المنقول مادياً أو معنوياً، كأجرة النجار الذى أصلح الأثاث، ومصروفات إنقاذ البضائع من الغرق أو من الحريق، وأجرة الحارس الاتفاقى فى إدارته الشئ المسلم إليه. والمبالغ التى ينفقها الدائن فى قطع تقادم الدين.

ويثبت الامتياز سواء كان من يطالب بهذه المصروفات قد أنفقها بنفسه أو دفع مبالغ لغيره لإنفاقها فى الحفظ أو الترميم بشرط أن يقيم الدليل فى هذه الحالة الأخيرة، أن المبالغ التى دفعها أنفقت فى الحفظ والترميم.

محل الامتياز ومرتبته:

يرد هذا الامتياز على المنقول الذى أنفقت المصروفات لحفظه أو ترميمه، فهو امتياز خاص على منقول. ويرد هذا الامتياز على المنقول كله بحيث يستوفى الدائن حقه من المقابل النقدي كله وليس فقط على ما ترتب على إنفاق

المصروفات من زيادة فى القيمة. ويبقى المنقول محملاً بالامتياز، سواء كان فى ملك المدين بالمصروفات أو غيره، وسواء كان الدائن يحبسه أم لا. ويأتى هذا الامتياز فى المرتبة الثالثة أى بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. فهو يتقدم على حقوق الامتياز الأخرى التى ترد على المنقول نفسه. على أن يلاحظ ما أسلفناه من أن التتبع فى المنقولات قد يصطدم بآثاره الحيازة، وأن المشرع قد اعتبر كلا من مؤجر العقار وصاحب الفندق حائزاً بالنسبة للمنقولات المؤجرة فى العين المؤجرة أو فى الفندق، وعلى ذلك فإذا كان أيهما حسن النية وقت وضع المنقول المحمل بامتياز مصروفات الحفظ والترميم فى العين المؤجرة أو فى الفندق، فلا يحتج عله لهذا الامتياز وتكون النتيجة أن يتقدم بامتيازه ولو أن هذا الامتياز متأخر فى المرتبة عن امتياز مصروفات الحفظ والترميم.

وإذا تعددت مصروفات الحفظ والترميم، فيما بينها يتقدم من أنفق المصروفات أخيراً على من أنفق قبله (م ١١٤٠/٢ مدنى) وذلك لأن من أنفق أخيراً هو الذى أفاد من أنفق أولاً. إذ لولا المصروفات الأخيرة لهلك الشئ ولم يحصل من أنفق أولاً على شئ أو لتلف فنقصت قيمته، فى حين أن من أنفق أخيراً لم يستفد شيئاً من المصروفات التى أنفقت أولاً.

رابعاً: حقوق الامتياز العامة:

تنص المادة ١١٤١ مدنى على أنه:

٢٥٢٤/٢٠٢٥ - يكون للحقول الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار: 2024/2025

أ - المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورعايتهم من أى نوع كان عن الستة أشهر الأخيرة.

ب - المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ومن يعوله من مأكّل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة.

ج- النفقة المستحقة فى ذمة الدين لأقاربه عن الستة أشهر الأخيرة.

٢- وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستوفى نسبة كل منها.

ويلاحظ على هذه الحقوق أن المشرع قد أعفاها من الشهر على أساس أنها حقوق امتياز عامة ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، سواء كانت أموال مادية أو غير مادية. وقد أشارت إلى الإعفاء من الشهر المادة ١١٣٤/٢ «حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر. ولا يثبت فيها التتبع، فإذا ورد الامتياز على منقول ثبت فى شأنه التتبع مع ما قد يصطدم به



ذلك من أثر مسقط بسبب قاعدة الحيابة فى المنقول سند الملكية إذا توافرت لصاحبها حسن النية والسبب الصحيح.

ويرد هذا الامتياز فى المرتبة الرابعة كما أثبت نص المادة ٢/١١٤١ مدنى، فإذا تراخمت الحقوق المشار إليها فيما بينها تكون معاملتها على قدم المساواة بحيث يكون الوفاء بها كل بنسبته إلى الديون الأخرى ومن قبل ذلك أن يتراحم دائن بنفخته مع دائن بأجر مع دائن بثمان ما أو ملبس.

ونعرض فيما يلى لحالات حقوق الامتياز العامة.

أولاً: أجور الخدم والكتبة وكل أجر آخر:

وتشمل هذه الحالة حقوق الإجراء بصفة عامة. وقد ثار جدل حول المقصود بالأجير الذى يتمتع بالامتياز المشار إليه. فقد ذهب رأى أول إلى أن الأجير هو العامل بالمعنى الدقيق وفقاً لما تقتضيه قواعد قانون العمل. وعلى هذا النحو فلا بد أن يكون الشخص قد أدى عملاً لحساب المدين وأن يكون أدائه لهذا العمل قد تم فى إطار رابطة التبعية القانونية بما تعنيه من إشراف وتوجيه وسلطة فى إعطاء الأوامر والتعليمات. فإذا كان من يؤدى العمل يؤديه على نحو مستقل دون رابطة التبعية كالمقاول مثلاً، فلا يعد أجيراً ولا يتمتع أجره بالامتياز المقرر فى القانون المدنى.

ويذهب الرأى الثانى، معتمداً على بعض ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى على أن الأجير هو كل ما يقدم عمله للغير فى مقابل أجر دون أن يخضع بالضرورة لمفهوم علاقة التبعية بمعناها الدقيق. ^{2024/2025}

2024/2025

تبدو أهمية هذا الخلاف فى صدد أجر المقاول، أو أجر الوكيل، وهل له امتياز أم لا. حيث يحرم من الامتياز وفقاً للرأى الأول ويتمتع به وفقاً للرأى الثانى. ونعتقد أنه فيما عدا حالة المقولة فإنه يمكن حصر وجه خلاف بين الرأيين. وفى تقديرنا أن أجر المقاول لا يدخل ضمن حالات الامتياز ذلك أن القانون المدنى إنما يتحدث عن حقوق الإجراء بالمعنى الذى يؤدي فيه شخص عملاً فى مقابل أجر له طابعه الحيوى بالنسبة إليه، حيث يعتمد عليه فى معيشته هو وأسرته وهو ما لا تستجب له عقود المقاولات من حيث المبدأ، فإذا ما استبعدنا أجر المقاول، فإننا نعتقد أن كل أجير آخر، حتى ولو كان وكيلاً مأجوراً، يتمتع بالامتياز.

وعلى هذا النحو يتمتع بالامتياز كل من يقدم عمله لشخص المخدم وأسرته كالتأهى والخدام، والكاتب والسكرتير الخاص، وعامل الزراعة، الخولى، والبستاني والمرضة، وسائق السيارة، والبواب.



ويستوفى في كل ذلك أن يكون العامل مقتصرًا على خدمة صاحب العمل أو أنه يعمل أيضاً لحساب أشخاص آخرين. كما يستوى أن يؤدي عمله بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة ويستوى أن يكون العامل مازال في الخدمة أو تركها.

الديون المضمونة بامتياز الإجراء:

واضح من النص أن الامتياز ينصرف إلى الأجور والمرتبات وبالتالي فهو لا ينصرف إلى كل المستحقات أياً كان وصفها بل لابد أن يتوافر للحق وصف الأجر أو المرتب ويدخل في مفهوم الأجر المرتب الأساسي مضافاً إليه الملحقات المستحقة لعامل، ومن هذا القبيل المكافأة أجر ساعات العمل الإضافي، علاوة غلاء المعيشة، البدلات المقررة للانتقال أو الاغتراب أو السفر أو المسكن. فجميع هذه العناصر تدخل في مفهوم لأجر بالمعنى الواسع المقصود في هذا المقام.

أما ما لا يدخل في مفهوم الأجر فلا يدخل تحت مظلة الامتيازات وعلى هذا النحو لا يعد ديناً ممتازاً المبالغ التي يدفعها العامل على سبيل الضمان أو الكفالة العينية ويرغب في استردادها كذلك الحال بالنسبة لما قد يستحق له من تعويض بسبب فصله بدون مبرر على نحو غير قانوني، ومكافأة نهاية الخدمة والمصروفات التي يتكبدها في دعوى قضائية أقامها ضد صاحب العمل حتى ولو كانت الدعوى للمطالبة بأجر متأخر.

مع ذلك فقد جاء قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بحكم خاص عدل به 2024/2025 (١١٤١ مدني) فقد نصت المادة 2034/2025 «يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بمقتضى حكم هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار» ووجه التعديل الذي جاءت به المادة الخامسة هو تعميم نطاق الحقوق الممتازة بحيث لا تقتصر على الأجر وملحقاته بل تشمل أيضاً كافة المبالغ التي تستحق للعامل حتى ولو لم تكن أجراً بالمعنى الصحيح طالما استحققت وفقاً لأحكام قانون العمل، وعلى هذا النحو يكون ديناً ممتازاً التعويض عن الفصل التعسفي لأنه يستحق وفق لقانون العمل، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الأجازة السنوية.

ويلاحظ أن الامتياز في القانون المدني لا يضمن سوى أجر العمال عن الستة أشهر الأخيرة، فهو لا يضمن أجوراً أبعد من هذه المادة. ومدة الستة أشهر هي تلك السابقة على الحجز وتحسب هذه المدة في حالة الإعسار أو الإفلاس أو وفاة المدين بدء من تاريخ الحادث الذي أدى إلى تصفية أموال المدين. ويلاحظ هنا أيضاً أنه بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون العمل فإن المادة الخامسة جاءت مطلقة في تقريرها للامتياز دون تحديد قيداً زمنياً يتعلق بمدة استحقاق المبالغ قبل صاحب العمل.

غير أن المادة ٣٧٨ مدنى تقرر تقادماً مسقطاً بالنسبة للأجور والمرتبات هو التقادم الحولى وذلك فإن هذه المدة تعد الحد الأقصى بالنسبة للمتمتع بالامتياز فى الحالات الخاصة لقانون العمل وللمادة الخامسة منه أما الحالات الخاضعة للقانون المدنى (م ١٤١١) فإن حقوق العامل فى أجره تكون متمتعة بالامتياز عن الستة أشهر الأخيرة، أما الستة أشهر السابقة عليها فإن الأجور الخاصة بها تبقى ديناً عادياً بغير امتياز.

ثانياً: حقوق الموردين:

وهو ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة ١١٤١ مدنى «المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكّل وملبس فى الستة أشهر الأخيرة» ويستند تقرير هذا لامتياز إلى الرغبة فى تدعيم ثقة الموردين فى المدين حتى يتسنى له الحصول منهم على ضروريات حياته من مأكّل وملبس، خاصة وأن فائدة هذا الامتياز لا تظهر بوضوح بالنسبة للدائن، إلا إذا كانت أحوال المدين المالية قد أصابها الاضطراب والتدهور. ويمتد الامتياز إلى ثمن ما يتم توريده للمدين ومن يعولهم من زوجة وأبناء وأصول وخدم.

شروط الامتياز المذكور وخصائصه:

١- أن يتم التوريد من شخص يتجر فى المأكّل والملبس، يستوى فى ذلك أن يكون هذا التاجر مقيداً فى السجل التجارى أو غير مقيد، يؤدى ما عليه من ضرائب أو لا يؤديها. فالعنصر المهم هو أن يكون المورد تاجراً من الناحية الفعلية على الأقل ويترتب على هذا الشرط أنه إذا تم توريد المأكّل أو الملبس من غير تاجر كصديق أو جار، وكان ذلك فى مقابل ثمن، فإن المديونية الناتجة عن هذا البيع لا تتمتع بالامتياز المذكور.

كما أن منطق النص والحكمة التى بنى عليها تقضى أن يكون حصول المدين على المأكّل والملبس يقصد استعمالها أما إذا كان لهدف آخر فلا امتياز ومن حالات تخلف المعنى أن يكون - المدين قد اشترى المأكّل والملبس للتجار فيها. يضاف إلى ذلك الآن الامتياز قاصراً على ثمن المأكّل والملبس فلا يتعدى إلى ثمن أشياء أخرى حتى ولو كانت ضرورية للمدين، كالأدوية ومصاريف الغاز والكهرباء أو التدفئة أو مصاريف التنظيف.

٢- أن الامتياز قاصراً على ثمن ما تم توريده فى الستة أشهر الأخيرة فقط وتحسب بدورها من تاريخ تصفية أموال المدين بسبب الوفاة أو الإعسار أو الإفلاس أو من تاريخ توقيع الحجز. ويلاحظ فى هذا المقام أيضاً أن هذه الديون تسقط بالتقادم الحولى وفقاً للمادة ٣٧٨ مدنى وبالتالي تكون المديونية

عن الستة أشهر السابقة على المدة الأخيرة مديونية عادية لا تتمتع بالامتياز.

٣- أن هذا الامتياز على جميع أموال المدين عن عقار منقول، ولا يجب فيه الشعور في وروده على العقار وبالتالي لا يتمتع في هذا الشأن بالتتابع وإن ورد على منقول فإن التتابع فيه محكوم بالأثر المسقط للحيازة. وأخيراً فهو في وروده على جميع أموال المدين يرد على المادى منها وغير المادى.

ثالثاً: نفقة الأقارب:

نصت على هذا الامتياز الفقرة (ج) من المادة ١١٤١ مدنى بقولها «النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة» وتشمل هذه النفقة ما يستحق للزوجة حيث تشملها صلة القرابة الواردة في النص. كما تشمل نفقة الأقارب الآخرين، كنفقة الأصول والفروع بعضهم مثل البعض الآخر حسب الأحوال.

وتتحدد النفقة الواجبة بإحدى وسيلتين: الاتفاق بين الدائن والمدين بالنفقة، فإذا تخلف الاتفاق تحددت بموجب حكم قضائى. وفى الحالتين تمتع بالامتياز المشار إليه.

ومرتبة هذا الامتياز هي الرابع. ويرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، ولا يشترط ولا يتبع فيه إذا ورد على العقار. إلى آخر ما سبق ذكره في صدر عرض الامتيازات العامة السابقة.

2024/2025 وإذا تراخمت ديون النفقة مع الديون الأخرى المضمونة بامتياز عام كحقوق الإجراء والموردين، فإنها تتساوى جميعاً في المرتبة ويستوفى كل منها بحسب نسبته إلى الديون الأخرى.

خامساً: امتياز مصروفات الزراعة والمبالغ المستحقة في مقابل الآلات الزراعية:

نصت المادة ١١٤٢ مدنى على أنه:

١- المبالغ المنصرفة في البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب المواد المقاومة للحشرات والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت في إنتاجه، وتكون لها جميعاً مرتبة واحدة.

٢- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصولات مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.

٣- وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل الآلات الزراعية حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات.

تشمل هذه الطائفة طائفتين من الحقوق الممتازة، الأولى حقوق امتياز المصروفات الزراعية، والثانية حقوق امتياز المبالغ المستحقة في مقابل الآلات الزراعية ذلك أن من العدالة أن يتقدم الدائن الذي قام بمصروفات في سبيل إنتاج المحصول وأفاد بذلك غيره من الدائنين. كما أن العدالة كذلك أن يستوفى الدائن الذي أوجد الآلات الزراعية في ذمة المدين المزارع حقه من ثمن تلك الآلات مثل غيره.

الحقوق الممتازة ومحلها:

١- المبالغ المنصرفة في البذور السماد وغيره من مواد التخصيب، والمواد المقاومة للحشرات. وكذلك المبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد فالامتياز يضمن في هذه الحالة كل ما نفق في البذور السماد والمواد الأخرى التي تستعمل في التخصيب، ويدخل في ذلك ثمن البذور والمواد وأجرة نقلها، مع مراعاة أن يكون لبائع البذور والمواد التي وردت للمزارع امتياز بائع المنقول بشرط أن تظل محتفظة بذاتها، فإذا لم يتحقق هذا الشرط، يكون لها الامتياز الذي نحن بصددده. كما يضمن الامتياز كذلك المبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد مثل المصروفات التي أنفقت في أعداد الأرض للزراعة وفي حرثها وفي حصادها وتعبئة المحصول.

ويدخل في ذلك أجور العمال الذين يساهمون في الأعمال السابقة وفي أعداد المحصول. كما يدخل فيها كذلك أجور الآلات التي تستخدم في الري وفي المحصول. على أنه بالنسبة للعمال بصفة عامة فإن المشرع يجعل لهم امتيازاً عاماً باعتبارهم إجراء، فيكون لهم الإفادة منه لأنه أسبق في المرتبة.

هذا ويراعى أنه ينبغي أن يثبت أن المبالغ السابقة قد أنفقت في إنتاج المحصول، سواء قدم الدائن المواد التي استخدمت، أو قام بنفسه بالعمل، أم كان قد أقرض هذه المبالغ للمدين، على أن يثبت أن هذا الأخير استخدمها في أعداد المحصول وأعمال الزراعة.

كما يراعى أيضاً ما قد يكون للدولة من امتياز في هذا الصدد بالنسبة للمبالغ التي تتحملها في مقاومة الحشرات والآفات الضارة.

ومحل هذا الامتياز المحصول الذي أنفقت المصروفات في إنتاجه، سواء كان إنتاجه يستغرق سنة أو أقل أو أكثر من ذلك. ويرد الامتياز على المحصول الذي أنتجه المصروفات بالذات دون غيره. فإذا كانت المبالغ قد أنفقت على عدة محاصيل، كان كل محصول منها ضامناً لهذه المبالغ بنسبة خاصة منها.

ولا يرد الامتياز على المحصول إلا بعد جنيته، ويظل الامتياز قائماً ما لم يصطدم بحق حائز حسن النية يتمسك في مواجهة الدائن بقاعدة الحيازة. وقد ثار



الخلافاً حول ما إذا كان الامتياز على المحصول يبقى في هذه الحالة حتى ولو ألحقت الثمار بعقار نتيجة لتسجيل تنبيه نزع الملكية إلا أنه ينبغي أن يراعى أن إلحاق الثمار بالعقار قد قصد به توفير الضمان للدائنين في استيفاء حقوقهم من ثمن هذا العقار قبل الدائنين العاديين، ولا يؤدي إلى إهدار الحق العيني المقرر للدائن على هذه الثمار بحكم القانون، ولذلك يظل امتياز مصروفات الزراعة، ويستوفى بمرتبة من ثمن الثمار.

٢- المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة:

يضمن الامتياز المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة، أيًا كانت هذه المبالغ من ثمنه ومصروفات إصلاح وتحسين، كما يضمن المبالغ المذكورة أيًا كانت آلات الزراعة، سواء كانت تستخدم في الحرث أم في الري أم في جمع المحصول ودرسه ونقله.

على أنه ينبغي أن يراعى في هذا الصدد أنه إذا تعلق الأمر بمبلغ ثمن فإن للبائع امتياز بائع المنقول، ولكنه متأخر في المرتبة عن الامتياز الذي نحن بصدده كما أن الامتياز الذي نحن بصدده يضمن الوفاء بالثمن وملحقاته، فضلاً عن أنه يضمن مصروفات إصلاح الآلات أو تحسينها، فهو بذلك يختلف من حيث نطاقه عن امتياز بائع المنقول الذي لا يضمن إلا الثمن وملحقاته. كما يختلف عن امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه إذ أن امتياز الحفظ والترميم لا يضمن مصروفات التحسين.

2024/2025 ومحل هذا الامتياز هو الآلات الزراعية التي استحققت المبالغ في مقابلتها، 2024/2025

فهو امتياز مستقل عن امتياز المصروفات الزراعية، وهو بذلك لا يرد على المحصول. وإذا ما صارت الآلات عقاراً بالتخصيص، ظل عليها الامتياز، اللهم إلا إذا شملها رهن على العقار، وكان المرتهن حسن النية، أي لا يعلم وقت إلحاقها بخدمة العقار وبالامتياز الذي عليها نظير ثمنها أو تحسينها. إذ في هذه الحالة لا يحتج عليه بالامتياز المذكور.

مرتبة الامتياز:

يأتى امتياز مصروفات الزراعة، وكذلك امتياز المبالغ المستحقة في مقابل الآلات في المرتبة الخاصة بعد الحقوق المتقدمة والمصروفات القضائية والمستحق للхранة، والحفظ والترميم والامتيازات العامة، وإذا تعددت مصروفات الزراعة، فإنها تستوفى من المقابل النقدي للمحصول بنسبة كل منها، وإذا تعددت المبالغ المستحقة مقابل الآلات فإنها تستوفى كذلك بنسبة كل منها وذلك من المقابل النقدي للآلة ذاتها.



سادساً: امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق:

أولاً: امتياز المؤجر:

يقوم هذا الامتياز لضمان حق المؤجر قبل المستأجر، ومبناه فكرة الرهن الضمني، على أساس أن المؤجر والمستأجر، عندما ينفقان على الإيجار، يقصدان ضمناً أن تكون المنقولات التي يضعها المستأجر من العين المؤجرة ضامنة لما يترتب في ذمة من التزامات قبل المؤجر بمقتضى عقد الإيجار. وإذا وقع الامتياز على المحصول في الأرض الزراعية فإن مبنى الامتياز فضلاً عن فكرة الرهن الضمني، فكرة العدالة، ذلك أن صاحب العقار قد ساهم في إنتاج المحصول نظراً لأنه ترك الأرض للمستأجر، وانتفاع المستأجر بها من أهم العناصر في إنتاج المحصول، لهذا يكون من العدل تفضيل أجره الأرض على توزيع ثمن المحصول.

والواقع أن امتياز المؤجر يحقق مصلحة كل من المؤجر والمستأجر، إذ يحصل المؤجر بمقتضاه، على التأمين فيبعث الثقة في نفسه، وبالتالي لا يتغالي في فرض الشروط على المستأجر أو يطلب ضمانات قد لا يتسنى لهذا تأديتها، ولهذا كان الامتياز في صالح المستأجر كذلك إذ لا يحرم من استعمال منقولاته الوارد عليها الامتياز مع عدم إرهاقه بتقديم ضمانات أخرى.

الحق الممتاز:

كل ما هو مستحق للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون ممتازاً في حدود ما نصت عليه المادة ١/١١٤٣^{٢٠٢٤/٢٠٢٥} فبالنسبة للأجرة يكون للحق امتياز لمدة لا تتجاوز سنتين أو لمدة إيجاره وإن قلت مدته عن السنتين. ولم يذكر المشرع ما إذا كانت مدة السنتين اللتين يضمنها الامتياز سابقين على التوزيع أم أي سنتين. النص مطلق ويقتضى ذلك أن يكون الامتياز ضامناً لأى سنتين.

كما يضمن الامتياز فضلاً عن الأجرة، أو حق آخر للمؤجر يستند إلى عقد الإيجار، كمبلغ تعويض عن تلك العين المؤجرة أو عن إساءة استعمالها. ولهذا لا يضمن الامتياز مبالغ أخرى لا تستند إلى عقد الإيجار، كقرض.

ولكى يكون الحق ممتاز في الحدود السابقة، يجب أن تكون بصدد عقد إيجار صحيح صادر بمال أو بأرض زراعية، فلا يسرى الحكم على إيجار المنقول، كما لا يسرى كذلك^(١) على إيجار غير المباني والأراضي الزراعية من العقارات كإيجار الأراضي الفضاء، إذ النص يحدد الامتياز بأجرة المباني والأراضي الزراعية فقط.

(١) د/ توفيق فرج: المرجع السابق، ص ٩١.

وقد أثير خلاف حول إيجار المنازل المفروشة، ونرى كذلك أن امتياز المؤجر يقوم بالنسبة لها يتضمن إيجار المبنى فقط على اعتبار أنها خالية، أي دون الأثاث، إذ يمكن القول أن هذه يدخل تحت عبارة أجرة المبنى، والتي نص عليها القانون. ويقدر أجره المنازل المفروشة باعتبارها خالية على أساس أجر المثل.

محل الامتياز:

يقوم الامتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز، ومن محصول زراعى. فمحل الامتياز إذن هو بصفة عامة المنقولات الموجودة بالعين، سواء كانت العين المؤجر من المبنى أم من الأراضي الزراعية، والمحصول الزراعى، وذلك فى حالة إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية.

ولكى يقع الامتياز على المنقولات الموجودة بالعين يجب:

١- أن تكون موجودة بالعين، حيث نص المشرع على إلزام المستأجر بوضع منقولات فى العين المؤجرة، فإذا خرجت بعلم المؤجر دون معارضة انقضى الامتياز.

٢- ويلزم أن تكون المنقولات قابلة للحجز عليها، حتى تتحقق الغاية من الامتياز.

٣- وأخيراً يجب أن تكون المنقولات مملوكة للمستأجر. وهذا ما نصت عليه المادة ١١٤٣/١. ولكن المشرع نص بعد ذلك فى الفقرتين التاليتين من المادة نفسها على حالات لا تكون فيها المنقولات مملوكة للمستأجر مع ثبوت الامتياز عليها، فتتص على أنه «يثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجـة المستأجر، أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها.

وعلى ذلك، فإن الامتياز يثبت على المنقولات المملوكة للزوجة، سواء كان المؤجر يعلم وقت وضعها أنها مملوكة لها أو لم يعلم بذلك.

كما يثبت على المنقولات المملوكة للغير حقاً على هذه المنقولات. وكل هذا دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. وعلى ذلك إذا كان المنقول الموجود فى العين مسروقاً أو ضائعاً فإن أمكنه أن يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع، ولا يكون للمؤجر أن يتمسك بامتيازـه فى مواجهة مالكها ولو كان هذا المؤجر حسن النية.

أما بالنسبة لمنقولات ومحصولات المستأجر من الباطن، فإن الامتياز يقع عليها أيضاً، كما تقضى المادة ١١٤٣/٣ «إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن، فإذا لم يشترط ذلك، فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التى

تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذر فيه المؤجر .

يأتى امتياز المؤجر في المرتبة السادسة بعد الامتيازات السابقة. وإذا كان المنقول الذى أدخل فى العين محملاً بامتياز وكان المؤجر يجهل ذلك فلا يحتج عليه بالامتياز على المنقول.

الضمانات القانونية لحماية امتياز المؤجر:

يخول المشرع للمؤجر ضمانات يستطيع بمقتضاها أن يحافظ على امتياز من ذلك أن يكون للمؤجر الحق فى حبس المنقولات وفى استردادها طبقاً لما تقضى به المادة ٥٨٩ مدنى. وله أن يلجأ إلى سبيل الحجز التحفظى طبقاً لما تقضى به المادة ٣١٧ مرافعات، كما يخول له القانون تتبع المنقول المباشرة حقه. وقد نصت المادة ٥/١١٤٣ على أنه «إذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه، ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة،بقى الامتياز قائماً على الأموال التى نقلت، دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. وعلى هذا إذا خرجت المنقولات فى هذه الحالة كان للمؤجر أن يتتبعها، ما لم يصطدم حقه بحق الحائز حسن النية.

ومن ذلك فإن المشرع يخول للمؤجر المنتبغ فى الحالة السابقة «حالة خروج المنقولات» رغم معارضته أو دون علمه حتى ولو فى مواجهة من يتمسك بقاعدة التغيير^{2024/2025} ويجعل امتياز قائماً خلال^{2024/2025} سنوات من وقت نقل المنقولات إذا قام^{2024/2025} المؤجر بتوقيع حجز استحقاقى عليها فى الميعاد القانونى.

فإذا بيعت المنقولات سلفة لذكر إلى مشتر حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثله، فإنه لا يكون للمؤجر حتى ولو أوقع الحجز إلا مستحقاً فى الميعاد القانونى أن يباشر امتيازاه عليها إلا إذا رد الثمن إلى من أشتراها.

ثانياً: امتياز صاحب الفندق:

نصت المادة ١١٤٤ مدنى على:

١- البالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزول عن أجرة الإقامة والمؤونه وما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للمزول - إذ لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عند بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة، ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من الفندق مادام لم يستوف حقه كاملاً

فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن النية».

٢- لامتياز صاحب الفندق ذات المرتبة التي لامتياز المؤجر، فإذا تزامم الحقان قدم الأسبق في التاريخ. ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الأخير.

يتضح من النص أن المشرع قرر هذا الامتياز حماية لصاحب الفندق نظراً لأنه لا يستطيع أن يحصل على مستحقته مقدماً في كل الحالات، فهو يؤدي لخدمة لعملائه ثم يحاسبهم في نهاية مدة الإقامة. يضاف إلى ذلك أن كثيراً من عملاء الفنادق هم أشخاص لا يعرفهم صاحب الفندق بصفة شخصية ولا يستطيع مسبقاً أن يقدر مدى يسارهم من إعسارهم وهو يركن على الأقل إلى ما معهم من أمتعة وأشياء صماناً لما قد يتحقق له قبلهم. ويتمتع بالامتياز المذكور صاحب الفندق وهي مهنة محددة لا تختلط بغيرها. وبالتالي لا يتسع الامتياز لغيره من أصحاب المقاهي أو الحانات والمطاعم، ذلك أن هذه الفئات تقدم شرباً وطعاماً ولكنها لا تقدم سكناً للعميل كما لا يتسع هذا الامتياز لمؤجر المفروش إذ يستفيد هذا المؤجر من امتياز المؤجر وليس من امتياز صاحب الفندق.

الحقوق الممتازة:

أشارت الفقرة الأولى من المادة ١١٤٤ مدنى إلى أن الامتياز يضمن المبالغ المستحقة في ذمة النزول عن أجرة الإقامة وما صرفه حسابه ويدخل في ذلك أجرة غرفة النوم وثمان ما يستهلكه من مأكولات ومشروبات ومصاريف أخرى ^{2024/2025} وما صرف لحساب أسرته وتابعيه ^{2024/2025} وما قد يوجد معه من حيوانات.

ويكون الحق الممتاز هو ذلك الحق الناشئ عن مستحقات حاله وليس عن مرات سابقة لم يتمسك صاحب الفندق بامتيازه عنها في حينها، يستوى أن يكون النزول من ذات البلد أو عابر من بلد آخر ذلك أنه من الصعب على صاحب الفندق أن يلم بمدى يسار النزول حتى ولو كان من ذات البلدة خاصة في المدن الكبرى. وأخيراً يستوى أن تكون مدة الإقامة طويلة أو قصيرة.

محل الامتياز ومرتبته:

يرد الامتياز على الأمتعة الموجودة مع النزول ولو كانت غير مملوكة له أى يستوى في ذلك أن تكون مملوكة له أو لغيره مادام صاحب الفندق لا يعلم وقت إدخالها إلى الفندق بحقوق الغير عليها، كما يشمل الامتياز أمتعة المقيمين مع النزول كزوجته وأبنائه وتابعيه ولو لم تكن أيضاً مملوكة لهم. كل ذلك مع تحفظ هو وجوب مراعاة أحكام الأشياء المفقود أو الضائعة.

والمقصود بالأمتعة هو كل ما يخص العميل وأحضره معه إلى الفندق من مجوهرات ونقود وأشياء أخرى قابلة للحجز عليها كالسيارة والخيول والبضائع وكل ما يستجد مع النزيل.

ولأن لصاحب الفندق امتيازاً على الأمتعة، فإنه يستطيع أن يعترض على خروجها من الفندق تأكيداً لضمان حقوقه. فإذا خرجت رغم معارضة أو بغير علمه كان له الحق في استردادها.

أما مرتبه هذا الامتياز هي المرتبة السادسة. وهي ذات مرتبة امتياز المؤجر. فإذا تزامن الحقان كانت الأولوية للأسبق منهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الغير.

فإذا أخرج المستأجر بعض الأمتعة من العين المؤجرة دون علم المؤجر ونزل بها في فندق صاحبه لا يعلم أن للمؤجر امتياز على هذه الأمتعة، أو حجز المؤجر عليها جزءاً استحقاقياً في الميعاد، فإن امتياز المؤجر هو الأسبق في التاريخ وهو الذي يقدم أما إذا لم يحجز المؤجر، فإن امتياز لا يكون نافذاً بالنسبة لصاحب الفندق فيقدم امتياز هذا الأخير كذلك إذا أخرج النزيل أمتعته ووضعها في عين مؤجره وكان المؤجر حسن النية، كان امتياز مقدماً لأن امتياز صاحب الفندق وهو الأسبق في التاريخ لا ينفذ في حقه.

سابعاً: امتياز بائع المنقول وامتياز المتقاسم في المنقول:

أولاً: امتياز بائع المنقول:

تنص المادة ١/١١٤٥ على أنه «ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون لها امتياز على الشئ المبيع، ويبقى الامتياز قائماً مادام المبيع محتفظاً بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية».

والحكمة من تقرير هذا الامتياز واضحة فالبايع هو الذي أدخل المنقول في ذمة المشتري فمن العدل أن يستوفى الثمن مثل الدائنين الآخرين اللذين يستوفون حقوقهم من هذا المنقول.

والحق الممتاز: هو حق البائع في الثمن كله أو بعضه مع ملحقاته، فيجب أولاً أن نكون بصدد عقد بيع صحيح، وأن يكون المبيع منقولاً سواء كان مادياً أو معنوياً، وتعتبر حوالة الحق بنقله مبيعاً، فيثبت الامتياز لضمان ثمن هذا الحق، كما يسرى على المقايضة فيما يتعلق بما يعين الوفاء بدين الفرق بين قيمتي الشئيين المتقايض فيهما أحكام المبيع فيكون هذا الدين مضموناً بامتياز البائع.

ولا يضمن الامتياز إلا الثمن وملحقاته كالفوائد ونفقات المطالبة بالثمن ويستوى أن يكون الثمن مؤجلاً أو غير مؤجل فهو مضمون بالامتياز مادام

المشتري لم يدفعه. أما الحقوق الأخرى التي تثبت للبائع بمقتضى البيع كالتعويضات التي يستحقها لإخلال المشتري بالتزام من التزاماته فلا يضمنها الامتياز، سواء كان التعويض قضائياً انفاقياً وفي هذا يختلف امتياز البائع عن امتياز المؤجر يضمن كافة الحقوق التي تنشأ لمؤجر بمقتضى الإيجار.

محل الامتياز ومرتبته:

يرد الامتياز على المنقول المبيع نفسه، فإذا تعددت المنقولات المباعة فإن كان البيع بثمن واحد يتحمل كل منها بالامتياز لضمان الثمن كله إذا حدد لكل منها ثمن خاص فلا يتحمل إلا بدين الثمن الذي يخصه. ويبقى المنقول محملاً بالامتياز مادام محتفظاً بذاتيته فإذا فقد ذاتيته زال عنه الامتياز كما لو استخدم المنقول في بناء فأصبح عقاراً بطبيعة كالطوب الذي يستخدم في البناء أو الأخشاب التي تصنع منها الأبواب والنوافذ. أما إذا خصص المنقول لخدمة العقار فأصبح عقار بالتخصيص فهذا لا يفقده ذاتيته فيبقى محملاً بحق الامتياز.

أما مرتبة الامتياز: فتأتى امتياز بائع المنقول فى المرتبة السابقة أى بعد حقوق الامتياز السابقة، ولكن إذا تراحم مع امتياز المؤجر أو امتياز صاحب الفندق وكان أيهما يعلم وقت وضع المنقول فى العين المؤجرة أو فى الفندق بوجود امتياز البائع. فيسرى امتياز البائع فى حق المؤجر أو صاحب الفندق. وقد نصت على هذا المادة ٢/١١٤٥ «يكون هذا الامتياز تالياً فى مرتبته لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق»²⁵ إذا ثبت أنهما كانا يعلمان²⁵ وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو

2024/2025

ثانياً: امتياز المتقاسم فى المنقول:

تنص المادة ١/١١٤٦ على أنه «للشركاء الذين اقتسموا منقلاً حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل «والحكمة من تقرير هذا الامتياز أن المنقول الذى آل إلى كل شريك على أثر القسمة لم يستقر فى ذمته ويختص به دائنوه إلا بناء على القسمة التى كان المتقاسم الذى تقرر له الامتياز طرفاً فيها، فالامتياز يقوم على اعتبارات قريبة الشبه من التى يقوم عليها امتياز البائع فصاحب الامتياز قد أسهم فى إيجاد محل الامتياز فى ذمة المدين ومن العدل إذن أني تقدم على دائنى هذا المدين الآخرين.

الحق الممتاز: يثبت الامتياز لكل حق يثبت لأحد المتقاسمين فى الرجوع على غيره بسبب القسمة، سواء كانت ودية أو قضائية وسواء كانت عينية أو بطريق التصفية. والحقوق التى قد تثبت للمتقاسم بسبب القسمة هي:

أولاً: معدل القسمة أى الفرق بين قيمة الحصص الذى تقرر دفعه بمقتضى القسمة إلى المتقاسم الذى أختص بالحصة الأقل قيمة.

ثانياً: ما يستحقه المتقاسم من ثمن المنقول الذى بيع لعدم إمكان قسمته عيناً إذا كان البيع لأحد الشركاء.

ثالثاً: ما يستحق المتقاسم من تعويض إذا أستحق مال ما آل إليه فى القسمة على أساس الالتزام بضمان الاستحقاق.

محل الامتياز: يرد امتياز المتقاسم الذى يداين غيره من المتقاسمين بشئ مما تقدم على المنقولات التى وقعت فى نصيب المتقاسم المدين، فإذا كان الدين هو المعدل ورد الامتياز على ما وقع فى نصيب من يلزم بالمعدل، وإذا كان الدين هو ما يخص أحد المتقاسمين فى ثمن المنقول الذى اشتراه غيره ورد لامتياز على هذا المنقول، وإذا كان الدين تعويضاً بسبب الاستحقاق. ورد الامتياز على جميع المنقولات التى أختص بها الشركاء الآخرون كل بقدر نصيبه فى التعويض.

مرتبة الامتياز: نصت المادة ٢/١١٤٦ على أنه «وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع، فإذا تزامن الحقان قدم الأسبق فى التاريخ» وعلى ذلك فامتياز المتقاسم يأتى فى المرتبة السابعة، أما فيما بينه وبين امتياز بائع المنقول فالأسبق هو الذى يتقدم، فإذا تمت القسمة بعد البيع قدم امتياز البائع، وإذا وقع البيع بعد القسمة قدم امتياز المتقاسم.

المبحث الثانى

2024/2025

2024/2025

2024/2025

حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على العقار

تقسيم:

عرضنا فيما سبق للطائفة الأولى من الحقوق الممتازة، وهى حقوق الامتياز العامة، وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول. وفى هذا المبحث نعرض لما تبقى من حقوق الامتياز، وهى حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار. وهذه الحقوق تشمل امتياز ما يستحق لبائع العقار، وامتياز ما يستحق للمقاولين والمهندسين المعماريين، وامتياز المتقاسم فى العقار.

ويجمع بين حقوق الامتياز المذكورة أولاً أنها حقوق امتياز خاصة ترد على مال معين، وثانياً أن هذا المال هو دائماً عقار ولأن الامتياز هو امتياز خاص عقارى فقد أخضعه القانون لأحكام الرهن الرسمى خاصة أحكام القيد وتجديده ومحو القيد والتطهير، وبالجمله كل ما لا يتعارض مع طبيعة حقوق الامتياز. ويترتب على ذلك أن مرتبة الامتياز الخاص العقارى تتحدد بتاريخ قيده فى الشهر العقارى، وبالتالي يصبح نافذاً فى حق الغير من وقت هذا القيد.

نعرض فيما يلى لكل من حقوق الامتياز المذكورة:

أولاً: امتياز بائع العقار

تنص المادة ١١٤٧ مدنى على:

١- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع.

٢- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً وتكون مرتبته من وقت القيد.

ويستهدف هذا الامتياز ضمان حقوق البائع فيما بقى له من الثمن أو جزء منه وكذلك ملحقات الثمن، وتبرر هذا الامتياز أيضاً اعتبارات العدالة إذ لا يجوز عدالة أن يحصل البائع على ثمن العقار ثم يزاحمه غيره من دائنى المشتري وإلا كان القول بعكس ذلك مؤدياً إلى إثراء هؤلاء الدائنين من غير سبب على حساب البائع الذى أدخل العقار فى ذمة المشتري دون أن يتقاضى منه كامل الثمن.

ويضمن امتياز بائع العقار حق البائع فى الثمن كله أو بعضه وملحقات الثمن على الوجه الذى بيناه عند دراسة امتياز بائع المنقول، فنكتفى بالإحالة إلى ما قلناه فى هذا الخصوص.

ويرد الامتياز على العقار المبيع، ويمتد إلى ملحقات هذا العقار كما هو الحال بالنسبة للرهن الرسمى (م/١١٣٤، ٢/١٠٣٦، ١٠٣٧).

ثانياً: امتياز المقاولين والمهندسين المعماريين:

تنص المادة ١١٤٨ على أنه:

٢٠٢٥/٢٠٢٤ المبالغ المستحقة لمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد

أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشييدها أو ترميمها أو فى صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بيعه.

٢- ويجب أن يقيد هذا الامتياز أن عمل المهندس أو المقاول قد أضاف قيمة جديدة إلى العقار فكان من العدل أن يتقدم بما يستحقه عن هذا العمل على ما تسبب فيه من زيادة القيمة.

الحق الممتاز: يجب أن يكون الحق الذى يضمه الامتياز مستحقاً لمقاول أو مهندس معمارى عهد إليه فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشييدها أو فى ترميم أو فى صيانتها. فيخرج بذلك ما يستحقه غير المهندسين والمقاولين، كالمستأجر أو الفضولى أو الحائز الذى يقوم بترميم وصيانة العقار، يجب أن يكون المقاول أو المهندس قد عهد إليه بالعمل الذى يطالب بالمبالغ المستحقة له من أجله، فإذا قام بالعمل من تلقاء نفسه فلا يستفيد من الامتياز. ولا يشترط أن يكون مالك العقار هو الذى عهد إليه المقولة بالعمل فيثبت الامتياز ولو كان مستأجر العقار أو حائزه هو الذى عهد إلى المقاول.

محل الامتياز ومرتبته:

يرد الامتياز على المنشآت التي شيدها المقاول أو المهندس أو أعاد تشييدها أو رممها أو صانها، لا في قيمتها كلها، دائماً بقدر ما ترتب على عمله من قيمة العقار وقت بيعه. فإذا أقام المهندس أو المقاول بناء على أرض فضاء فلا يكون له امتياز على كل قيمة الأرض بما عليها من بناء، ولا على الفرق بين قيمة الأرض وحدها وقيمتها بما عليها من بناء وقت البناء، بل على الفرق وقت البيع.

أما مرتبة الامتياز فتتحدد من وقت القيد. ولكن يلاحظ أن المشرع بعد أن نص في المادة ١٠٣٦ على أن يشمل الرهن ملحقات العقار والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك، قال «مع عدم الإحلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليها في المادة ١١٤٨».

والحكم من تقدير هذا الحكم أن المشرع لو أطلق القاعدة الخاصة بأسبقية الحق المقيد أولاً، لأحجم المهندسون والمقاولون عن القيام بالأعمال اللازمة في العقار المرهون إذ أن الرهن سوف يشمل ما يحدث من الإنشاءات والتحسينات. وعلى أساس هذه الحكمة ذهب الشراء بالرغم من إطلاق النص^(١) إلى القول بقصر تطبيقه على حاله ما إذا كان المهندس أو المقاول قد قام بالأعمال في عقار مرهون من قبل. أما إذا قام بالأعمال في عقار غير مرهون، ثم رهن العقار ^{2024/2025} ^{2024/2025} تلك فتكون الأولوية للرهن أو المقاول أو المهندس وفقاً للأسبقية في القيد، إذ يجب على المهندس أو المقاول أن يبادر إلى قيد حقه فإذا تأخر في قيد الرهن فليس هناك ما يدعو إلى حمايته، كما أنه ليس من العدل أن يجعل الامتياز نافذاً في حق المرتهن الذي ارتهن العقار بما فيه من إنشاءات أو تحسينات ولم تكن لديه الوسيلة إلى العلم بامتياز المهندس أو المقاول.

ثالثاً: تنص المادة ١١٤٩/١ على أن للشركاء الذين اقتسموا عقاراً حق امتياز عليه تأميناً لما تخوله القسمة من حق رجوع لكل منهم على الآخرين بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة».

ويصدق هنا نفس ما قلناه بالنسبة لامتياز المتقاسم في المنقول ومن ثم يحيل عليه.

ومحل الامتياز هو الحصة المفروزة التي وقعت في نصيب كل متقاسم، وذلك بنفس الحدود التي رأيناها عند عرض امتياز المتقاسم في منقول.

(١) د/ منصور مصطفى منصور: التأمينات ص ٢٧٨.

أما مرتبة الامتياز فهي تثبت من وقت قيده، فهذا ما يقضى به عجز المادة ١١٤٩ أن يقول «يجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبة من وقت القيد وقد أورد عجز المادة ١٠٣٩ استثناء على القاعدة المتقدمة ومضمون هذا الاستثناء أنه حيث يرهن أحد الشركاء على الشيوع حق الشائع في العقار أو جزءاً مفزاً منه، ثم يقع في نصيبه عند القسمة أعيان أخرى فإن الرهن الذي رتبته ينتقل بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعين على أثره على عريضة، ويرتد القيد الذي يجريه المرتهن على هذا القدر، متى وقع في مدة التسعين يوماً التي حددتها هذه المادة - إلى التاريخ الذي أجرى فيه القيد الألو على ألا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه بامتياز المتقاسم ومعنى عدم إضراره أني تقدم امتياز المتقاسم على الرهن بالرغم من أنه وفق الأثر الرجعي - تكون مرتبة الرهن أسبق من الامتياز.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الباب الثالث الرهن الحيازي

تمهيد :

الرهن فى القانون الوضعى يقصد به واحد من ثلاثة:- العقد الذى ينشئ الرهن باعتباره مصدراً للحق، الحق العينى ذاته الذى ينشأ عن العقد، المال الذى يرهن (محل الرهن). فإذا أردنا تعريف الرهن يجب أن نبين أولاً ماذا يقصد بـ :-
العقد أو الحق أو المال .

وعلى هذا تكون المادة ١٠٩٦ مدنى حين عرفت الرهن الحيازي^(١) بأنه «عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدون شيئاً يرتب عليه الدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشئ لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى إقتضاء حقه من هذا الشئ فى أى يد يكون^(٢)، تكون قد عرفت العقد الذى ينشئ الرهن.

وقد أفصحت الأعمال التحضيرية عن ذلك^(٣) إذ قالت أن المشرع قد عرف العقد على أن تعريف الشئ لا يكون بتعريف مصدره بل بتعريفه هو - الحق - خاصة وأن المشرع يعالج الرهن الحيازي فى الكتاب المخصص للحقوق العينية التبعية لذلك فمن المنطق أنه كان يعرف الحق ذاته^(٤).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) هو أول نوع من التعامل فى مجال التأمينات العينية، وقد بدأ فى مستهل عهده فى صورة نقل ملكية الشئ المراد تحميله بالضمان إلى الدائن ثم التزم هذا الدائن برد الملكية إلى المدين إذا ما استوفى حقه. ثم فى مرحلة لاحقه توصل إلى التفرقة بين الحيازة والحق، واقتصر حق المرتهن على حيازة المرهون دون ملكيته التى ظلت ثابتة للراهن. وقد عرف القانون الرومانى الرهن الحيازي فى صدر عهده ثم وجد بجانبه الرهن الرسمى. وظل النظامان موجودان يردان على المنقول والعقار إلى آخر أيام القانون الرومانى. كذلك عرف القانون الفرنسى القديم بدوره نظام الرهن الحيازي إلى جانب الرهن الرسمى. وكذلك الحال فى القانون المدنى القديم، والجديد الذى استمد أحكامه من القديم مع بعض التعديلات متأثراً بالشرعية الإسلامية فيما نظمته من أحكام عن الرهن الحيازي. د. شفيق شحاته: النظرية العامة للتأمين العينية ط٣ ١٩٥٩ ص ٩، د. سليمان مرقس التأمينات العينية فى التقنين المدنى الجديد طبعة ١٩٥٩ ص ٣٤٣، د. أحمد سلامة: الرهن الطليق للمنقول. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية السنة العاشرة ١٩٦٨ ع ٢ ص ٣٠٤.

(٢) يطلق على الرهن الحيازي فى القانون الفرنسى لفظ Nantissement وهو قد يرد على منقول فيسمى Gage وقد يرد على عقار فيطلق عليه Antichrèse. وقد وحد المشرع المصرى هذه الاصطلاحات تحت إسم الرهن الحيازي وهو يشمل رهن المنقول ورهن العقار على السواء.

(٣) الأعمال التحضيرية ح ٧ ص ٤، ص ١٨٩.
(٤) د. عبد الفتاح عبد الباقي: التأمينات الشخصية والعينية طبعة ١٩٥٤ ص ٢٩٤، د. أحمد سلامة: التأمينات العينية والشخصية طبعة ١٩٧٨ ص ٥٩.

على أن نص المادة ١٠٩٦ مدنى قد تضمن فى نفس الوقت تعريفاً لحق الرهن الحيازى عن طريق مضمونه بقوله أن الحق العينى يخول لصاحبه حبس الشئ لحين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائن العاديين والدائنين التالبيين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشئ فى أى يد تكون (١).

على أن أهم ما يؤخذ من هذا النص أن الحيازة ضرورية لنفاذ الرهن الحيازى فى حق الغير لا لإنعقاد الرهن وإلى جانبها الحبس الذى يثبت للدائن المرتهن حتى يستوفى دينه. وأن الشئ المرهون يصح أن يكون منقولاً أو عقاراً. أما بغية التعريف بأن الدائن المرتهن حيازياً يستوفى دينه متقدماً ومتتبعاً فهذه المعانى مشتركة بين الرهن الحيازى والرهن الرسمى، فالخلاف بينهما يدور حول أن عقد الرهن الرسمى عقداً رسمياً أما الحيازى فهو رضائى لا يشترط فيه الرسمية.

وإن كان أهمية التفرقة بينهما تظهر فى «الحيازة والحبس». فالرهن الحيازى يخول حبس الشئ المرهون - منقولاً كان أو عقاراً - حتى يستوفى الدائن دينه ، وهذا فى خصوص العقارات يمثل عبئاً على المدين لا يجد ما يبرره مع إمكان أن تكون هذه العقارات محلاً للرهن الرسمى مع الاحتفاظ للمدين بحيازته وسلطته فى استغلال العقار المرهون. فى حين أن الحيازة والحبس تمثل فى رهن المنقول أسباب استمراره وشيوعه خاصة وأن المنقولات لا تسمح طبيعتها بتقرير نظام الشهر الذى يتطلب الرهن الرسمى ^{2024/2025} ^{2024/2025} عن أن انتقال حيازة الشئ المرهون ^{2024/2025} ^{2024/2025} للمرتهن من شأنه أن يحميه من تصرفات المدين للغير حسن النية الذى يتمكن بتسلمه للمنقول من الاحتجاج فى مواجهة المرتهن بقاعدة الحيازة فى المنقول سند الحائز.

وإذ أضفنا إلى ما سبق حقيقة تقضى بأن فى الرهن الحيازى الوارد على المنقول لأبد من «الحبس وانتقال الحيازة» والتي وإن استجابت لضرورات عصرها حيث لم تكن بعض المنقولات قد اكتسبت أهمية باعتبارها أدوات إنتاج خطيرة الشأن. فإن التقدم الصناعى وازدهار التجارة وتنوعها أدى إلى خلق قيم منقولة مذهلة القيمة - الطائرة ، السفينة، المتجر، الآلات الميكانيكية ، وفى انتقالها إلى الدائن المرتهن باعتبارها منقولات ضرر كبير بالمدين، لأن هذه القيم المنقولة تكون فى كثير من الأحيان مورد رزق صاحبها بحيث يؤدى انتقال حيازتها إلى

(١) د. خميس خضر : التأمينات الشخصية والعينية طبعة ١٩٨٢ ص ١٧٥.

أن يحرم هذا المدين من هذا المورد، بالإضافة إلى أن ذلك المال قد يتطلب في بعض الأحيان كفاءة مهنية معينة لإدارته قد لا تتوفر غالباً للدائن (١).

هذه النتيجة تؤدي إلى تعطيل استفادة الشخص من ثروته عن طريق الائتمان ، وفي سبيل تلافي ذلك قطع المشرع في هذه المسألة بحلول جزئية. وأصدر بعض التشريعات التي خرجت عن قاعدة انتقال الحيازة في المنقول. منها القانون ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها (٢). والقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٥١ بحقوق الامتياز والرهن البحرية، ثم قانون التجارة البحري المصري الجديد الصادر في ٣ مايو ١٩٩٠ (٣)، وكذا القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات (٤). هذه القوانين التي لها صفة الخروج والاستثناء عن قاعدة انتقال الحيازة في الرهن الحيازي للمنقول جاءت نتيجة ضالة قيمة الاعتبارات التي تقضى بانتقال الحيازة بالنسبة لها. فهي ليست من المنقولات سريعة التداول التي يتعرض الدائن إذا لم يحزمها لفقدانها لصعوبة تتبعها ، فضلاً على أن هناك من العناصر ما يحدد ذاتيتها على نحو يسمح بتتبعها مادياً. ومن ناحية أخرى فهي تخضع لنظام التسجيل وهو ما يسمح بشهر الحقوق الواردة عليها على نحو يمكن الغير من الوقوف عليها بغير عناء.

تقسيم :

نظم المشرع أحكام الرهن الحيازي متتبِعاً لإنشائه ، آثاره، ثم انقضاءه. وفي

2024/2025

النهاية تعرض لبعض أنواع الرهن الحيازي التي نص عليها القانون.

(١) د. نبيلة رسلان : سلطات الدائن المرتين حيازياً بين الشريعة والقانون، مجلة روح القوانين ع ٣ سنة ١٩٩٠ ص ٨٥.

(٢) بهذا القانون أباح المشرع رهن المحل وما يشتمل عليه من مهمات وآلات رهناً تأمينياً تبقى معه في حيازة صاحبه. ويكاد يجمع الفقه في الوقت الحاضر على أن المحل التجاري منقول معنوي وعلى هذا الأساس فلا توجد صعوبة قانونية تعترض إخراج المحل التجاري من نطاق انتقال الحيازة في الرهن الحيازي.

(٣) نص المشرع في هذا القانون صراحة على أنه « مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسرى على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة».

(٤) إذا كانت الطائرة ملاً منقولاً فهي مع ذلك تخضع لنظام قانوني خاص بها يباعد بينها وبين سائر المنقولات في ضرورة تقيد أهم البيانات والتصرفات المتعلقة بها بسجلات خاصة تشرف عليها الدولة. د. فرج سليمان: رهن الطائرة طبعة ١٩٧٦ ص ٧١.

الفصل الأول إنشاء الرهن الحيازي

تحديد أركانه :

الرهن الحيازي عقد رضائي، يكفي لإبرامه التقاء الإرادتين المتطابقتين لطرفاه - المرتهن والراهن - على العناصر الجوهرية للرهن مستوفية لشروطها الجوهرية. وسنعرض في إيجاز للتراضي ثم للمال المرهون، ثم للالتزام المضمون، متلافين تكرار القواعد العامة أو القواعد التي يتشابه فيها الرهن الحيازي مع الرهن الرسمي.

المبحث الأول التراضي

الأصل في العقود، أن التراضي لازم وكافي لإبرامها ما لم يشترط المشرع شكل خاص في شأن أحدها (م ٨٩ مدني). ذلك الأصل طبقة المشرع في شأن عقد الرهن الحيازي. فالأخير يتم تبادل الرضا بين طرفيه وهما الراهن والدائن المرتهن. وقد يكون الراهن هو المدين، كما قد يكون شخصاً آخر، وهذا ما يتضح من المادة ١٠٩٦ التي تنص على أن «الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره».

ولا يوجد ما يختص به الرهن الحيازي من أحكام في هذا الصدد، ولهذا 2024/2025
تطبق القواعد العامة من حيث وجود الرضا وصحته. أما الأهلية بالنسبة لإبرام عقد الرهن الحيازي والوكالة والولاية في إبرامه نيابة عن الغير فنخصصها بالدراسة.

أهلية الراهن وأهلية المرتهن :

يجب أن تتوفر في الراهن أهلية التصرف في المال المرهون، فإذا كان الراهن وهو المدين لازم أن يتوافر لديه أهلية مباشرة الأعمال الدائرة بين النفع والضرر. أما إذا كان الراهن شخصاً غير المدين كان العقد بالنسبة له عملاً ضاراً ضرراً محضاً وبالتالي لازم له أهلية التبرع أو التصرف دائراً بين النفع والضرر وبالتالي لازم له أهلية التصرف بحسب ما إذا كان قد رهن ماله متبرعاً أو تقاض مقابلاً.

أما الدائن المرتهن ، فالرهن الحيازي يعتبر دائراً بين النفع والضرر، إذ العقد الذي ينشئه عقد ملزم للجانبين، وبالتالي يشترط في الدائن المرتهن بلوغه سن الرشد وإلا كان قابلاً للإبطال.

سلطة إبرام عقد الرهن الحيازي نيابة عن الغير :

لما كانت الالتزامات التي ينشئها الرهن الحيازي في ذمة المرتهن هي من قبيل أعمال الإدارة، فإنه يكفي لقبول الارتهان نيابة عن المرتهن أن يكون لدى الوكيل وكالة عامة كما أن الولي والوصي والقيم يجوز لهم قبول الارتهان دون إذن المحكمة.

أما عن الراهن لابد أن تكون الوكالة خاصة، أما في شأن مباشرتها عن طريق النائب القانوني (ولي أو وصي). فالأمر يختلف بحسب ما إذا كان الرهن يقدم ضماناً لدين على الراهن أو غيره. فإذا كان الرهن يقدم ضماناً لدين على الراهن، فإن الولاية أو الوصاية عن الراهن تحكمها أحكام الولاية أو الوصاية في أعمال التصرف^(١).

أما حيث يراد تقديم الرهن ضماناً لدين على غيره وكان معتبراً تقديمه له عملاً متبرعاً فإنه لا يجوز للولي أن يبرم رهناً حيازياً على مال من أموال القاصر المشمول بالولاية ضماناً لدين على غيره مطلقاً، حيث أنه ليس من صلاحيات المحكمة أن تأذن له في ذلك إلا إذا كان المال محل الرهن آل إلى القاصر عن طريق التبرع من وليه.

المبحث الثاني

المال المرهون

2024/2025

2024/2025

2024/2025

تقسيم :

نصت المادة ١٠٩٧ على أنه «لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول أو عقار» معنى هذا لكي ينعقد الرهن صحيحاً يجب أن يكون المال المرهون من الأشياء التي يجوز رهنها رهناً حيازياً ، وأن يكون هذا الشيء مملوكاً للراهن، ونعرض لذلك في فرعين .

الفرع الأول

المال القابل للرهن الحيازي

العقار والمنقول كلاهما يصح أن يكون محلاً للرهن الحيازي. فيصح أن يكون عقاراً أي كان نوعه سواء كان في صورة مبنى أو أرض. شأنه في ذلك شأن الرهن الرسمي تماماً. فما يصح رهنه رسمياً يصح رهنه حيازياً.

(١) د همام محمد محمود زهران : التأمينات العينية والشخصية طبعة ١٩٩٧ ص ٣٤٨.

بالإضافة إلى هذا فإنه يصح رهن المنقول متى كان قابلاً للحيازة، وسواء كان منقولاً مادياً أو معنوياً. فيجوز رهن المنقولات المادية، سواء كانت قيمة أم مثليه، بشرط ألا تكون عقارات بالتخصيص. وتلحق السندات لحاملها بالمنقولات المادية على اعتبار اندماج الحق في الصك.

وبالنسبة للنقود، فيجوز رهنها رهنًا حيازياً وهو ما يعرف في العمل بالكفالة النقدية أو التأمين النقدي. وهو ما يقدمه الشخص من مبلغ نقدي ضماناً للوفاء بما قد ينشأ في ذمته من التزامات، كالمبالغ التي يقدمها المستأجر للمؤجر على سبيل التأمينات، أو ما يقدمه مقاولوا الأشغال العامة لجهة الإدارة ضماناً لتنفيذ التزاماتهم في عقد المقاولة. والواقع أن الرهن هنا يختلف عن الوضع العادي في الرهن، إذ أن المرتهن هنا يملك النقود المسلمة إليه على أن يرد مثلها فيما بعد، أي لا يعتبر ما سلم إليه أمانة يجب ردها، كما هو الشأن بالنسبة للأموال الأخرى التي تسلم إلى المرتهن على سبيل الرهن الحيازي^(١).

ويجوز كذلك رهن الأموال المنقولة المعنوية، بشرط أن تكون قابله للبيع بالمزاد مثل حقوق المؤلفين، وبراءات الاختراع والمحال التجارية والعلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية. كما يجوز أيضاً رهن الديون والسندات وبوالص التأمين متى كانت قابلة للتحويل. وعلى العكس لا يجوز رهن المهاييا والمعاشات والديون والسندات الغير قابلة للتحويل.

2024/2025

٢٥ الشروط الواجب توافرها في المال المرهون :

يشترط في المال المرهون سواء كان عقاراً أو منقولاً مجموعه من الشروط .

الشرط الأول : أن يكون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني.

يلزم أن يكون المال المرهون مما يدخل في دائرة التعامل، أي من الأموال التي يجوز بيعها وهبتها والتصرف فيها، على نحو ما بينا عند الكلام على الرهن الرسمي. كما يلزم أن يكون المال مما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني، فلا يكفي أن يكون المال داخلاً في دائرة التعامل، وإنما يلزم أن يكون مما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد. وهذا شرط تقتضيه الحكمة من الرهن.

الشرط الثاني : أن يكون المال المرهون معيناً.

ينص القانون بالنسبة للرهن الرسمي على ضرورة تعيينه تعييناً دقيقاً. فهل يلزم ذلك بالنسبة للرهن الحيازي؟ لم يرد بين نصوص الرهن الحيازي ما يحيل

(١) د توفيق حسن فرج : التأمينات الشخصية والعينية طبعة ١٩٨٤ ص ٢١٥.



على النصوص الخاصة بالرهن الرسمي في هذا الصدد، لذلك ثار الخلاف عن انطباق القواعد الخاصة بالرهن الرسمي من حيث استلزام كون المرهون معيناً تعييناً دقيقاً، أم نطبق القواعد العامة التي تكتفي بأن يكون محل الالتزام معيناً أو قابلاً للتعيين.

يذهب الرأي السائد (١) إلى أنه حيث لم يرد في خصوص الرهن الحيازي ما جاء في شأن الرهن الرسمي من وجوب تخصيص العقار المرهون عن طريق تعيينه تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه في العقد ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً. فإنه يكفي في تعيين المال المرهون حيازياً أن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة، بأن يكون معيناً بالذات أو معيناً بالنوع ولو لم يحدد بذاته مع ذكر مقداره أو ما يستطيع به تعيين مقداره. ويستند هذا الاتجاه إلى أن المشرع لم يحل في م ١٠٩٨ إلى م ١٠٣٥ المتضمنة لمبدأ تخصيص الرهن.

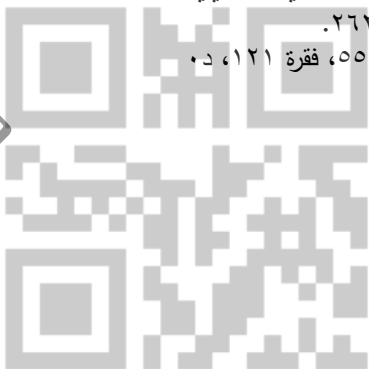
كما يستند هذا الاتجاه أيضاً إلى أنه أحاله م ١٠٩٨ إلى م ١٠٣٣ مدني وما تتضمنه من بطلان رهن المال المستقبلي لا يستفاد منها الأخذ بمبدأ التخصيص، بمقتضى إشارة النص، على اعتبار أن بطلان رهن المال المستقبلي يستند إلى عدم وجود المعقود عليه حال التعاقد وليس إلى مخالفته لمبدأ التخصيص، وإلا لما لزم النص عليه بحكم خاص في المادة ١٠٣٣ مدني. بدلالة أن رهن المال المستقبلي يكون باطلاً ولو عين المال المستقبلي تعييناً دقيقاً.

2024/2025 بينما يذهب اتجاه آخر (٢) إلى انطباق حكم المادة ١٠٣٥ على الرهن 2024/2025

الحيازي، على أساس أن مبدأ تخصيص الرهن مقرر فيه أيضاً، مستندي في هذا إلى أن منع رهن المال المستقبلي حكم يقتضيه مبدأ تخصيص الرهن وما دام الشارع يأخذ به في الرهن الحيازي، فإن هذا يقتضي أيضاً أن يكون المال المرهون معيناً تعييناً دقيقاً يمنع اختلاطه بغيره، لأن هذا التعيين وسيله أساسية لتحقيق تخصيص الشيء المرهون.

ويضيف أصحاب هذا الرأي أن القانون يستلزم تعيين المال المرهون رهناً حيازياً في قائمة القيد، إذ تقرر المادة ١١١٤ أنه يسرى على القيد بالنسبة للرهن الحيازي العقاري الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي، ومن هذه الأحكام وجوب

(١) د. عبد المنعم البدرأوى: التأمينات العينية طبعة ١٩٧٢ ص ٣٠٣، د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط ١٠ ح. التأمينات الشخصية والعينية طبعة ١٩٧٠ ص ٧٦٥، د. منصور مصطفى منصور: التأمينات العينية طبعة ١٩٦٣ ص ١٩٨، د. نبيل سعد: التأمينات العينية والشخصية طبعة ١٩٨٢ ص ١٨٣، أحمد سلامة: المرجع السابق ص ٢٦٢.
(٢) د. شفيق شحاته: النظرية العامة للتأمين العيني ط ٣ طبعة ١٩٥٩ فقرة ٥٥، فقرة ١٢١، د. توفيق فرج: المرجع السابق ص ٢١٦.



تعيين العقار تعييناً دقيقاً. كما تقرر المادة ١١١٧ فى شأن رهن المنقول أنه يشترط لنفاذه فى حق الغير، إلى جانب انتقال الحيازة، أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن، والعين المرهونة بياناً كافياً.

والواقع أنه يمكن تبرير عدم استلزام تعيين الشئ المرهون رهنًا حيازياً بذاته، والاكتفاء بتعيينه فى الاتفاق على هذا الرهن، أو حتى قابليته للتعيين، دون أن يكون ذلك مؤدياً إلى أى ضرر بمصالح الدائن المرتهن أو الغير^(١). على أساس أن تخلى الراهن عن حيازة الشئ المرهون للدائن المرتهن أو الغير، يقتضى بالضرورة تعيين هذا الشئ المرهون بذاته، عند تسليمه إلى من تنتقل إليه الحيازة، مما يغنى عن استلزام هذا التعيين الكامل للشئ المرهون منذ الاتفاق على الرهن الحيازى، مادام الإجراء اللاحق والضرورى لقيام الرهن فى مواجهة الغير، وهو نقل الحيازة، يتم به هذا التعيين الكامل ويحقق الفوائد المترتبة على هذا التعيين.

الشرط الثالث: أن يكون المال المرهون موجوداً وقت الرهن :

سواء كان المال المرهون عقاراً أم منقولاً فإنه يجب أن يكون موجوداً وقت إبرام العقد، فإذا لم يكن موجوداً وإنما كان شيئاً مستقبلاً، وقع الرهن باطلاً بطلاناً مطلقاً. وقد نصت المادة ١٠٩٨ على أن «تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة ١٠٣٣». وهذه الأخيرة تنص فى فقرتها الثانية على أنه يقع باطلاً رهن المال المستقبلى.

2024/2025

الفصل الثانى

2024/2025

ملكية الراهن للشئ المرهون

لكى ينعقد الرهن الحيازى صحيحاً، كما هو الشأن بالنسبة للرهن الرسمى، يجب أن يكون الراهن مالكاً للشئ المرهون، سواء كان الراهن هو المدين نفسه أو كان شخصاً آخر يقدم الرهن ضماناً لدين على المدين مادة ١٠٩٦ مدنى. ولكن ما هو الحكم إذا رهن الشخص شيئاً لا يملكه، وهو رهن ملك الغير، رهن المالك تحت شرط، رهن المبانى المقامة على أرض الغير، رهن الأشياء المملوكة على الشيوع.

أولاً : رهن ملك الغير :

أسلفنا أنه لى ينعقد الرهن الحيازى صحيحاً، يجب أن يكون الراهن مالكاً للشئ المرهون، فما هو الحكم إذا رهن الشخص شيئاً - عقاراً أو منقول - لا يملكه؟ نصت المادة ١٠٩٨ على أن تسرى أحكام المادة ١٠٣٣ الخاصة بالرهن

(١) د جميل الشرقاوى : التأمينات الشخصية والعينية طبعة ١٩٩١ ص ٣٢٢.

الرسمى على الرهن الحيازى. وقد نصت المادة ١٠٣٣ على حكم رهن ملك الغير فقضت بأنه «إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، فإنه عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن».

يتضح من هذا النص أن رهن ملك الغير يقع قابلاً للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن ويزول هذا البطان ويصبح عقد الرهن صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى، أو إذا صار الراهن مالكاً للشئ المرهون. إلا أنه يلاحظ فى هذا الصدد أن إقرار المالك الحقيقى فى حالة الرهن الرسمى، يلزم أن يكون طبقاً للمادة ١٠٣٣ بورقة رسمية، وذلك نظراً لأن الرهن نفسه لا ينعقد إلا فى الشكل الرسمى. ولكن لما كان الرهن الحيازى يتم دون حاجة إلى ورقة رسمية، فإن إقرار المالك الحقيقى فى هذه الحالة لا يلزم أن يكون بورقة رسمية. ولكن أن لم يقر المالك الحقيقى الرهن فلا يكون للعقد أثر بالنسبة له، ويكون له تبعاً لذلك أن يعتبر الرهن غير موجود ويتصرف فى الشئ على هذا الأساس.

إلا أنه نظراً إلى أن الرهن الحيازى يرد على المنقول كما يرد على العقار، فإن تطبيق قاعدة كسب الحقوق على المنقول بالحيازة مع حسن النية وفقاً لحكم المادة ٩٧٦ مدنى يؤدى إلى نفاذ رهن منقول مملوك للغير، رهنأ حيازياً، إلى المالك حسن النية، على مالك هذا المنقول دون صدور إقرار منه لهذا الرهن. وقد نص المشرع فى صدد الرهن الحيازى بصفة خاصة على هذا الحكم فقضت المادة ١١١٨ بأن « ١- الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها، تسرى على رهن المنقول. ٢- وبوجه خاص يكون للمرتهن، إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن، ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشئ المرهون، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشئ المرهون، ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن».

وهذا يعنى أن مرتهن ملك الغير، حسن النية، أى الذى لا يعلم عند بدء حيازته للمنقول المرهون، أن الراهن غير مالك، ينشأ لمصلحته حق رهن يحتج به فى مواجهة المالك والغير، استناداً للحيازة وحسن النية، والسبب الصحيح الذى هو العقد الذى لا يعيبه سوى صدوره من غير مالك. ويلاحظ فى هذا الصدد أن الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقدّم الدليل على عكس ذلك م ٩٧٦/٣.

إذا كان للدائن المرتهن أن يتمسك بقاعدة الحيازة على النحو السابق ، فإنه بموجب المادة ١/٩٧٧ يكون للمالك المنقول أن يسترده مما حازه بحسن نية في حالة الفقد أو السرقة وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة ، ويكون للمالك أن يسترد الشيء دون أن يكون للحائز التمسك قبله بقاعدة الحيازة.

وإذا كان المشرع قد حمى الحائز حسن النية، وأجاز له التمسك بقاعدة الحيازة وجعل لصاحب الشيء المنقول أن يسترده في حالة الفقد والسرقة خلال ثلاث سنوات، فإنه قد نظر إلى مصلحة الحائز مرة أخرى، إذ نص في المادة ٢/٩٧٧ على أنه «فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه مما يتجر في مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه». وهذه الفقرة تجعل للمشتري الحق في مطالبة المسترد بالثمن الذي دفعه في هذه الحالة فهل يفيد المرتهن الذي ارتهن المنقول المسروق أو الضائع ممن يتجر في مثله من هذا الحكم، فيطالب المسترد بأن يؤدي له الحق المضمون بالرهن كشرط للاسترداد؟

ذهب رأى أن المادة ٢/٩٧٧، لا تعنى سوى مشتري المنقول المسروق أو الضائع، فلا يحق للدائن المرتهن أن يستفيد من حكمها، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن حكم المادة ٢/٩٧٧ ينسحب كذلك إلى الدائن المرتهن الذي يكون له أن يتمسك بحكمها ويمتنع عن رد المنقول حتى يستوفى الدين الذي قام رهن المنقول ضماناً للوفاء به.

2024/2025

2024/2025

ونذهب مع أصحاب الرأي الثاني (١)، لأن مقتضى الإحالة الواردة في المادة ١١١٨ هو وجوب إعمال النصوص المحال إليها ومن بينها المادة ٢/٩٧٧ على الوجه الذي يلائم مركز المرتهن، فيفترض انصراف الحكم إلى المرتهن ويكون له الحق في المطالبة بالحق المضمون.

الرهن من المالك تحت شرط :

قد تكون ملكية الراهن للشيء المرهون معلقة على شرط ، سواء كان شرطاً واقفاً أم فاسخاً، ويسرى على الرهن الحيازي المعلق على شرط الأحكام السابق بينها بالنسبة للرهن الرسمي. إلا أنه ينبغي أن يراعى ما يترتب على إعمال قاعدة الحيازة في حالة المرهون المنقول في هذا الصدد، فقاعدة الحيازة كثيراً ما تعطل الأثر الرجعي للشرط، إذ يكون للدائن المرتهن أن يتمسك بها ويمتنع عن رد الشيء المرهون.

(١) د توفيق فرج: المرجع السابق ، ص ٢٢٠ ، د جميل الشرقاوى: ص ٣٢٨.



وينبغي أن يراعى أن المالك تحت شرط واقف، قد لا تتوافر له حيابة الشيء ، فلا يستطيع نقل حيازته إلى الدائن المرتهن، وبالتالي لا يمكن للدائن عملاً ، أن يتمسك بالقاعدة (١). وبالنسبة لحالة الشرط الفاسخ، إذا تحقق الشرط فإنه يزول الملكية بأثر رجعي، مما يؤدي إلى القول بزوال الرهن أيضاً، إلا أن هذا الزوال المترتب على منطق الأثر الرجعي، يصطدم في حالة رهن المنقول بتمسك الدائن المرتهن بقاعدة الحيازة، وبذلك يظل الرهن قائماً رغم زوال ملكية الراهن .

وإذا كان المشرع قد حمى الدائن المرتهن حسن النية في الرهن الرسمي وأبقى على الرهن المقرر على عقار زالت ملكيته عن الراهن بأثر رجعي (م ١٠٣٤) إلا أنه لم يحل إلى حكم هذا النص فيما أحال إليه من أحكام الرهن الرسمي بالنسبة للرهن الحيازي، لذا قال بعض الفقه بعدم تطبيق حكمه على الرهن الحيازي، ولكن أغلب الشراح يذهبون إلى تطبيق حكمه في الرهن الحيازي، على أساس أن هذا الحكم مقرر كقاعدة عامة في نص المادة ١٧/٢ من قانون الشهر العقاري. بل ويضيف البعض أن حماية الأوضاع الظاهرة تؤدي إلى القول بالإبقاء على الرهن حماية للمرتهن حسن النية إذا زالت ملكية الراهن بأثر رجعي.

رهن المباني المقامة على أرض الغير :

رهن الأبنية المقامة في ملك الغير رهناً حيازياً ، لا تختلف أحكامه عن أحكام رهن هذه الأبنية رهناً رسمياً، وذلك رغم أن نصوص الرهن الحيازي في القانون المدنى لا تحيل إلى حكم المادة ١٠٣٨ التي تنظم رهنها رهناً رسمياً، على أساس أن ما تقرره المادة ١٠٣٨ من أحكام رهن الأبنية استقلاً ، هو حكم القواعد العامة للقانون، وأن انتقال حق المرتهن حيازياً إلى ما يحل محل هذه الأبنية ثم أنقاضها أو من التعويض الذى يستحقه الباني قبل مالك العقار الأصلي ، تطبيق لحكم المادة ١٠٤٩ مدنى التى تقضى بانتقال حق المرتهن إلى ما ينشأ للراهن من حقوق بسبب تلف الشيء المرهون أو هلاكه ، وأن حكم المادة ١٠٤٩ ينطبق على الرهن الحيازي، وفقاً لنص المادة ١١٠٢/٢ مدنى والتي تنص على:- «تسرى على الرهن الحيازي أحكام المادتين ١٠٤٨ ، ١٠٤٩ المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمياً أو تلفه، بانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق». ويفسر الفقه نص المادة ١٠٤٩ إلى الأحوال التى تزول فيها ملكية الراهن دون أن يكون للمرتهن حق تتبع العقار كما هو الحال بالنسبة لنزع الملكية للمنفعة العامة.

(١) د. توفيق فرج : المرجع السابق ص ٢٢١.



رهن الشيء المملوك على الشيوع :

المشرع نظم الآثار المترتبة على رهن المالك الشائع رهناً رسمياً (م ١٠٣٩) ولكن بالنسبة إلى الرهن الحيازي لم يرد تنظيم خاص في هذا الصدد، ولم يحل المشرع إلى الأحكام الخاصة برهن المالك الشائع رهناً رسمياً.

وإذا كان المشرع لم يورد تنظيماً خاصاً لرهن المال الشائع رهن حيازه، فإن الأمر يخضع للقواعد العامة، فيجوز رهن الحصة الشائعة رهن حيازه، ويقع هذا الرهن صحيحاً وإن اصطدم بعقبة عدم إحكام حيازة هذه الحصة حتى ينفذ الرهن في حق الغير. غير أن هذه العقبة يمكن التغلب عليها بأن يحوز المال «عدل» نيابة عن بقية الشركاء وعن الدائن المرتهن.

أما رهن جزء مفرز فيقع صحيحاً أيضاً بين طرفيه، وإن كان لا ينفذ في حق بقية الشركاء، غير أن عدم النفاذ هذا قد يتعطل إذا توافرت شروط الحيازة في المنقول سند الحائز.

المبحث الثالث

الالتزام المضمون

إحالة إلى أحكام الرهن الرسمي :

الرهن الحيازي ككل تأمين عيني أو شخصي، حق تابع لا يتصور قيامه إلا استناداً لوجود حق آخر يكون الرهن الحيازي ضماناً له، وبالإضافة إلى وجود الحق، يجب أن يكون هذا الحق معيناً، وهي نفس الشروط التي تلزم في الحق الذي يضمنه الرهن الرسمي، وهو ما يؤخذ من المادة ١٠٩٨ مدني التي تقضي بانطباق حكم المادتين ١٠٤٠، ١٠٤٢ الواردتين في تنظيم الرهن الرسمي، على الرهن الحيازي. فالمادة ١٠٤٠ مدني تنص على أنه يجوز أن يرتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي أو اعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار، بشرط تحديد مقدار الدين المضمون أي بيان حده الأقصى، أما المادة ١٠٤٢ مدني فتقضي بارتباط الرهن بالدين المضمون وجوداً وعدماً، ولذا نحيل في أحكام الحق الذي يضمنه الرهن الحيازي إلى ما سبق بيانه في خصوص الالتزام المضمون بالرهن الحيازي (١).

(١) راجع ما سبق ص ١٦٣ وما بعدها.

الفصل الثانى آثار الرهن الحيازى

تقسيم :

الرهن الحيازى عقد ينشئ للمرتهن حقاً عينياً تبعياً على الشئ المرهون، ومن ثم تترتب عليه طائفتان من الآثار، آثار بين المتعاقدين، وآثار بالنسبة للغير. ونعرض لكلٍ فى مبحث مستقل .

المبحث الأول

آثار الرهن بين المتعاقدين

آثار الرهن بين عاقدين تتخذ صورة التزامات وحقوق، أما الالتزامات فهي تثقل عاتق كل من الطرفين نظراً لأن العقد ملزم للجانبين. وأما الحقوق فهي تكون للمرتهن. وإن كان يقال أن هناك حقاً تكون للراهن، غير أن هذه الحقوق لا تنشأ له بمقتضى عقد الرهن، بل تبقى له بمقتضى حقه فى الملكية.

الفرع الأول

إلتزامات الراهن وحقوقه

إلتزام الراهن بإعطاء حق الرهن :

ينشئ عقد الرهن الحيازى التزم على عاتق الراهن بأن ينشأ للمرتهن حق الرهن الحيازى، وهو حق عينى تبعى على الشئ المرهون يكتسبه المرتهن فور التعاقد طالما كان الشئ المرهون معيناً بذاته ومملوكاً للراهن. أما إذا كان الشئ المرهون غير معين بالذات، بل بالنوع، فلا ينشأ حق الرهن إلا بالإفراز، وعلى الراهن أن يقوم بذلك وإلا كان مخالفاً بالتزامه.

وإذا كان الشئ المرهون معيناً بذاته لكنه مملوك لغير الراهن، فلا ينشأ حق الراهن إلا إذا تملك الراهن الشئ المرهون، فإذا لم يتم ذلك اعتبر الراهن مخالفاً بالتزامه، ويكون للدائن أن يطالبه بالدين فوراً لسقوط الأجل بسبب عدم تقديم ما وعد به من تأمينات (١)، كما يكون للدائن كذلك أن يطالبه بالتعويض إن كان له محل.

الالتزام بتسليم الشئ المرهون :

التسليم ليس ركناً من أركان عقد الرهن الحيازى لأنه عقد رضائى وليس عقداً عينياً، ولكنه التزم يقع على عاتق الراهن بتسليم الشئ المرهون إلى الدائن

(١) د أحمد سلامة: المرجع السابق ص ٣٦٩، د توفيق فرج: المرجع السابق ص ٢٢٨.

المرتتهن أو إلى الشخص الذى عينه المتعاقدان (المواد ١٠٩٦ - ١٠٩٩ - ١١٠٩ مدنى). والالتزام بالتسليم له أهمية كبيرة فى الرهن الحيازى، فتتفذه شرط لنفاذ الرهن فى مواجهة الغير، أى شرط للاحتجاج بحق الرهن فى مواجهة الدائنين الآخرين وغيرهم ممن يكسب حقوقاً على الشئ المرهون، كما أنه أساس لنشوء التزامات المرتتهن بصيانة الشئ المرهون واستغلاله.

وقد أحال الشارع فى تنظيم التزام الراهن بتسليم الشئ المرهون إلى أحكام تسليم الشئ المبيع، وعلى ذلك يلتزم الراهن بتسليم الشئ المرهون، وملحقاته بالحالة التى كان عليها وقت الرهن. كما تطبق أحكام البيع كذلك بالنسبة لزمان التسليم ومكانه وكيفيته.

وينبغى أن يراعى ألا تطبق من أحكام البيع إلا ما لا يتعارض مع الحكمة التى اشترط التسليم من أجلها. ذلك أن تسليم الشئ المرهون إلى المرتتهن أو إلى العدل، قصد من ورائه جعل الرهن نافذاً قبل الغير. ولهذا لا تسرى على التسليم هنا أحكام التسليم الحكمى لأنه لا يجرى فى نفاذ الرهن على الغير. فلا يصح أن يحتفظ الراهن بالمال المرهون على أساس آخر كالعارية أو الإيجار. إلا أنه إذا كان المرهون عقاراً أو استبقى الراهن حيازته على سبيل الإيجار، فإن الرهن يصح متى ذكر ذلك فى قائمة القيد أو تم التأشير به إذا وقع فى تاريخ لاحق.

ونظر للأهمية الظاهرة لحيازة الشئ المرهون، على نفاذ حق الرهن، فإن 2024/2025 2024/2025 الراهن بالتزامه بالتسليم إخضاعاً للالتزام أساسى يجعل للدائن المرتتهن حق حمله على تنفيذه جبراً إن كان ذلك ممكناً طبقاً للقواعد العامة، فإذا أصبح التنفيذ غير ممكن جاز فسخ الرهن، والمطالبة بالوفاء بالدين المضمون فوراً لسقوط الأجل بسبب عدم تقديم المدين ما وعد به من تأمينات. كما يجوز المطالبة بالتعويض إن كان له محل.

الالتزام بضمان سلامة الشئ المرهون :

تنص على هذا الالتزام المادة ١١٠١ من القانون المدنى التى تقضى بأن «يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتى عملاً ينقص من قيمة الشئ المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتتهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشئ المرهون».

يتضح من النص السالف أن الراهن يضمن سلامة الشئ المرهون، بأن يمتنع عن إتلافه أو إنقاص قيمته عما كانت عليه عند إبرام الرهن، أو الاستيلاء

على بعض ملحقاته، قبل التخلي عن حيازته إلى المرتهن أو الأجنبي الذي يتفق على تسليمه إليه.

كما يلتزم الراهن بضمان استعمال الدائن المرتهن حقوقه على الشيء المرهون ، بمعنى أن يمتنع عليه التعرض لهذا المرتهن أو العدل في حيازة الشيء المرهون ، كما يترتب عليه أيضاً وجوب امتناعه عن وضع أية عوائق أمام قيام المرتهن باستغلال الشيء المرهون والحصول على ثماره.

أما ضمان الراهن لنفاذ الرهن، فيوجب عليه أن يعاون المرتهن في كل إجراء يلزم اتخاذه لتحقيق نفاذ الرهن في مواجهة الغير، كالمعاونة في إجراء قيد الرهن إن كان الشيء المرهون عقاراً، وتحرير سند بعقد الرهن إن كان المرهون منقولاً (م ١١١٧ مدنى) بالإضافة إلى انتقال الحيازة. وكذا يوجب عليه التزامه بضمان نفاذ الرهن ألا يتصرف فيه بعد الرهن إن كان منقولاً إلى شخص حسن النية مع تمكنه من الحيازة قبل المرتهن حتى لا يصبح مفضلاً على هذا الأخير وفقاً لقواعد الحيازة. وإذا كان المرهون عقاراً يجب عليه ألا يقوم ببيعه لشخص يقوم بالتسجيل قبل قيد الرهن، إذ لا يكون الرهن نافذاً في هذه الحالة في مواجهة المشتري.

تبعة هلاك الشيء المرهون :

تنظم المادة ١١٠٢ مدنى أثر هلاك الشيء المرهون، فتتضمن بأنه «١- يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً لخطئه 2024/2025 أو ناشئاً عن قوة قاهرة. ٢- وتسرى على الرهن الحيازي أحكام المادتين ١٠٤٨، ١٠٤٩ المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمياً أو تلفه، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق».

وحكم الفقرة الأولى من المادة ١١٠٢ ، فيما تقرره من ضمان الراهن لهلاك الشيء المرهون بخطئه أو بالقوة القاهرة، هو تطبيق للقواعد التي تلزم الراهن بضمان سلامة الشيء المرهون، أو تلك التي تجعله باعتباره مالكا، متحملاً بتبعة هلاك ما يملكه بقوة قاهرة. أما الفقرة الثانية من هذه المادة فهي إحالة إلى المادة ١٠٤٨ ، ١٠٤٩ مدنى لتطبيق أحكامها فيما يتعلق بهلاك العقار المرهون رهناً رسمياً، وانتقال حق الدائن إلى ما يحل محله. لذا نكتفى في بيان حقوق كل من المدين والدائن المرتهن التي تترتب على هلاك الشيء المرهون في صورته المختلفة لما سبق أن بيّناه في دراسة الرهن الرسمي^(١).

(١) راجع ما سبق ص ١٧٨ وما بعدها.

ثانياً : حقوق الراهن :

لا يؤدي الرهن إلى خروج الشيء المرهون من ملك الراهن، ولذا يظل مالكاً لحقوق المالك وسلطاته إلا ما يتعارض منها مع حقوق الدائن المرتهن. ولكن ولأن الرهن الحيازي يقتضى تخلى الراهن عن حيازة الشيء المرهون، لذا يتعطل من سلطات المالك ما يرتبط بالحيازة كالاستغلال، ويبقى له حق التصرف .

فللراهن أن يتصرف فى الشيء المرهون ، مع ملاحظة أنه بالنسبة للتصرفات المادية لا يكون للراهن القيام بها، متى كانت تؤدي إلى المساس بسلامة الشيء المرهون. أما بالنسبة للتصرفات القانونية، فتبقى للراهن وحده، فله أن يبيع الشيء المرهون أو يهبه وله أن يرهنه كذلك وهذا لا يؤثر بطبيعة الحال فى حق المرتهن طالما كان حقه سابقاً على هذه التصرفات وسارياً فى مواجهة الغير المتصرف إليهم. ويكون للمرتهن أن يمتنع عن تسليم الشيء المرهون ويحبسه إلى أن يستوفى حقه. هذا ولا يقتصر الأمر على بقاء الملكية للراهن فى هذه الحالة، بل تظل له الحيازة القانونية للشيء ، أما المرتهن فإنه مجرد حائز عرضى. ولهذا فإن المرتهن لا يمتلك الشيء بالتقادم مهما طالّت المدة - ما لم يغير سبب حيازته (م ٩٧٢ مدنى). ويترتب على ذلك أيضاً أنه إذا كان الراهن قد رهن ملك الغير، وتوافرت شروط كسب الملكية بالتقادم، فإن التقادم، يتم لحساب الراهن، حتى ولو كان الشيء فى حيازة المرتهن، لأن هذا الأخير يحوز نيابة عن الراهن.

2024/2025

الفصل الثانى

2024/2025

التزامات المرتهن وحقوقه

الرهن عقد جامع بين الأمانة والتوثق، بمعنى أن المرهون وثيقة فى يد الدائن المرتهن لضمان حقه فى الحصول على الدين المضمون بالرهن، كما أنه أمانة يلتزم بالمحافظة عليها وردها بعد قضاء دينه وعلى ذلك ومتى انتقلت الحيازة إلى المرتهن تمكن هذا من حبس العين المرهونة إلى حين استيفاء حقه، وتمكن أيضاً - من مباشرة دوره كدائن مرتهن، فيستطيع أن يحافظ على العين المرهونة ويديرها ويستغلها، ويحاسب الراهن بما أنفق عليه إذا لم يكن قد ترك له ما ينفق عليه منه ، إلى أن ينتهى الرهن فيرده إلى مالكة.

لذلك يفرض المشرع على هذا المرتهن من الالتزامات ويعطى له من سلطات ما يحقق الغرض من الرهن وهو نفع طرفيه، فيلزمه بحفظ المرهون وما يستتبع هذا الحفظ من صيانة وإدارة واستغلال لذلك الشيء، كما يلتزم برده. ونعرض لكل من ذلك .

المحافظة على المرهون وصيانتة :

سلطة الدائن المرتهن في حفظ الشيء المرهون تبدأ من لحظة تسلمه إياه. فإذا تسلم الشيء المرهون فإنه يلتزم بحفظه وصيانتة. وقد جاءت المادة ١١٠٣ مدني صريحة في ذلك أن المرتهن يقوم بأعمال الحفظ والصيانة إذا تسلم الشيء المرهون حيث قضت « إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانتة من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه ».

فيجب على الدائن أن يقوم بما يلزم لحفظ الشيء وبقاؤه على الحالة التي كان عليها وقت أن تسلمه لأنه يلتزم برده بهذه الحالة. وهذا بالطبع يختلف بحسب طبيعة الشيء المرهون، عقاراً أو منقولاً ، مادياً أو معنوياً. فإذا كان المرهون بناء وجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية له ^(١). وإن كان سيارة أو آلة أخرى وجب عليه أن يقوم بأعمال الصيانة المعتادة لها وأن يستبدل ما عطب من أجزائها حتى لا تتلف الأجزاء الأخرى وألا يتركها دون استعمال لفترة طويلة ^(٢).

وقد أورد المشرع في المادة ١/١١١٦ تطبيقاً للقاعدة السابقة إذ ألزم الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب أو تكاليف. على أن هذا النص يطبق كذلك على رهن المنقول بما لو كانت هناك ضرائب مستحقة عنه ^(٣).

وقد أورد المشرع تطبيقاً آخر ^{2024/2025} للقاعدة في باب رهن الدين حيث ألزمت ^{2024/2025} المادة ٢/١١٢٦ المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه وأن يخطر الراهن بذلك.

وأساس التزام المرتهن بالمحافظة على الشيء أن الراهن لا ينقل إليه ملكية الشيء وإنما ينقل له الحيازة فقط وبصفة مؤقتة بما يؤدي بذاته إلى ضرورة قيام المرتهن بالمحافظة على الشيء الموجود وحيازته حماية لحق المرتهن في الملكية. وفي سبيل ذلك يلتزم باتخاذ مسلك معين في المحافظة على الشيء المرهون وصيانتة، هذا المسلك نص عليه المشرع في المادة ١١٠٣ مدني «بأن يبذل في حفظه وصيانتة من العناية ما يبذله الشخص المعتاد».

(١) د جمال الدين زكي : التأمينات ص ٤٠١ ، د توفيق فرج: المرجع السابق ص ٢٣٣.

(٢) د السنهوري : الوسيط : ١٠٠ ص ٨١٠.

(٣) د شفيق شحاته : التأمينات ص ١٣٧ ، د عبد التفاح عبد الباقي: التأمينات ص ٤٧٨.

أى أن المعيار الذى اعتد به القانون فى العناية المطلوبة فى حفظ المال المرهون هى عناية الشخص المعتاد . فالقانون يحدد معيار الحفظ بمعيار مادي متوسط هو معيار رب الأسرة المعنى بشئون أسرته كلها. بمعنى أن درجة العناية فى حفظ المرتهن للمال المرهون أمر يرجع للظروف والأحوال وهو يختلف حسب نوع الشئ المرهون وعرف الجهة وظروف التعاقد. أى لتقدير قاضى الموضوع.

كان مؤدى التزام الدائن المرتهن ببذل عناية الرجل العادى فى حفظ الشئ المرهون وصيانته أن يتعين على الراهن فى حالة هلاك الشئ أو تلفه أن يقيم الدليل طبقاً للقواعد العامة فى الالتزام ببذل عناية على تقصير الدائن المرتهن ليسأله عن هذا الهلاك أو ذلك التلف. ولكن المشرع قضى فى المادة ١١٠٣ مدنى على النقيض بأن الدائن المرتهن مسئول عن هلاك الشئ أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب آخر لا يد له فيه. وقد علل جانب من الفقه ذلك المسلك التشريعى بأن مسؤولية المرتهن فى المحافظة على الشئ المرهون هى مسؤولية تعاقدية فهو مسئول عن هلاك الشئ إلا إذا أثبت أن الهلاك يرجع إلى سبب آخر لا يد له فيه (١).

واعتبر جانب آخر من الفقه هذا المسلك تشدداً من المشرع (٢) فى نفي المسؤولية عن المرتهن، ولكن لا يؤدى كما اعتقد البعض إلى اعتبار التزام المرتهن التزاماً بنتيجة (٣)، فالالتزام لا يكون التزاماً بنتيجة بالمعنى القاطع إلا إذا ثبت فيه المدين تبعة الحادث المفاجئ، والقوة القاهرة، والأمر غير ذلك بالنسبة للدائن المرتهن.

على أن رأى الراجح (٤) والذى نؤيده يذهب إلى أن طبيعة التزام المرتهن بالحفظ لا يتأسس على نوع المسؤولية وكونها عقدية، بل على نوع التزام المرتهن وكون محله تحقق نتيجة أو بذل عناية. فالمشرع لم يكتف فى المادة ١١٠٣ مدنى بفرض التزام بالحفظ على عاتق الدائن المرتهن محله بذل عناية، بل ألقى عليه كذلك التزاماً بسلامة الشئ المرهون ومحله تحقيق نتيجة. هى أن يظل الشئ المرهون فى حيازته بالحالة التى كان عليها وقت أن تسلمه. فإن تلف أو هلك انعقدت مسؤوليته باعتباره ضامناً لنتيجة معينة، ما لم يثبت السبب الأجنبى.

(١) الأعمال التحضيرية د ٧ ص ٣١١، د السهنورى الوسيط د ١٠ ص ٨١١.

(٢) د سمير تناغو، التأمينات الشخصية والعينية طبعة ١٩٨٥ ص ٣٧٦.

(٣) د شفيق شحاته: المرجع السابق، ص ١٣٦.

(٤) د جمال زكى: التأمينات ص ٤٠٢، د منصور مصطفى: التأمينات ص ٢٢٤، د سليمان مرقس: التأمينات ص ٤١٠، د شمس الدين الوكيل: التأمينات طبعة ١٩٥٦ ص ٤٥٩.

ويضيف الفقه أن هذا الالتزام في الواقع يتفرع عن الالتزام برد الشيء المرهون عند انتهاء الرهن.

إدارة المال المرهون :

ما يتفرع عن الحفظ في باب الرهن الحيازي، التزام المرتهن بإدارة. فالمشرع يلقي على عاتق الدائن المرتهن حيازياً التزاماً بإدارة المال محل الرهن واستثماره على نحو قد يفضي إلى استهلاك الدين وملحقاته، دون حاجة للالتجاء إلى إجراء بيعه جبراً^(١). والدائن المرتهن إذ يباشر هذه السلطات يصدق عليه وصف الحائز القانوني، فهو يتمتع بسلطة مباشرة على الشيء المرهون وتلقى على عاتقه التزاماً بإدارته بالأسلوب الذي يتفق وصلاحيته. وهذا أمر منطقي إذ أنه الذي يحوز المرهون بحيث لا يوجد غيره يصلح لهذه الإدارة، ولأن الإدارة السليمة تعد مقتضى من مقتضيات المحافظة على المال المرهون.

وعلى هذا نصت المادة ١/١١٠٦ مدني « ١ - يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله».

يؤخذ من هذا النص أن الدائن المرتهن يلتزم بإدارة الشيء المرهون حيازياً بيد أنه يتقيد في هذه الإدارة بثلاث قيود :-

^{2024/2025} **الأول :** أن يبذل في هذه الإدارة من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، فلا يطلب عناية أكبر من ذلك ولا أقل ، مهما كانت عنايته بشئونه الخاصة، وبراعي في هذه الإدارة ما يتفق وطبيعة المرهون.

الثاني : أن يباشر هذه الإدارة كما كان يباشرها الراهن، بحيث لا يجوز له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن، ولأن تغيير طريقة الاستغلال لا تدخل في أعمال الإدارة المعتادة بل في أعمال التصرف المادية^(٢).

الثالث : أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله في الإدارة لأن عناية الشخص المعتاد التي تحدد مدى إلتزام المرتهن في الإدارة تقتضي المبادرة إلى هذا الإخطار، وأيضاً تعرضه بمناسبة التزام بالمحافظة على المرهون أيضاً.

(١) د. عبد الفتاح عبد الباقي : التأمينات ص ٥٨٩ ، د. شمس الوكيل : ص ٤٠٣.

(٢) د. نبيله رسلان : سلطات المرتهن حيازياً بين الشريعة والقانون ص ١١٥.

لا يتقاضى الدائن المرتهن أجراً عن هذه الإدارة لأنها التزام عليه، إلا أنه يبذل مصروفات في إدارة المال المرهون، فهذه كلها يستوفيه من غلة الشيء المرهون أو يستوفيه من الراهن. ومن هذه المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن، «المصروفات الضرورية» ويستوفيه كلها من الراهن، لأن الأخير كان يصرفها لو كان الشيء في حيازته .

أما «المصروفات النافعة» يستوفى منها الدائن المرتهن من الراهن أقل القيمتين ما صرف فعلاً وما زاد عن قيمة الشيء المرهون بسبب ما صرف. وليس للدائن المرتهن حق امتياز بسبب هذه المصروفات ولكن له الحق في الحبس. أما «المصروفات الكمالية» فلا يسترد منها شيئاً.

أما الفوائد والضرائب التي يدفعها المرتهن على الشيء المرهون، له أن يستوفيه من ريع الشيء المرهون أو يستوفيه بالتقدم من ثمن المرهون. وما قد يصيب الدائن المرتهن من ضرر بسبب حيازة الشيء المرهون، وإن كان الأصل أنه لا يتقاضى أجراً عن الإدارة إلا أنه يجوز له أن يتفق مع الراهن على تقاضيه أجراً مقابل قيامه بإدارة المال المرهون لأن للراهن مصلحة في هذه الإدارة.

وتنص المادة ٢/١١٠٦ مدني «إذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو إدارة الشيء المرهون إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة، أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه . وفي حالة الإهمال الأخير إذا كان المبلغ المضمّن بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله، فلا يكون للدائن إلا ما بقي من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين الوفاء ويوم حلول الدين.

وبين من هذه المادة أنه إذا أخل الدائن المرتهن بواجبه في إدارة المال المرهون بأن تحقق أمر من الأمور التي نص عليها - إساءة استعمال حق الإدارة - الإدارة السيئة، الإهمال الجسيم فيها. كان للراهن الخيار بين أمرين:-

الأول : أن يطلب الراهن وضع الشيء المرهون تحت الحراسة فينزع الشيء المرهون من إدارة الدائن المرتهن السيئة، ويوضع في يد حارس يعنى به العناية اللائقة وقد يستمر ذلك إلى أن ينقضى الرهن.

الثاني : أن كان الراهن مستعداً أن يدفع ما عليه من الدين، فله أن يدفع الدين فينقضى الرهن. ومن ثم يسترد الراهن الشيء المرهون.

وطبقاً للقواعد العامة يكون ما يجريه الدائن المرتهن من إخلال بواجب الإدارة غير نافذ في حق الراهن، ويكون للأخير مطالبته بالتعويض عما يصيبه من ضرر نتيجة هذا الإخلال.

استثمار المال المرهون :

إدارة المال المرهون تقتضى استغلاله فيما لو كان هذا المال يغل ريعاً. وهذا حكم عام سواء كان محل الرهن الحيازي عقاراً أو منقولاً قابلاً للاستثمار. فالمرتتهن مكلف باستغلال العين المرهونة. وقد نصت على ذلك المادة ١١٠٤/٢ على المرتتهن أن يستثمر الشيء المرهون استثماراً كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك. بمعنى إذا كان الراهن قد أعفاه من هذا الالتزام فلا يسأل عن استغلال العين.

والاستغلال من التزامات المرتتهن، فوجود العين فى حيازته يجعل استغلالها من أُلزم واجباته خاصة وأن هذا الاستغلال يصبح متعزراً على المالك بعد خروج العين من حيازته، كما أن الراهن لا يستطيع أن يستبقى لنفسه حق الاستغلال لما فى ذلك من تعطيل لحق الحبس الذى يعتبر من صميم الرهن الحيازي.

وإن كان القانون قد أوجب على المرتتهن أن يستثمر الشيء على الوجه الذى يصلح له وبالطريقة المألوفة - فإنه لا يجوز أن يغير هذه الطريقة إلا إذا رضى الراهن بذلك. فاستغلال الأرض بزراعتها أو تأجيرها لمن يزرعها، واستغلال المساكن والبيوت يكون بسكنها أو بتأجيرها للسكنى. واستثمار المرهون وإن كان من طبيعة الرهن إلا أنه ليس من مستلزماته، فيجوز الاتفاق على ترك المرهون بدون استثمار سواء تم الاتفاق عند عقد الرهن أو بعده، صريحاً أم يستدل عليه ضمناً من ظروف الحال.

وإذا كان الدائن المرتتهن يلتزم باستثمار الشيء المرهون وإنما يلتزم باستثماره 2024/2025 لمصلحة الراهن، إذ ليس للمرتتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك. لأن انتفاع الدائن بالشيء المرهون دون مقابل يعنى حصوله على فائدة ربويه مستترة لدينه، هى مقابل هذا الانتفاع، وهى فائدة على خلاف المقرر قانوناً^(١).

لذلك يصبح المرتتهن مديناً للراهن بغلة الشيء المرهون، ويقصد بها المبالغ التى تبقى من تجارة بعد خصم نفقات الاستغلال. وإذا كان الدائن المرتتهن يستعمل الشيء المرهون بنفسه كما إذا سكن الدار المرهونة تعين تقدير قيمة الفائدة التى عادت عليه، وتقع المقاصة بين ما يكون المرتتهن مديناً به للراهن وما يكون دائماً به لهذا الأخير، فتخصم الغلة من مبلغ الدين.

ولما كانت القواعد العامة لا تجيز المقاصة بين ثمار الشيء المرهون وحقوق الدائن المرتتهن، لأن المقاصة لا تتم إلا بين دينين مستحقى الأداء م ٣٦٢

(١) د / السنهورى الوسيط د ١٠ ص ٨١٩، د / جمال زكى : ص ٤٠١

مدنى. فإنه استثناء من هذه القواعد العامة نصت المادة ٣/١١٠٤ على خصم هذه الثمار من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، كما وضع المشرع ترتيباً معيناً لهذا الخصم : فما حصل عليه الدائن من صافى الربح وما استفادة من استعمال الشئ يخصم : -

أولاً : من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشئ وفى الإصلاحات وتشمل أيضاً الضرائب والرسوم.

ثانياً : يخصم بعد ذلك المصروفات الأخرى التى أدخلها المشرع فيما يضمنه الرهن كمصروفات العقد الذى أنشأ الدين المضمون بالرهن، مصروفات عقد الرهن وقيدده عند الاقتضاء والمصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن مثل نفقات نقل الحيازة.

ثالثاً : وتخصم بعد ذلك الفوائد التى تستحق على أصل الدين سواء كانت فوائد قانونية أو اتفاقية.

رابعاً : ما تبقى بعد ذلك يخصم من أصل الدين المضمون.

ويستثمر المرتهن الشئ المرهون ويأخذ غلته أو يستفيد بها، وقد رأينا أن يتعين خصم صافى قيمتها من الالتزام المضمون وفقاً لترتيب معين نص عليه القانون. وقد يحدث أن يتفق الراهن والمرتهن - فى حالة ما إذا كان الشئ المرهون ينتج ثماراً أو إيراداً - على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد التى تستحق للمرتهن عما له من دين فى دمة مدينه. وفى هذه الحالة ووفقاً للمادة ١/١١٠٥ مدنى قرر المشرع أن يكون هذا الاتفاق نافذاً فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من فوائد اتفاقية.

وبناء على ذلك إذا اتفق على خصم الثمار من فوائد الدين كان الاتفاق صحيحاً و نافذاً قانوناً فى حدود ٧% وهو الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. فإذا لم يتفق على سعر الفائدة احتسبت على أساس السعر القانونى وهو ٤% فى المواد المدنية، ٥% فى المواد التجارية ويشترط ألا يجاوز هذا السعر قيمة الثمار وفى هذه الحالة إذا عين الطرفان أجلاً لحلول الدين يكون الدائن عند حلول الأجل المتفق عليه أن يطالب بما تبقى له بعد خصم صافى الغلة طبقاً للترتيب السابق، أما إذا لم يعيناً أجلاً لحلول الدين المضمون، فإن القانون لا يجيز للدائن أن يطالب باستبقاء حقه إلا عن طريق استنزاه من قيمة الثمار، ويخول للمدين الحق فى أن يوفى بالدين فى أى وقت بعد إجراء الخصم.



قد اختلف الفقه حول مركز المرتهن في استثمار الشيء المرهون وإدارته؛ هل يعتبر المرتهن نائباً عن الراهن في إدارة الشيء المرهون واستثماره أم يعتبر أصيلاً عن نفسه ظهر اتجاهان رئيسيان.

الاتجاه الأول : يذهب إلى أن الدائن المرتهن يعتبر نائباً عن الراهن ومن هذا الفريق من ذهب إلى أن يعتبر وكيلاً عنه، ذلك أن عقد الرهن يتضمن توكيلاً من الراهن إلى المرتهن بالإدارة والاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك، وإن كان البعض يرى أن من الصعب القول بأن الراهن قد انصرفت نيته إلى توكيل المرتهن، ولكنه يجد نفسه بحكم ما يرتبه القانون على الرهن الحيازي من آثار ملزماً بترك الحيازة للمرتهن، لهذا فإن ولاية المرتهن تستند إلى القانون، أي أنه نائب قانوني.

الاتجاه الثاني : ذهب إلى أن الدائن يقوم بالإدارة والاستثمار أصيلاً عن نفسه بمقتضى ما يخوله حقه العيني على الشيء المرهون من سلطات. فالمرتهن يستولى على الغلة أصيلاً عن نفسه لا نائباً عن الراهن. فهو حائز قانوني ومباشرته لسلطاته اقتضت من المشرع أن يلقى على عاتقه التزاماً بإدارة الشيء المرهون واستثماره على نحو قد يقضى إلى استهلاك الدين وملحقاته. ومن هنا إذا باشر الدائن المرتهن سلطته في الاستثمار - مراعيًا في ذلك الأحكام التي نصت عليها المادة ١١٠٦ مدني فإنه يعتبر في إدارة الشيء المرهون والاستيلاء على الشيء أصيلاً عن نفسه فيما هو مستحق له باعتباره ان حق الرهن يخوله ذلك. كما يعتبر في ذات الوقت نائباً عن الراهن فيما يزيد عن المستحق له، وعليه بهذه الصفة أن يقدم حساباً للراهن عن استثماره الشيء المرهون.

وإذا كان الدائن المرتهن يكتسب صفة الحائز القانوني، وهو بهذه المثابة يباشر سلطة الاستغلال والاستعمال ولا ينحرف في مباشرتها عن مسلك الرجل المعتاد كما يجب عليه إن وجد من الأمور ما يستدعي تدخل الراهن أن يبادر بإخطاره ، وعليه توزيع ما ينتج من الثمار على نحو معين، لأن هذه التصرفات من جانبه فيها مصلحة المدين وكذا مصلحته، فإذا قصر المرتهن في شيء من ذلك كان مسؤولاً أمام الراهن عن تقصيره. وقد تكفلت المادة ١١٠٦ مدني بتفصيل ذلك.

فإذا هلك الشيء المرهون أو تلف يفترض أن ذلك وقع بتقصير من الدائن المرتهن لأن الشيء في حيازته، وعليه أن ينفي مسؤوليته أن يثبت أن الهلاك أو التلف قد وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه. فإن لم يثبت ذلك فلا يجوز له أن يطلب شيئاً لأن الهلاك أو التلف قد حدث بخطأ منه، بل يجب عليه أن يدفع تعويضاً

عما أُلْفِه بخطئه. ويحل هذا التعويض محل ما هلك من الشيء أو تلف. ويصبح مرهوناً مثله في دين الدائن وهذا مثل من أمثلة الحلول العينية.

أما إذا كان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي فإن تبعة الهلاك أو التلف تنتقل على عاتق مالك الشيء وهو المدين أو الراهن، ويكون بالخيار بين أن يسقط أجل الدين فيصبح حالاً فيدفعه فوراً للدائن المرتهن أو يقدم تأميناً كافياً بدلاً من التأمين الهالك أو التالف.

الالتزام برد الشيء المرهون :

نصت المادة ١١٠٧ على أن « يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصرفات وتعويضات ».

ويتحدث النص عن التزام الدائن برد الشيء المرهون متى استوفى الراهن كامل حقه وما يتصل بهذا الحق. وذلك لأن الدين المضمون ينقضى في هذه الحالة، فينقضى الرهن تبعاً له ، وإنما يلزم أن ينقضى الدين المضمون كاملاً مع ما يتصل به. فإذا بقي جزء مما يضمنه الرهن، بقي الرهن إلى حين الوفاء بهذا الجزء الباقي إعمالاً لقاعدة عدم تجزئة الرهن.

وقد يلتزم المرتهن بالرد حتى ولو لم يستوف كامل حقه، وذلك كما إذا انقضى الرهن بنزول المرتهن عنه، أو إذا أساء إدارة الشيء المرهون حيث يلتزم برده إلى حارس يعين لتسلمه (م ١١٠٦/٢). وبصفة عامة يمكن القول بأن التزام الدائن برد الشيء المرهون لا يأتي نتيجة انقضاء الدين المضمون وتوابعه، ولكنه يأتي نتيجة انقضاء الرهن نفسه، لأي سبب من الأسباب. فإذا انقضى الرهن تعين على الدائن رد المرهون، وإذا كان الشيء في يد شخص آخر وهو "العدل" التزم برده كذلك.

وللراهن في سبيل الحصول على الشيء المرهون أن يطلب رده بإحدى دعويتين :-

الدعوى الشخصية الناشئة عن عقد الرهن نفسه ، ودعوى الاستحقاق.
وهناك فارق بين الدعويتين، فللراهن أن يلجأ إلى الدعوى الشخصية ولو لم يكن مالكا للشيء، أما دعوى الاستحقاق فلا يلجأ إليها إلا إذا كان مالكا. كما أن الدعوى الشخصية تسقط بالتقادم في تاريخ انقضاء الرهن، أي تاريخ التزام المرتهن بالرد، أما الاستحقاق فلا يسقط بالتقادم، لأن المرتهن وورثته يد عارضه على المرهون، ما لم يغيروا سند حيازتهم (م ٩٧٢ مدني).

حقوق الدائن المرتهن :

للدائن المرتهن رهناً حيازياً حقوق تثبت له باعتباره دائناً عادياً، وله بذلك ضمان عام على أموال مدينه، وإلى جانب ذلك حقوق تثبت له بمقتضى حق الرهن وهو حق عيني على الشئ المرهون.

فللدائن المرتهن بوصفه دائناً عادياً أن ينفذ على أموال المدين غير المرهونة، وهو بذلك يعتبر كبقية الدائنين العاديين، لا يكون له حق التقدم، كل هذا مع مراعاة أنه ليس للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال المدين لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف (مادة ٤٤٢ مرافعات).

وإذا كان الراهن غير المدين ، أى إذا كان الراهن هو الكفيل العيني، فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك (م ١٠٥٠ مدنى) وحكم هذه المادة واجب الأخذ به فى حالة الرهن الحيازى نظراً لإحالة المادة ١١٠٨ عليها.

وللدائن المرتهن حقوق باعتباره صاحب حق عيني تبعى هو حق الرهن. ومن هذه الحقوق ما يقابل التزامات الراهن. وله كذلك حقه فى التنفيذ على الشئ المرهون وأن يطلب بيعه وفقاً للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات. وتتص المادة ١١٠٨ على أنه «يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة ١٠٥٢ المتعلقة بشرط الملكية عند عدم الوفاء ، وشروط البيع ٢٠٢٤/٢٠٢٥ إجراءات.

2024/2025

وإذا كان الأصل أن يكون التنفيذ على الشئ المرهون وفقاً للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لرهن المنقول فنص فى المادة ١١٢١ على أنه «١- يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشئ المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق. ٢- يجوز له أيضاً أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشئ وفاء للدين على أن يجب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء».

المبحث الثانى آثار الرهن بالنسبة إلى الغير

تمهيد:

الرهن إذا ترتب على الشئ وأصبح نافذاً فى حق الغير يعطى للدائن المرتهن سلطة على الشئ هى أن يحبسه فى مواجهة الراهن والغير، وأن ينفذ عليه بالبيع فيستوفى حقه من الثمن متقدماً على من يتلوه من الدائنين، وتتبع العين فى يد من انتقلت إليه ملكيتها. هذا ما أوجزته المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى (١) يتضمن كل ما يثيره هذا الجزء من آثار الرهن.

فلا يكفى أن ينعقد الرهن حتى ينفذ فى حق الغير، بل لابد أن يقوم المرتهن بالإجراء الذى رسمه القانون ليصبح حقه سارياً بالنسبة للغير. ويقصد فى هذا الصدد بالغير كل من عدا المتعاقدين وورثتهما ممن يضار من استعمال المرتهن السلطات التى يخولها له حق الرهن. ويخول الرهن الحيازى الدائن المرتهن الحق فى حبس الشئ المرهون عن الكفالة، كما يخوله حق التقدم والتتبع. إلا أن الدائن لا يستطيع مباشرة هذه الحقوق فى مواجهة الغير إلا إذا كان الرهن نافذاً فى حقهم.

ونعرض أولاً لشروط نفاذ الرهن فى حق الغير، ثم حقوق المرتهن فى مواجهة الغير .

2024/2025

2024/2025
الفرع الأول

2024/2025

شروط نفاذ الرهن فى حق الغير

نصت المادة ١/١١٠٩ على أنه يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشئ المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان، وبناء على هذا النص فإن أول شرط لنفاذ الرهن الحيازى فى حق الغير هو «الحيازة». على أنه لا يكفى تسليم العين المرهونة للدائن المرتهن حتى ينفذ الرهن فى حق الغير، بل يجب أيضاً أن يقيد العقد إذا وقع الرهن على عقار، أو بدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ تحتوى على بيانات معينة إذا وقع الرهن على منقول، أو أن تتخذ إجراءات نفاذ حوالة الحق إذا كان ديناً. وعلى ذلك يجب توافر أمرين معاً حتى ينفذ الرهن الحيازى فى حق الغير ، الأول : حيازة المرتهن أو العدل للمال المرهون، والثانى: إجراء آخر يختلف باختلاف المال المرهون. ويجب توافر الأمرين معاً ولا يغنى أحدهما عن الآخر، ولا تثبت للمرتهن مرتبته إلا فى اللحظة التى يخضعان لها.

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية د ٧ ص ٢٢٠.

أولاً : الحيابة :

دور الحيابة فى الرهن :

استلزم القانون لنفاذ الرهن فى حق الغير أن تنتقل الحيابة إلى الدائن المرتهن أو إلى الشخص الذى يرتضيه الراهن أو المرتهن وهو ما يسمى بالعدل. فالحيابة شرط لنفاذ الرهن فى حق الغير أياً ما كان المال المرهون، عقاراً أو منقولاً، أياً ما كان نوع المنقول. مع ملاحظة أن الحيابة التى تنتقل إلى المرتهن أو العدل هى الحيابة العرضية. ويترتب على ذلك أولاً أن المرتهن لا يمكن أن يكتسب ملكية المال المرهون بالتقادم إلا إذا عارض حق المالك، أى غير سند حيازته. ويترتب على ذلك أيضاً أنه لو كان المال المرهون غير مملوك للراهن، وتوافرت شروط اكتساب المال بالتقادم، فإن التقادم يتم لمصلحة الراهن وليس لمصلحة المرتهن.

وانتقال الحيابة تحقق هدفين فى رهن المنقول، وتحقيق هدفها منهما فى رهن العقار فهى أولاً أداة لإعلام الغير أن المنقول لم يعد محرراً، أى أداة لإشهار حق الدائن المرتهن بما يحمله من حبس وتقدم وتتبع. وهى ثانياً تمكن المرتهن من الحصول على ثمار المنقول وخصمها من مستحقاته. أما بالنسبة للعقار فلا تحقق إلا هدفاً واحداً، فهى لا تقوم بوظيفة الإعلان أى الشهر، إذ الأخير فى العقار لا بد أن يقيد حتى ينفذ فى حق الغير (١). وإن كانت الحيابة فى العقار لا تقوم بوظيفة الإعلان إلا أنها تقوم بالوظيفة الثانية وهو تمكين المرتهن من قبض الثمار وخصمها من حقوقه لدى المدين الراهن.

شروط الحيابة :

يجب أن تكون الحيابة ظاهرة، ومستمرة حتى يقال أنها متوافرة فينفذ الرهن فى حق الغير.

١- أن تكون ظاهرة ، فيشترط فى الحيابة أن تكون ظاهرة ، لا خفاء فيها ولا غموض ولهذا لا يصح أن يحوز الراهن الشئ المرهون نيابة عن المرتهن أو أن يستعيه أو يعهد إلى الراهن بإدارته بصفته شريكاً للمرتهن، أو يستأجره منه. ويراعى هنا حالة العقارات. فقد خرج المشرع بالنسبة للعقارات حيث نصت المادة ١١١٥ مدنى على أنه يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير، فإذا اتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته، أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر

(١) د أحمد سلامة: المرجع السابق ، د توفيق فرج : المرجع السابق ص ٢٤٣.

به في هامش القيد، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمناً.

وإذا كان يلزم أن تكون الحيابة ظاهرة، فإنها تكفى متى كانت كذلك، حتى ولو كانت رمزية، طالما كان المرهون تحت سيطرة المرتهن بصورة تدل على أنه أصبح صاحب حق عليه. وتطبيقاً لفكرة الحيابة الرمزية نص القانون التجارى على أن الدائن يعتبر حائزاً للبضائع متى كانت تحت تصرفه فى مخزن أو سفينة أو فى الجمرىك أو مودعه فى مخزن عمومى أو متى سلمت اليه قبل وصول تذكرة شحنها أو نقلها (م ٧٧ تجارى).

وكذلك بالنسبة لرهن الديون، يكتفى القانون بتسليم سنداتها ، لأن الدين شئ معنوى لا تتصور حيابته، وفى هذا ما يدل على الاكتفاء بالحيابة الرمزية. وفى كل الأحوال سواء كانت الحيابة حقيقية أم رمزية يجب أن تكون ظاهرة واضحة حتى تتحقق فيها فكرة الإشهار والإعلان بالنسبة للغير.

٢- أن تكون الحيابة مستمرة : لكى يظل الرهن سارياً فى حق الغير يجب أن تستمر الحيابة بعيدة عن يد الراهن، فإذا عاد المرهون إلى يد الراهن أصبح الرهن غير نافذ فى حق الغير. وتضع المادة ١١٠٠ المبدأ العام فى هذا الشأن فتقضى « إذا رجع المرهون إلى حيابة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن، كل هذا دون إخلال بالشروط الأخرى لنفاذ الرهن فى حق الغير ».

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وفى الرجوع الذى يترتب عليه انقضاء الرهن يجب التفرقة بين الرجوع برضاء المرتهن والرجوع دون رضاه. وفى الحالة الثانية لا يفيد الرجوع تنازل المرتهن عن الرهن، ومن ثم يحق له أن يطلب استرداده من الراهن أو من غيره الذى اختلسه أو سرقه أو حازه لأى سبب من الأسباب.

أما إذا عاد الشئ المرهون برضاء المرتهن فيفرق بين ما إذا كان هذا الرجوع يفيد تنازل المرتهن عن الرهن، أو لا يفيد، فإن كان يفيد انقضى الرهن ، سواء فى علاقة الطرفين أو بالنسبة للغير. أما إذا كان الرجوع اختيارياً ولكنه لا يفيد النزول عن الرهن، فإن الرهن يبقى ويكون للمرتهن أن يسترد العين، إذا لم يكن رضى أن تبقى مدة معينة فى يد الراهن. فإذا كان قد رضى فلا يحق له أن يستردها إلا بعد انتهاء هذه المدة.

ثانياً : الشروط الأخرى لنفاذ الرهن فى حق الغير :

أسلفنا أن الحيابة لازمة لنفاذ الرهن فى حق الغير أياً ما كان الشئ المرهون. هذه الحيابة يضاف إليها شرط آخر يختلف باختلاف هذا الشئ.

أ - إذا كان المرهون عقاراً . نصت المادة ١١١٤ مدنى على أن «يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن»، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى. فلا تكفى الحيازة هنا بل يجب قيد الرهن، ولا يكتسب المرتهن مرتبة إلا منذ اجتماع هذين الأمرين. فلو تعددت الرهون فإن أسبقية القيد وحدها لا تكفى، بل ولا بد وأن تقترن بوضع اليد.

ب - إذا كان المرهون منقولاً مادياً . نصت المادة ١١١٧ مدنى على أنه « يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن.

واستلزام كتابة العقد هنا شرط لنفاذ الرهن فى حق الغير، مع تضمن الورقة البيانات اللازمة لتخصيص الدين المضمون والمال المرهون. أما ثبوت التاريخ فمقصود به منع الغش الذى يحتمل أن يأتیه الراهن والمرتهن إضراراً بالغير عن طريق تقديم التاريخ. وهذا يقتضى أن يكون عقد الرهن مكتوباً. مع ملاحظة أن الكتابة هنا لا تعتبر ركناً فى العقد، ولا شرطاً لنفاذه فى حق الغير، ولا حتى باعتبارها أداة لإثباته، وإنما حتى يتسنى إثبات تاريخ العقد.

وتتحدد مرتبة الدائن المرتهن من الوقت الذى يجتمع فيه شرط انتقال الحيازة وشرط ثبوت التاريخ كما أوضحنا معاً.

ج - بالنسبة لرهن الدين يفرق بين رهن الديون العادية والديون الثابتة 2024/2025 2024/2025 فى السندات الإسمية والإذنية والسندات لحاملها.

فبالنسبة للديون العادية، إذا كان الرهن يتم بين الراهن والمرتهن بإيجاب وقبول، إلا أنه لا ينفذ فى حق المدين (مدين الراهن) إلا بإعلانه أو بقبوله، كما هو الأمر فى حوالة الدين، ولا ينفذ فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون. وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول، متى كان سند الدين قد سلم إلى المرتهن. فإذا لم يسلم إليه إلا بعد التاريخ الثابت للإعلان أو القبول، فلا يكون للرهن مرتبته إلا من تاريخ التسليم (مادة ١١٢٣ مدنى). فالرهن لا ينفذ فى حق الغير إلا بانتقال حيازة سند الدين إلى المرتهن وبصيورته نافذاً فى حق المدين بالدين المرهون (مدين الراهن) من وقت إعلانه أو بقبوله الثابت التاريخ.

وبالنسبة للديون الثابتة فى سندات، يفرق من ناحية بين حالة ما إذا كان السند لحامله، وبين ما إذا كان إسمياً أو إذنياً من ناحية أخرى. فالسندات لحاملها تعامل معاملة المنقولات المادية نظراً لإندماج الحق فى السند، أما بالنسبة للنوعين

الآخرين من السندات فقد نصت المادة ١١٢٤ مدنى: « السندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحالة هذه السندات على أن يذكر أن الحالة قد تمت على سبيل الرهن، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.

فرهن السندات الإذنية يتم بتظهير هذه السندات بما يفيد أنه تم بقصد الضمان وتاريخ هذا التظهير مع حيازة السند يحدد مرتبة الرهن .. أما رهن السندات الإسمية فيتم بالتنازل عنها على سبيل الضمان، وإثبات هذا التنازل فى دفاتر الجهة التى أصدرتها مع التأشير به على الصك. وهذا القيد فى الدفاتر يحدد مرتبة الرهن.

الفرع الثانى

حقوق الدائن المرتهن فى مواجهة الغير

يخول حق الرهن الحيازى، للدائن المرتهن فى مواجهة الغير، ميزة التقدم وميزة التتبع، فضلا عن حق الحبس الذى يكفل له ضمان الوفاء بحقه. ونعرض لكل من هذه الحقوق .

الحق فى حبس الشئ المرهون :

تنص المادة ١١١٠ على أنه «١- يخول الرهن للدائن المرتهن الحق فى حبس الشئ المرهون عن الناس كافة، دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون. ٢- وإذا خرج الشئ من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه، كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة».

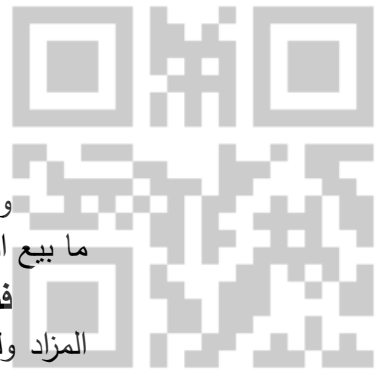
2024/2025

2024/2025

2024/2025

يعتبر حق الحبس على هذا النحو، ميزة تنفرع عن الحق العينى التبعى الذى ينشأ عن الرهن الحيازى للدائن المرتهن، فيختلف من ثم عن الحق فى الحبس الذى تنظمه المواد ٢٤٦ - ٢٤٨ مدنى. لذلك يتحدد نفاذ حق الحبس على مقتضى نفاذ حق الرهن، فيكون للدائن المرتهن أن يحتج به على الأشخاص الذين يكون الرهن نافذاً فى مواجهتهم .

فيكون للمرتهن أن يحتج بحق الحبس فى مواجهة الراهن حتى يستوفى حقه المضمون، ولو كان الراهن لم يستكمل إجراءات نفاذه فى مواجهة الغير، حيث ينشأ حق الرهن فيما بين المتعاقدين بمجرد إبرام العقد. ويكون للمرتهن كذلك متى صار الرهن نافذاً فى مواجهة الغير أن يحتج بحق الحبس فى مواجهة الغير، سواء كانوا دائنين عاديين للراهن، أم دائنين ذوى حقوق عينية تبعية ترتبت لهم على الشئ المرهون بعد استكمال إجراءات نفاذه فى مواجهة الغير، إنما لا يكون حق الحبس نافذاً فى مواجهة الغير الذين ترتبت لهم حقوق على الشئ المرهون، استكملت إجراءات نفاذها فى مواجهة الغير قبل الرهن .



ولكن هل يجوز للدائن المرتهن أن يحبس الشيء عن الراسى عليه المزداد إذا ما بيع الشيء جبراً؟ يفرق هنا بين رهن المنقول ورهن العقار.

فبالنسبة للعقار لا يجوز للدائن الحابس أن يحبس الشيء عن الراسى عليه المزداد ولو لم يستوف حقه كاملاً، سواء كان من باشر الإجراءات هو الدائن أو غيره، لأن رسو المزداد يطهر العقار من كافة الحقوق المقيدة ومنها الرهن الحيازى.

أما بالنسبة للمنقول يفرق بين ما إذا كان طالب البيع هو الدائن المرتهن حيازياً أم غيره. فإذا كان المرتهن حيازياً هو الذى طلب البيع، فلا يكون له حبس الشيء المرهون عن الراسى عليه المزداد ولو لم يستوف حقه كاملاً، لأن طلب البيع يتضمن نزولاً منه عن حقه فى الحبس، فلا يكون له إلا أن يستوفى حقه من الثمن بحسب مرتبته.

أما إذا كان البيع بناء على طلب دائن آخر، وكان هذا الدائن مفضلاً عن المرتهن حيازياً الحابس للشيء، فلا يكون للحابس الامتناع عن تسليم الشيء إلى الراسى عليه المزداد، إذ لا يجوز له التمسك بالحبس فى مواجهة الدائنين الذين حفظوا حقوقهم قانوناً. أما إذا كان طالب البيع دائناً متأخراً فى المرتبة عن الحابس أو دائناً عادياً، يكون للحابس أن يمتنع عن تسليم الشيء إلى الراسى عليه المزداد، إلى حين استيفاء حقه كاملاً.

حق التقدم :

للمرتهن وفقاً للمادة ١٠٩٦ مدنى، أن يتقدم الدائنين العاديين، والدائنين ^{2024/2025} التالىين له فى المرتبة، فى اقتضاء ^{2024/2025} حقه من ثمن الشيء المرهون. فيفترض استعمال حق أو ميزه التقدم - كما فى الرهن الرسمى - تنازعا بين الدائن المرتهن ودائن آخر، أو دائنين آخرين للراهن، وتخول له هذه الميزة أن يتقدم فى اقتضاء حقه على جميع الدائنين العاديين لهذا الأخير، وكذلك على الدائنين الذين ترتبت لهم حقوق عينية تبعية على الشيء المرهون بعد أن استكمل رهنه إجراءات نفاذه فى مواجهة الغير.

فيستوفى الدائن المرتهن حقه، عند تعدد الحقوق العينية التبعية على الشيء المرهون، وفقاً لمرتبة رهنه، التى تتحدد فى وقت استكمال إجراءات نفاذه فى مواجهة الغير وهى :- فى العقار انتقال حيازة العقار المرهون وقيد الرهن .. وفى المنقول المادى انتقال الحيازة وتدوين الرهن فى ورقة ثابتة التاريخ تتضمن تخصيص الرهن .. وفى الديون انتقال حيازة السند وثبوت تاريخ قبول المدين للرهن أو إعلانه به.



وحق التقدم يكون بالنسبة لما يضمنه الرهن، وقد حددت المادة ١١١١ مدنى المبالغ التى يضمها الرهن ، لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق، وإنما يضمن أيضاً وفى نفس المرتبة ما يأتى:-

١- المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشئ. وهذه المصروفات يلتزم بها الراهن على أساس الإثراء بلا سبب. والرهن لا يضمن إلا المصروفات الضرورية لكنه لا يضمن المصروفات النافعة. لهذا لا يكون للمرتهن بالنسبة للأخيرة إلا أن يحبس الشئ طبقاً للقواعد العامة م ٢٤٦ وما بعدها.

٢- التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشئ. كما إذا كان المرهون حيازياً حيواناً مريضاً، ولم يبين الراهن ذلك ، ثم وضعه المرتهن بين ماشيته فنقل إليها العدوى واستحق تعويضاً عن ذلك.

٣- مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء.

٤- المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى، وكذلك المصروفات التى تنفق فى سبيل تسليم المرهون.

٥- جميع الفوائد المستحقة إلى يوم رسو المزداد، وذلك لأن المرتهن رهناً حيازياً من حقه أن يستوفى الفوائد كلها من غلة الشئ المرهون.

حق التتبع :

يكون للمرتهن وفقاً للمادة ١٠٩٦^{٢٠٢٤/٢٠٢٥} مدنى أن يستوفى حقه من ثمن الشئ^{٢٠٢٤/٢٠٢٥} المرهون فى أى يد تكون، وتعتبر ميزة التتبع التى تنقرر على هذا النحو، للدائن المرتهن إحدى خصائص رهن الحيازة، كغيره من الحقوق العينية التبعية. ويلاحظ أن المرتهن حيازة يتتبع العين فى يد الغير مع أن حيازتها فى يده، ذلك لأن التتبع ليس تتبعاً مادياً للحيازة، بل هو تتبع معنوى للملكية ، يستطيع الدائن بمقتضاه أن ينفذ على العين بعد أن تنتقل ملكيتها من الراهن (١).

(١) د توفيق فرج: ص ٢٥٠ ، د أحمد سلامة: ص ٣٩٨ ، د جمال ذكى: ص ٤١٧.

الفصل الثالث

إنقضاء الرهن الحيازي

حق الرهن الحيازي حق عيني تبعي، ولذا فإنه ينقضى بصفة تبعية لاقتضاء الحق الأصلي المضمون به، وعلى هذا نصت المادة ١١١٢ بقولها «ينقضى حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون». وهو ينقضى أيضاً لأسباب تؤدي إلى ذلك، ولو كان الحق المضمون مازال قائماً، أى ينقضى أيضاً بصفة أصلية للأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

إنقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية :

تنص المادة ١١١٢ على انقضاء الرهن بصفة تبعية «ينقضى حق الرهن الحيازي بانقضاء المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته».

وهذا النص يطابق نص المادة ١٠٨٢ التي تقرر انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعية، وعودة الرهن إذا زال سبب انقضاء الدين، وقد سبق شرحها عند انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعية (١). لذلك ما سبق عن أحوال انقضاء الحق المضمون لا تؤدي إلى انقضاء الرهن الرسمي الضامن لهذا الحق ، يؤخذ به أيضاً بالنسبة للرهن الحيازي، كما لو كان انقضاء الحق بالوفاء مع الحلول أو بالتجديد. كما أن عودة الرهن نتيجة لروال سبب انقضاء الدين المضمون لا تضر، كما تنص على ذلك صراحة المادة ١١١٢ مدني بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الرهن وعودته، فإذا رتب الراهن في هذه الفترة رهناً جديداً لدائن حسن النية أو تصرف في الشيء المرهون إلى مشتر حسن النية، ثم عاد الرهن ، لم يكن نافذاً على المتصرف إليه الذي يكسب ملكية الشيء خالياً من الرهن، كما يبقى الرهن الجديد سابقاً في المرتبة على الرهن الذي عاد.

انقضاء الرهن الحيازي بصفة أصلية :

نصت المادة ١١١٣ مدني على أنه « ينقضى أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية : (أ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين. ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً من تخلي الدائن باختباره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ. على

(١) راجع ما سبق ص ٢٥٧.

ذلك إذا كان الرهن مثقلاً بحق تقرر لمصلحة الغير فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره.

التنازل عن الرهن الحيازي تصرف ينزل به الدائن المرتهن عن حقه في الرهن، ودون أن ينزل عن الحق المضمون به، إذا رغب في ذلك، ونزوله صحيح وملزم إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك. وقد عني نص المادة ١١١٣/أ بالإشارة إلى الأهلية اللازمة لصحة النزول، فقرر أنها الأهلية لإبراء المدين من الدين المضمون بالرهن، وذلك رغم أن النزول عن الرهن لا يعنى الإبراء من الدين، لما يمثله النزول عن التأمين العيني من خطر عدم إمكان استيفاء الدائن حقه، وعلى ذلك فالأهلية اللازمة لصحة النزول عن الرهن الحيازي هي الأهلية الكاملة.

والنزول تصرف بالإرادة المنفردة، ولا يشترط له شكل خاص، فكما يجوز بتعبير صريح عن ترك حق الرهن، يجوز بتعبير ضمني. وقد أوردت المادة ١١١٣ نفسها صورتين للنزول الضمني عن الرهن. الأولى في حالة تخلي الدائن المرتهن باختياره عن حيازة الشئ المرهون إلى الراهن، والثانية هي حالة موافقته - دون تحفظ - على تصرف الراهن في الشئ المرهون إلى الغير على أن كلاً من هاتين القرينتين يقبل إثبات العكس، فيحق للمرتهن أن يثبت أنه إذا تخلى عن العين لم يكن يقصد أبداً أن يتنازل عن رهنه وإنما تخلى لأى سبب آخر، أو أن موافقته على التصرف فيها قد أتت باعتباره شاهداً وليس بحسابه متنازلاً.

2024/2025

2024/2025

ومتى كان هناك نزول عن الرهن، فإن هذا النزول يجب ألا يضر بحقوق الغير. فهذا هو صريح المادة ١١١٣، وهو أيضاً ما تقضى به القواعد العامة. فإذا كان المرتهن قد رهن بدوره حقه المضمون لدائن له فإن حق هذا الدائن الثاني يمتد إلى الرهن، ولا يترتب على تنازل الدائن الأول عن الرهن ضياع حق الدائن الثاني، بل يبقى حق الأول قائماً لمصلحته ما لم يقر مدينه على التنازل.

تنص المادة ١١١٣ مدنى على أنه « ينقضى أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية : (ب) إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.

إتحاد الذمة يتحقق في الرهن الحيازي إذا صار الدائن المرتهن مالكا للشئ المرهون، أو إذا آل حق الرهن إلى المدين الراهن، أى إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد. واتحاد الذمة لا يؤدي إلى انقضاء الرهن بصفة كاملة ونهائية، فهو لا يعدو أن يكون مانعاً من مباشرة المرتهن لحقه

مادام اتحاد الذمة قائماً. فإذا زال سبب هذا الاتحاد بأثر رجعي، عاد حق الرهن إلى الظهور، كما لو فسخ العقد الذي اشترى به الدائن المرتهن العين المرهونة. ويذهب الفقه (١) إلى أن اتحاد الذمة - قياساً على حالة النزول عن حق الرهن - يجب ألا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير. مثال ذلك حالة قيام الدائن المرتهن برهن حقه المضمون بالرهن إلى شخص آخر، ثم يكسب ملكية الشيء المرهون، فهنا يتحقق اتحاد الذمة. ولكن الرهن لا ينقضي ولا يتعطل استعماله لأنه أصبح ضماناً لحق الدائن المرتهن الجديد. كما يضيف ذات الفقه أن اتحاد الذمة لا يؤدي إلى انقضاء الرهن إذا كانت لمالك العين المرهونة مصلحة في بقاء الرهن قائماً، كما لو كان الراهن كفيلاً عينياً وآل إليه الحق المضمون بالرهن، ثم نقل حقه المضمون بالرهن إلى الغير، فإن الرهن يبقى على العين المرهونة بمديونيته، ضماناً للحق المنقول.

تنص المادة ١١١٣ مدني على أنه « ينقضي حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب التالية (ج) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.

هلاك الشيء هو حكم حتمي يترتب على زوال محل الحق العيني بصفة عامة، فالحق العيني سلطة على شيء معين بالذات، فإن زال هذا الشيء زال الحق العيني، ولكن القانون يقرر انتقال حق الدائن عندئذ إلى ما يحل محل الشيء المرهون من حقوق في حالة هلاكه كما رأينا في الرهن الرسمي.

2024/2025 عرضنا للحالات التي ينقضي فيها الرهن الحيازي بصفة أصلية والتي نصت عليها المادة ١١١٣ مدني. ويثور التساؤل حول ما إذا كان الرهن الحيازي ينقضي إذا بيع المرهون جبراً بالمزاد العلني، كما هو الشأن بالنسبة للرهن الرسمي.

لم يرد نص في شأن الرهن الحيازي، ولكن المادة ٤٥٠ مرافعات تنص على أنه «يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهن الرسمية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة البيع وأخذوا بتاريخ جلسته.

وهذا الحكم خاص بالعقار فقط. أما بالنسبة للمنقول فإنه لا يترتب على بيعه جبراً تطهيره من الرهن الحيازي، ويكون للدائن أن يحبس الشيء عن الراسي عليه المزاد، ما لم يكن الدائن هو طالب البيع، أو كان طالب البيع مفضلاً عليه.

(١) د محمد جمال الدين زكي : التأمينات ص ٤٠١ ، أحمد سلامة: التأمينات ص ٤٠١ ، د جميل الشرقاوي : التأمينات ص ٣٩٢.

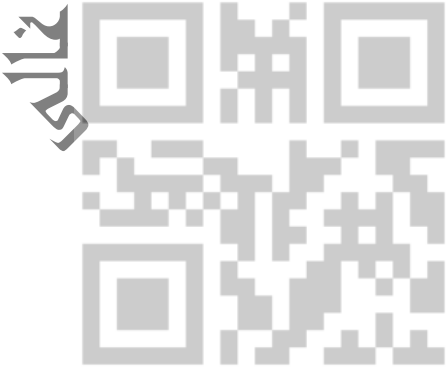


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة
٩	القسم الأول الكفالة
١١	الباب التمهيدي: التعريف بالكفالة
٢٧	الباب الأول: انعقاد الكفالة
٤١	الباب الثاني: آثار الكفالة
٧٩	الباب الثالث: انقضاء الكفالة
٨٥	القسم الثاني التأمينات العينية
٨٧	الباب الأول : الرهن الرسمي
١٧٥	الباب الثاني: حقوق الامتياز
٢٠٩	الباب الثالث: الرهن الحيازي
٢٤٥	الفهرس

2024/2025

2024
0125342206

زيد المنيعة حسن زيد المنيعة حسن

خالد

